

Curso Examen de Grado
Módulo 6: Derecho de Familia.

Presentación.

Módulo 6: Derecho de Familia.

El Derecho de Familia junto con el Derecho Sucesorio son las áreas del Derecho Civil donde la autonomía de la voluntad, principio cardinal, se ve disminuida y en algunos casos suprimida, es por eso que el legislador ha regulado con precisión las distintas materias que lo componen.

El estudio del Derecho de Familia se centra en el matrimonio y sus efectos, de carácter personal (derechos y obligaciones de los cónyuges), patrimonial (los regímenes matrimoniales), sucesorios y finalmente la filiación matrimonial de los hijos.

Los alumnos deberán conocer la institución del matrimonio, sus requisitos de existencia y validez y sus efectos. En relación a los regímenes matrimoniales se espera que tenga un acabado manejo de cada uno de los tres regímenes que existen en nuestro ordenamiento jurídico, aprendiendo a diferenciar las consecuencias jurídicas de cada uno de ellos, como también los bienes familiares, instituto que es transversal a cualquier régimen.

En materia de filiación, los alumnos deberán conocer y diferenciar los tipos de filiación que existen, como asimismo saber dar aplicación a los principios que la informan, interés superior del niño, derecho a la identidad, etc.

Los contenidos se abordarán a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: Nociones Generales.
- Unidad 2: El Matrimonio.
- Unidad 3: Separación de los Cónyuges.
- Unidad 4: Extinción del Matrimonio.
- Unidad 5: Efectos del Matrimonio.
- Unidad 6: Regímenes Matrimoniales.
- Unidad 7: Los Bienes Familiares.
- Unidad 8: Filiación.
- Unidad 9: El Estado Civil.
- Unidad 10: Derecho de Alimentos.

Durante el desarrollo del módulo, los y las participantes dispondrán de los contenidos a través del sitio del curso. Accederán a recursos como PDF, sitios de interés, multimedios y bibliografía relacionada con los contenidos, así como también se propone la realización de actividades de evaluación para medir sus progresos.

Las consultas sobre contenidos, serán canalizadas a través del correo electrónico y el Foro de Debate.

Bien, iniciemos ahora nuestro aprendizaje, revisando la unidad 1.

Unidad 1: Nociones Generales.

Tema 1: Concepto de Familia.

La familia ha sido definida como un conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún efecto jurídico; por ejemplo, impedimento matrimonial relativo al parentesco, llamamiento a la sucesión ab intestato, designación para la tutela etc. (José Castán Tobeñas). En términos parecidos, la define Somarriva: "conjunto de personas unidas por el vínculo de matrimonio, del parentesco o de la adopción".

No existe en nuestra legislación una **definición de familia**, salvo el artículo 815 inc. 3º del Código Civil, para fines muy limitados (uso y habitación).

Tema 2: Características del Derecho de Familia

Tiene el **Derecho de Familia** algunas características que lo diferencian claramente del **Derecho Patrimonial**:

1. **El Derecho de Familia es de contenido eminentemente ético.** Ello explica que en él se pueden encontrar preceptos sin sanción o con sanción atenuada, obligaciones incoercibles, porque el Derecho o es por sí mismo incapaz de provocar mediante la coerción la observancia de dichos preceptos, o cree más conveniente confiar su observancia al sentimiento ético, a la costumbre, a otras fuerzas que actúan en el ambiente social. Así ocurre por ejemplo, con aquella norma de nuestro Código Civil que establece que el hijo debe respeto y obediencia a sus padres (art. 222); con aquella otra que establece el derecho y el deber de cada cónyuge de vivir en el hogar común (art. 133), etc. Fácil es entender que si una mujer casada, por ejemplo, quiere dejar el hogar común, no se le va a poder obligar a que permanezca en él. Por su naturaleza no es posible obtener un cumplimiento forzado de esa obligación, quedando su cumplimiento entregado al sentido ético del cónyuge.
2. **Todo el Derecho de Familia es disciplina de condiciones personales o estados (estado de cónyuge, de padre, de hijo, de pariente, etc.), que son inherentes a la persona y se imponen, como derechos absolutos, respecto de todos.** De estos estados o posiciones personales surgen o pueden surgir relaciones económicas patrimoniales (derechos familiares patrimoniales, les llama la doctrina). Pero estos derechos económicos patrimoniales son consecuencia de dichos estados y por lo mismo inseparables de ellos. Ello hace que la relación económica cuando se produce en el seno de la familia adopte modalidades especiales. Así, por ejemplo, el padre de familia tiene un usufructo legal sobre los bienes de su hijo, que presenta diferencias esenciales con el derecho real de usufructo. El alimentario tiene un derecho personal o crédito para poder exigir que el alimentante le pague la pensión, que tiene formas especiales de ser cumplido, que lo diferencian de un crédito corriente (v. gr. arrestos). La obligación del tutor o curador de rendir cuenta de su

administración, está sometida a reglas especiales que lo diferencian del mandatario, etc.

3. **En el Derecho de Familia hay un claro predominio del interés social sobre el individual.** El interés individual es sustituido por un interés superior, que es el de la familia. Ese es el que se aspira a tutelar.

De las características recién señaladas derivan importantes **consecuencias**:

a) Las normas reguladoras del Derecho de Familia son de orden público, y como tales imperativas, inderogables. Es la ley únicamente, y no la voluntad de las partes, la que regula el contenido, extensión y eficacia de las relaciones familiares. Ciertamente es que la voluntad de los individuos juega, pero sólo en el inicio, pues posteriormente es la ley la que regula íntegramente esos actos.

b) El principio de la autonomía de la voluntad -piedra angular del derecho patrimonial- no juega o está muy restringida en el Derecho de Familia. Buen ejemplo de lo que decimos lo constituye el artículo 149 del Código Civil, que sanciona con nulidad cualquiera estipulación que contravenga las disposiciones del párrafo sobre los Bienes Familiares.

c) En el derecho patrimonial se parte del principio de la igualdad de las partes. En cambio en derecho de familia, hay casos en que no es así. Existen relaciones de superioridad y recíprocamente de dependencia, llamados derechos de potestad. Y ello explica institutos tan importantes como el de la autoridad paterna o de la patria potestad. Y explica también, que en el régimen de sociedad conyugal, sea el marido el que administre no sólo los bienes sociales sino también los propios de su mujer, no obstante que desde la entrada en vigencia de la Ley 18.802, ella es plenamente capaz.

d) Exceptuados los derechos de potestad recién referidos, los demás derechos familiares son recíprocos, v. gr. la obligación de los cónyuges de guardarse fe, de socorrerse y de ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, de respetarse y protegerse (art. 131). Así también en los derechos de alimento y sucesorios.

e) Las relaciones de estado familiar son, en buena medida, derechos y deberes, p. ejemplo la patria potestad, confiere al padre o madre una serie de derechos que también son deberes (administrar los bienes del hijo, representarlo, etc.); en el régimen de sociedad conyugal, la administración de los bienes sociales y de los de la mujer es un derecho y un deber del marido.

f) Los derechos de familia son en sí y por regla general, inalienable, intrasmisible, irrenunciable e imprescriptible, ejemplo el derecho de alimentos (art. 334).

g) Los actos de derecho de familia no están sujetos a modalidades. En algunos casos lo dice claramente la ley, como ocurre en el artículo 102 al definir el matrimonio; en el artículo 189 inc. 2° al tratar del reconocimiento de un hijo, o en el pacto del artículo 1723.

h) Otra característica típica del Derecho de Familia es que la mayor parte de sus actos son solemnes, al revés de lo que ocurre en derecho patrimonial en que la tendencia es al consensualismo. Ejemplos los encontramos en el matrimonio (art. 102); en el reconocimiento de un hijo (art. 187); en el pacto del artículo 1723; en las capitulaciones matrimoniales (art. 1716), etc.

Tema 3: Principios que informan el derecho de familia en el Código Civil Chileno.

Las bases fundamentales del Derecho de Familia a la fecha de la dictación del Código Civil chileno eran las siguientes:

- Matrimonio religioso e indisoluble;
- Incapacidad relativa de la mujer casada;
- Administración unitaria y concentrada en el marido de la sociedad conyugal;
- Patria potestad exclusiva y con poderes absolutos; y
- Filiación matrimonial fuertemente favorecida.

A continuación revisaremos cada una de ellas.

a. Matrimonio religioso e indisoluble.

El Código Civil original mantuvo, en materia de matrimonio, lo que existía vigente a esa época, es **decir reconoció como único matrimonio válido el religioso, entregando a la Iglesia Católica todo lo relacionado con su celebración, solemnidades, impedimentos y jurisdicción para conocer de su nulidad**. Así quedó consagrado en los artículos 117 y 103. El primero decía: "El matrimonio entre personas católicas se celebrará con las solemnidades prevenidas por la Iglesia, y compete a la autoridad eclesiástica velar sobre el cumplimiento de ellas". Y el 103 agregaba: "Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído" "La Ley Civil reconoce como impedimentos para el matrimonio los que han sido declarados tales por la Iglesia Católica; y toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre su existencia y conceder dispensas de ellos".

No olvidó Bello el matrimonio de los no católicos. En el artículo 118 lo trató especialmente. También debía celebrarse ante un sacerdote católico que actuaba, en este caso, como ministro de fe, y ante dos testigos. En estos matrimonios no se cumplía ninguno de los ritos o solemnidades del matrimonio católico.

En esta materia, como en tantas otras, Bello demostró su sentido práctico. No siguió a su modelo francés que había secularizado el matrimonio medio siglo antes, sino que respetó la situación existente en un país eminentemente católico.

Varios años después, con la dictación de la Ley de Matrimonio Civil de 10 de enero de 1884, se produce la secularización del matrimonio. Pero en los años transcurridos, se habían dictado diversas leyes que habían abierto el camino a la transformación. Es así como el 27 de julio de 1865, se promulgó una ley que interpretando el artículo 5º de la Constitución de 1833 -que establecía la religión católica como religión oficial- declaró que dicha disposición permitía a los que no profesaban esa religión, practicar sus propios cultos dentro de edificios de propiedad particular, y además, autorizó a los disidentes para fundar y sostener escuelas privadas para la instrucción de sus hijos en la doctrina de sus religiones. Más adelante, el 13 de octubre de 1875 se dictó la Ley Orgánica de Tribunales, que suprimió el fuero eclesiástico. Así, entonces, a la fecha de dictación de la Ley de Matrimonio Civil, la situación era distinta a la del año 1855.

El último hito en esta materia es la nueva Ley de Matrimonio Civil -ley 19.947 del 17 de mayo de 2004- que en su artículo 20, establece que "los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley ...".

En cuanto al principio de la indisolubilidad matrimonial, se mantuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la nueva Ley de Matrimonio Civil, esto es, hasta el 18 de noviembre de 2004, que consagró por primera vez en Chile el divorcio con disolución de vínculo.

b. Incapacidad de la mujer casada.

En el Código Civil de Bello, la mujer casada era relativamente incapaz. **Siempre se dio como razón, que era necesaria esta incapacidad para mantener la unidad del régimen matrimonial chileno.** La mujer era incapaz no por ser mujer ni por ser casada, sino por encontrarse casada en un régimen de sociedad conyugal. El artículo 1447 del Código Civil, la consideraba relativamente incapaz, al lado de los menores adultos y de los disipadores en interdicción de administrar lo suyo.

La situación anterior se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley 18.802, el 8 de septiembre de 1989. Hay que agregar sin embargo, que la condición de la mujer había ido mejorando paulatinamente en virtud de una serie de leyes modificatorias del Código Civil. Así, por ejemplo, con el Decreto Ley 328 del año 1925, posteriormente modificado por la Ley 5.521 de 19 de diciembre de 1934, se estableció en Chile la institución de los Bienes Reservados de la Mujer Casada, que le dio plena capacidad para administrar lo que adquiriere con su trabajo separado de su marido.

c. Administración unitaria y concentrada del marido de la sociedad conyugal.

En la actualidad se mantiene este principio, pero atenuado por varias leyes. Desde luego, el Decreto Ley 328 y la Ley 5.521, recién mencionados, al establecer el patrimonio reservado de la mujer casada, **excluyeron de la administración del marido todos aquellos bienes que la mujer adquiere con su trabajo.** En seguida, la Ley 10.271, de 2 de abril de 1952, introdujo importantes limitaciones a las facultades con que el marido administraba los bienes sociales, obligándolo a obtener autorización de la mujer para enajenar y gravar los bienes raíces sociales o arrendarlos por más de 5 u 8 años, según se trate de bienes urbanos o rústicos, respectivamente. Y la Ley 18.802, del 9 de junio de 1989, amplió estas limitaciones, en forma importante.

d. Patria potestad exclusiva y de poderes absolutos del padre de familia.

Bello, en materia de patria potestad, se separó de lo que era la tendencia universal -incluir en ella tanto lo relativo a las persona como a los bienes del hijo- y la limita únicamente a los bienes. En seguida, quita a la mujer toda ingerencia en esta materia. Sigue la tendencia romanista y del derecho español antiguo que consideraba la patria potestad como una prerrogativa exclusiva del padre.

Varios años después con el D.L. 328 de 1925 y con la Ley 5.521, de 1934, se vino a reparar esta situación, admitiendo la patria potestad de la madre a falta del padre legítimo. Posteriormente la Ley 18.802, otorga a la mujer a quien judicialmente se le confiera el cuidado de un hijo legítimo, el derecho a pedir su patria potestad (art. 240 inc. penúltimo, anterior a la reforma de la ley N° 19.585). Termina esta evolución con la ley N° 19.585 que da al artículo 244 del Código Civil el siguiente texto “la patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente, según convengan en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil...”

e. Filiación matrimonial fuertemente favorecida.

El Código Civil original privilegió claramente la filiación matrimonial. Así lo demuestra el hecho de que no se permitía la investigación de la filiación no matrimonial, no obstante que a la fecha en que se dictó el Código Civil, varios códigos que le sirvieron de inspiración ya la admitían. Así lo demuestra también el hecho de que los hijos legítimos excluían a los naturales en el primer orden de sucesión abintestato. Es decir, habiendo hijos legítimos sólo ellos heredaban, a menos que el padre hiciera testamento, y dispusiera en su favor.

Varias leyes fueron atenuando este principio. En primer lugar debe ser mencionada la Ley 5.750 de 2 de diciembre de 1935 que, por primera vez, consagró la investigación de paternidad y de la maternidad ilegítimas, para fines alimentarios. En seguida, la Ley 10.271 de 2 de abril de 1952, mejoró notablemente la condición del hijo natural. Así a partir de su entrada en vigencia, se admitió el reconocimiento forzado (artículos 271 N°s 2, 3 y 4); en seguida, introdujo profundas modificaciones en materia sucesoria, v. gr. el hijo natural, pasó a concurrir conjuntamente con los legítimos en el primer orden de sucesión intestada, si bien, no en la misma proporción (art. 988 anterior a la reforma de la ley 19.585); pasó a ser asignatario de la cuarta de mejoras (art. 1167 N° 4, hoy N° 3), etc. Finalmente la ley N° 19.585 termina definitivamente con toda discriminación entre los hijos. Todos ellos, provengan de filiación matrimonial o no matrimonial, gozan de los mismos derechos.

Tema 4: Principales leyes complementarias y modificatorias del Código Civil, en materia de familia.

Entre las leyes complementarias deben señalarse: la **Ley de Matrimonio Civil de 10 de enero de 1884 y la de Registro Civil de 17 de julio de 1884**, que secularizaron el matrimonio y que entraron a regir el 1º de enero de 1885 (la primera de éstas ha sido reemplazada por la ley 19.947 del 17 de mayo de 2004); la **Ley 5.343 de 6 de enero de 1934**, sustituida por la **Ley 7.613 de 21 de octubre de 1943**, que incorporó en Chile la institución de la adopción y, sobre esta misma materia, la **Ley 18.703 de 10 de mayo de 1988**, que reguló la adopción de menores y la **ley 19.620, que entró en vigencia el 27 de octubre de 1999**, que establece el nuevo estatuto en materia de adopción, derogando a partir de esa fecha las leyes 7.613 y 18.703.

Entre las leyes modificatorias, hay varias importantes: el **Decreto Ley 328 de 29 de abril de 1925, reemplazado por la Ley 5.521 de 19 de diciembre de 1934**, que mejoró la situación jurídica de la mujer, incorporando la institución de los bienes reservados de la mujer casada y permitiendo, por primera vez, pactar el régimen de separación de bienes en las capitulaciones matrimoniales celebradas con anterioridad al matrimonio; la **Ley 5.750 de 2 de diciembre de 1935**, que suprimió los hijos de dañado ayuntamiento y admitió por primera vez en Chile, la investigación de la paternidad y maternidad ilegítimos; la **Ley 7.612 de 21 de octubre de 1943**, que modificó diversos preceptos del Código Civil, entre otros el artículo 1723, que autorizó a los cónyuges para sustituir el régimen de sociedad conyugal por el de separación total de bienes; la **Ley 10.271 de 2 de abril de 1952** que, introdujo relevantes innovaciones en Derecho de Familia, especialmente en lo relativo a régimen matrimonial y filiación natural.

La ley 18.802, de 9 de junio de 1989, dio plena capacidad jurídica a la mujer casada e introdujo otras modificaciones destinadas a mejorar su situación jurídica.

La ley 19.335, publicada el 23 de septiembre de 1994, incorporó el Régimen de "Participación en los Gananciales" y la institución de "Los Bienes Familiares".

La ley 19.585 publicada en el Diario Oficial del 26 de octubre de 1998, que eliminó la distinción entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos y, como consecuencia de ello, modificó sustancialmente lo relativo a patria potestad y derechos hereditarios

La ley 19.947 de 17 de mayo de 2004 -que entró en vigencia 6 meses después- junto con establecer una nueva Ley de Matrimonio Civil -que incorpora la institución del divorcio vincular y de la separación judicial- modifica además, entre otras, la ley 4.808 sobre Registro Civil y la ley 16.618 sobre menores.

Finalmente la ley 19.968 que creó los Tribunales de Familia que debe entrar a regir el 1º octubre del año 2005, que contienen disposiciones que en cierto modo pueden significar modificaciones o complementaciones importantes a la legislación vigente (v. gr. ponderación de la prueba en los juicios de familia)

Tema 5: Parentesco.

El parentesco se define como la relación de familia que existe entre dos personas y puede ser de dos clases: **parentesco por consanguinidad** y **parentesco por afinidad**.

El primero, llamado también **natural**, se funda en la relación de sangre que existe entre dos personas, cuando una desciende de la otra o ambas de un tronco o antepasado común. En esos términos está definido en el artículo 28: "es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados".

El parentesco por **afinidad**, o parentesco legal, es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer (art. 31 inc. 1º).

El parentesco por afinidad subsiste aún después de la muerte de uno de los cónyuges, pues el artículo 31 al referirse a este parentesco habla de una persona que "está o ha estado casada".

No hay duda que el parentesco más importante es el por consanguinidad. El parentesco por afinidad, no confiere derechos y la ley lo considera para establecer un impedimento para contraer matrimonio (art. 6º de la Ley de Matrimonio Civil) y como inhabilidad en ciertos casos, como ocurre con los artículos 412 y 1061 del Código Civil.

a) Línea y grado de parentesco.

Se entiende por **línea** de parentesco la serie de parientes que descienden unos de otros (línea recta) o de un tronco común, (línea colateral, transversal u oblicua). Así, por ejemplo, el abuelo, padre e hijo están en la línea recta porque el padre desciende del abuelo y el hijo del padre y del abuelo. En cambio, los hermanos están en la línea colateral u oblicua, porque ambos descienden de

un tronco común: el padre. Lo mismo ocurre con los primos o con el tío y sobrino.

Grado es la distancia que existe entre dos parientes. Es importante porque mientras más cercano confiere mayores derechos.

El parentesco en la línea recta se cuenta por el número de generaciones: padre e hijo, primer grado; nieto y abuelo, segundo grado. En el parentesco colateral, para determinar el grado se sube hasta el tronco común y después se baja al pariente cuyo grado se desea conocer. Así, por ejemplo, los hermanos, se encuentran en segundo grado en la línea colateral, porque en el primer grado se sube de uno de los hijos al padre y después se baja del padre al otro hijo. Por esto, el grado más cercano de parentesco entre dos colaterales es el segundo grado (hermanos), no hay parientes colaterales en primer grado. Por eso se criticaba el artículo 5º de la anterior Ley de Matrimonio Civil, que establecía que no podían contraer matrimonio entre sí: 2º Los colaterales por consanguinidad **hasta el segundo grado inclusive**, lo que importa una incorrección pues daba a entender que había parentesco colateral en primer grado. Este error ha sido corregido por la actual Ley de Matrimonio Civil (art. 6º).

Respecto del **parentesco por afinidad**, se aplican las mismas reglas. Así lo dispone el artículo 31 inc. 2º: “La línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califican por la línea y grado de consanguinidad de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad, en la línea transversal, con los hermanos de su mujer”.

UNIDAD 2: EL MATRIMONIO

Tema 1: Definición

El artículo 102 del Código Civil, lo define como "un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente".

Sus elementos son:

a) El matrimonio es un contrato.

Este es un punto muy discutido en doctrina, lo que lleva a estudiar las **principales teorías** para explicar la naturaleza jurídica del matrimonio.

Hay varias, que pueden resumirse del modo siguiente: i) el matrimonio es un contrato; ii) el matrimonio es un acto del Estado; y iii) el matrimonio es una institución.

i) La tesis de que el matrimonio es un contrato, fue la dominante desde el siglo XVII al XIX. Los canonistas ya lo habían sostenido aduciendo que el vínculo matrimonial derivaba del acuerdo de las voluntades de los esposos. Es la que ha prevalecido entre los juristas franceses e italianos. Quienes la sustentan se apresuran a expresar que es un contrato con características peculiares, contrato sui generis, pero contrato al fin de cuentas, desde que es el acuerdo de voluntades el creador de la relación jurídica.

Hay serias críticas a esta tesis. Así Roberto de Ruggiero afirma que "no basta que se dé en aquél un acuerdo de voluntades para afirmar sin más que sea un contrato; ni es cierto tampoco que todo negocio bilateral sea contrato aunque los contratos constituyen la categoría más amplia de tales negocios". Agrega que "las normas que no sólo limitan, sino que aniquilan toda autonomía de la voluntad, demuestran la radical diferencia que media entre el contrato y el matrimonio". No es contrato porque las partes no pueden disciplinar la relación conyugal de modo contrario al que la ley establece.

ii) El matrimonio es un acto del Estado. El italiano Cicus defiende esta concepción. Es el Estado, quien a través del oficial civil, une a las partes en matrimonio. La voluntad de las partes sólo representa un presupuesto indispensable para que el Estado pueda unir a los contrayentes en matrimonio.

iii) El matrimonio es una institución. Los partidarios de esta teoría, buscan fundar la idea de la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio institución repele la noción de divorcio. Esta tesis se resume en las siguientes palabras de Jorge Iván Hübner Gallo, que sigue en esta materia a Renard: "El matrimonio es también una institución, donde el acuerdo de voluntades es sólo el acto de fundación que le da origen. La idea directriz es el propósito de "un hombre y una mujer de unirse actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente" "Constituida la institución matrimonial, cobra existencia propia y su estatuto, fijado por la Ley Civil como un reconocimiento del orden natural, no puede ser alterado por la voluntad de los fundadores. La "sociedad conyugal", formada por los bienes de ambos cónyuges, es la dotación económica destinada a la subsistencia y progreso de la institución y colocada bajo la administración del marido, en su calidad de jefe de grupo. Como corolario del carácter institucional del matrimonio,

se deduce que no puede ser disuelto por la voluntad de los cónyuges; que su objeto está fuera del comercio humano; y que produce plenos efectos respecto de terceros”.

Se dan en el matrimonio los elementos de toda institución: núcleo humano básico (los cónyuges) que pasa a tener un valor por sí mismo; está organizado dentro del orden jurídico; hay una idea directriz de bien común (vivir juntos, procrear -es decir formar una familia- y auxiliarse mutuamente); es permanente, en cuanto dura lo que viven los cónyuges y sus efectos perduran en la descendencia legítima. El acto fundacional se expresa en la voluntad de los contrayentes de recibirse el uno al otro como marido y mujer.

b) Contrato solemne.

Las principales solemnidades son la presencia de un Oficial Civil y de dos testigos hábiles.

c) Vínculo entre un hombre y una mujer.

Agrega la definición de matrimonio, que por el matrimonio "un hombre y una mujer ...". Queda así claro que es de la esencia del matrimonio la diferencia de sexo. También queda claro que los que se unen es, es UN hombre y UNA mujer, en singular, con lo que se está descartando la poligamia y la poliandria.

d) Unión actual e indisoluble y por toda la vida.

La definición continua expresando que "se unen actual e indisolublemente y por toda la vida".

La voz "actual", descarta la idea de cualquier modalidad suspensiva.

Respecto a las expresiones "indisolublemente", y "por toda la vida" si bien se mantienen en la definición, no corresponden a la realidad actual del matrimonio, desde que la ley 19.947, introdujo el divorcio vincular. Al discutirse en el Senado esta última ley, se explicó que “La Cámara de Diputados no modificó el artículo 102 del Código Civil en lo referido a la indisolubilidad del matrimonio, porque entendió que el divorcio sería una situación excepcional” (Boletín del Senado Nº 1759-18, p. 37). La misma opinión la sustenta el profesor Hernán Corral, quien considera que “el divorcio, concebido como un remedio excepcional en ningún caso podrá llegar a cambiar la fisonomía jurídica del matrimonio tal como existe en la actualidad. Las personas -se dice- se casan para vivir juntos toda la vida y no para divorciarse...”.

e) Finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.

Termina la definición señalando los fines del matrimonio: "vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente". Sobre este punto, deberá tenerse presente que la finalidad no sólo es procrear, porque si así fuera, no se admitirían los matrimonios de ancianos, de personas enfermas o el matrimonio en artículo de muerte.

Tema 2: Ley de Matrimonio Civil.

En Chile el matrimonio se secularizó con la entrada en vigencia de la **Ley de Matrimonio Civil, el 1º de enero de 1885**. Sin embargo, la actual ley **-ley N° 19.947-** establece que los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público, producirán los mismos efectos del matrimonio civil siempre que se cumplan determinadas exigencias (art. 20).

Tema 3: Requisitos del matrimonio.

Hay que distinguir entre: requisitos de existencia y requisitos de validez.

3.1 Requisitos de existencia.

Ellos son:

- i) diversidad de sexo de los contrayentes;
- ii) consentimiento;
- iii) presencia del Oficial del Registro Civil.

La falta de alguno de estos requisitos **produce la inexistencia del matrimonio** (inexistencia, no nulidad). En efecto si se casan dos varones o dos mujeres, es evidente que esa unión no es matrimonio. No se requiere que un tribunal así lo resuelva (justamente la teoría de la inexistencia nació para explicar lo que ocurría si se casaban personas del mismo sexo). Lo mismo, si el matrimonio se contrae ante el Director de Impuestos Internos, el Contralor General de la República o ante cualquier funcionario, por importante que sea, esa unión no es matrimonio, porque no se celebró ante el único funcionario que puede autorizarlo que es el Oficial Civil.

No es fácil que se den situaciones como las señaladas. Pero puede ocurrir -y de hecho se han producido algunos casos- cuando el matrimonio ha sido contraído ante funcionarios diplomáticos que no tienen entre sus atribuciones la de autorizar matrimonios. Así la Corte de Apelaciones de Santiago declaró nulo el matrimonio de dos hijos de franceses nacidos en Chile, celebrado en la Legación de Francia en Santiago de Chile, por el Ministro de ese país en Chile. (T. 32, sec. 2a, p. 17). En rigor debió haberse declarado la inexistencia y no la nulidad. Años después se presentó un nuevo caso, resolviendo la Corte Suprema que "es inexistente el matrimonio celebrado en el extranjero ante el Cónsul de Chile durante la vigencia del Decreto Ley 578 de 29 de septiembre de 1925" (T. 50, sec. 1ª, p. 382.). Sin duda, esta última es la doctrina correcta.

Distinguir entre la inexistencia y nulidad de un matrimonio, es importante porque si el matrimonio es nulo puede ser putativo, y producir los mismos efectos civiles que el válido (art. 51 de la ley 19.947). En cambio, no hay putatividad frente a un matrimonio inexistente. Seguramente esa fue la razón por la que la Corte de Santiago, declaró nulo -y no inexistente como correspondía- el matrimonio celebrado en la Legación francesa.

Nuestra Corte Suprema ha hecho la distinción entre matrimonio nulo e inexistente, afirmando que el primero tiene una existencia imperfecta, por cuanto adolece de vicios en su constitución que pueden traer consigo la nulidad; en cambio, el inexistente es sólo una apariencia de matrimonio,

porque carece de los elementos sin los cuales no puede concebirse el acto (T. 45, sec. 1ª, p. 107).

3.2 Matrimonio por poder.



En relación con el consentimiento, es importante tener presente que el Código Civil admite que el consentimiento pueda manifestarse a través de mandantarios. Así lo establece el artículo 103: **"El matrimonio podrá celebrarse por mandatario especialmente facultado para este efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario"**.

El artículo 103 es bastante exigente respecto del mandato. Este debe ser: a) especial, b) solemne (se otorga por escritura pública, lo que constituye una excepción a la regla general del artículo 2123 de que el mandato sea consensual); y c) determinado, puesto que debe indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario. No se necesita dar las razones.

3.3 Requisitos de validez del matrimonio.

Los requisitos de validez del matrimonio son: consentimiento libre y espontáneo; capacidad de los contrayentes y ausencia de impedimentos dirimentes; y cumplimiento de las formalidades legales.

3.3.1 Consentimiento exento de vicios.

De acuerdo a lo que establece el artículo 8º de la ley 19.947, los vicios de que puede adolecer el consentimiento en materia matrimonial son: **el error y la fuerza**.

No se comprende el dolo, lo que corresponde a una tradición que viene del Derecho Romano a través de Pothier y de los inspiradores y redactores del Código Francés. Según tal tradición establecer el dolo como vicio del consentimiento significaba poner en peligro la estabilidad del vínculo matrimonial, ya que es normal que en las relaciones que preceden a las nupcias se adopten actitudes destinadas a impresionar que pudieran llegar a ser constitutivas de este vicio.

a) El error

El artículo 8º de la actual ley de matrimonio civil contempla dos clases de error: **a) "error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente", y b) "error acerca de alguna de sus cualidades personales que atendida la naturaleza de los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento"**.

Respecto de este último tipo de error debe tenerse presente que para que vicie el consentimiento debe recaer, no en cualquiera cualidad personal, sino en una que atendida la naturaleza o fines del matrimonio, sea estimada como determinante para otorgar el consentimiento. Sería el caso, por ejemplo, de quien se casa ignorando que la persona con la que contrae nupcias es impotente o estéril.

b) La fuerza

El artículo 8º de la Ley de Matrimonio Civil señala: **"Falta el consentimiento libre y espontáneo en los casos siguientes: 3º Si ha habido fuerza, según los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa que hubiere sido determinante para contraer el vínculo"**.

La referencia a los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, significa que para que la fuerza vicie el consentimiento debe ser grave, injusta y determinante.

Grave es la fuerza capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición (art. 1456), considerándose que tiene este carácter el justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El artículo 1456 agrega que el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.

La fuerza es injusta cuando constituye una coacción que implica actuar al margen de la ley o contra la ley, de modo que el ejercicio legítimo de un derecho jamás puede ser fuerza que vicie la voluntad, aún cuando indiscutiblemente signifique coacción.

Finalmente la fuerza es determinante cuando se ha ejercido con el objeto de obtener el consentimiento (art. 1457). El artículo 8º insiste en la idea de que para que la fuerza vicie el consentimiento tiene que haber sido determinante para contraer el vínculo matrimonial

Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que sea empleada por el otro contrayente, pues el artículo 8º sólo habla de "ocasionada por una persona". La situación entonces es igual a la establecida en el artículo 1457 del Código Civil. La novedad que introduce la ley 19.947 es que la fuerza puede ser ocasionada por una "circunstancia externa". Este agregado que hizo la ley 19.947, tuvo por objeto permitir la disolución del matrimonio de una mujer que se casa embarazada y que lo hace por la presión social que mira con malos ojos el que una mujer soltera sea madre.

3.3.2 Capacidad de los contrayentes y ausencia de impedimentos dirimentes.

En lo concerniente al matrimonio, las incapacidades se llaman **impedimentos**.

La regla general, igual que en materia patrimonial, es que todas las personas sean capaces. De consiguiente no hay más impedimentos que los que la ley señala.

Los impedimentos en nuestra legislación pueden ser de dos clases: **dirimentes**, que son los que obstan a la celebración del matrimonio, de tal suerte que si no se respetan, la sanción es la nulidad del vínculo matrimonial; e **impedientes**, que nuestro Código Civil llama prohibiciones, cuyo incumplimiento no producen nulidad sino otro tipo de sanciones.

Los impedimentos dirimentes están tratados en la Ley de Matrimonio Civil; las prohibiciones están en el Código Civil.

Los impedimentos pueden ser de dos clases: absolutos, si obstan al matrimonio con cualquier persona, ej. la demencia, el vínculo matrimonial no disuelto (art. 5º de la Ley de Matrimonio Civil), y relativos, si sólo impiden el matrimonio con determinadas personas, por ejemplo vínculo de parentesco (artículos 6 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil).

a) Impedimentos dirimentes absolutos.

Los establece el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil: “No podrán contraer matrimonio:

1º Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto;

Es un impedimento de carácter universal contemplado en casi todas las legislaciones, con escasas excepciones correspondientes a países islámicos que aceptan la poligamia.



El incumplimiento de este impedimento no sólo tiene una sanción civil (nulidad del segundo matrimonio), sino también una penal, pues tipifica el delito de bigamia sancionado por el artículo 382 del Código Penal.

Es básico para determinar si existe este impedimento, la circunstancia de que el primer matrimonio sea válido, puesto que si es nulo, normalmente el impedimento no existe (salvo el caso del matrimonio putativo). Por ello el artículo 49 de la Ley de Matrimonio Civil establece que “Cuando, deducida la acción de nulidad fundada en la existencia de un matrimonio anterior, se adujere también la nulidad de este matrimonio, se resolverá en primer lugar la validez o nulidad del matrimonio precedente”.

La acción de nulidad corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges, al cónyuge anterior o a sus herederos (art. 46 letra d). La acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges (art. 48 letra d).

2º Los menores de dieciséis años;

En la ley anterior el impedimento era la impubertad (art. 4 Nº 2).

Si se incumple este impedimento la sanción es la nulidad del matrimonio, la que sólo pueden alegar cualquiera de los cónyuges o alguno de sus ascendientes, pero alcanzados los 16 años por parte de ambos cónyuges, la acción de nulidad se radica únicamente en él o los que hubieran contraído matrimonio sin tener esa edad (art. 46 letra a). En este caso la acción de nulidad prescribe en un año contado desde la fecha en que el cónyuge inhábil para contraer matrimonio llegare a la mayoría de edad (art. 48 letra a).

3º Los que se hallaren privados del uso de razón; y los que por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio;

El artículo 5º señala que no podrán contraer matrimonio: 3º “Los que se hallaren privados del uso de razón, y los que por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio”

Este numerando comprende dos situaciones distintas: la privación de razón; y la existencia de un

trastorno o anomalía psíquica. En la ley anterior el impedimento lo constituía únicamente la demencia.

Respecto a la privación de razón (demencia), un doble motivo justifica el impedimento. En primer lugar, uno eminentemente jurídico: imposibilidad de manifestar la voluntad. Y, en seguida, uno de orden eugenésico: la inconveniencia de que las personas que padecen este tipo de males contraigan matrimonio para evitar una descendencia con taras. No tiene importancia la declaración de interdicción. Basta que la demencia exista al momento de contraer matrimonio para que opere el impedimento.

En relación a la causal de padecer de una anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, que incapacite a la persona de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio este impedimento tiene su origen en el Derecho Canónico que establece que “son incapaces de contraer matrimonio quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica” (Canon 1095 Nº 3). Carlos López Díaz expresa que “no estamos aquí en presencia de una privación del uso de razón como la anterior, sino de un trastorno o anomalía psíquica. Pero no cualquiera: debe incapacitar para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio, y más todavía, de manera “absoluta”. Y agrega este autor, que pueden quedar incluidos en este caso los trastornos de identidad sexual como el fetichismo y el travestismo. (Carlos López Díaz, “Matrimonio Civil, Nuevo Régimen”, Edit. Librotecnia, 2004, pp. 60-61). Ramos cree que “podrían encontrarse en este caso las personas que padecen el Síndrome de Down. Sin embargo, como es sabido, existen grados distintos de esta afección, lo que nos hace pensar que aquellos que la padecen en forma moderada no quedarían comprendidos en el impedimento. Será un problema médico legal resolver si esa persona esta incapacitada en forma absoluta para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio”.

4º Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio, y

Este impedimento no estaba en la ley anterior, y lo contempla hoy el artículo 5º Nº 4 de la Ley de Matrimonio Civil. También ha sido tomado del Derecho Canónico (Nº 2 del Canon 1095). Queda comprendido en este caso el de aquél que sin padecer una enfermedad psiquiátrica, carece de la madurez necesaria para entender y asumir las obligaciones y deberes propios del matrimonio.

5º Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas”.

Este caso equivale al que la ley anterior establecía en el artículo 4 Nº 4, con la salvedad que antes el consentimiento sólo podía expresarse de palabra o por escrito. En cambio la ley actual permite que se pueda manifestar por “medio del lenguaje de señas”.

b) Impedimentos dirimentes relativos.



Los impedimentos dirimentes relativos están contemplados en los artículos 6 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil y son: **parentesco y prohibición de casarse con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer.**

b.1) Parentesco.

El artículo 6º de la Ley de Matrimonio Civil establece que “No podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado”.

“Los impedimentos para contraerlo derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan”.

El parentesco que obsta al matrimonio, en el caso de los ascendientes y descendientes, es tanto el por consanguinidad como el por afinidad, por lo que no podría un padre casarse con su hija, o un yerno con la suegra; en cambio tratándose del parentesco colateral, sólo opera la prohibición en la consanguinidad: no pueden casarse los hermanos, pero podrían hacerlo los cuñados. Nótese también que el parentesco a que se refiere el artículo 6º, puede provenir tanto de filiación matrimonial como de extramatrimonial, ya que la ley no distingue y porque, además, las razones que justifican el impedimento son las mismas en ambos casos. Debe tenerse presente que en el caso de los hermanos, el impedimento rige sea que se trate de hermanos de doble conjunción (hermanos carnales) o de simple conjunción (medios hermanos).

El impedimento de parentesco se encuentra establecido en todas las legislaciones. Habría que agregar que en esa materia el Derecho Canónico es más drástico, exigiendo, por ejemplo dispensas para la celebración del matrimonio entre primos.

b.2) Prohibición de casarse con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito.

Este impedimento lo establece el artículo 7º de la Ley de Matrimonio Civil. Equivale al que se contenía en el artículo 6º de la ley anterior, con algunas modificaciones: a) se habla ahora de “imputado” para adecuar el lenguaje al nuevo procedimiento procesal penal; b) se incluye en el impedimento al encubridor. Antes la prohibición comprendía sólo al autor y al cómplice; c) la ley antigua impedía el matrimonio sólo en el caso de homicidio calificado (hablaba de “asesinato”); y d) en la ley anterior se requería, para que operara el impedimento, que existiera condena, en cambio actualmente basta con estar imputado.

Pothier explicaba que el fundamento de este impedimento era evitar que una persona estimulare al amante a matar a su cónyuge, para casarse con ella.

c) Impedimentos impedientes o prohibiciones.

En la legislación chilena, los llamados en doctrina “impedimentos impedientes”, se denominan **“prohibiciones”**. A diferencia de los impedimentos dirimentes que están tratados en la Ley de Matrimonio Civil, las prohibiciones lo están en el Código Civil, artículos 105 a 116 y 124 a 129 normas que, con algunas modificaciones, mantienen su vigencia.

No están definidos. Podemos decir que son ciertas limitaciones que la ley establece para la celebración del matrimonio, cuyo incumplimiento produce diversas sanciones que en ningún caso consisten en la nulidad del matrimonio.

Estos impedimentos son: **consentimiento de ciertas personas para contraer matrimonio; guardas; segundas nupcias.**

c.1) Consentimiento de ciertas personas para contraer matrimonio.

De acuerdo al artículo 107 del Código Civil, los menores de 18 años, están obligados a obtener el consentimiento de ciertas personas para poder casarse.

El artículo 105 Código Civil, establece que “no podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario según las reglas que van a expresarse, o sin que conste que el respectivo contrayente no ha menester para casarse el consentimiento de otra persona, o que ha obtenido el de la justicia en subsidio”.

En relación con lo que señala la disposición recién transcrita, el artículo 9 de la Ley de Matrimonio Civil, prescribe que al momento de la manifestación deberá indicarse los nombres y apellidos “de las personas cuyo consentimiento fuere necesario”.

- **Personas que deben prestar el consentimiento.**

Para saber qué persona debe prestar el consentimiento, debe **distinguirse entre hijos con filiación determinada e hijos de filiación indeterminada.**

Respecto de los primeros, la autorización para contraer matrimonio deben darla:

- a) Sus padres y si faltare uno de ellos, el otro padre o madre;
- b) A falta de ambos padres, el ascendiente o ascendientes del grado más próximo, y si se produjere igualdad de votos preferirá el favorable al matrimonio (art. 107).
Se entiende faltar el padre, la madre u otro ascendiente, no sólo por haber fallecido, sino por estar demente; o por hallarse ausente del territorio de la República y no esperarse su pronto regreso; o por ignorarse el lugar de su residencia. También se entenderá faltar el padre o madre cuando la paternidad o maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición (art. 109). Finalmente, de acuerdo al artículo 110, también se entiende que falta el padre o la madre, cuando estén privados de la patria potestad por sentencia judicial o que, por su mala conducta, se hallen inhabilitados para intervenir en la educación de sus hijos.
- c) A falta de padres o ascendientes, la autorización la debe otorgar el curador general (art. 111); y
- d) A falta de curador general, el consentimiento debe darlo el oficial del Registro Civil que deba intervenir en la celebración (art. 111 inc. 2°).

Tratándose de hijos que no tienen filiación determinada respecto de ninguno de sus padres, el consentimiento para el matrimonio lo dará su curador general si lo tuviere o, en caso contrario, el oficial del Registro Civil llamado a intervenir en su celebración (art. 111 inc. final).

- **Momento y forma de otorgar el consentimiento.**

Se puede prestar por escrito o en forma oral. Así se desprende del artículo 12 de la Ley de Matrimonio Civil: “se acompañará a la manifestación una constancia fehaciente del consentimiento para el matrimonio, dado por quien corresponda, si fuere necesario según la ley y no se prestare oralmente ante el oficial del Registro Civil”.

El consentimiento debe ser especial y determinado, es decir, se debe indicar la persona con quien

va a contraer matrimonio. No basta una autorización general.

- **Disenso**

Si el consentimiento lo deben prestar el padre, la madre o los ascendientes, estas personas no necesitan justificar su disenso. En estos casos, simplemente no podrá procederse al matrimonio del menor. Así lo consigna el artículo 112 inciso 1º: "Si la persona que debe prestar este consentimiento lo negare, aunque sea sin expresar causa alguna, no podrá procederse al matrimonio de los menores de dieciocho años".

Cuando quien debe prestar el consentimiento es el curador general o el oficial del Registro Civil, si lo niega debe expresar causa, y en tal caso el menor tendrá derecho a pedir que el disenso sea calificado por el juzgado competente (art. 112 inc. 2º). Tienen competencia en esta materia los jueces de familia (art. 8 N° 5 de la ley 19.968).

Las razones que justifican el disenso están señaladas taxativamente en el artículo 113: "Las razones que justifican el disenso no podrán ser otras que éstas:

1. La existencia de cualquier impedimento legal, incluso el señalado en el artículo 116;
2. El no haberse practicado algunas de las diligencias prescritas en el título "De las segundas nupcias", en su caso;
3. Grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia o de la prole;
4. Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual de la persona con quien el menor desea casarse;
5. Haber sido condenada esa persona por delito que merezca pena aflictiva;
6. No tener ninguno de los esposos medios actuales para el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio".

- **Sanciones para el caso en que se omita el consentimiento.**

La sanción no es la nulidad del matrimonio, porque estamos frente al incumplimiento de un impedimento impediendo, no de uno dirimente. Las sanciones aplicables al menor son las siguientes:

1. Cuando el consentimiento debía prestarlo un ascendiente, puede ser desheredado, no sólo por aquel cuyo consentimiento se omitió sino por todos los demás ascendientes (art. 114 primera parte). El "desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legítimo sea privado del todo o parte de su legítima" (art. 1207 inc. 1º). El artículo 114 debe ser concordado con el 1208 N° 4º, que al señalar las causas del desheredamiento, menciona este caso en su numeral 4º: "por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo".
2. El menor pierde la mitad de lo que le habría correspondido en la sucesión intestada de los mismos ascendientes (art. 114 segunda parte).
3. El ascendiente cuyo consentimiento se omitió (sólo éste, no los demás como en los casos anteriores), puede revocar las donaciones que antes del matrimonio le hubiere hecho al menor (artículo 115 inc. 1º).

- **Sanciones penales al Oficial Civil que autoriza un matrimonio de un menor sin exigir la autorización.**

El artículo 388 del Código Penal (con la redacción dada por la ley 19.947), establece que: "El oficial civil que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción, sufrirá las penas de relegación menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará al ministro de culto que autorice un matrimonio prohibido por la ley".

La ley 19.947 derogó los artículos 385 a 387 del Código Penal, que también contemplaban sanciones penales para el menor.

c.2) Impedimento de guardas.

Lo contempla el artículo 116 del Código Civil: "Mientras que una persona no hubiere cumplido dieciocho años, no será lícito al tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes, casarse con ella, sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez, con audiencia del defensor de menores" (inc. 1º). "Igual inhabilidad se extiende a los descendientes del tutor o curador para el matrimonio con el pupilo o pupila". (Inc. 2º).

El fundamento de esta inhabilidad es impedir que el guardador o sus parientes cercanos contraigan matrimonio con el pupilo o pupila, para encubrir una administración dolosa.

- **Sanción para el incumplimiento del impedimento guardas.**

La establece el artículo 116 inciso tercero: "El matrimonio celebrado en contravención a esta disposición, sujetará al tutor o curador que lo haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le corresponda, sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan".

c.3) Impedimento de segundas nupcias.

Lo contempla el artículo 124 del Código Civil: "El que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curaduría, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando y le pertenezcan como heredero de su cónyuge difunto o con cualquier otro título.

Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial".

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 19.947, este impedimento era aplicable sólo al "viudo o viuda", que tuviere hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría y quisiere volver a casarse. Se aplicaba al viudo o viuda, porque como el matrimonio se disolvía por la muerte de uno de los cónyuges era el único caso en que alguno de ellos se podía volver a casar. Pero al incorporarse la institución del divorcio vincular la situación cambió porque los divorciados están habilitados para contraer nuevas nupcias.

En el caso que el hijo no tenga bienes propios de ninguna clase en poder del padre o madre, habrá lugar al nombramiento del curador para el sólo efecto de que certifique esta circunstancia (art. 125).

"El Oficial del Registro Civil correspondiente no permitirá el matrimonio del que trata de volver a casarse, sin que se le presente certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los objetos antedichos, o sin que preceda información sumaria de que no tiene hijos de precedente matrimonio, que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría".

- **Sanción**

Si se celebra el matrimonio incumpléndose este impedimento hay sanciones para el viudo o viuda, para el divorciado o para quien anuló su matrimonio, y para el Oficial Civil o para el ministro de culto que autorizó ese matrimonio.

Respecto de los primeros dice el artículo 127: "El viudo o divorciado o quien hubiere anulado su matrimonio por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse en tiempo oportuno el inventario prevenido en el artículo 124, perderá el derecho de suceder como legitimario o como heredero

abintestato al hijo cuyos bienes ha administrado".

El artículo 127 sanciona al viudo o divorciado o quien hubiere anulado su matrimonio, cuando el inventario no se hace "en tiempo oportuno". Ello quiere decir, antes que se produzca una confusión entre los bienes del hijo con los del padre o de la madre y con los de la nueva sociedad conyugal.

El artículo 384 del Código Penal sanciona penalmente al que por sorpresa o engaño obtiene que el Oficial Civil autorice el matrimonio, sin haberse cumplido con este impedimento.

Además, hay sanción penal para el Oficial del Registro Civil que celebre el matrimonio sin hacer respetar el impedimento (art. 388 Código Penal).

c.4) Impedimento especial para la viuda o mujer cuyo matrimonio se haya disuelto o declarado nulo.

El artículo 128 establece que "cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o (no habiendo señales de preñez) antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad"

"Pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración, y en los cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer".

El artículo 129 establece que "El oficial del Registro Civil correspondiente no permitirá el matrimonio de la mujer sin que por parte de ésta se justifique no estar comprendida en el impedimento del artículo precedente"

El fundamento de este impedimento es evitar la confusión de paternidades.

Cuando el artículo 128, habla de "matrimonio disuelto o declarado nulo", incurre en una incorrección pues el matrimonio nulo también está disuelto, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley sobre Matrimonio Civil. Habría bastado con que se hubiera dicho matrimonio disuelto.

Es corriente la situación que plantea el artículo 128, especialmente en el caso de la mujer que anula su matrimonio. Es frecuente que haya tramitado la nulidad para casarse de nuevo y, sólo en ese momento el Oficial del Registro Civil le advierte que no puede hacerlo hasta que transcurran los 270 días contados desde la fecha en quedó ejecutoriada la sentencia que declaró la nulidad. La situación se remedia, pidiendo autorización judicial que se otorga previo informe del médico legista que acredita que la mujer no se encuentra embarazada.

• Sanción a la omisión de este impedimento

La sanción se establece en el artículo 130 inciso 2°, en los siguientes términos: "Serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias, y su nuevo marido".

Además, tanto la mujer como el Oficial Civil que autoriza el matrimonio incurren en responsabilidad penal, de acuerdo a los artículos 384 y 388 del Código Penal, respectivamente.

3.3.3 Formalidades legales del matrimonio.

Para estudiar las formalidades del matrimonio es necesario distinguir entre: **matrimonios celebrados en Chile y matrimonios celebrados en el extranjero.**

a) Formalidades del matrimonio celebrado en Chile.

Atendiendo al tiempo en que son exigidas, pueden ser: **anteriores al matrimonio; coetáneas a su celebración; y posteriores al matrimonio.**

a.1) Formalidades previas o diligencias preliminares

1. La manifestación. Se define como el acto en que los futuros contrayentes dan a conocer al Oficial del Registro Civil, su intención de contraer matrimonio ante él. Puede hacerse por escrito, oralmente o por medio de lenguaje de señas. Así lo señala el artículo 9º de la Ley de Matrimonio Civil: “Los que quisieren contraer matrimonio lo comunicarán por escrito, oralmente o por medio de lenguaje de señas (inc. 1º). “Si la manifestación no fuere escrita, el Oficial del Registro Civil levantará acta completa de ella, la que será firmada por él y por los interesados, si supieren y pudieren hacerlo, y autorizada por dos testigos” (inc. 2º).

La manifestación se hace ante cualquier oficial del Registro Civil (art. 9 inc. 1º). A ella deberá acompañarse una constancia fehaciente del consentimiento para el matrimonio dado por quien corresponda, si fuere necesario según la ley y no se prestare oralmente ante el oficial del Registro Civil (art. 12).

En cuanto al contenido de la manifestación, dice el artículo 9, que se hará “indicando sus nombres y apellidos; el lugar y la fecha de su nacimiento; su estado de solteros, viudos o divorciados y, en estos dos últimos casos, el nombre del cónyuge fallecido o de aquél con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio, respectivamente; su profesión u oficio; los nombres y apellidos de los padres, si fueren conocidos; los de las personas cuyo consentimiento fuere necesario, y el hecho de no tener incapacidad o prohibición legal para contraer matrimonio”.

2. Información sobre finalidad del matrimonio. El artículo 10 establece que “al momento de comunicar los interesados su intención de celebrar el matrimonio, el Oficial del Registro Civil deberá proporcionarles información suficiente acerca de las finalidades del matrimonio, de los derechos y deberes recíprocos que produce y de los distintos regímenes patrimoniales del mismo” (inc. 1º).

“Asimismo, deberá prevenirlos respecto de la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo” (inc. 2º) y “deberá además, comunicarles la existencia de cursos de preparación para el matrimonio, si no acreditan que los han realizado. Los futuros contrayentes podrán eximirse de estos cursos de común acuerdo, declarando que conocen suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial. Este inciso no se aplicará en los casos de matrimonios en artículo de muerte” (inc. 3º).

El inciso final establece que “la infracción a los deberes indicados no acarreará la nulidad del matrimonio ni del régimen patrimonial, sin perjuicio de la sanción que corresponda al funcionario en conformidad a la ley”. Existe una sanción penal que contempla el artículo 388 del Código Penal.

3. Cursos de preparación para el matrimonio. Estos cursos persiguen promover la libertad y seriedad del consentimiento matrimonial, y tienen por objeto especialmente que los contrayentes conozcan los derechos y deberes que impone el vínculo y tomen conciencia de las responsabilidades que asumen (art. 11 inc. 1º).

Pueden ser dictados por el Servicio del Registro Civil, entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público, por instituciones de educación públicas o privadas reconocidas por el Estado o por personas jurídicas sin fines de lucro cuyos estatutos comprendan la realización de actividades de

promoción y apoyo familiar” (art. 11 inc. 2º) El contenido de los cursos que no dictare el Servicio de Registro Civil e Identificación, será determinado libremente por cada institución y deben ajustarse a la Constitución y a la ley. Para facilitar el reconocimiento de ellos, las instituciones deben inscribirse previamente en un Registro especial que llevará el Servicio de Registro Civil (art. 11 inc. 3º).

4. Información de testigos. Se puede definir como la comprobación, mediante dos testigos, del hecho que los futuros contrayentes no tienen impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio (art. 14)

Los matrimonios en artículo de muerte no requieren de manifestación, información testigos ni de cursos de preparación para el matrimonio. Así lo establecen los artículos 10 inc. 3º y 17 inc., final de la Ley de Matrimonio Civil.

a.2) Formalidades coetáneas al matrimonio

De acuerdo al artículo 15 de la Ley de Matrimonio Civil, "Inmediatamente después de rendida la información y dentro de los noventa días siguientes, podrá procederse a la celebración del matrimonio. Transcurrido dicho plazo sin que el matrimonio se haya efectuado, habrá que repetir las formalidades prescritas en los artículos precedentes”.

- **Todo Oficial Civil es competente para la celebración del matrimonio.**

Hasta que entró en vigencia la ley 19.947, sólo tenía competencia para autorizar un matrimonio, el Oficial Civil de la comuna en que cualquiera de los contrayentes tuviera su domicilio o hubiere vivido durante los tres meses anteriores a la fecha de la celebración del matrimonio. Así lo establecía el artículo 35 de la Ley 4808, sobre Registro Civil.

La ley 19.947 derogó este artículo 35 y estableció en su artículo 17 que “el matrimonio se celebrará ante el oficial del Registro Civil que intervino en la realización de las diligencias de manifestación e información.” Como, de acuerdo al artículo 9º, la manifestación se puede hacer ante cualquier Oficial del Registro Civil, quiere decir que las personas pueden casarse ante cualquier oficial del Registro Civil, con tal que sea el mismo ante el cual se hizo la manifestación e información de testigos.

La razón por la que se derogó el artículo 35 de la ley 4808 y se atribuyó competencia a cualquier oficial del Registro Civil, fue eliminar la posibilidad de que se demandara la nulidad de un matrimonio por incompetencia del Oficial del Registro Civil que, como es sabido, a falta de una ley de divorcio vincular, era la puerta de escape para disolver los matrimonios.

- **Lugar donde debe efectuarse el matrimonio.**

De acuerdo al artículo 17 de la Ley de Matrimonio Civil, el matrimonio se podrá efectuar:

- a) En el local de la oficina del Oficial del Registro Civil; o
- b) En el lugar que señalaren los futuros contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro de su territorio jurisdiccional.

- **Presencia de testigos hábiles.**

El artículo 17 inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil establece que el matrimonio se debe celebrar ante dos testigos que pueden ser parientes o extraños.

Los testigos deben ser hábiles, y la regla es que cualquier persona, pariente o extraño, lo sea. No hay

más testigos inhábiles que los indicados en el 16: “No podrán ser testigos en las diligencias previas ni en la celebración del matrimonio: 1º: Los menores de 18 años; 2º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia; 3º Los que se hallaren actualmente privados de razón; 4º Los que hubieren sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos; y 5º Los que no entendieren el idioma castellano o aquellos que estuvieren incapacitados para darse a entender claramente”.

El artículo 45 de la actual ley, establece que “es nulo el matrimonio que no se celebre ante el número de testigos hábiles determinados en el artículo 17”.

- **Acto de celebración del matrimonio.**

El artículo 18 de la Ley de Matrimonio Civil establece que “En el día de la celebración y delante de los contrayentes y testigos, el Oficial del Registro Civil dará lectura a la información mencionada en el artículo 14 (información de testigos) y reiterará la prevención indicada en el artículo 10 inciso 2º” (necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo).

Agrega el artículo 18 que “A continuación, leerá los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil (estas disposiciones se refieren a los deberes conyugales). Preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido y mujer y, con la respuesta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley”.

Es el Oficial Civil, quien, representando al Estado y una vez verificado que se han cumplido todas las exigencias legales, declara casados a los contrayentes.

Es esta la razón, por la que si el matrimonio no se celebra -o en el caso del artículo 20 (matrimonio ante una entidad religiosa de derecho público), no se ratifica- ante un Oficial Civil, tal matrimonio no tiene existencia. No es que sea nulo, sino que es inexistente, según lo estima la doctrina nacional. Y por la misma razón, si el matrimonio no se celebra ante Oficial del Registro Civil, no podrá ser putativo.

a.3) Formalidades posteriores al matrimonio.

Trata de esta materia el artículo 19 de la Ley de Matrimonio Civil: “Inmediatamente (de declararlos casados en nombre de la ley), el Oficial del Registro Civil levantará acta de todo lo obrado, la cual será firmada por él, los testigos y los cónyuges, si supieren y pudieren firmar; y procederá a hacer la inscripción en los libros del Registro Civil en la forma prescrita en el reglamento”.

Agrega el artículo 19 que “si se trata de matrimonio en artículo de muerte, se especificará en el acta el cónyuge afectado y el peligro que le amenazaba” (inc. 2º).

En el acto del matrimonio se pueden reconocer hijos comunes no matrimoniales, y pactar separación de bienes o participación en los gananciales.

Lo primero está autorizado por el artículo 187 N° 1º, parte final, del Código Civil y por el artículo 37 de la ley 4808 (en su texto dado por la ley 19.947). Esta última norma señala que: “El Oficial del Registro Civil no procederá a la inscripción del matrimonio sin haber manifestado privadamente a los contrayentes que pueden reconocer los hijos comunes nacidos antes del matrimonio, para los efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente”.

Respecto a la posibilidad de separación de bienes o participación en los gananciales, el artículo 38 inciso 2º de la ley 4808 lo permite expresamente, agregando en el inciso 3º, que si advertidos los

contrayentes que pueden establecer estos regímenes matrimoniales, no lo hacen o nada dicen, se entenderán casados en régimen de sociedad conyugal.

Los vicios en que se pueda incurrir en el acta o en la inscripción, o incluso su omisión, no producen la nulidad del matrimonio, desde que éste quedó perfeccionado cuando el Oficial del Registro Civil los declaró casados en nombre de la ley. Luego, lo ocurrido con posterioridad, no puede producir la nulidad del matrimonio.

b) Matrimonios celebrados ante entidades religiosas de derecho público.

Desde el 1º de enero de 1885 en que entró en vigencia la antigua Ley de Matrimonio Civil, el único matrimonio que producía efectos civiles era el celebrado ante un Oficial del Registro Civil. La falta de esa solemnidad producía, por lo menos en doctrina, la inexistencia del matrimonio.

Sin embargo, la ley 19.947, cambió esta realidad, al establecer que “Los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial lo prescrito en este Capítulo -De la celebración del matrimonio- desde su inscripción ante un Oficial del Registro Civil” (art. 20, inc. 1º).

b.1) Requisitos para que el matrimonio religioso produzca efectos civiles.

Para que este matrimonio religioso produzca efectos civiles deben cumplirse los siguientes requisitos:

- a) Debe celebrarse ante una entidad religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público y debe autorizarlo un ministro del culto que estatutariamente tenga facultades para ello;
- b) Debe levantarse un acta que acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, como el nombre y edad de los contrayentes y los testigos y la fecha de su celebración. Los testigos son dos y no les debe afectar alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 16. El acta deberá estar suscrita por el ministro del culto ante quien se hubiere contraído el matrimonio religioso y deberá cumplir con las exigencias contempladas en el artículo 40 bis) de la ley 4808.
- c) El acta debe ser presentada por los contrayentes ante cualquier Oficial del Registro Civil, dentro de ocho días, para su inscripción. El plazo corre desde la celebración del matrimonio religioso.

Respecto de esta exigencia es necesario tener presente:

- Que quienes deben presentar el acta al Registro Civil, son los propios contrayentes, en forma personal, no pudiendo hacerlo por medio de mandatarios. La ley 19.947 agregó un inciso 2º al artículo 15 de la ley 4808, que disipa cualquier duda. En efecto, el inciso 1º de esa disposición permite que los interesados en una inscripción en el Registro Civil, puedan cumplir ese trámite personalmente o a través de mandatarios. Ahora bien, el inciso 2º agregado por la ley 19.947 dispone lo siguiente: “No tendrá aplicación lo previsto en el inciso precedente, tratándose de las inscripciones a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil”. La referencia al artículo 20 de la Ley sobre Matrimonio Civil corresponde al matrimonio religioso.
- El plazo es de ocho días corridos (art. 50 del Código Civil). Es un plazo de caducidad, puesto que de no inscribirse dentro los 8 días “tal matrimonio no producirá efecto civil alguno”. Esto

significa que el matrimonio es inexistente.

- El plazo es para presentar el acta ante el Oficial del Registro Civil y para que se inscriba el matrimonio (para las dos cosas). Ello es así porque el artículo 20 inciso 2º parte final dice: “**Si no se inscribiere** en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno”.

- d) Los comparecientes deben ratificar, ante el Oficial del Registro Civil, el consentimiento prestado ante el ministro de culto de su confesión, de lo que se deberá dejar constancia en la inscripción respectiva que también deben suscribir ambos contrayentes (art. 20 inc. 3º).

Dice Ramos “¿qué pasa si vigente el plazo de 8 días muere alguno de los contrayentes (no me atrevo a llamarle cónyuges)? ¿Lo hereda el sobreviviente? Pensamos que la respuesta es no, porque todavía no hay matrimonio ya que éste, y pese a todo lo que se diga, sólo se va a perfeccionar cuando ambas partes concurren al Registro Civil a ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto de su confesión. Otro problema: ¿qué pasa si alguno de los contrayentes se niega a concurrir al Registro Civil a ratificar el consentimiento?. Creemos que no hay delito penal, pero si podría existir responsabilidad extracontractual”.

b.2) Requisitos de la inscripción del matrimonio religioso en el Registro Civil.

La ley 19.947 incorporó a la ley 4808 el artículo 40 ter que establece los requisitos que deben contener las inscripciones de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas.

Dentro de estas exigencias hay cuatro que, según el artículo 40 ter inciso final, son esenciales: **a)** debe contener el acta a que se refiere el artículo 20 de la ley de Matrimonio Civil (acta de la entidad religiosa); **b)** debe señalar el documento que acredite la personería del respectivo ministro de culto; **c)** debe constar que se ratificó por los contrayentes el consentimiento ante el Oficial del Registro Civil; y **d)** la firma de los requirentes de la inscripción y del Oficial del Registro Civil.

b.3) Negativa del Registro Civil de inscribir el matrimonio religioso.

El artículo 20 inciso 4º establece que “sólo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la ley. De la negativa se podrá reclamar ante la respectiva Corte de Apelaciones”.

b.4) Fecha del matrimonio religioso.

Un aspecto importante que debe ser dilucidado es precisar la fecha del matrimonio en el caso que venimos tratando ¿será la de la ceremonia religiosa o aquella en que se ratifica ante el Registro Civil? Este problema no es menor, ya que puede ser importante para varios efectos, v. gr., para la aplicación de la presunción del artículo 184 del Código Civil; para determinar a qué patrimonio ingresa un bien adquirido entre la fecha del matrimonio religioso y su ratificación ante el Registro Civil, etc.

A juicio de Ramos debe estimarse para todos los efectos legales que si el matrimonio religioso se ratifica dentro de los 8 días ante el Registro Civil, debe estarse a la fecha del matrimonio religioso, entendiéndose que cuando se inscribe en el Registro Civil sus efectos se retrotraen a la fecha del matrimonio religioso. En el mismo sentido opina Hernán Corral: “Entendemos que el consentimiento matrimonial válido se presta en estos casos ante el Ministro de Culto. De allí que se hable de “ratificar” el consentimiento ya prestado, y no de renovar o repetir nuevamente dicha voluntad. Se ratifica lo que ya existe, y esa ratificación operará, según las reglas generales, con efecto retroactivo, bajo condición de que se practique la inscripción en el Registro Civil del matrimonio religioso contraído. Es decir la fecha del matrimonio será la de su celebración religiosa, sin perjuicio de que se proteja a los terceros por la falta de publicidad de la unión en tanto no proceda la inscripción”.

c) Matrimonios celebrados en el extranjero.

El artículo 80 de la nueva ley señala que el matrimonio celebrado en el extranjero podrá ser declarado nulo de conformidad con la ley chilena si se ha contraído contraviniendo lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la ley, vale decir, sin respetar los impedimentos dirimentes.

El artículo 80 distingue entre: a) requisitos de forma; b) requisitos de fondo; y c) efectos del matrimonio.

c.1) Los requisitos de forma

Los requisitos de forma están referidos a las solemnidades externas. Se rigen por la ley del país en que el matrimonio se celebra (*lex locus regit actum*). Se sigue en esta materia el mismo principio que el artículo 17 del Código Civil adopta para la forma de los instrumentos públicos.

c.2) Requisitos de fondo

En cuanto a los requisitos de fondo (capacidad y consentimiento), también se rigen por la ley del lugar de celebración del matrimonio. Ello con dos excepciones: 1) deben respetarse los impedimentos dirimentes contemplados en los artículos 5, 6 y 7 de la ley, y 2) priva de valor en Chile a los matrimonios en que no hubo consentimiento libre y espontáneo de los cónyuges (art. 80 inc. 3º).

c.3) Efectos del matrimonio celebrado en el extranjero

Finalmente en lo que se refiere a los efectos del matrimonio celebrado en el extranjero (derechos y obligaciones entre los cónyuges), éste produce en Chile los mismos efectos que si se hubiere contraído en Chile, siempre que se trate de la unión de un hombre y una mujer.

El artículo 82 se refiere a un efecto específico del matrimonio, al derecho de alimentos. Establece que el cónyuge domiciliado en Chile podrá exigir alimentos del otro cónyuge ante los tribunales chilenos y en conformidad a la ley chilena (inc. 1º). El inciso 2º agrega que del mismo modo, el cónyuge residente en el extranjero podrá reclamar alimentos del cónyuge domiciliado en Chile.

UNIDAD 3: SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES

El Capítulo III de la Ley de Matrimonio Civil trata **“De la separación de los cónyuges”**, distinguiendo entre **separación de hecho** y **separación judicial**.

Tema 1: Separación de hecho

La **Ley de Matrimonio Civil**, trata la separación de hecho, buscando regular las consecuencias que de ella derivan: relaciones de los cónyuges entre sí y con los hijos, cuidado de estos últimos; derecho-deber del padre o madre que vive separado de los hijos de mantener con ellos una relación directa y regular; alimentos para los hijos y para el cónyuge más débil; administración de los bienes sociales y de la mujer cuando están casados en sociedad conyugal, etc. Así se desprende de los artículos 21 y siguientes de la ley.

La ley establece dos formas de hacer esta regulación: de **común acuerdo** y **judicialmente**.

1.1 Regulación de común acuerdo.

Se refiere a ella el artículo 21: **“Si los cónyuges se separaren de hecho, podrán, de común acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio”**

“En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere a su cuidado”

“Los acuerdos antes mencionados deberán respetar los derechos conferidos por las leyes que tengan el carácter de irrenunciables”.

Es importante este acuerdo porque, si cumple los requisitos que en seguida se verán, dan fecha cierta al cese de la convivencia entre los cónyuges, lo que es importante cuando se demanda el divorcio, como se desprende del artículo 55 de la ley.

- **Requisitos para que el acuerdo otorgue fecha cierta al cese de la convivencia.**

Según el artículo 22, el acuerdo otorga fecha cierta al cese de la convivencia cuando consta por escrito en alguno de los siguientes instrumentos: a) escritura pública, o acta extendida y protocolizada ante notario público (nótese que debe cumplir ambos requisitos: extendida ante notario público y protocolizada); b) acta extendida ante un Oficial del Registro Civil, o c) transacción aprobada judicialmente.

Además “si el cumplimiento del acuerdo requiriese una inscripción, subinscripción o anotación en un registro público, se tendrá por fecha del cese de la convivencia aquélla en que se cumpla tal

formalidad” (art. 22 inc. 2º). Al discutirse la ley se puso como ejemplo de esta situación, el caso en que en el acuerdo se constituya un usufructo sobre un bien raíz.

Este artículo agrega finalmente que “La declaración de nulidad de una o más de las cláusulas de un acuerdo que conste por medio de alguno de los instrumentos señalados en el inciso primero, no afectará el mérito de aquél para otorgar una fecha cierta al cese de la convivencia”.

1.2 Regulación judicial.

Si los cónyuges no logran ponerse de acuerdo sobre las materias a que se refiere el artículo 21, cualquiera de ellos podrá solicitar la regulación judicial (art. 23). Lo importante de esta norma es que ello podrá pedirse en el juicio iniciado respecto de cualquiera de las materias señaladas en el referido artículo 21 (alimentos, tuición, etc.). Así lo dice el artículo 23: **“A falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que el procedimiento judicial que se sustancie para reglar las relaciones mutuas, como los alimentos que se deban, los bienes familiares o las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio; o las relaciones con los hijos, como los alimentos, el cuidado personal o la relación directa y regular que mantendrán con ellos el padre o madre que no los tuviere bajo su cuidado, se extienda a otras materias concernientes a sus relaciones mutuas o a sus relaciones con los hijos”**.

El artículo 24 agrega que “Las materias de conocimiento conjunto a que se refiere el artículo precedente se ajustarán al mismo procedimiento establecido para el juicio en el cual se susciten” (inc. 1º).

Como se puede observar, con estos artículos se obtiene unidad de competencia (art. 23) y unidad de procedimiento (art. 24), lo que representa una evidente economía procesal para las partes.

- **Fecha cierta del cese de la convivencia cuando hay regulación judicial.**

Cuando la regulación de las materias señaladas en el artículo 21, se hace judicialmente, el cese de la convivencia tendrá fecha cierta a partir de la notificación de la demanda (art. 25 inc.1º).

1.3 Casos que dan fecha cierta del cese de la convivencia.

De lo dicho resulta que hay fecha cierta del cese de la convivencia en los siguientes casos:

- a) Cuando el acuerdo de los cónyuges conste, por escrito, en alguno de los instrumentos contemplados en el artículo 22;
- b) Cuando a falta de acuerdo, se demande judicialmente alguna de las materias que indica el artículo 23, caso en que la fecha cierta será la de la notificación de la demanda (art. 25 inc. 1º); y
- c) Hay un tercer caso, contemplado en el artículo 25 inciso 2º: “Asimismo, habrá fecha cierta, si no mediare acuerdo ni demanda entre los cónyuges, cuando, habiendo uno de ellos expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a través de cualquiera de los instrumentos señalados en las letras a) y b) del artículo 22 o dejado constancia de dicha intención ante el juzgado correspondiente,

se notifique al otro cónyuge”. En estos casos se trata de una gestión voluntaria a la que se podrá comparecer personalmente, debiendo la notificación practicarse según las reglas generales.

(El art. 2º transitorio de la Ley 19.947 dispone: “Los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se registrarán por ella en lo relativo a la separación judicial, la nulidad y el divorcio... no registrarán las limitaciones señaladas en los arts. 22 y 25 para comprobar la fecha de cese de la convivencia entre los cónyuges; sin embargo, el juez podrá estimar que no se ha acreditado si los medios de prueba aportados al proceso no le permiten formarse plena convicción sobre ese hecho”, es decir, los matrimonios celebrados antes del 18 de noviembre de 2004, fecha en que entró en vigencia la ley, pueden probar el cese de la convivencia por cualquier medio, eso sí con la limitación indicada).

Tema 2: Separación judicial

El párrafo 2º del Capítulo III de la ley, arts. 26 al 41 trata de la separación judicial.

2.1 Causales de separación judicial

La separación judicial se puede demandar:

a) Por uno de los cónyuges si mediere **falta imputable al otro**, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común.(art. 26 inc. 1º). El adulterio no es causal de separación judicial cuando exista previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges (inc. 2º)

En este caso, la acción para pedir la separación corresponde únicamente al cónyuge que no ha dado lugar a la causal (art. 26 inc. 3º);

b) Por cualquiera de los cónyuges, cuando hubiere **cesado la convivencia** (art. 27 inc. 1º).

En este caso, si la solicitud fuere conjunta, “los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo será **completo** si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21. Se entenderá que es **suficiente** si resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges cuya separación se solicita”.

Hernán Corral estima que “por razones de coherencia interna del nuevo cuerpo legal -se refiere a la nueva Ley de Matrimonio Civil- si los cónyuges obtienen de común acuerdo la separación personal hay que entender que optan por esa fórmula de regulación de ruptura, que en la ley aparece claramente como un régimen de regulación de la ruptura alternativa al divorcio. No será admisible, entonces que uno de ellos pretenda extinguir el régimen jurídico de la separación invocando el cese de la convivencia como fundamento del divorcio unilateral. Se aplicará aquí la doctrina de los actos propios. El cónyuge ha optado por una figura alternativa que mantiene la vigencia del vínculo y lo ha hecho de común acuerdo con su marido o mujer, no podría luego ir contra su propia decisión y solicitar el divorcio unilateral, imponiéndole este estado civil a su consorte”. Ramos no comparte

esta opinión. Cree que la separación judicial y el divorcio son instituciones diferentes, de tal suerte, que lo que se resuelva respecto de la primera no puede inhabilitar a los cónyuges para interponer una demanda de divorcio.

La acción para demandar la separación judicial es irrenunciable. Así lo establece el artículo 28.

2.2 Medidas provisionales para proteger el patrimonio familiar y el bienestar de cada uno de los miembros que la integran.

De acuerdo al **artículo 30** cuando los cónyuges se encontraren casados en el régimen de sociedad conyugal “cualquiera de ellos podrá solicitar al tribunal la adopción de las medidas provisionales que estimen conducentes para la protección del patrimonio familiar y el bienestar de cada uno de los miembros que la integran”. Ello sin perjuicio del derecho de las partes para demandar alimentos o pedir la declaración de bienes familiares de acuerdo a las reglas generales.

2.3 Contenido de la sentencia que declara la separación.

Según el **artículo 31** debe:



a) Pronunciarse sobre cada una de materias que indica el artículo 21, a menos que se encuentren regulados o no procediere la regulación de alguna de ellas, lo que indicará expresamente. Si las partes hubieren establecido la regulación, el tribunal debe revisar tal acuerdo, procediendo de oficio a subsanar las deficiencias o a modificarlo, si fuere incompleto o insuficiente (art. 31 incs. 1º y 2º); y

b) Debe, además, liquidar el régimen matrimonial que hubiere existido entre los cónyuges, si así se hubiere solicitado y se hubiere rendido la prueba necesaria (art. 31 inciso final). Evidentemente esto será así únicamente si estaban casados en sociedad conyugal o participación de gananciales. Esta norma constituye una excepción a la regla general de que la liquidación de la sociedad conyugal, se debe hacer en conformidad a las normas de la partición de bienes, por un árbitro de derecho.

2.4 Efectos de la separación judicial.

La sentencia de separación judicial producirá sus efectos desde que quede ejecutoriada. Debe además subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Dice el artículo 32 que “**La separación judicial produce sus efectos desde la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia que la decreta. Sin perjuicio de ello, la sentencia ejecutoriada en que se declare la separación judicial deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Efectuada la subinscripción, será oponible a terceros y los cónyuges adquirirán la calidad de separados, que no los habilita para volver a contraer matrimonio**”.

a) A partir del momento en que se subinscribe, se adquiere por los cónyuges el estado civil de “**separados judicialmente**”. La prueba de este nuevo estado se hace con la correspondiente partida de matrimonio, según la modificación que la ley 19.947 introduce al artículo 305 del Código Civil.

b) Deja subsistentes los derechos y obligaciones personales de los cónyuges, con excepción de aquellos cuyo ejercicio sea incompatible con la vida separada de ambos, como los deberes de cohabitación y de fidelidad (art. 33).

c) Se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubiere existido entre los cónyuges, sin perjuicio de que se pueda constituir prudencialmente a favor del cónyuge no propietario, un derecho de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares (art. 34). Concordante con ello el nuevo art. 173 del Código Civil dice: “Los cónyuges separados judicialmente administran sus bienes con plena independencia uno del otro, en los términos del artículo 159”, es decir, los cónyuges separados judicialmente pasan a tener el régimen de separación de bienes.

d) En principio, no se altera el derecho a sucederse por causa de muerte, salvo que se hubiere dado lugar a la separación por culpa de un cónyuge, caso en que el juez efectuará en la sentencia la declaración correspondiente, de la que se dejará constancia en la subinscripción (art. 35). Para estos efectos, la ley 19.947 sustituyó el artículo 1182 inciso 2º del C. Civil privando de la calidad de legitimario al cónyuge que por culpa suya haya dado ocasión a la separación judicial y dio una nueva redacción al artículo 994, que ahora paso a decir: “El cónyuge separado judicialmente, que hubiere dado motivo a la separación por su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido”.

e) En materia de alimentos, rigen las reglas especiales contempladas en el párrafo V del Título VI del Libro I del Código Civil (art. 35 inc. 2º). El nuevo texto del artículo 175 (que establece la ley 19.947) prescribe: “El cónyuge que haya dado causa a la separación judicial por su culpa, tendrá derecho para que el otro cónyuge lo provea de lo que necesite para su modesta sustentación, pero en este caso, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad a él”.

f) De acuerdo al artículo 178 del Código Civil, en el nuevo texto dado por la ley 19.947, se aplica a los cónyuges separados la norma del artículo 160, según el cual **ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común en proporción a sus facultades**, debiendo el juez hacer la regulación en caso necesario.

g) No se altera la filiación ya determinada (art. 36).

h) El hijo concebido durante el estado de separación no goza de la presunción del artículo 184 del Código Civil, de tener por padre al marido (art. 37). No obstante, podrá el hijo ser inscrito como hijo de los cónyuges, si concurre el consentimiento de ambos. Esto último es lógico pues importa un reconocimiento voluntario.

i) La sentencia firme de separación judicial autoriza para revocar todas las donaciones que por causa de matrimonio se hubieren hecho al cónyuge que dio motivo a la separación judicial (art. 1790 en el nuevo inciso 2º agregado por la ley 19.947).

j) Los cónyuges separados judicialmente pueden celebrar contratos de compraventa entre sí (art. 1796, en el nuevo texto).

k) No se suspende la prescripción a favor de la mujer separada judicialmente de su marido (art. 2509 en el nuevo texto dado por la ley 19.947).

l) El cónyuge que dio lugar a la separación judicial pierde el beneficio de competencia a que podría

tener derecho (art. 1626 N° 2).

2.5 Reconciliación o reanudación de la vida en común.

El párrafo 4 del Capítulo III de la nueva Ley de Matrimonio Civil, artículos 38 al 41, regula esa materia.

La reanudación de la vida en común de los cónyuges, con ánimo de permanencia, pone fin al procedimiento destinado a declarar la separación judicial o a la ya decretada, y, en este último caso, restablece el estado civil de casados (art. 38).

Decretada la separación judicial en virtud del art. 26 (por falta o culpa de uno de los cónyuges) será necesaria una nueva sentencia que a petición de ambos cónyuges, revoque la sentencia de separación. Para que esta nueva sentencia sea oponible a terceros, se debe subinscribir al margen de la inscripción matrimonial (art. 39 inciso 1°).

En el caso que la separación judicial se hubiere producido porque uno de los cónyuges lo solicitó en conformidad al artículo 27 (cese de la convivencia) para que la reanudación sea oponible a terceros “basta que ambos cónyuges dejen constancia de ella en un acta extendida ante el Oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción matrimonial”. En este caso “el Oficial del Registro Civil comunicará esta circunstancia al tribunal competente, que ordenará agregar el documento respectivo a los antecedentes del juicio de separación” (art. 39 inc. 2°).

La reanudación de la vida en común no revive la sociedad conyugal ni el régimen de participación en los gananciales, pero los cónyuges podrán pactar por una sola vez este último en conformidad con el artículo 1723 del Código Civil (art. 40 de la ley de matrimonio civil y art. 165 inc. 2° del Código Civil).

Finalmente el artículo 41 agrega que “La reanudación de la vida en común no impide que los cónyuges puedan volver a solicitar la separación, si ésta se funda en hechos posteriores a la reconciliación”.

Unidad 4: Extinción del Matrimonio.

Esta materia está tratada en **el Capítulo IV de la Ley de Matrimonio Civil, artículos 42 y siguientes.**

De acuerdo al art. 42, las únicas causales de terminación del matrimonio son:

- La muerte de uno de los cónyuges;
- La muerte presunta de uno de los cónyuges, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo 43;
- La sentencia que declara la nulidad del matrimonio; y
- La sentencia que declara el divorcio.

Tema 1: Disolución del matrimonio por muerte natural.

Respecto a la muerte natural, poco hay que decir, salvo recordar que de acuerdo a la propia definición de matrimonio que da el artículo 102 del Código Civil, los contrayentes se unen actual e indisolublemente **y por toda la vida**, con lo que queda claramente establecido que el fallecimiento de uno de los cónyuges, pone término al matrimonio.

Tema 2: Disolución del matrimonio por muerte presunta.

De acuerdo al artículo 42 N° 2, “el matrimonio termina: 2º Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente”. Estos plazos son los siguientes:

- a) El matrimonio se disuelve cuando transcurren diez años desde la fecha de las últimas noticias, fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte (art. 43 inc. 1º).
- b) El matrimonio también termina, si cumplidos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido setenta años desde el nacimiento del desaparecido (art. 43 inc. 2º, primera parte).
- c) Cuando la presunción de muerte se haya declarado, en virtud del número 7 del artículo 81 del Código Civil -caso de la persona que recibe una herida grave en la guerra o le sobreviene otro peligro semejante- transcurridos cinco años contados desde la fecha de las últimas noticias (art. 43 inc. 2º, segunda parte); y
- d) En los casos de los artículos 8 y 9 del artículo 81 del Código Civil -persona que viajaba en una nave o aeronave perdida; y caso del desaparecido en un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas, respectivamente- el matrimonio se termina transcurrido un año desde el día presuntivo de la muerte (art. 43 inc. 3º).

Tema 3: Nulidad del matrimonio.

La Ley de Matrimonio Civil destina el **Capítulo V, artículos 44 a 52, a reglamentar la nulidad del matrimonio.**

3.1 Algunas particularidades de la nulidad matrimonial.



Observación

La nulidad del matrimonio presenta algunas características propias, que la diferencian de la nulidad patrimonial.

a) No hay causales genéricas de nulidad de matrimonio. La ley señala en forma precisa los vicios que acarrean la nulidad. En derecho patrimonial, existen causales genéricas, v. gr. son nulos los contratos prohibidos por la ley; son nulos los actos o contratos en que se han omitido las solemnidades legales, etc. En cambio, tratándose de la nulidad del matrimonio, las causales son taxativas, p. ej. el matrimonio es nulo por no haberse celebrado ante del número de testigos hábiles determinados en el artículo 17, etc.

La Ley de Matrimonio Civil, sigue en esta materia la opinión dominante de los tratadistas franceses del siglo 19, en orden a que no hay nulidad de matrimonio sin texto expreso.

b) En materia de nulidad matrimonial, no cabe distinguir entre nulidad absoluta o relativa. Simplemente hay nulidad porque la ley no ha hecho tal distinción. Esta es la opinión mayoritaria de la doctrina y jurisprudencia.

c) En materia patrimonial, declarada la nulidad, las partes vuelven al estado anterior a la celebración del acto o contrato (art. 1687 del Código Civil). En materia matrimonial, no ocurre lo anterior respecto del cónyuge que de buena fe y, con justa causa de error celebró el matrimonio. Juega en la nulidad del matrimonio una institución muy importante, el **matrimonio putativo**, destinada justamente a evitar que se produzcan algunos efectos propios de la nulidad. Esta materia estaba tratada antes en el artículo 122 del Código Civil, y hoy lo está en los artículos 51 y 52 de la Ley de Matrimonio Civil.

d) No puede alegar la nulidad de un acto o contrato el que lo celebró sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba (artículo 1683 del Código Civil). En materia de nulidad de matrimonio, **no rige esta regla**, si bien ha habido sentencias que han dicho lo contrario argumentando que nadie se puede aprovechar de su propio dolo.

A juicio de Ramos las razones que aconsejan la nulidad matrimonial, son de tanta trascendencia para la sociedad, que debe admitirse que aun quien se casó sabiendo el vicio pueda alegar la nulidad. Así por ejemplo, si una persona conociendo su parentesco, se casa con su hermana ¿podría alguien sostener que no puede alegar la nulidad porque celebró el matrimonio conociendo el vicio que lo invalidaba? Otro ejemplo, de más fácil ocurrencia: el bígamo puede pedir la nulidad de su segundo matrimonio invocando que se casó no obstante estar casado. Así lo ha resuelto, la Corte Suprema (T. 55, sec. 1ª, p. 305). En otro caso, la Corte de Apelaciones de Santiago, aplicando el principio de que nadie se puede aprovechar de su propio dolo, resolvió que no podía alegar la nulidad de su matrimonio, la persona impotente que sabiendo que lo era, contrajo matrimonio. (T. 54, sec. 2ª, p. 55). El mismo tribunal, en sentencia publicada en Gaceta Jurídica Nº 123, p. 15, resolvió que "debe rechazarse la demanda de nulidad de matrimonio invocando como causal la

existencia de un matrimonio celebrado en el extranjero, por cuanto al actor le está vedado invocar en su beneficio la nulidad de que se trata de acuerdo al artículo 1683”.

e) A diferencia de la nulidad en materia patrimonial, por regla general, la acción de **nulidad de matrimonio no prescribe, pero debe alegarse en vida de los cónyuges** (artículos 47 y 48 de la Ley de Matrimonio Civil).

3.2 Causales de nulidad de matrimonio.

Las causales de nulidad son **taxativas y los vicios** que las constituyen deben haber existido al tiempo del matrimonio. Así lo consigna el artículo 44 en su primera parte “el matrimonio **sólo** podrá ser declarado nulo por alguna de las siguientes causales, **que deben haber existido al tiempo de su celebración**”. Luego las únicas causales de nulidad de matrimonio en Chile, son las siguientes:

a) Matrimonio celebrado existiendo algún impedimento dirimente (art. 44, letra a).

El artículo 44 de la Ley de Matrimonio Civil señala que “el matrimonio sólo podrá ser declarado nulo por alguna de las siguientes causales, que deben haber existido al tiempo de su celebración: a) Cuando uno de los contrayentes tuviere alguna de las incapacidades señaladas en el artículo 5º, 6º o 7º de esta ley”.

b) Falta de consentimiento libre y espontáneo de alguno de los contrayentes (art. 44 letra b).

Esta causal está contemplada en el artículo 44 letra b) de la Ley de Matrimonio Civil: “cuando el consentimiento no hubiere sido libre y espontáneo en los términos expresados en el artículo 8º”.

c) Celebración del matrimonio ante testigos inhábiles o en menor número de los que la ley exige (art. 45).

El matrimonio se debe celebrar ante dos testigos (art. 17) y no hay más testigos inhábiles que los que indica el artículo 16 de la Ley de Matrimonio Civil.

3.3 Eliminación de la causal de incompetencia del Oficial del Registro Civil.

Bajo la vigencia de la anterior Ley de Matrimonio Civil, **la incompetencia del Oficial del Registro Civil, podía obedecer a dos razones:**



a) Cuando un oficial del Registro Civil autorizaba un matrimonio fuera de su **territorio jurisdiccional** como, por ejemplo si el Oficial Civil de Valdivia celebrara un matrimonio en Concepción; y

b) Cuando el matrimonio se verificaba ante un Oficial del Registro Civil, que no correspondía al **domicilio o residencia** (por el tiempo legal) de ninguno de los contrayentes (art. 35 de la ley 4808). Era el caso, por ejemplo, de las personas que se casaban en Concepción teniendo el varón domicilio en Santiago y la mujer en Viña del Mar.

Respecto del primer caso nada ha cambiado. Los Oficiales Civiles sólo pueden ejercer su ministerio dentro del territorio que la ley les asigna. Si autoriza un matrimonio fuera de su territorio jurisdiccional, ese acto adolece de nulidad de derecho público, que se rige por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

De las dos situaciones recién descritas, la verdaderamente importante era la segunda pues a ella se recurría para anular los matrimonios.

El artículo 31 de la anterior Ley de Matrimonio establecía que era nulo el matrimonio que no se celebrara ante el oficial del Registro Civil correspondiente. Y el artículo 35 de la Ley de Registro Civil, establecía cuál era ese Oficial Civil correspondiente: “Será competente para celebrar un matrimonio el Oficial del Registro Civil de la comuna o sección en que cualquiera de los contrayentes tenga su domicilio, o haya vivido los tres últimos meses anteriores a la fecha del matrimonio”.

Como en Chile no hubo divorcio vincular hasta que entró en vigencia la ley 19.947 (18 de noviembre de 2004), las personas que querían anular su matrimonio recurrían al artificio de sostener que a la fecha de su casamiento, el domicilio y la residencia de ambos estaba en un lugar distinto de aquél en que se habían casado, con lo que venía a resultar que el matrimonio aparecía celebrado ante un funcionario incompetente. Y para probar el domicilio y residencia que afirmaban haber tenido recurrían a la prueba de testigos. Como se trataba de probar un hecho negativo (que no tenían domicilio ni residencia en la comuna o sección del Oficial Civil ante el que se casaron), se probaba el positivo contrario, por lo que los testigos atestiguaban que ambos contrayentes a la fecha del matrimonio y durante los tres meses anteriores a su celebración tenían su domicilio y residencia en un lugar distinto de aquél en que se casaron.

Esta situación comenzó a ser aceptada por nuestros tribunales alrededor del año 1925.

La ley 19.947, eliminó esta causal de nulidad al derogar el artículo 35 de la ley 4808 y dispuso que se podía contraer matrimonio ante cualquier oficial de Registro Civil (art. 9° de la nueva ley de matrimonio civil).

3.4 Acción de nulidad de matrimonio

La nulidad de un matrimonio debe ser declarada judicialmente. No opera por el sólo ministerio de la ley. De consiguiente, si el matrimonio adolece de vicios que producen su nulidad, deberá interponerse la acción de nulidad.

a) Características de la acción de nulidad

La acción de nulidad tiene algunas características que le son propias:

- Es una acción de derecho de familia. Por ello está fuera del comercio; es irrenunciable; no es susceptible de transacción (art. 2450 Código Civil), no cabe a su respecto el llamado a conciliación (art. 262 del Código de Procedimiento Civil); no puede someterse a compromiso (arts. 230 y 357 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales).
- Por regla general su ejercicio sólo corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges (art. 46).
- Por regla general, es imprescriptible (art. 48).
- Por regla general, sólo se puede hacer valer en vida de los cónyuges (art. 47).

b) Titulares de la acción de nulidad

La acción de nulidad de matrimonio, corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges (art. 46)

Esta regla tiene varias excepciones:

- La nulidad fundada en el N° 2 del artículo 5° -matrimonio de una persona menor de 16 años-

podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges o por alguno de sus ascendientes, pero alcanzados los 16 años por parte de ambos contrayentes, la acción se radicará únicamente en el o los que lo contrajeron sin tener esa edad (art. 46 a);

- La acción de nulidad fundada en alguno de los vicios del artículo 8º (vicios del consentimiento) corresponde exclusivamente al cónyuge que ha sufrido el error o la fuerza (art. 46 b);
- En los casos de matrimonio en artículo de muerte, la acción corresponde también a los demás herederos del cónyuge difunto (art. 46 c);
- Cuando la causal invocada es la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto, corresponde también la acción de nulidad al cónyuge anterior o a sus herederos (art. 46 d).
- La declaración de nulidad fundada en alguna de las causales contempladas en los artículo 6 y 7 – vínculo de parentesco y matrimonio de una persona con el que tuvo participación en el homicidio de su marido o mujer– puede ser alegada, por cualquier persona, en el, interés de la moral y de la ley. La naturaleza del vicio explica que se otorgue en este caso acción popular para demandar la nulidad (art. 46 e).

c) La acción de nulidad es imprescriptible

El artículo 48 establece que la acción de nulidad de matrimonio no prescribe por tiempo. Y en seguida contempla varias excepciones:

- La causal fundada en la menor edad de uno de los contrayentes, prescribe en el plazo de un año, contado desde la fecha que el cónyuge inhábil para contraer matrimonio hubiere adquirido la mayoría de edad (art. 48 a);
- Cuando la causal fuere vicio del consentimiento, la acción prescribe en tres años contados desde que hubiere desaparecido el hecho que origina el vicio de error o la fuerza (art. 48 b) ;
- En el caso del matrimonio en artículo de muerte, la acción prescribe en un año contado desde la fecha del fallecimiento del cónyuge enfermo (art. 48 c);
- Si la causal invocada es vínculo matrimonial no disuelto, la acción prescribe en un año contado desde el fallecimiento de uno de los cónyuges (art. 48 d); y
- Si la causal de nulidad es la falta de testigos hábiles, la acción prescribe en un año, contado desde la celebración del matrimonio (art. 48 e).

d) La acción de nulidad sólo puede intentarse en vida de los cónyuges.

Según el artículo 47 de la Ley de Matrimonio Civil, “la acción de nulidad del matrimonio sólo podrá intentarse mientras vivan ambos cónyuges, salvo los casos mencionados en las letras c) y d) del artículo precedente”, esto es, en los casos del matrimonio en artículo de muerte o cuando el vicio sea vínculo matrimonial no disuelto.

Respecto a la excepción relativa al vínculo matrimonial no disuelto, cabe señalar que fue incorporada por la Ley 10.271, y tuvo por objeto permitir que en el caso de bigamia, fallecido uno de los cónyuges se pudiera demandar la nulidad, para evitar que los dos matrimonios quedaren consolidados produciéndose dos líneas de descendencia matrimonial, dos sociedades conyugales etc., lo que habría ocurrido de no establecerse la excepción.

e) Efectos de la declaración de nulidad del matrimonio.

La sentencia que declara la nulidad debe subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial. Así lo dispone el inciso 2º del artículo 50. Sólo se trata de un requisito de oponibilidad frente a terceros. De consiguiente, si un cónyuge anulado contrae nuevas nupcias antes de subinscribir la sentencia de nulidad, su segundo matrimonio es válido, pues el vínculo matrimonial anterior ya estaba extinguido.

Declarada la nulidad de un matrimonio, los cónyuges quedan en la misma situación que tenían al

momento de casarse. Ello por aplicación del art. 50 inc. 1º de la ley de matrimonio civil y artículo 1687 del Código Civil. Ello significa lo siguiente:

- Si con posterioridad a la celebración del matrimonio que se anuló, uno de ellos contrajo un nuevo matrimonio, tal matrimonio es válido, pues no existe el impedimento de vínculo matrimonial no disuelto. Por la misma razón tampoco se ha incurrido en el delito de bigamia;
- No se ha producido parentesco por afinidad entre cada cónyuge y los consanguíneos del otro;
- No ha habido derechos hereditarios entre los cónyuges;
- Las capitulaciones matrimoniales que pudieren haber celebrado caducan;
- No ha habido sociedad conyugal, habiéndose formado únicamente entre los cónyuges una comunidad que debe ser liquidada de acuerdo a las reglas generales;
- La mujer no ha tenido el privilegio de cuarta clase que le otorga el artículo 2481 Nº 3º del Código Civil;
- La filiación de los hijos concebidos dentro del matrimonio anulado, sería extramatrimonial.

Fácil es entender la gravedad que toda esta situación supone. Por ello, y pensando especialmente en la filiación de los hijos, ha nacido la institución del matrimonio putativo, que pretende justamente evitar que se produzcan los efectos propios de la declaración de nulidad.

f) Matrimonio putativo.

Declarada la nulidad de un matrimonio, deberían las partes volver al mismo estado en que se hallarían si no se hubieren casado, lo que significa, entre otras cosas, aceptar que habrían convivido en concubinato, y que los hijos, que en ese estado hubieren concebido tendrían filiación no matrimonial. Esta situación es de tal gravedad que desde antiguo ha preocupado a los juristas y los ha llevado a elaborar la institución del Matrimonio Putativo.

El matrimonio putativo es uno de los tantos aportes al Derecho, introducidos por el Derecho Canónico.

El Código Civil dio cabida a la institución del Matrimonio Putativo en el artículo 122, que fue suprimido por la ley 19.947, que lo reemplazó por los artículos 51 y 52 de la Ley de Matrimonio Civil. El inciso 1º del artículo 51 prescribe que "El matrimonio nulo, que ha sido celebrado o ratificado ante el oficial del Registro Civil produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe, y con justa causa de error, lo contrajo, pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges".

f.1) Requisitos del matrimonio putativo.

De la definición del artículo 51, se desprende que los requisitos para que exista matrimonio putativo, son los siguientes:

i) Matrimonio nulo. Si el matrimonio es inexistente no cabe el matrimonio putativo. Esto es absolutamente claro y no hay opiniones discordantes. Y justamente, por esta razón es trascendente la distinción entre matrimonio inexistente y nulo.

ii) Debe celebrarse ante Oficial del Registro Civil. La Ley 19.947 agregó lo de "ratificado" ante el Oficial del Registro Civil, para comprender los matrimonios celebrados ante una entidad religiosa los que para que adquieran valor se deben ratificar ante un Oficial del Registro Civil.

iii) Buena fe, a lo menos, de uno de los cónyuges. Este es el requisito esencial del matrimonio putativo puesto que la institución es un reconocimiento a esta buena fe.

El Código no define lo que se entiende por buena fe. Se ha entendido que es la conciencia que tiene el contrayente de estar celebrando un matrimonio sin vicios.

La buena fe es un requisito que se debe tener al momento de celebrarse el matrimonio.

Con anterioridad a la ley 19.947, se discutía si la buena fe debía probarse o se presumía igual que en materia posesoria (art. 707). En general, la doctrina se pronunciaba por la tesis de que el artículo 707, si bien está ubicado en materia posesoria, es de alcance general por lo que también debía aplicarse al matrimonio putativo (Fueyo, Somarriva, Rossel). En cambio Claro Solar, aceptando que la opinión generalmente aceptada era presumir la buena fe, dice estar de acuerdo con Laurent cuando este autor afirma que una vez anulado el matrimonio, no puede producir efecto sino por excepción, cuando ha sido celebrado de buena fe y que, por tanto, es al esposo que reclama un efecto civil, a quien toca probar que lo ha contraído de buena fe desde que éste será el fundamento de su demanda. Hubo fallos en ambos sentidos.

La ley 19.947 vino a poner fin a esta discusión, resolviendo el problema del mismo modo que lo había entendido la mayoría de la doctrina, es decir, que la buena fe se presume. Así lo dice expresamente el artículo 52 de la Ley de Matrimonio Civil: "Se presume que los cónyuges han contraído matrimonio de buena fe y con justa causa de error, salvo que en el juicio de nulidad se probare lo contrario y así se declare en la sentencia".

iv) Justa causa de error.

Lo que ha querido decir el artículo 51, al establecer esta exigencia es que cualquier error no es suficiente. Debe tratarse de un error excusable. En definitiva este requisito tiende a confundirse con el de la buena fe.

Un error de hecho puede ser excusable. Pero es dudoso que pueda serlo un error de derecho, desde que la ley se presume conocida (art. 8º del Código Civil). Dice Ramos: "Por lo demás, si antes se aceptaba que respecto de esta institución regía la presunción de buena fe establecida en la posesión, un mínimo de consecuencia, obligaba a aplicar también el artículo 706 ubicado en la misma materia según el cual "el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario".

Continúa el autor "Pongamos un ejemplo para clarificar las cosas: si se casa una pareja de hermanos, sin saber que lo eran, han padecido un error de hecho, que permite la putatividad. En cambio, si la misma pareja se casa a sabiendas que eran hermanos, pero ignorando que la ley no permite tal matrimonio, han sufrido un error de derecho que, según algunos, sería incompatible con la existencia de un matrimonio putativo".

Somarriva es de opinión de admitir el error de derecho, por cuanto el artículo 122 del Código Civil (hoy artículo 51 de la ley de matrimonio civil), no hace ninguna distinción, sólo habla de "justa causa de error". Además, por la función que cumple la institución es conveniente ampliar su campo de aplicación.

f.2) Declaración judicial de putatividad

En general la doctrina nacional no exige más requisitos para el matrimonio putativo, que los 4 que se han señalado.

Bajo el imperio de la ley antigua (artículo 122 del Código Civil) Fueyo opinaba que se requería además de una resolución judicial que declare que el matrimonio había sido putativo. Así también lo resolvió en su momento una sentencia de la Excm. Corte Suprema (T. 29, sec. 1ª, p. 73).

En general, la doctrina vinculaba este problema con el de la buena fe y la justa causa de error. Hoy día este problema está expresamente resuelto. En efecto, al presumirse estos requisitos debe concluirse que todo matrimonio nulo es putativo, salvo que en el juicio de nulidad se probare lo contrario y así lo declare la sentencia (art. 52).

f.3) Efectos del matrimonio putativo

El artículo 51 precisa los efectos al señalar que "produce los mismos efectos civiles que el válido, respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo".

Los autores hacen en esta materia las siguientes distinciones: efectos en relación con los hijos; y efectos entre los cónyuges.

i) Efectos en relación con los hijos.

La institución del matrimonio putativo fue creada con el objeto de evitar la ilegitimidad de los hijos en los casos en que el matrimonio se anulaba. Por ello resulta lógico que el hijo concebido durante el matrimonio putativo de los padres mantenga la filiación matrimonial.

Este efecto se produce sea que el matrimonio haya sido putativo para ambos padres sea que lo haya sido sólo para uno de ellos, puesto que siendo el estado civil indivisible, no podrían los hijos tener filiación matrimonial respecto de uno de sus padres y no tenerla respecto del otro.

Los efectos que produce el matrimonio putativo respecto de los hijos, son permanentes, se mantienen aún cuando desaparezca la putatividad. Ello es consecuencia de ser el estado civil una calidad "permanente" de toda persona.

La nulidad del matrimonio no afecta en caso alguno la filiación ya determinada de los hijos, aunque el matrimonio no sea putativo.

Así lo establece el artículo 51 inciso 4º: "Con todo, la nulidad no afectará la filiación ya determinada de los hijos, aunque no haya habido buena fe ni justa causa de error por parte de ninguno de los cónyuges".

Es importante destacar que en el artículo 122 del Código Civil (derogado por la ley 19.947) la situación era distinta porque cuando no se daban los requisitos del matrimonio putativo, la nulidad no afectaba la filiación matrimonial de los hijos únicamente cuando la nulidad se había declarado por incompetencia del Oficial Civil, por no haberse celebrado el matrimonio ante el número de testigos requeridos por la ley o por inhabilidad de estos. En los demás casos, declarada la nulidad del matrimonio, ésta afectaba la filiación de los hijos. Con la ley 19.947 la excepción se amplía a todo matrimonio nulo, cualquiera sea el vicio de nulidad.

ii) Efectos en relación con los cónyuges.

El matrimonio putativo produce los mismos efectos civiles del válido mientras se mantenga la buena fe a lo menos en uno de los cónyuges. Desaparecida la buena fe en ambos, cesan los efectos del matrimonio putativo. Así lo señala el artículo 51 inciso 1º, parte final.



¿Cuándo cesa la buena fe? Respecto del cónyuge que demanda la nulidad del matrimonio debe entenderse que el sólo hecho de presentar la demanda, constituye prueba de que la buena fe ha desaparecido para él, en ese momento. En cuanto al demandado, Somarriva, aplicando por analogía la regla dada por el artículo 907 al hablar de las prestaciones mutuas, sostiene que la buena fe desaparece con la contestación de la demanda. De acuerdo a esto, el

matrimonio nulo produce los mismos efectos civiles que el válido hasta el momento de la contestación de la demanda. Ello, sin perjuicio de que pueda probarse que la buena fe desapareció antes.

Atendido lo que se acaba de explicar, mientras se mantiene la buena fe a lo menos en un cónyuge, el matrimonio produce todos sus efectos, tanto en la persona de los cónyuges como respecto de los bienes. Así, deben cumplir con todos los deberes y obligaciones que surgen del matrimonio: fidelidad, ayuda mutua, socorro, se ha generado entre ellos sociedad conyugal si se casaron bajo ese régimen, etc.

Un estudio aparte merece lo relativo a la sociedad conyugal. Declarada la nulidad del matrimonio, si

el matrimonio ha sido putativo, se disuelve la sociedad conyugal. Si el matrimonio ha sido simplemente nulo, ésta no ha nacido y por ende no se puede disolver lo que no ha existido. Así resulta del efecto retroactivo de la declaración de nulidad (artículo 1687). Por ello, cuando el artículo 1764 indica entre las causales de extinción de la sociedad conyugal la declaración de nulidad (Nº 4), debe entenderse que ello sólo es así si el matrimonio fue putativo. En caso contrario, no se ha generado la sociedad conyugal, y sólo se ha producido una comunidad o sociedad de hecho que habrá de disolverse y liquidarse de acuerdo a las reglas generales.

En relación con la sociedad conyugal, cabe preguntarse qué ocurre cuando, los requisitos del matrimonio putativo, sólo concurren respecto de uno sólo de los cónyuges. Es un problema que antes de la ley 19.947 no estaba resuelto. En todo caso es claro que no puede haber sociedad conyugal para uno de ellos, y no para el otro. O hay sociedad conyugal para ambos o no la hay para ninguno. En general, se pensaba que el cónyuge que celebró el matrimonio de buena fe tenía derecho a optar entre liquidar la comunidad de acuerdo a las reglas dadas para la liquidación de la sociedad conyugal o a las establecidas para liquidar una comunidad o sociedad de hecho.

La ley 19.947, resolvió este problema en la misma forma que lo hacía la mayor parte de la doctrina. El artículo 51 inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil estableció que: "Si sólo uno de los cónyuges contrajo matrimonio de buena fe, éste podrá optar entre reclamar la disolución y liquidación del régimen de bienes que hubiere tenido hasta ese momento, o someterse a las reglas generales de la comunidad".



Observación

Otro efecto que produce el matrimonio putativo, es permitir al cónyuge de buena fe conservar las donaciones que por causa de matrimonio le hizo o prometió hacer el otro cónyuge. Así lo establece el inciso 3º del artículo 51 "Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio se hayan hecho por el otro cónyuge al que casó de buena fe, subsistirán no obstante la declaración de la nulidad del matrimonio". Está demás decir que, *contrario sensu*, las donaciones que se ha hecho al cónyuge de mala fe deben ser restituidas. Así,

por lo demás lo dice en forma expresa el artículo 1790 inciso primero del Código Civil.

Tema 4: El Divorcio.

Dice Ramos "En el párrafo 5º de la anterior Ley de Matrimonio Civil, artículos 19 al 28, se establecía un mal llamado divorcio. Y decimos **"mal llamado divorcio"**, porque universalmente se entiende que el divorcio produce la ruptura del vínculo matrimonial, pudiendo los ex cónyuges contraer válidamente nuevas nupcias, lo que no ocurría con el que venimos comentando. Los cónyuges quedaban separados de mesa, casa y lecho, pero no podían contraer un nuevo matrimonio. Había dos clases de divorcio, uno perpetuo y otro temporal, no pudiendo este último exceder de 5 años. Los efectos de uno y otro eran distintos, pero ninguno de los dos rompía el vínculo matrimonial".

La gran innovación de la ley 19.947, es introducir el divorcio vincular en Chile.

Respecto a las causales de divorcio, la doctrina y la legislación comparada se mueven entre dos polos: "divorcio-sanción" y "divorcio remedio" (llamado también "divorcio solución"). El divorcio-sanción está concebido como una pena para el cónyuge culpable de una conducta que lesiona gravemente la vida familiar. En el divorcio-remedio, en cambio, se acepta como solución a la ruptura definitiva de la armonía conyugal, cuando la convivencia de la pareja se torna imposible.

Dice Ramos "en ninguna parte (del mundo) se adoptan posiciones extremas, sino que se buscan fórmulas intermedias, en lo pudiera llamarse un sistema mixto. Es lo que ocurre con la ley que

estamos glosando. En efecto, el artículo 54 contempla causales propias del divorcio sanción, y el artículo siguiente establece el divorcio como remedio para una convivencia que ya no existe o que está gravemente deteriorada”.

4.1 Causales de divorcio-sanción o “por culpa”.

El **artículo 54** establece que “el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, **por falta imputable al otro**, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común”.

Luego los requisitos son: **a) falta imputable a uno de los cónyuges; b) esta falta debe constituir una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos; y c) el incumplimiento de estos deberes u obligaciones debe hacer intolerable la vida en común.**

Respecto al primer requisito deberá tenerse presente que la falta debe ser “imputable”, es decir, culpable, de tal suerte que si, por ejemplo uno de los cónyuges sufre un grave accidente que lo deja parapléjico, tal hecho puede hacer intolerable la vida en común, pero no configura una causal de divorcio (Javier Barrientes Grandón).

Sin duda el tercer requisito es el determinante. Por consiguiente frente a una demanda de divorcio será el tribunal que conozca del juicio de divorcio el que tendrá que ponderar si hubo incumplimiento a los deberes para con el otro cónyuge o para con los hijos y si este incumplimiento es de tal entidad que haga intolerable la vida en común.

La norma agrega que se incurre en esta causal, **entre otros casos**, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos:

1º Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos;

2º Transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común, es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio;

3º Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal” (dentro de estos títulos están los delitos de aborto, abandono de niños o personas desvalidas, delitos contra el estado civil de las personas, rapto, violación, estupro y otros delitos sexuales, incesto, matrimonios ilegales, homicidio, infanticidio, lesiones corporales, duelo, calumnia, injurias);

4º Conducta homosexual;

5º Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos; y

6º Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.

Estas causales no son taxativas, pues la norma emplea la expresión “entre otros casos”.

4.2 Causales de divorcio-remedio o “por cese de la convivencia”.

El **artículo 55** contempla dos casos de divorcio remedio:

a) Cuando **ambos cónyuges lo piden de común acuerdo**, acreditando que ha cesado la convivencia entre ellos durante un lapso mayor de **un año** y acompañen un acuerdo regulatorio (completo y suficiente, en los términos de los arts. 21 y 27) de sus relaciones mutuas y para con los hijos (art. 55 incs. 1° y 2°).

b) Cuando lo solicite **cualquiera de los cónyuges** por haberse producido un cese efectivo de la convivencia conyugal, durante a lo menos **tres años** (art. 55 inc. 3°). Nótese que estamos frente a un caso de divorcio unilateral.

De acuerdo a este inciso 3°, los requisitos para que opere el divorcio en el presente caso son: 1) Cese efectivo de la convivencia conyugal; 2) que esta situación haya durado a lo menos tres años; y 3) el actor haya cumplido con su obligación alimenticia respecto de su cónyuge e hijos.

En relación con el primer requisito, llama la atención que esta disposición hable de “**cese efectivo** de la convivencia conyugal”, y no simplemente “cese de la convivencia”, como lo establece el inciso 1°. Sobre ello Javier Barrientos señala: “Este requisito de la ‘efectividad’ del cese de la convivencia, no obstante su apariencia de objetividad, no ha de referirse a lo que algunos civilistas denominan, por influencia canónica, *corpus separationis* o hecho material de la separación física, sino propiamente al *animus separationis*, ya que si la *affectio* subsiste entre los cónyuges no habrá cese efectivo de la convivencia, aunque haya separación material y los esposos vivan en lugares diferentes y, por el contrario, si falta la *affectio*, tendrá lugar técnicamente el cese de la convivencia aunque convivan los esposos bajo el mismo techo”.

Respecto al segundo requisito -que el cese efectivo haya durado a lo menos tres años- **sólo podrá probarse** en la forma que indica los artículos 22 y 25 (art. 55 inc. 4°), esto es:

a) **Por alguno de los instrumentos que se indican en el artículo 22** (escritura pública, o acta extendida y protocolizada ante notario público; acta extendida ante un Oficial del Registro Civil; transacción aprobada judicialmente) mediante los cuales los cónyuges regulen su separación de hecho;

b) **Por la notificación de la demanda de regulación de sus relaciones mutuas**, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio y, si hubiere hijos, al régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tuviere a su cuidado (arts. 23 y 25 inc. 1°);

c) Cuando no mediando acuerdo ni demanda entre los cónyuge, uno de ellos haya expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a través de cualquiera de los instrumentos indicados en el artículo 22 letras a) y b) y se haya notificado al otro cónyuge (art. 25 inc. 2°); y

d) Cuando uno de los cónyuges haya dejado constancia de su intención de poner fin a la convivencia ante el juzgado correspondiente y ello sea notificado al otro cónyuge (art. 25 inc. 2°).

La notificación se practicará según las reglas generales (art. 25 inc. 2°, parte final).

Esta limitación probatoria para acreditar el cese de la convivencia no rige para los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio civil. En estos casos, las partes no tienen mayores limitaciones probatorias, salvo que la sola confesión no es suficiente, debiendo el juez analizar si los medios de prueba aportados por las partes le permiten formarse plena convicción sobre este hecho (art. 2º transitorio, inc. 3º).

En relación al tercer requisito si la parte demandada lo solicitare, el juez debe verificar que el demandante durante el tiempo del cese de la convivencia ha dado cumplimiento a su obligación alimenticia respecto de su cónyuge e hijos. El incumplimiento reiterado e injustificado de esta obligación hará que la demanda de divorcio sea rechazada (art. 55 inc. 3º).

La parte demandada para hacer exigible esta exigencia debe oponer la correspondiente excepción perentoria.

La sentencia que rechace la demanda no produce cosa juzgada de tal suerte que se puede volver a demandar, previo cumplimiento de los requisitos legales, es decir, nuevo cese de la convivencia, nuevo plazo de 3 años y cumplir en forma regular durante este nuevo plazo los deberes alimenticios, con el cónyuge e hijos.

4.3 Características de la acción de divorcio.

- a) Pertenece exclusivamente a los cónyuges (art. 56 inc. 1º);
- b) Corresponde a ambos cónyuges, salvo en el caso del artículo 54, es decir, cuando el divorcio es por culpa de uno de ellos, en que no la tiene el culpable (art. 56 inc. 2º);
- c) Es irrenunciable (art. 57);
- d) Es imprescriptible (art. 57);
- e) Por su misma naturaleza tiene que intentarse en vida de los cónyuges.

4.4 Efectos del divorcio.

El artículo 59 inciso 1º señala que **“el divorcio producirá efectos entre los cónyuges desde que quede ejecutoriada la sentencia que lo declare”** y el inciso 2º agrega que **“sin perjuicio de ello, la sentencia ejecutoriada en que se declare el divorcio deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Efectuada la subinscripción, la sentencia será oponible a terceros y los cónyuges adquirirán el estado civil de divorciados, con lo que podrán volver a contraer matrimonio”**.

1. Se adquiere el estado civil de divorciados y se puede volver a contraer matrimonio (art. 59 inc. 2º).

El estado civil de divorciado se prueba en conformidad al art. 305 del C. Civil.

2. El divorcio no afecta la filiación ya determinada de los hijos ni los derechos y obligaciones que

emanan de ella. Luego los hijos continuarán siendo hijos de filiación matrimonial de sus padres y tendrán, respecto de ellos, los derechos y obligaciones que tal filiación supone (art. 53).



3. El divorcio pone fin a los derechos de carácter patrimonial, como el de alimentos y sucesorios entre los cónyuges (art. 60). Ello sin perjuicio de que se acuerde o se fije judicialmente una compensación al cónyuge económicamente más débil, determinada en la forma dispuesta en los artículos 61 y siguientes.

4. Habilita al cónyuge para pedir al juez la desafectación de un bien de su propiedad que esté declarado como bien familiar (art. 145 del C. Civil, inciso final).

5. La sentencia de divorcio firme autoriza para revocar todas las donaciones que por causa de matrimonio se hubieren hecho al cónyuge que dio motivo al divorcio por su culpa, con tal que la donación y su causa constare por escritura pública (art. 1790 inc. 2°).

4.5 Divorcio obtenido en el extranjero

La ley 19.947 regula esta materia en el artículo 83 en los siguientes términos:

El inciso 1º establece que “El divorcio estará sujeto a la ley aplicable a la relación matrimonial al momento de interponerse la acción” **¿Cuál es esa ley aplicable a la relación matrimonial?** La respuesta debe buscarse en los principios de derecho internacional privado (puede ser la ley de la nacionalidad, del domicilio, etc.).

El inciso 2º se refiere a un segundo aspecto: “las sentencias de divorcio y de nulidad de matrimonio dictadas por tribunales extranjeros serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil”. Dicho en otras palabras, para cumplir esas sentencias en Chile, deberá darse el exequátur por la Corte Suprema, para lo cual deberá acompañarse una copia debidamente legalizada de la sentencia.

Los incisos siguientes del artículo 83 privan de valor a las sentencias de divorcio extranjeras, en los siguientes casos:

a) Cuando no ha sido declarado por resolución judicial (art. 83, inc. 3º);

b) Cuando se oponga al orden público chileno (art. 83, inc. 3º)

c) Cuando se ha obtenido con fraude a la ley (art. 83, inc. 4º). Y aquí se agrega algo importante, con el fin de evitar que las personas domiciliadas en Chile se vayan a divorciar al extranjero para evitar las limitaciones que establece la nueva ley. Dice la norma que “se entenderá que se ha actuado en fraude a la ley cuando el divorcio ha sido declarado bajo una jurisdicción distinta a la chilena, a pesar de que los cónyuges hubieran tenido domicilio en Chile durante cualquiera de los tres años anteriores a la sentencia que se pretende ejecutar, si ambos cónyuges aceptan que su convivencia ha cesado a lo menos ese lapso, o durante cualquiera de los cinco años anteriores a la sentencia, si discrepan acerca del plazo de cese de la convivencia. El acuerdo o la discrepancia entre los cónyuges podrá constar en la propia sentencia o ser alegado durante la tramitación del exequátur”. Nótese que este inciso 4º establece una presunción de derecho de fraude a la ley.

Aunque la disposición tiene una redacción algo confusa, es claro que lo que pretende evitar es que los interesados en el divorcio viajen a hacerlo al extranjero para evitar el plazo de cese de la convivencia que le exige la legislación chilena.

Tema 5: Reglas comunes a ciertos casos de separación, nulidad y divorcio.

El Capítulo VII de la ley, artículos 61 y siguientes, da algunas reglas aplicables al divorcio, nulidad y algunos tipos de separación. Estas son: **compensación económica, conciliación y mediación.**

5.1 Compensación económica.

Esta materia la trata el párrafo 1º del título VII, artículos 61 al 66.

a) Concepto

Consiste en el derecho que asiste a uno de los cónyuges -normalmente la mujer- cuando por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar no pudo durante el matrimonio desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el menoscabo económico que, producido el divorcio o la nulidad, sufrirá por esta causa. Así se desprende del artículo 61. La compensación económica es una institución que persigue un objetivo de justicia.

b) Factores para determinar la cuantía de la compensación.

El artículo 62, señala los distintos aspectos que se deben considerar especialmente para fijar el quantum de esta compensación: duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges -nótese no sólo la duración del matrimonio sino también la duración de la vida en común-; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación previsional y beneficios de salud; su cualificación profesional y posibilidades del acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

Estos rubros no son taxativos, pues el artículo 62, dice que ellos se deben considerar “especialmente”.

c) Improcedencia o rebaja de la compensación

De acuerdo al artículo 62 inciso 2º, se puede denegar o rebajar esta compensación al cónyuge que dio lugar al divorcio por su culpa o falta.

d) Determinación de la procedencia y monto de la compensación.

Puede fijarse de dos maneras por acuerdo de las partes o judicialmente.



Observación

- Fijación por las partes. Dice el artículo 63: “La compensación económica y su monto y forma de pago, serán convenidas por los cónyuges, si fueren mayores de edad, mediante acuerdo que constará en escritura pública o acta de avenimiento, las cuales se someterán a la aprobación judicial”.
- Fijación por el tribunal. Si no hay acuerdo, se fija judicialmente. Se puede

pedir esta determinación en la demanda o con posterioridad, para lo cual, el tribunal informará a los cónyuges sobre la existencia de este derecho durante la audiencia de conciliación. Si el juez acoge la demanda de nulidad o de divorcio debe pronunciarse sobre la compensación económica en la sentencia (art. 64).

e) Forma de pago de la compensación.

De acuerdo al artículo 65, en la misma sentencia el juez debe señalar la forma de pago de la compensación, para lo cual podrá establecer las siguientes modalidades:

- Disponer la entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes. Si se fija una suma de dinero, podrá el juez fijar una o varias cuotas reajustables, debiendo el tribunal adoptar las seguridades para su pago; o
- Constituir un derecho de usufructo uso o habitación respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. La constitución de estos derechos no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario hubiere tenido a la fecha de su constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviere en cualquier tiempo (de aquí se deduce que es un derecho personalísimo del cónyuge titular).

Si el deudor no tuviere bienes suficientes para solucionar el monto de la compensación mediante las modalidades señaladas, el juez puede dividirlo en cuantas cuotas fueren necesarias, para lo cual tomará en consideración la capacidad económica del cónyuge deudor y expresará el valor de cada cuota en alguna unidad reajutable (art. 66). Estas cuotas se consideran alimentos **para el efecto de su cumplimiento**, a menos que se hubieren ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago, lo que se declarará en la sentencia (art. 66). Por consiguiente, para su pago el cónyuge deudor puede ser apremiado. Estas cuotas no constituyen una pensión alimenticia. Se las considera alimentos únicamente para los efectos del cumplimiento por lo que no rige la limitación contenida en el artículo 7º de la ley 14.908, de que no puede exceder del 50% de las rentas del deudor. Otra consecuencia importante es que una vez fijada no se debe alterar por circunstancias sobrevinientes, por ej. si el cónyuge que tiene que pagar queda cesante, tenga otros hijos o mejore su condición económica por cualquier razón.

5.2 Conciliación.

Según el artículo 67 solicitada la separación o el divorcio, se debe llamar a las partes a una audiencia de conciliación especial, que persigue dos objetivos: tratar de superar el conflicto de la pareja y si ello no es factible acordar las medidas relativas a los alimentos de los cónyuges e hijos, su cuidado personal, la relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o la madre que no los tenga a su cuidado, y el ejercicio de la patria potestad. Este artículo 67 debe relacionarse con el artículo 90.

A la audiencia de conciliación se debe comparecer personalmente, pudiendo apremiarse al cónyuge que se niegue a asistir sin causa justificada (art. 68). El juez debe instar a las partes a la conciliación y proponerles bases de arreglo que se ajusten a las expectativas de cada parte (art. 69).

5.3 Mediación.

Se debe ordenar por el tribunal si las partes lo piden. No procede mediación en las causas de nulidad (art. 71).

Si las partes no la solicitan, puede ordenarla el tribunal, al término de la audiencia de conciliación,

salvo que estime que no sería útil. Para ello citará a las partes a una audiencia para proceder a la designación del mediador, que si no es elegido de común acuerdo, lo debe designar el tribunal de inmediato de entre los que figuren en un Registro de Mediadores que debe llevar el Ministerio de Justicia (art. 72).

La mediación presenta las siguientes características:

- a) Debe hacerse por profesionales idóneos, que aparezcan en un Registro elaborado por el Ministerio de Justicia, salvo que los mediadores sean designados de común acuerdo por las partes (arts. 77 y 78);
- b) Es voluntaria en el sentido que basta que alguna de las partes, citadas por dos veces, no concurra a la audiencia del mediador para que ésta se estime frustrada (art. 73, inc. 2º);
- c) El proceso de mediación tiene plazo de duración: no puede durar más de 60 días desde que el mediador haya recibido la comunicación del tribunal que lo designó, pero los cónyuges, de común acuerdo, pueden pedir ampliación del plazo hasta por otros 60 días (art. 75);
- d) Puede ser gratuita o remunerada. En este último caso, su costo será de cargo de las partes, siendo los honorarios máximos los establecidos en un arancel que dictará mediante decreto, el Ministerio de Justicia. Los que gocen de privilegio de pobreza o sean patrocinadas por la Corporación de Asistencia Judicial recibirán atención gratuita (art. 79);
- e) Si hay acuerdo, el acta debe ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho. Aprobada por el juez, tendrá valor de transacción judicial (art. 76).

5.4 Legislación aplicable a los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 19.947.

De acuerdo al artículo 2º transitorio las personas casadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, podrán separarse judicialmente, anular sus matrimonios y divorciarse en conformidad a las disposiciones de la nueva ley, con las siguientes salvedades:

- a) Las formalidades y requisitos externos del matrimonio y las causales de nulidad que su omisión origina, se regirán por la ley vigente al tiempo de su celebración, pero los cónyuges no podrán hacer valer la causal de nulidad por incompetencia del Oficial del Registro Civil contemplada en el artículo 31 de la anterior Ley de Matrimonio Civil;
- b) No rige para estas personas las limitaciones contempladas en los artículos 22 y 25 de la Ley de Matrimonio Civil, para acreditar el cese de la convivencia. Ello quiere decir que las personas casadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, no es necesario que el cese de la convivencia se pruebe por alguno de estos medios, pudiendo recurrir a los demás medios probatorios (la confesión no basta por si sola). Será el juez en cada caso el que deberá resolver si la prueba rendida es suficiente.

Es necesario recordar que para obtener el divorcio (salvo el caso contemplado en el artículo 54) se debe acreditar el **cese de la convivencia entre los cónyuges** (por uno o tres años, según los casos), y este cese sólo se puede probar por alguno de los medios indicados en los arts. 22 y 25.

Unidad 5: Efectos del Matrimonio.

El matrimonio es una institución de la cual derivan importantes efectos como:

- Relaciones personales de los cónyuges (derechos y obligaciones de que tratan los artículos 131, 133 y 134);
- Régimen matrimonial;
- Filiación matrimonial; y
- Derechos hereditarios.

A continuación revisaremos cada uno de estos temas.

Tema 1: Relaciones personales de los cónyuges.

El Código Civil en el Título VI del Libro I, artículos 131 y siguientes, **regula las relaciones personales de los cónyuges**, otorgándoles derechos e imponiéndoles deberes de contenido eminentemente moral.

Son los siguientes:

- a) Deber de fidelidad (artículo 131)
- b) Deber de socorro (artículos 131 y 134)
- c) Deber de ayuda mutua o de asistencia (art. 131)
- d) Deber de respeto recíproco (art. 131)
- e) Deber de protección recíproca (art. 131)
- g) Derecho y deber de vivir en el hogar común (art. 133)
- h) Deber de cohabitación;
- i) Deber de auxilio y expensas para la litis.

Respecto a la sanción por el incumplimiento de estos deberes hay que tener presente el artículo 155 inc. 2º: "(EL juez) también la decretará (la separación de bienes) si el marido, por su culpa, no cumple con las obligaciones que le imponen los artículos 133 y 134..."; y los arts. 26 y 54 de la Ley de Matrimonio Civil que autorizan solicitar la separación judicial o el divorcio "si mediare falta imputable al otro cónyuge, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común".

a) Deber de fidelidad (artículo 131)

Del matrimonio deriva una obligación que pudiéramos llamar principal: el deber de guardarse fidelidad el uno al otro. Está consagrada en el artículo 131: "Los cónyuges están obligados a guardarse fe...", lo que significa no tener relaciones sexuales con terceros, no cometer adulterio.

El artículo 132, (texto dado por la Ley 19.335) expresa que "el adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé" y agrega que "cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el varón casado que yace con mujer que no sea su cónyuge". El adulterio trae aparejadas las

siguientes sanciones:

- Es causal de separación judicial (artículo 26) y de divorcio (artículo 54 Nº 2 de la Ley de Matrimonio Civil). En el caso de la separación judicial no puede invocarse el adulterio cuando exista previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges (art. 26, inc. 2º).
- La mujer casada en régimen de sociedad conyugal, puede pedir la separación judicial de bienes, en conformidad al artículo 155 inciso 2º del Código Civil.

b) Deber de socorro (artículos 131 y 134)

Está establecido en los artículos 131 y 321 Nº 1 del Código Civil. El primero señala que los cónyuges están obligados "a socorrerse" y el segundo precisa que se deben alimentos entre sí.

Respecto de este deber, los cónyuges pueden hallarse en diversas situaciones:

- Pueden encontrarse casados en régimen de sociedad conyugal y en estado de normalidad matrimonial, esto es, viviendo juntos. En este supuesto, el marido debe proporcionar alimentos a la mujer, lo que hará con cargo a la sociedad conyugal ya que el artículo 1740 Nº 5 señala que la sociedad es obligada al mantenimiento de los cónyuges;
- Pueden estar separados de bienes o casados en régimen de participación en los gananciales. En estos supuestos, los artículos 134 y 160, regulan la forma como ellos deben atender a las necesidades de la familia común. La primera de estas normas señala que "El marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos medie". El artículo 160 reitera lo anterior, precisando que "en el estado de separación, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común en proporción a sus facultades";
- Pueden estar separados judicialmente. En este caso opera el artículo 175: "El cónyuge que haya dado lugar a la separación judicial por su culpa, tendrá derecho para que el otro cónyuge lo provea de lo que necesite para su modesta sustentación; pero en este caso, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad a él";
- Pueden haber anulado su matrimonio. En este caso cesa la obligación de prestarse alimentos, aunque el matrimonio hubiere sido putativo;
- Pueden encontrarse divorciados, caso en que cesa la obligación alimenticia.

c) Deber de ayuda mutua o de asistencia (art. 131)

Consiste en los cuidados personales y constantes, que los cónyuges se deben recíprocamente.

Este deber está consagrado en el artículo 131 del Código Civil. Por lo demás, se desprende de la propia definición de matrimonio.

d) Deber de respeto recíproco (art. 131)

Los cónyuges tienen la obligación recíproca de guardarse respeto (art. 131).

e) Deber de protección recíproca (art. 131)

El artículo 131 prescribe que "el marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos".

f) Derecho y deber a vivir en el hogar común (art. 133)

Esta situación está tratada en el artículo 133. Dice esta disposición: "Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que a alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo".

En el caso de que sea la mujer la que se resista a vivir en el hogar común, se ha dicho que cesaría la obligación del marido de darle alimentos. Esta solución importa la aplicación en esta materia del principio de que la mora purga la mora (artículo 1552). Ramos dice que es evidente que esta sanción propia del derecho patrimonial, no se ajusta al incumplimiento de obligaciones derivadas del derecho de familia. Sin embargo, existen viejas sentencias que aceptaron esta solución. También hay fallos en contra.

El incumplimiento de este deber puede constituir una causal de divorcio. En efecto el artículo 54 Nº 2º establece como causal de divorcio "el abandono continuo o reiterado del hogar común".

g) Deber de cohabitación.

Es distinto al anterior, pues mira a la obligación que tienen los cónyuges de tener relaciones sexuales entre sí.

h) Deber de auxilio y expensas para la litis.

Esta materia está tratada en el artículo 136 del Código Civil: "Los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. El marido debe, además, si está casado en sociedad conyugal, proveer a la mujer de las expensas para la litis que ésta siga en su contra, si no tiene los bienes a que se refieren los artículos 150, 166 y 167, o ellos fueren insuficientes".

Como se puede observar, esta norma regula dos situaciones diferentes: en la primera parte, la obligación de ambos cónyuges de proporcionarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales; y en la segunda, la obligación del marido casado en régimen de sociedad conyugal, de otorgar expensas para la litis a su mujer.

La segunda obligación sólo existe si se cumplen los siguientes requisitos:

- Pleitos seguidos entre marido y mujer, sin que importe la naturaleza de la acción deducida, ni la condición procesal de cada uno. Sin embargo, esto último puede discutirse por la redacción de la norma que sólo confiere a la mujer expensas para **la litis que ésta** (la mujer) **siga en su contra** (en contra del marido). Pese a los términos de la disposición, Ramos piensa que la situación procesal de demandante o demandada, carece de relevancia, pues constituiría una injusticia inadmisibles que el marido pudiera demandar a su mujer y que ésta por carecer de recursos no pudiese defenderse;
- Sólo cabe si los cónyuges están casados en régimen de sociedad conyugal; y
- Es indispensable que la mujer carezca de bienes suficientes, para atender por sí misma este

gasto. Por ello si tiene patrimonio reservado, o los bienes a que se refieren los artículos 166 ó 167, no puede demandar expensas, a menos que sean insuficientes, caso en que podrá pedir lo necesario.

Tema 2: Potestad marital.

Con anterioridad a la Ley 18.802, el Código Civil establecía la denominada potestad marital, que el artículo 132 definía como **"el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer"**. **La Ley 18.802 derogó esta norma, con lo que desapareció esta institución.**

De la potestad marital derivaban importantes consecuencias:

- a) Incapacidad relativa de la mujer casada (arts. 136, 137, 138, 144, 146, 147, 148, etc.);
- b) Representación legal de la mujer por su marido (art. 43);
- c) Deber de obediencia de la mujer (art. 131 inc. 2º);
- d) Obligación de la mujer de seguir a su marido a donde quiere éste trasladare su residencia (art. 133 inc. 1º);
- e) La mujer tenía como domicilio legal el de su marido (art. 71);
- f) Derecho del marido para oponerse a que la mujer ejerciera un determinado trabajo o industria (Art. 150).

Todos estos efectos desaparecieron con la supresión de la potestad marital.

Tema 3: Plena capacidad de la mujer casada.

Hasta la entrada en vigencia de la Ley 18.802, la mujer casada en régimen de sociedad conyugal era relativamente incapaz. Como tal estaba contemplada en el artículo 1447 al lado de los menores adultos y de los disipadores en interdicción de administrar lo suyo. Esa ley cambió el texto del inciso 3º del artículo 1447 dejando como relativamente incapaces únicamente a los menores adultos y a los disipadores en interdicción.

Sin embargo, es importante no confundir la capacidad que pasó a tener la mujer, con el derecho a administrar sus propios bienes y los bienes sociales. En efecto, el artículo 1749 del Código Civil mantiene el principio de que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y, los de su mujer idea que refuerza el artículo 1750: "El marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales..." y el artículo 1754 inciso final en cuanto establece: "La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis".

Luego, la capacidad que con la reforma de la Ley 18.802 adquirió la mujer no le sirve de mucho desde que no se le da ninguna participación ni en la administración de los bienes sociales ni en la administración de sus bienes propios. Sólo continúa con la administración de aquellos bienes que ya antes administraba (150, 166, 167).

Unidad 6: Regímenes Matrimoniales.

Tema 1: Generalidades.

1.1 Definición

Se define el régimen matrimonial como el estatuto jurídico que regla las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí y respecto de terceros.



1.2 Enumeración de los regímenes matrimoniales

La generalidad de los autores nacionales distingue entre los siguientes tipos de regímenes:

a) Régimen de comunidad de bienes.

Se define como aquel en que todos los bienes que los cónyuges aportan al matrimonio (esto es los que tienen al momento de casarse) como los que adquieren durante el matrimonio, pasan a constituir una masa o fondo común que pertenece a ambos cónyuges y que se divide entre ellos una vez disuelta la comunidad.

Hay diversos grados de comunidad, clasificándose este régimen en *comunidad universal* y *comunidad restringida*. Y esta última puede ser comunidad restringida de bienes muebles y ganancias o restringida de ganancias únicamente.

En la *comunidad universal* todos los bienes que tengan los cónyuges al momento de casarse y los que durante el matrimonio adquieran, sin distinción alguna, forman un fondo común que se repartirá entre ellos, por mitad, al momento de disolverse la comunidad. De manera que durante el matrimonio existe un solo patrimonio que es el patrimonio común.

En la *comunidad restringida*, sólo algunos bienes pasan a ser comunes. Si la *comunidad es restringida de bienes muebles y ganancias* integran el patrimonio común los bienes muebles que los cónyuges aportan y los que adquieren, a cualquier título, durante el matrimonio. Además, forman parte del haber común los inmuebles adquiridos durante el matrimonio a título oneroso y las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. De manera, que sólo quedan excluidos de la comunidad los bienes raíces que aportan y los que adquieran durante el matrimonio a título gratuito.

En la *comunidad restringida de ganancias únicamente*, sólo ingresan al haber común los bienes muebles o inmuebles que los cónyuges adquieran durante el matrimonio a título oneroso y los frutos producidos tanto por esos bienes como por sus bienes propios. Todos los demás forman parte del haber propio de cada cónyuge.

En Chile existe un régimen de comunidad restringida de ganancias únicamente, porque si bien es cierto que los bienes muebles que aportan o adquieran durante el matrimonio a título gratuito ingresan al haber social, no lo es menos que confieren al cónyuge aportante o adquirente un derecho de recompensa o crédito que se hará efectivo al liquidarse la sociedad conyugal. Este régimen de comunidad restringida existente en Chile se denomina "Sociedad conyugal" y es entre nosotros el régimen legal patrimonial, esto es, el que la ley contempla cuando las partes nada dicen. Así se desprende del artículo 135 inciso 1º: "Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de

bienes entre los cónyuges...”.

b) Régimen de separación de bienes.

Es exactamente el régimen contrario al anterior. Hay claramente dos patrimonios: el del marido y el de la mujer, que cada uno de ellos administra con la más amplia libertad.

En Chile existe el régimen de separación de bienes, como alternativa al de la sociedad conyugal o al de participación en los gananciales.

c) Régimen sin comunidad.

Según Somarriva, es un régimen intermedio entre los dos que ya hemos analizado. En efecto, tal como ocurre en el de separación, cada cónyuge conserva sus propios bienes, pero -y en esto se asemeja al régimen de comunidad- todos los bienes son administrados por el marido, salvo algunos que la ley llama *reservados*, cuya administración corresponde a la mujer. Entre ellos están los adquiridos por la mujer con su trabajo; los que los cónyuges aportan en las Capitulaciones Matrimoniales con ese carácter; y los que deja un tercero a la mujer con la condición de que no los administre el marido.

d) Régimen dotal

Se caracteriza por la existencia de dos clases de bienes: *los dotaless*, que la mujer aporta al matrimonio y entrega al marido para que éste haga frente a las necesidades familiares; y *los parafernales* que la mujer conserva en su poder, administrándolos y gozándolos. Tiene su origen en Roma.

e) Régimen de participación en los gananciales

En doctrina, el régimen de participación en los gananciales, admite dos modalidades: a) sistema de comunidad diferida; o b) sistema crediticio o de participación con compensación de beneficios.

En el primero, vigente el régimen, cada cónyuge tiene su propio patrimonio, que administra con libertad. A su extinción, se forma entre los cónyuges o, entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido, una comunidad respecto de los bienes que cada uno adquirió durante el matrimonio a título oneroso, que se divide entre ellos por partes iguales. Se denomina de comunidad diferida, pues la comunidad se posterga hasta la extinción del régimen. Claudia Schmidt señala que "en la participación con comunidad diferida, como su nombre lo da a entender, nace una comunidad efímera, limitada en el tiempo, para el solo efecto de ser liquidada y dividida entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto".

En la segunda variante, vigente el régimen cada cónyuge tiene su propio patrimonio que administra con libertad, pero producida su extinción, el cónyuge que ha adquirido bienes a título oneroso por menos valor, tiene un crédito de participación en contra del otro cónyuge, con el objeto de que, en definitiva, ambos logren lo mismo a título de gananciales. No se produce comunidad en ningún momento.

En Chile, la Ley N° 19.335 de 1994 introdujo el régimen de participación en los gananciales en esta segunda variante como alternativa a la sociedad conyugal y a la separación de bienes.

1.3 Régimen matrimonial chileno

En el Código Civil original no existió otro régimen matrimonial que el que consagraba y consagra el artículo 135: "*por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título De la sociedad conyugal*" (inc. 1°).

Sin embargo, con la dictación del D.L. 328 de 28 de abril de 1925 -que posteriormente fue reemplazado por la Ley Nº 5.521 del año 1934- la situación cambió pues se permitió pactar separación de bienes en las Capitulaciones Matrimoniales. Desde ese momento, el régimen de sociedad conyugal quedó únicamente como régimen legal matrimonial es decir, pasó a ser el régimen matrimonial que regía para los cónyuges que no pactaban separación de bienes. Por una modificación posterior establecida por la Ley 7.612 de 21 de octubre de 1943 se permitió sustituir el régimen de sociedad conyugal bajo el cual se habían casado, por el régimen de separación total de bienes.

El último hito en esta materia lo constituye la Ley Nº 19.335 de 1994, que incorporó a nuestra realidad positiva, el régimen de participación en los gananciales, en la variante crediticia.

Tema 2: Capitulaciones Matrimoniales.

Las capitulaciones matrimoniales están definidas en el artículo 1715 inciso 1º: *“Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer el matrimonio o en el acto de su celebración”*. De manera que caracteriza a la capitulación matrimonial el que sea un pacto celebrado antes o en el momento del matrimonio. Por esa razón no constituyen capitulación matrimonial los pactos que en conformidad al artículo 1723 del Código Civil puedan acordar los cónyuges, pues se celebran *durante la vigencia* del matrimonio.

Puede observarse también que el Código la define como una “convención”. No dice que sea un contrato. El Código emplea bien el lenguaje porque las capitulaciones matrimoniales no serán contrato si no crean derechos y obligaciones para las partes. De modo que una capitulación matrimonial puede ser contrato si realmente crea derechos y obligaciones para los esposos; no lo será en caso contrario. Así, por ejemplo, si sólo tiene por objeto estipular el régimen de separación de bienes, no es contrato sino una simple convención. En cambio, será contrato si el esposo, en conformidad al art. 1720 inc. 2º, se obliga a dar a la esposa una determinada pensión periódica. En nuestro país se usa la denominación capitulaciones matrimoniales; en otras partes estos acuerdos de orden patrimonial que convienen los esposos se llaman contratos matrimoniales.

2.1 Características de las capitulaciones matrimoniales.

- Son una convención, esto es, un acto jurídico bilateral;
- Obligan no sólo a los esposos, sino también a los terceros que contraten con ellos;
- Constituyen un acto jurídico dependiente; esto significa que es de la esencia de esta institución el que no van a llegar a existir si no existe el matrimonio. Aparentemente podría pensarse que constituyen un acto jurídico condicional suspensivo (así lo piensa Pablo Rodríguez), esto es, sujeto en su existencia al hecho futuro e incierto de existir el matrimonio. Pero la condición es un elemento accidental, en cambio la existencia del matrimonio es de la esencia de la capitulación matrimonial;
- Por regla general son inmutables. Las únicas excepciones la constituyen los pactos del inc. 1º del art. 1723 (art. 1716 inc. final) y del art. 1792-1 inc. 2º, parte final.

2.2 Consentimiento y capacidad para celebrar capitulaciones matrimoniales.

Los esposos pueden prestar su consentimiento personalmente o a través de mandatarios. Lo que la ley no permite es que se preste el consentimiento a través de un representante legal. Ello porque si alguno de los esposos es absolutamente incapaz, simplemente no puede casarse, y si es relativamente incapaz -menor adulto o disipador en interdicción de administrar sus bienes-, las capitulaciones las celebra el propio incapaz, con aprobación de la persona o personas que lo deben autorizar para que contraiga matrimonio. De manera que la capacidad para celebrar capitulaciones matrimoniales es la misma que se exige para casarse. Pero si se es menor de edad requiere contar con la autorización de las mismas personas que lo deben autorizar para contraer matrimonio. Así lo establece el artículo 1721: *“El menor hábil para contraer matrimonio podrá hacer en las capitulaciones matrimoniales, con aprobación de la persona o personas cuyo consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio, todas las estipulaciones de que sería capaz si fuese mayor”*. Pero esta misma norma agrega que si el contrayente es menor de edad, requiere de autorización judicial para celebrar las capitulaciones que tengan por objeto: 1) renunciar los gananciales, 2) enajenar bienes raíces, o 3) gravarlos con hipotecas, censos o servidumbres.

El inciso 2° del artículo 1721 establece que: *“El que se halla bajo curaduría por otra causa que la de menor de edad, necesita de la autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales, y en lo demás estará sujeto a las mismas reglas que el menor”*. Esta norma tiene aplicación únicamente en el caso del interdicto por disipación, pues tratándose del demente, del sordomudo, que no pueda darse a entender por escrito o del impúber, ninguno de ellos puede contraer matrimonio.

2.3 Solemnidades de las capitulaciones matrimoniales.

Las capitulaciones matrimoniales son un acto jurídico solemne. La solemnidad es diferente según se celebren antes del matrimonio o en el acto del matrimonio.

Si las capitulaciones se celebran antes del matrimonio, la solemnidad es triple:

- a) Escritura pública;
- b) Subinscripción al margen de la respectiva inscripción matrimonial, y
- c) Que esta subinscripción se practique al momento de celebrarse el matrimonio o dentro de los 30 días siguientes (art. 1716, inc. 1°, primera parte). Nótese que la subinscripción es una solemnidad, no un requisito de publicidad frente a terceros, pues el artículo 1716 dice que *“sólo valdrán entre las partes y respecto de terceros”*. Nótese también que los 30 días son un plazo fatal y de días corridos, esto es, no se descuentan los feriados (art. 50 Código Civil). El artículo 1716 se ha puesto en el caso de los matrimonios celebrados en el extranjero y que no se hallen inscritos en Chile, y nos dice que *“será menester proceder previamente a su inscripción en el registro de la primera sección de la comuna de Santiago, para lo cual se exhibirá al Oficial Civil que corresponda el certificado de matrimonio debidamente legalizado. En estos casos el plazo a que se refiere el inciso anterior -los 30 días- se contará desde la fecha de la inscripción del matrimonio en Chile”*.

Respecto de las capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto del matrimonio, como en ellas sólo se puede pactar separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales (art. 1715, inc. 2°), no requieren de las mismas solemnidades, bastando que el pacto conste en la inscripción del matrimonio. Así lo señala el artículo 1716 inciso 1°, parte final, norma que agrega que *“sin este requisito no tendrán valor alguno”*.

2.4 Modificaciones de las capitulaciones matrimoniales. Inmutabilidad.

Las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio pueden modificarse, debiendo hacerse estas modificaciones con las mismas solemnidades de las originales (art. 1722). Pero estas modificaciones sólo son posibles antes de celebrarse el matrimonio, pues, verificado éste, *“las capitulaciones no podrán alterarse, aun con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en ellas, sino en el caso establecido en el inciso 1º del artículo 1723”* (art. 1716, inc. final). Esta regla se encuentra complementada por lo dispuesto en el art. 1792-1, inc. 2º.

Aplicando ambas normas se tiene que los cónyuges pueden introducir las siguientes modificaciones al régimen matrimonial bajo el cual se casaron:

- a) Si lo hicieron en sociedad conyugal pueden sustituirlo por el de separación total de bienes (art. 1723, inc. 1º);
- b) Si lo hicieron en sociedad conyugal pueden sustituirlo por el de participación en los gananciales (art. 1723 inc. 1º y art. 1792-1 inc. 2º);
- c) Si se casaron en régimen de separación de bienes, pueden reemplazarlo por el de participación en los gananciales (art. 1723 inc. 1º parte final y art. 1792-1 inc. 2º);
- d) Si se casaron en régimen de participación en los gananciales, pueden pasar al de separación total de bienes (art. 1792-1 inc. 2º parte final).

Como se puede apreciar, si los cónyuges se casaron en régimen de participación en los gananciales o separación de bienes, no pueden sustituirlo por el de sociedad conyugal. Si lo hicieron en régimen de sociedad conyugal y después lo sustituyeron por el de participación en los gananciales o separación de bienes, tampoco les es permitido volver a la sociedad conyugal.

Situaciones distintas no resueltas en la ley, son las siguientes:

- Si quienes se casaron en régimen de sociedad conyugal y posteriormente, usando el art. 1723, lo sustituyeron por el de separación de bienes, podrían nuevamente y en virtud del art. 1723 celebrar un nuevo pacto en que reemplazaran la separación de bienes por el de participación en los gananciales, y
- Si habiéndose casado en sociedad conyugal, y habiéndolo sustituido por el de participación en los gananciales, podrían celebrar un nuevo pacto en virtud del cual reemplazaran la participación en los gananciales por la separación de bienes.

2.5 Objeto de las capitulaciones matrimoniales

a) Estipulaciones permitidas.

El objeto de las capitulaciones matrimoniales es distinto según si se celebraron antes del matrimonio o en el acto del matrimonio.

Las capitulaciones que se celebran en el acto del matrimonio sólo pueden tener por objeto pactar la separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales, nada más (art. 1715, inc. 2º).

En cambio, en las que se celebran antes del matrimonio el objeto puede ser muy variado; así, por ejemplo, se podrá acordar la separación total o parcial de bienes (art. 1720, inc. 1°); estipular que la mujer dispondrá libremente de una determinada suma de dinero o de una determinada pensión periódica (art. 1720, inc. 2°); hacerse los esposos donaciones por causa de matrimonio (arts. 1406 y 1786 y sgtes.); eximir de la sociedad conyugal cualquier parte de los bienes muebles (art. 1725 N° 4, inc. 2°); la mujer podrá renunciar a los gananciales (arts. 1719 y 1721); destinar valores de uno de los cónyuges a la compra de un bien con el objeto de que ese bien no ingrese a la sociedad conyugal sino que sea propio del cónyuge respectivo (art. 1727 N° 2°), etc.

b) Estipulaciones prohibidas.

El art. 1717 dice que las capitulaciones matrimoniales *“no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes”* ni serán *“en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan a cada cónyuge respecto del otro o de los descendientes comunes”*. Así, a modo de ejemplo, no se podrá convenir en las capitulaciones que la sociedad conyugal será administrada por la mujer; que la mujer no podrá tener un patrimonio reservado; etc. Hay que agregar que el propio Código prohíbe expresamente algunas estipulaciones, por ejemplo, el artículo 153 señala que *“la mujer no podrá renunciar en las capitulaciones matrimoniales la facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes”*, la renuncia a la acciones de separación judicial y de divorcio (arts. 28 y 57 de la Ley de Matrimonio Civil, respectivamente), los pactos sobre sucesión futura (art. 1463); el art. 1721 inciso final establece que *“no se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes o después de contraerse el matrimonio; toda estipulación en contrario es nula”*, no podría prohibirse que se demandara la declaración de un bien como *“bien familiar”* (art. 149).

Tema 3: Sociedad Conyugal.

Se acostumbra a definir la sociedad conyugal como la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio, definición que se obtiene del artículo 135 inciso 1°.

La sociedad conyugal comienza con el matrimonio, y cualquier estipulación en contrario es nula (arts. 135 inc. 1° y 1721 inc. final).

La sociedad conyugal termina en los casos, señalados en el art. 1764.

3.1 Naturaleza jurídica de la sociedad conyugal

Se ha discutido acerca de cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal. Varias explicaciones se han dado. Se le ha querido asimilar al contrato de sociedad, a la comunidad, o a una persona jurídica.

Con respecto al **contrato de sociedad**, hay varias diferencias que demuestran que la sociedad conyugal, no obstante su nombre, no es una sociedad. En efecto, en la sociedad conyugal necesariamente debe existir diferencia de sexo, circunstancia irrelevante en el contrato de sociedad; en la sociedad conyugal, no hay obligación de hacer aportes, en cambio es sabido que es elemento de la esencia del contrato de sociedad la estipulación de aportes; la sociedad conyugal la administra siempre el marido, siendo diferente en el contrato de sociedad, en que la puede administrar cualquiera de los socios o un tercero; en la sociedad conyugal las utilidades producidas -llamadas gananciales- se reparten por mitades, siendo diferente en el contrato de sociedad en que las utilidades se reparten en proporción a los aportes. Finalmente, la sociedad conyugal no se puede

pactar por un plazo determinado lo que sí ocurre en el contrato de sociedad.

También hay buenas razones para estimar que la sociedad conyugal es una institución muy distinta a la **comunidad**. En primer lugar, mientras dura la sociedad conyugal la mujer no tiene ningún derecho sobre los bienes sociales. El artículo 1750 señala que el marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formarían un solo patrimonio. El artículo 1752 es todavía más enfático: "La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del artículo 145" (si bien esta norma no ha sido modificada debemos entender hecha la referencia al artículo 138 y no al 145, pues la Ley 19.335 cambió la numeración) .

Hay además un interesante antecedente de historia fidedigna. Bello en una anotación hecha en el Proyecto de 1853, textualmente decía: "se ha descartado el dominio de la mujer sobre los bienes sociales durante la sociedad; ese dominio es una ficción que a nada conduce".

Otra razón para descartar la idea de comunidad es que la comunidad nace precisamente al momento en que la sociedad conyugal se disuelve. En esta comunidad que nace, lo repetimos, a la disolución de la sociedad conyugal, los comuneros serán los cónyuges o el cónyuge sobreviviente con los herederos del cónyuge fallecido, según sea el caso. Disuelta la sociedad, la comunidad que se forma será liquidada de acuerdo a las reglas que establece el Código Civil, en los artículos 1765 y siguientes.

La jurisprudencia ha hecho aplicación del principio de que vigente la sociedad conyugal los cónyuges no son comuneros, al resolver que si una mujer casada vende un bien social está vendiendo cosa ajena (T. 37, sec. 2ª, p.1). Otro fallo resolvió que "carece de objeto y por lo tanto debe rechazarse la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, sobre derechos que a la mujer le corresponderían en un inmueble de la sociedad conyugal, ya que no puede prohibírsele la celebración de actos o contratos sobre derechos que no tiene, los que sí corresponden al marido, vigente que se halle la señalada sociedad" (T. 82 sec. 1ª, p. 42).

Tampoco puede afirmarse que la sociedad conyugal sea una **persona jurídica**, puesto que frente a los terceros, según ya se ha dicho, sólo existe el marido. No se puede demandar a la sociedad conyugal, sin perjuicio de que sea ésta la que en definitiva soporte la deuda. Se demanda al marido, no en representación de la sociedad conyugal, se le demanda directamente.

En resumen, la sociedad conyugal, no es sociedad, no es comunidad, no es persona jurídica. Se trata de una institución sui generis con características propias. Tal vez a lo que más se parece, como lo dice Jossierand, es a un patrimonio de afectación, esto es a un conjunto de bienes aplicados a un fin determinado (satisfacción de las necesidades económicas de la familia), con un activo y un pasivo propios.

3.2 Haber de la Sociedad Conyugal.

Haber o activo de la sociedad conyugal son los bienes que lo integran. Para hacer este estudio es necesario formular un distinguo entre haber o activo absoluto y haber o activo relativo.

El haber absoluto lo forman todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal en forma definitiva, sin derecho a recompensa; en cambio, **el haber relativo o aparente**, lo integran aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal otorgando al cónyuge aportante o adquirente un derecho de recompensa que éste hará valer al momento de la liquidación. Ejemplo de cada caso: durante el matrimonio uno de los cónyuges compra un automóvil. Ese bien ingresa al activo

absoluto de la sociedad conyugal (art. 1725, Nº 5). En cambio si al momento del matrimonio uno de los cónyuges era dueño de un automóvil, tal bien ingresa a la sociedad conyugal, pasa a ser un bien social, pero el cónyuge que era dueño (le llamaremos cónyuge aportante), adquiere un crédito, recompensa, que hará valer cuando se termine la sociedad conyugal y se liquide. En ese momento tendrá derecho a que se le reembolse el valor del automóvil, actualizado. De manera que el automóvil en este último ejemplo, ingresó al haber relativo de la sociedad conyugal.

Es importante agregar que esta terminología -haber absoluto y haber relativo- no la hace la ley, pero surge del artículo 1725.

3.2.1 Haber o activo absoluto de la sociedad conyugal

Está integrado por los bienes que contemplan los artículos 1725 Nº 1, 1725 Nº 2, 1725 Nº 5, 1730 y 1731.

a) Los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, devengados durante el matrimonio (art. 1725 Nº 1).

Cualquiera remuneración que perciba uno de los cónyuges durante el matrimonio, queda comprendida dentro de este rubro, sin que tenga importancia la denominación que reciba: honorarios, gratificaciones, sueldos, salarios, etc. Lo único importante, es que "se devenguen" durante el matrimonio. Así por ejemplo, si al momento de casarse un abogado, tenía una gestión terminada y le adeudaban los honorarios, que se los pagan cuando ya está casado, ese bien no ingresa al haber absoluto, sino al relativo, porque no se devengó "durante el matrimonio" sino antes.

Este caso crea algunas dificultades cuando se trata de servicios que se comienzan a prestar de solteros y se terminan cuando los cónyuges ya se encuentran casados. La doctrina soluciona el problema, distinguiendo si el trabajo que motivó los honorarios es divisible o indivisible. Si es divisible, corresponderá a la sociedad conyugal la parte del honorario devengado durante la vigencia de la sociedad conyugal y al cónyuge aquella otra parte devengada mientras permanecía soltero. El ejemplo que suele ponerse es el caso de los honorarios de abogados que se van devengando según sea el progreso del juicio respectivo.

En cambio si el trabajo es indivisible, por ejemplo, se le encomienda a una persona la confección de una estatua, en ese caso el honorario se entenderá devengado cuando la obra esté terminada, pasando a ser los honorarios propios o sociales según corresponda.

Otro aspecto importante relacionado con el artículo 1725 Nº 1, es el que se refiere a las **donaciones remuneratorias**. Según el artículo 1433, se entiende por donaciones remuneratorias "las que expresamente se hicieren en remuneración de servicios específicos, siempre que éstos sean de los que suelen pagarse" (inc. 1º). El artículo 1738 resuelve sobre el destino de esas donaciones remuneratorias, distinguiendo entre donaciones muebles e inmuebles y distinguiendo también según tales donaciones den o no den acción en contra de la persona servida. Si la donación es inmueble y corresponden a servicios que dan acción en contra de la persona servida, tal donación ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal. En cambio si no dan acción, ingresan al haber propio del cónyuge. Si la donación recae sobre un mueble y corresponde al pago de servicios que dan acción en contra de la persona servida, la donación ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal. Si no dan acción en contra de la persona servida, ingresan al haber relativo.

Si bien ingresan al haber absoluto de la sociedad conyugal todas las remuneraciones de cualquiera de los cónyuges devengadas durante la sociedad conyugal, en el caso en que esas remuneraciones las perciba la mujer, en el ejercicio de un trabajo, profesión o industria separada de su marido, será ella quien administrará tales recursos, atendido lo dispuesto en el artículo 150. Pero esta circunstancia no le quita a esos bienes el carácter de sociales, ya que su destino definitivo a la disolución de la sociedad conyugal, será ingresar a la masa de gananciales, a menos que la mujer los renunciare.

b) Todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio (art. 1725 Nº 2)

De manera que si un inmueble social produce rentas, esas rentas ingresan al activo absoluto de la sociedad conyugal. Lo mismo ocurre si el inmueble que produce las rentas es propio de uno de los cónyuges. A primera vista pudiere parecer injusto que no se haga una distinción. Aparentemente, y de acuerdo al principio de que las cosas producen para su dueño, lo justo sería que las rentas producidas por el bien propio ingresaran al haber del cónyuge dueño del bien que las produce. Este principio se rompe aquí. La explicación está en que los ingresos producidos sea por los bienes propios o sociales están destinados a atender las necesidades de la familia.

Por otra parte, la solución dada por el Código es justa, si se tiene en cuenta que, según el artículo 1740 Nº 4 "la sociedad es obligada al pago: de todas las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada cónyuge". De modo que la situación es equitativa: si la sociedad soporta el pago de las reparaciones de los bienes propios del cónyuge, es razonable que los ingresos que ese bien genera ingresen también a la sociedad conyugal.

El artículo 1725 Nº 2, habla de "frutos" sin formular ninguna distinción. Por ello, ingresarán al haber absoluto de la sociedad conyugal, tanto los frutos civiles como los naturales. Lo único importante es que los frutos "se devenguen durante el matrimonio" (con más exactitud la norma debió haber dicho "se devenguen durante la sociedad conyugal").

Recordemos que los frutos civiles se devengan día a día (art. 790, norma que si bien está ubicada en el usufructo se estima, por la doctrina que es de aplicación general); en cambio los frutos naturales para saber a quién corresponden habrá que ver si están pendientes o percibidos. Así viene a resultar que si al momento de casarse una persona es dueña de un bien raíz y se casó, por ejemplo el día 15 de septiembre, las rentas de arrendamiento provenientes de la primera quincena no ingresan al activo absoluto (sino al relativo). En cambio, si la persona al casarse tiene un predio plantado con manzanas, y al momento del matrimonio esas manzanas están todavía en el árbol, el producto de esas manzanas ingresa al haber absoluto. En cambio si, ya las tenía cosechadas, ingresarán al haber relativo (artículos 645, 781, 1772).

Cabe preguntarse, por qué modo adquiere la sociedad conyugal estos frutos. La respuesta va a depender según se trate de los frutos producidos por los bienes propios del cónyuge o por un bien social. En el caso del fruto producido por un bien social, la sociedad conyugal, lo adquirirá por el modo de adquirir accesión, de acuerdo a lo que previenen los artículos 646 y 648. En cambio, si el fruto proviene de un bien propio de uno de los cónyuges, la situación varía, pues en ese caso no puede hablarse de accesión (en cuya virtud **el dueño** de un bien se hace dueño de lo que la cosa produce), debiendo concluirse que el modo de adquirir es la ley -artículo 1725 Nº 2- que otorga a la sociedad conyugal el dominio de los frutos de los bienes propios del cónyuge.

- **Usufructo del marido sobre los bienes de la mujer**

Lo que estamos viendo lleva a estudiar el derecho de usufructo del marido sobre los bienes de su mujer y a determinar cuál es su verdadera naturaleza jurídica.

El Código hace referencia al derecho de usufructo que el marido tiene sobre los bienes de su mujer, en los artículos 810 y 2466 inciso final. También la Ley de Quiebras, en el artículo 64 inciso 4º.



Pregunta

Pues bien **¿es cierto que el marido tiene el usufructo sobre los bienes de su mujer?** La respuesta dada por la doctrina es negativa (Somarriva; Gonzalo Barriga Errázuriz; Arturo Alessandri). Se afirma que no hay derecho de usufructo, pese a que el Código lo llama de esa manera. Ello por las razones siguientes:

a) Si el marido tuviere un derecho de usufructo cuando enajenare los bienes de la mujer, estaría enajenando únicamente la nuda propiedad y eso no es así;

b) Hay un argumento de historia fidedigna. En los proyectos del Código Civil sólo se hablaba del usufructo que tenía el padre sobre los bienes del hijo de familia; no se hacía referencia a este otro usufructo que sólo vino a ser establecido en el Proyecto Definitivo, sin duda por inadvertencia del codificador.

- **Inembargabilidad del usufructo del marido**

El artículo 2466 -ubicado en el título De la prelación de créditos- señala en su inciso 3º: "Sin embargo, no será embargable el usufructo del marido sobre los bienes de la mujer....". Se ve una suerte de contradicción entre esta norma y el artículo 1725 Nº 2, pues la primera dice que es inembargable el usufructo del marido sobre los bienes de la mujer en tanto que la última señala que tales frutos ingresan al haber absoluto de la sociedad conyugal y eso implica que ellos pueden ser embargados para hacer efectivas las obligaciones sociales. Se han dado varias soluciones para resolver la contradicción:

Leopoldo Urrutia, es de opinión que la inembargabilidad de que habla el artículo 2466 es excepcional, se produciría, por ejemplo, en el caso de que la mujer en las capitulaciones matrimoniales hubiere renunciado a los gananciales. En tal caso los frutos pertenecerían al marido para hacer frente a las cargas del matrimonio (art. 1753). No es satisfactoria esta opinión, pues no hay ninguna razón para afirmar que el artículo 2466 establezca la inembargabilidad sólo en casos excepcionales

Carlos Aguirre Vargas, da otra explicación. Distingue entre el usufructo en sí mismo -que es inembargable- de los frutos provenientes de los bienes de la mujer, una vez que han ingresado a la sociedad conyugal, que serían embargables de acuerdo a las reglas generales.

José Clemente Fabres tiene una opinión muy parecida a la anterior la que comparte don Manuel Somarriva. Según él el usufructo es inembargable. Pero los terceros pueden embargar los frutos, con la limitación de que no pueden privar al marido de lo que necesite para atender las cargas de familia. Esta opinión recibió apoyo del antiguo artículo 1363 del Código de Comercio, sustituido después, por el artículo 61 de la Ley de Quiebras y posteriormente por el artículo 64 inciso 4º de la actual Ley de Quiebras, norma que establece lo siguiente: "La administración que conserva el fallido de los bienes personales de la mujer e hijos, de los que tenga el usufructo legal, quedará sujeta a la intervención del síndico mientras subsista el derecho del marido, padre o madre en falencia. El síndico cuidará de

que los frutos líquidos que produzcan estos bienes ingresen a la masa, deducidas las cargas legales o convencionales que los graven. El tribunal, con audiencia del síndico y del fallido, determinará la cuota de los frutos que correspondan al fallido para sus necesidades y las de su familia, habida consideración a su rango social y a la cuantía de los bienes bajo intervención".

c) Los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso (art. 1725 Nº 5).

De acuerdo a esta disposición, cualquier bien que se adquiera durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso (compra, permuta, etc.) ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal. No tiene ninguna importancia el que el bien se compre a nombre de la mujer o del marido, pues en ambos casos, el bien ingresa al activo absoluto de la sociedad conyugal. Lo único que interesa es que el título traslativo en cuya virtud se adquiere el bien, se haya celebrado vigente la sociedad conyugal y, además, que el título traslativo sea oneroso (arts. 1736, 1725 Nº 5).

Si el bien lo adquiere la mujer dentro de su patrimonio reservado, ese bien forma parte de dicho patrimonio y está sujeto en su administración a las normas contempladas en el artículo 150.

- **Casos de los artículos 1728 y 1729**

El Código Civil, en los artículos 1728 y 1729, hace una aplicación especial, para los casos que indica, del principio sentado en el artículo 1725 Nº 5.

Artículo 1728: "El terreno contiguo a una finca propia de uno de los cónyuges, y adquirido por él durante el matrimonio a cualquier título que lo haga comunicable según el artículo 1725, se entenderá pertenecer a la sociedad; a menos que con él y la antigua finca se haya formado una heredad o edificio de que el terreno últimamente adquirido no pueda desmembrarse sin daño; pues entonces la sociedad y el dicho cónyuge serán codueños del todo, a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorporación"

Esta disposición establece en su primera parte, que cuando se adquiere durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso (ese es el alcance de la expresión "que lo haga comunicable"), un inmueble contiguo al inmueble propio de uno de los cónyuges, el bien que se adquiere ingresa al haber de la sociedad conyugal. Hasta aquí la norma es la confirmación del artículo 1725 Nº 5. Pero agrega en seguida la situación excepcional: "a menos que con él -el terreno que se adquiere- y la antigua finca se haya formado una heredad o edificio de que el terreno últimamente adquirido no pueda desmembrarse sin daño, pues entonces la sociedad y el dicho cónyuge serán dueños del todo, a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorporación".

Lo que ocurre es que el predio antiguo y el nuevo se han confundido de tal modo que han llegado a perder su individualidad. En este caso, la norma estima conveniente, por una razón de tipo económico, considerarlos como un todo, que pasa a ser común de ambos cónyuges a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorporación.

Como el artículo 1728 se refiere al caso en que la nueva adquisición es a título oneroso, la situación excepcional que establece la norma no se da si el nuevo bien se adquiere a título gratuito, situación ésta que se regirá por las reglas generales.

Artículo 1729: "La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otras personas proindiviso, y de que durante el matrimonio se hiciere dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá proindiviso a dicho cónyuge y a la sociedad, a prorrata del valor de la cuota que

pertenecía al primero, y de lo que haya costado la adquisición del resto".

Se trata en este caso, de que el cónyuge es comunero con otras personas en un bien propio, y de que, vigente la sociedad conyugal, adquiere, a título oneroso, las cuotas que le faltan. En este caso, se mantiene la indivisión, ahora entre el cónyuge dueño de la cuota primitiva y la sociedad conyugal, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al primero, y de lo que haya costado la adquisición del resto. En el caso en que las nuevas cuotas se hayan adquirido a título gratuito, se extingue la comunidad, y el cónyuge pasa a ser dueño del total (art. 1729 a contrario sensu en relación con el art. 2312 N° 1).

Para que tenga lugar lo previsto en el artículo 1729, deben concurrir los siguientes requisitos:

- a) Que exista una indivisión entre uno de los cónyuges y otra persona;
- b) Que la cuota del cónyuge constituya un bien propio; y
- c) Que las demás cuotas se adquieran a título oneroso.

d) Las minas denunciadas por uno o por ambos cónyuges, durante la vigencia de la sociedad conyugal (art. 1730).

Esta norma es concordante con lo que establece el Código de Minería en su artículo 25. Según esta disposición los derechos adquiridos en virtud de un pedimento o de una manifestación mineros por las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal ingresarán al haber social, a menos que sea aplicable el artículo 150 del Código Civil.

e) La parte del tesoro que corresponde al dueño del sitio en que se encuentra, cuando el tesoro es hallado en un terreno social (art. 1731).

3.2.2 Haber relativo de la sociedad conyugal.

El haber relativo está formado por aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal pero que otorgan un crédito o recompensa al cónyuge aportante o adquirente, que se hace efectivo a la disolución de la sociedad.

Está integrado por los bienes que contemplan los artículos 1725 N° 3, 1725 N° 4, 1731, 1738 inc. 2º y 1736 inciso final.

a) Dinero aportado o adquirido por uno de los cónyuges a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Así lo dice el artículo 1725 N° 3. Cuando se habla de **dineros aportados** al matrimonio se quiere significar los dineros que el cónyuge tenía al momento de casarse.

El numerando 3º del artículo 1725, demuestra que estos dineros ingresan al haber relativo al establecer que la sociedad se obliga a pagar la correspondiente recompensa.

Es importante consignar que con anterioridad a la reforma de la Ley 18.802, la norma tenía una redacción diferente. Establecía que la sociedad se obligaba a la restitución de **igual suma**. El cambio es significativo, porque hasta la vigencia de la Ley 18.802, se entendía que el monto de la recompensa era la **misma suma** que el cónyuge aportó o adquirió a título gratuito, esto es, la recompensa no se pagaba reajustada sino por su valor nominal lo que, por cierto, quitaba a la

institución toda importancia. Con la reforma, queda claro que se debe pagar **la correspondiente recompensa**, y de acuerdo al artículo 1734, también con el texto dado por la Ley 18.802, tal recompensa debe enterarse de manera que la suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo. Claramente del nominalismo se pasa al valorismo.

Si se observa la redacción del artículo 1725 Nº 3, se verá que no está dicho que para que los dineros ingresen al haber relativo, tienen que haber sido adquiridos **a título gratuito**. Sin embargo, es así, pues si se adquieren a título oneroso, tales dineros ingresan al haber absoluto, sea porque correspondan al pago de remuneraciones (art. 1725 Nº 1), sea porque correspondan a réditos, pensiones intereses o lucros generados por bienes sociales o propios de un cónyuge (art. 1725 Nº 2).

b) Bienes muebles aportados o adquiridos a título gratuito por cualquier cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal

Respecto de los bienes muebles aportados, al igual que en el número anterior, se entiende por bien aportado, el que tenía el cónyuge al momento del matrimonio. En cuanto a los bienes muebles adquiridos durante el matrimonio, no dice el artículo 1725, que para que ingresen al haber relativo los bienes muebles tienen que haberse adquirido a título gratuito, pero ello está establecido hoy día -después de la modificación de la Ley 18.802- en el inciso 2º del artículo 1726 y en el inciso 2º del artículo 1732. Dice la primera de estas normas: "Si el bien adquirido (a título de donación, herencia o legado) es mueble, aumentará el haber de la sociedad, la que deberá al cónyuge o cónyuges adquirentes la correspondiente recompensa". Y el artículo 1732 inc. 2º, confirma la misma idea: "Si las cosas donadas o asignadas a cualquier otro título gratuito fueren muebles, se entenderán pertenecer a la sociedad, la que deberá al cónyuge donatario o asignatario la correspondiente recompensa".

Debe tenerse en cuenta que el artículo 1725 Nº 4, habla de "especies muebles" y no de "bienes muebles". Lo anterior es importante porque queda perfectamente claro que la cosa mueble puede ser corporal o incorporeal. Si se hubiera hablado de "bienes muebles" sólo habrían quedado comprendidos, de acuerdo con el artículo 574, los bienes muebles a que se refiere el artículo 567, es decir los bienes muebles corporales por naturaleza.

Al establecer el numerando 4º que la sociedad queda obligada a pagar la correspondiente recompensa, claramente está indicando que esos bienes ingresan al haber relativo.

La Ley 18.802, modificó la redacción del artículo en lo relativo al pago de la recompensa. En efecto, antes se decía: "quedando obligada la sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición". Hoy la norma prescribe: "quedando obligada la sociedad a pagar la correspondiente recompensa". El cambio es trascendente, porque la disposición había sido entendida en el sentido que el valor de la recompensa era la misma suma de dinero que el bien valía al momento del aporte o de la adquisición. Es decir, regía el nominalismo. Con la nueva redacción dada al artículo 1725 Nº 4, queda perfectamente resuelto que la recompensa se entera en valor reajustado, pues se debe pagar la "correspondiente recompensa" y el artículo 1734, dice que las recompensas se pagan en valor actualizado.

El artículo 1725 Nº 4, en su inciso 2º, establece que "podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones matrimoniales". De manera que si el cónyuge, por ejemplo, al momento de casarse tiene un número importante de acciones o es dueño de un vehículo, y no quiere que estos bienes ingresen al haber relativo de la sociedad conyugal, puede hacerlo excluyéndolos en las capitulaciones matrimoniales.

c) Tesoro.

El artículo 1731 establece que "La parte del tesoro, que según la ley pertenece al que lo encuentra, se agregará al haber de la sociedad, la que deberá al cónyuge que lo encuentre la correspondiente recompensa; y la parte del tesoro, que según la ley pertenece al dueño del terreno en que se encuentra, se agregará al haber de la sociedad, la que deberá recompensa al cónyuge que fuere dueño del terreno".

Para la acabada comprensión de esta situación, hay que relacionar esta norma con los artículos 625 y 626 del Código Civil. El primero, en su inciso 2º, define lo que se entiende por tesoro, diciendo "se llama tesoro las monedas o joyas, u otros efectos preciosos que elaborados por el hombre han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueño". A su turno el artículo 626 establece la forma como se reparte el tesoro entre el descubridor y el dueño del terreno en que se encontraba oculto. Señala la norma: "El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento".

"Pero esta última no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito, o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno".

"En los demás casos, o cuando sean una misma persona el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno".

Si se relaciona el artículo 626 con el 1731, se tienen las siguientes conclusiones:

- La parte del tesoro que corresponde al descubridor -50%- ingresa al haber relativo, quedando obligada la sociedad al pago de la correspondiente recompensa a dicho cónyuge descubridor;
- La parte del tesoro que corresponde al dueño del terreno -50%- seguirá la siguiente suerte:
 - Si el tesoro es descubierto en el terreno de uno de los cónyuges, la parte del dueño del terreno ingresará al activo relativo de la sociedad conyugal, la que deberá recompensa al cónyuge dueño del terreno; y
 - Si el tesoro es encontrado en un terreno social, la parte del dueño del terreno ingresará al activo absoluto de la sociedad.

Respecto del artículo 1731, debe decirse que la Ley 18.802 no se pronunció a quien pertenecía la parte del tesoro que corresponde al dueño del terreno cuando éste se encuentra en un bien social. Sin embargo, esta omisión no tiene mayor significación pues resulta obvio que tiene que ingresar al haber absoluto por aplicación del artículo 626.

d) La donación remuneratoria mueble que se hace a uno de los cónyuges, cuando el servicio prestado no daba acción en contra de la persona servida.

Así está establecido en el artículo 1738 inciso 2º. "Si la donación remuneratoria es de cosas muebles aumentará el haber de la sociedad, la que deberá recompensa al cónyuge donatario si los servicios no daban acción contra la persona servida o si los servicios se prestaron antes de la sociedad".

e) Bienes muebles adquiridos por un cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella.

Así resulta de aplicar el artículo 1736, primera parte, en relación con su inciso final.

3.2.3 Haber propio o personal de cada cónyuge.

La sociedad conyugal constituye un régimen de comunidad restringida de bienes, conservando cada cónyuge un cierto patrimonio propio o personal. Forman parte de este patrimonio propio:

a) Bienes inmuebles que un cónyuge tiene al momento del matrimonio

No está dicho en forma expresa en el Código que los bienes raíces de que un cónyuge es dueño al momento de casarse permanezcan en su haber propio. Sin embargo, ello resulta claro por exclusión, ya que no ingresan al activo social.

Puede ocurrir que el bien raíz lo adquiriera el cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal y que no obstante, no ingrese al activo social sino al haber propio del cónyuge. Se refiere a esta situación el artículo 1736, que en su primera parte establece: "La especie adquirida durante la sociedad, no pertenece a ella aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella". En seguida, la norma coloca diversos ejemplos. Para que estos bienes incrementen el haber propio, tienen que ser inmuebles, pues en el caso de los muebles, ingresan al haber relativo, según lo consigna el inciso final: "Si los bienes a que se refieren los números anteriores son muebles, entrarán al haber de la sociedad, la que deberá al cónyuge adquirente la correspondiente recompensa"

• Casos del artículo 1736:

1. "No pertenecerán a la sociedad las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de ella, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique durante ella".

Este numeral contempla dos situaciones diversas:

Una primera que se produce cuando al momento del matrimonio uno de los cónyuges está poseyendo un bien raíz, pero aún no ha transcurrido el plazo para ganarlo por prescripción, lo que sólo viene a acontecer durante la vigencia de la sociedad conyugal. Ese bien, no es social, sino que propio del cónyuge, pues la causa o título de su adquisición ha precedido a la sociedad. Ello es lógico por cuanto, declarada la prescripción por sentencia judicial, los efectos de la prescripción operan retroactivamente al momento en que se comenzó a poseer.

La segunda, dice relación con la adquisición del bien raíz por transacción. La transacción en cuanto se limite a reconocer o declarar derechos preexistentes, no forman nuevo título (art. 703, inc. final). Por ello si el cónyuge adquiere el bien raíz disputado en virtud de una transacción que se celebra vigente la sociedad conyugal, ese bien no es social sino propio del cónyuge, pues la transacción es en ese caso un título declarativo.

2. No pertenecerán a la sociedad conyugal, sino al cónyuge "los bienes que se poseían antes de ella por un título vicioso, pero cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación, o por otro remedio legal".

Este numerando se refiere al caso en que uno de los cónyuges ha adquirido de soltero un bien raíz

por un título vicioso, esto es susceptible de anularse. Pues bien, si durante la sociedad conyugal se sanea el vicio, sea por ratificación o por extinguirse la acción de nulidad por prescripción (que es el otro medio legal de sanear el vicio), este saneamiento opera retroactivamente a la fecha en que se había adquirido el bien raíz por el cónyuge, por lo que resulta lógico que ingrese al haber propio y no al de la sociedad.

3. No pertenecen a la sociedad conyugal "los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por nulidad o resolución de un contrato, o por haberse revocado una donación".

Se trata de que un cónyuge de soltero vendió un bien raíz (o celebró respecto de él cualquier otro título traslativo). Posteriormente, cuando ya está casado, la venta o el título traslativo de que se trate, se anula o se resuelve, volviendo por consiguiente el bien a su dominio en virtud del efecto propio de la nulidad o resolución. En este caso, el bien a pesar de adquirirse durante la sociedad conyugal, no ingresa a ella, sino al cónyuge que había celebrado el contrato que se anuló o resolvió.

Este número se pone también en el caso de que un bien raíz que el cónyuge había donado de soltero, vuelva a su patrimonio por revocarse la donación. Si bien la revocación se realiza cuando ya está casado, el bien no ingresa a la sociedad conyugal, sino a su haber propio, porque, como dice Somarriva, la revocación por ingratitud o en el caso del artículo 1187, al igual que la nulidad o resolución operan retroactivamente, como se desprende de los artículos 1429 y 1432.

4. No ingresan tampoco a la sociedad conyugal "los bienes litigiosos y de que durante la sociedad ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica".

Se trata en este caso de un inmueble que el cónyuge adquirió de soltero, pero ya vigente la sociedad conyugal, es demandado por un tercero que alega derechos sobre ese bien. Dictada la sentencia que resuelve el conflicto en favor del cónyuge, los efectos de esa sentencia se retrotraen a la fecha de la adquisición, pues la sentencia no constituye un nuevo título sino que es un simple título declarativo, según lo señala el artículo 703 inc., penúltimo.

5. Tampoco ingresa a la sociedad conyugal, "el derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge...".

El cónyuge adquiere de soltero, la nuda propiedad sobre un bien raíz. Posteriormente cuando ya está casado, se consolida el dominio, por extinguirse el usufructo.

6. No pertenece a la sociedad conyugal, sino al cónyuge acreedor "lo que se paga (tiene que tratarse de un inmueble) a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos constituidos antes del matrimonio... Lo mismo se aplicará a los intereses devengados por uno de los cónyuges antes del matrimonio y pagados después".

7. "También pertenecerán al cónyuge los bienes que adquiera durante la sociedad en virtud de un acto o contrato cuya celebración se hubiere prometido con anterioridad a ella, siempre que la promesa conste de un instrumento público, o de instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros de acuerdo con el artículo 1703".

En virtud de este número si una persona de soltero celebrare un contrato de promesa de compra de un bien raíz y el contrato definitivo se otorga cuando ya estaba en vigencia la sociedad conyugal el bien raíz ingresa al haber propio del cónyuge.

Sin embargo, para que opere esta situación excepcional es necesario que la promesa conste en un instrumento público o en un instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros de acuerdo con el artículo 1703.

Dos observaciones finales sobre el art. 1736:

En **primer lugar** la norma no es taxativa. Así lo deja de manifiesto el enunciado y la frase "por consiguiente", con que se inicia el inciso 2º. De manera que siempre que se adquiriera durante la sociedad conyugal un bien raíz, no pertenecerá a ella sino al cónyuge cuando la causa o título de la adquisición, cualquiera fuere el motivo, ha precedido a la sociedad.

Segundo, si el bien raíz se adquiere con bienes de la sociedad y del cónyuge, éste deberá la recompensa respectiva. Así lo dice el inciso penúltimo del artículo 1736.

b) Inmueble adquirido a título gratuito por uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Los artículos 1726 y 1732 establecen que los inmuebles adquiridos a título gratuito por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio ingresan a su haber propio. Dice el artículo 1726: "Las adquisiciones de bienes raíces hechas por cualquiera de los cónyuges a título de donación, herencia o legado, se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, heredero o legatario; y las adquisiciones de bienes raíces hechas por ambos cónyuges simultáneamente, a cualquiera de estos títulos, no aumentará el haber social, sino el de cada cónyuge" (inc. 1º). Y el artículo 1732 reitera la regla: "Los inmuebles donados o asignados a cualquiera otro título gratuito, se entenderán pertenecer exclusivamente al cónyuge donatario o asignatario y no se atenderá a si las donaciones u otros actos gratuitos a favor de un cónyuge, han sido hechos por consideración al otro".

Como puede observarse, las dos disposiciones son casi idénticas, por lo que es válida la observación de Somarriva en orden a que los dos artículos pudieron constituir una sola y única norma que contemplara las diversas modalidades de las adquisiciones gratuitas.

c) Bienes muebles que los cónyuges excluyen de la sociedad en las capitulaciones matrimoniales.

Las especies muebles que los cónyuges tienen al momento de casarse ingresan al activo relativo de la sociedad conyugal (art. 1725, Nº 4, inciso 1º). Sin embargo, el inciso 2º de este numerando permite excluir de la sociedad a algunos bienes de este tipo, que por ello permanecen en el patrimonio propio del interesado: "pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquier parte de sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones matrimoniales".

d) Aumentos que experimenten los bienes propios de los cónyuges.

El artículo 1727 señala: "No obstante lo dispuesto en el artículo 1725 no entrarán a componer el haber social: 3º "Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquier especie de uno de los cónyuges formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa". Luego, si no ingresan al haber social, quiere decir que forman parte del haber propio del cónyuge respectivo.

El bien propio de un cónyuge puede experimentar aumentos por causas naturales -aluvión, por ejemplo- o debidos a la mano del hombre (edificación, plantación). Ambas situaciones están comprendidas en el artículo 1727 Nº 3. En el primer caso, nada deberá el cónyuge a la sociedad. Así

lo consigna el artículo 1771 inciso 2º: "Por los aumentos que provengan de causas naturales e independientes de la industria humana, nada se deberá a la sociedad". En cambio, si el aumento proviene de la mano del hombre, se genera una recompensa para la sociedad conyugal. Así lo consigna el artículo 1746: "Se la debe asimismo recompensa por las expensas de toda clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los cónyuges, en cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor de los bienes, y en cuanto subsistiere este valor a la fecha de la disolución de la sociedad; a menos que este valor exceda al de las expensas, pues en tal caso se deberá sólo el importe de éstas".

e) Créditos o recompensas que los cónyuges adquieren contra la sociedad y que pueden hacer valer al momento de su disolución.

Ya hemos visto al tratar del activo relativo, que ciertos bienes de los cónyuges ingresan al activo social, pero esta situación genera en favor del cónyuge aportante o adquirente un crédito o recompensa en contra de la sociedad conyugal que hará valer al momento de que ésta se disuelva. Las recompensas pueden surgir también por otras razones. Estas recompensas o créditos, constituyen un bien que permanecen en el patrimonio personal de cada cónyuge mientras está vigente la sociedad conyugal. Son pues, un bien propio del cónyuge de que se trata.

f) Inmuebles subrogados a un inmueble propio de uno de los cónyuges o a valores.

El artículo 1727 señala que "no obstante lo dispuesto en el artículo 1725 no entrarán a componer el haber social:

1º "El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges";

2º "Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio".

Estos dos numerandos plantean la adquisición de un bien raíz por uno de los cónyuges, a título oneroso, durante la vigencia de la sociedad conyugal y que, no obstante ello, no ingresa al activo de la sociedad conyugal, como debería ocurrir atendido lo dispuesto en el artículo 1725 Nº 5. Ciertamente es que el Nº 2 habla de "cosas compradas", sin distinguir si es mueble o inmueble, pero es claro que si la cosa fuere mueble, entraría al activo relativo de la sociedad conyugal (art. 1725 Nº 4).

Luego esta institución -subrogación- constituye una excepción a la regla contenida en el artículo 1725 Nº 5, de que todos los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, ingresan al activo absoluto de la sociedad conyugal.

Clases de subrogación:

La subrogación puede ser de dos clases:

1. Subrogación de inmueble a inmueble; y
2. Subrogación de inmueble a valores

A su turno la subrogación de inmueble a inmueble puede ser de dos tipos:

- a) Subrogación por permuta y
- b) Subrogación por compra.

Una cosa importante, es que cualquiera que sea la subrogación de que se trate, el bien que se adquiere es siempre inmueble.

- **Subrogación por permuta**

Esta situación la establece el artículo 1733 inciso 1º: "Para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno de los cónyuges, es necesario que el segundo se haya permutado por el primero..."

Requisitos:

1. Que uno de los cónyuges sea dueño de un inmueble propio;
2. Que vigente la sociedad conyugal permute ese bien raíz por otro;
3. Que en la escritura de permuta se exprese el ánimo de subrogar (art. 1733, inc. 1º, Parte final);
4. Que exista una cierta proporcionalidad en los valores de ambos bienes (art. 1733, Inc. 6º); y
5. Que si el bien raíz que se subroga es de la mujer ésta preste su autorización (art. 1733, inc. Final).

1. Que uno de los cónyuges sea dueño de un inmueble propio.

Justamente la finalidad de la institución es que el cónyuge dueño de un inmueble pase a serlo del nuevo que reemplaza al anterior.

Esta institución opera respecto de cualquiera de los cónyuges, con la salvedad de que cuando es un bien de la mujer el que se subroga se requiere que la mujer preste su autorización.

La razón por la que el cónyuge pueda tener en su haber propio un bien raíz puede ser variada: lo adquirió de soltero; o durante la sociedad conyugal a título gratuito; o a título oneroso, pero subrogándolo a otro bien raíz propio, o a valores o dineros destinados a ese objeto en las capitulaciones matrimoniales.

2. Que vigente la sociedad conyugal se permute ese bien inmueble por otro bien inmueble.

3. Que en la escritura pública de permuta se exprese el ánimo de subrogar.

Ello quiere decir que en la escritura pública de permuta se debe indicar que el nuevo bien que se adquiere por permuta se subrogará al que se entrega en virtud de la misma permuta, es decir, pasará a ocupar la misma situación que tenía el que sale, esto es, integra el haber propio del cónyuge y no el activo social.

4. Debe existir una cierta proporcionalidad entre el bien que se entrega y el que se recibe.

Este requisito está establecido, en el artículo 1733 inciso 6º: "Pero no se entenderá haber

subrogación, cuando el saldo en favor o en contra de la sociedad excediere a la mitad del precio de la finca que se recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social, quedando la sociedad obligada a recompensar al cónyuge por el precio de la finca enajenada o por los valores invertidos y conservando éste el derecho a llevar a efecto la subrogación, comprando otra finca".

Ejemplos:

- El cónyuge es dueño de un bien raíz que vale \$3.000.000 y se permuta por otro que vale \$5.000.000. Para saber si hay subrogación, debemos ver lo siguiente:

a) El saldo en favor o en contra de la sociedad. En este caso \$2.000.000;

b) Mitad del valor de la finca que se recibe. En este caso: \$2.500.000. En la situación planteada **hay subrogación**, porque el saldo en contra de la sociedad (\$2.000.000) no excede a la mitad del precio de la finca que se recibe (\$2.500.000).

- El cónyuge es dueño de un inmueble que vale \$2.000.000. y se permuta por otro que vale \$6.000.000. En este caso **no hay subrogación** porque el saldo en contra de la sociedad (\$4.000.000) excede a la mitad del valor de la finca que se recibe (\$3.000.000).

5. Autorización de la mujer cuando la subrogación se haga en bienes de la mujer.

- **Subrogación por compra**

En este caso los requisitos son los siguientes:

1. Que uno de los cónyuges sea dueño de un bien raíz propio;
2. Que este bien se venda y que con el producido de la venta se compre otro inmueble;
3. Que en las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar;
4. Que haya una cierta proporcionalidad entre el precio del inmueble que se vende y el del inmueble que se compra;
5. Que si el bien que se subroga es de la mujer, ella preste su autorización.

Respecto del requisito signado con el Nº 2 el Código trata de la situación en que primero se vende el bien raíz propio, y en seguida, con los dineros provenientes de esa venta, se compra el nuevo bien. Sin embargo, no está considerada la posibilidad de que se obre al revés, vale decir, que se compre primero (por ejemplo usándose dineros obtenidos en préstamo) y, posteriormente, se venda el primer bien. Esta situación es lo que en doctrina se llama "subrogación por anticipación" o "subrogación por antelación". Don Manuel Somarriva señala que en el Derecho Francés se acepta esta clase de subrogación, agregando que en Chile las opiniones están divididas; él no ve inconvenientes en aceptarla. René Ramos está con la tesis de don Arturo Alessandri de que no tendría valor, por cuanto siendo la subrogación una institución excepcional, no puede dársele a sus normas más amplitud que las que literalmente tienen. Ello, no obstante pensar que sería de mucha utilidad práctica.

En cuanto al requisito Nº 3, de que en las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar, tal exigencia está contemplada en la parte final del inciso primero del artículo 1733: "y que en las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar".

- **Subrogación de inmueble a valores**

Esta forma de subrogación está contemplada en el artículo 1727 Nº 2: "Las cosas **compradas** con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio".

Se destaca la forma verbal "comprada", pues ello está demostrando que no hay, en este caso, subrogación por permuta. Somarriva, sin embargo, piensa que por aplicación del aforismo "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición" no habría inconvenientes en aceptar en este caso la subrogación por permuta. Ramos encuentra discutible tal solución, por el carácter excepcional que tiene la subrogación que no admite interpretaciones por analogía.

Los requisitos son:

1. Que se compre un inmueble con valores propios de uno de los cónyuges, destinado a ello en las capitulaciones matrimoniales o, en una donación por causa de matrimonio;
2. Que se deje constancia en la escritura de compra que tal compra se hace con el dinero proveniente de esos valores y se deje constancia también del ánimo de subrogar;
3. Que exista una cierta proporcionalidad entre los valores y el inmueble que se adquiere;
4. Que si la subrogación se hace en bienes de la mujer ésta preste su autorización.

En cuanto al primer requisito, hay dos oportunidades en que se puede dar a los valores este destino: en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio. Respecto de esta última puede ser hecha por un cónyuge al otro o por un tercero al cónyuge. Don Manuel Somarriva cree que también esa destinación podría hacerse en un legado.

Sobre el segundo requisito, el artículo 1733 inciso 2º exige una doble declaración:

- a) que el inmueble se compra con el dinero proveniente de los valores destinados a ese efecto en las capitulaciones matrimoniales o en una donación (o en un legado); y
- b) que la compra se realiza con el ánimo de subrogar, vale decir de que el inmueble pase a ocupar el lugar jurídico que tales valores tenían, o sea, de que integren el haber propio del cónyuge.

- **Diferencias que se producen en toda subrogación cuando los valores del bien subrogado y subrogante son diferentes.**

Cuando el valor entre el bien subrogado y subrogante son diferentes, pueden presentarse diversas situaciones:

- i) Que no haya subrogación por no respetarse la proporcionalidad contemplada en el artículo 1733 inc. 6º. En este caso el bien que se adquiere ingresa al activo absoluto de la sociedad conyugal (1725 Nº 5). Sin perjuicio de ello el cónyuge que era dueño del bien propio tiene derecho a recompensa

por el precio de la finca enajenada y conserva el derecho a efectuar la subrogación comprando otra finca (art. 1733, inc. 6º, parte final).

ii) Que produciéndose subrogación, el bien que se adquiere sea de menor valor que el inmueble o valores que se enajenan. En este caso el cónyuge dueño de tales bienes adquiere una recompensa en contra de la sociedad conyugal (art. 1733 incisos 3º, 4º y 5º);

iii) Que produciéndose subrogación, el bien que se adquiere sea de mayor valor que el inmueble o valores que se enajenan, caso en que el cónyuge en cuyo favor se hace la subrogación deberá pagar a la sociedad conyugal la correspondiente recompensa (art. 1733 incisos 3º, 4º y 5º).

3.3 Pasivo de la sociedad conyugal

Al igual que en el activo de la sociedad conyugal en el pasivo, también hay que distinguir entre **el pasivo real y pasivo aparente** de la sociedad conyugal.

Una deuda integra el **pasivo real** de la sociedad conyugal, cuando ésta debe pagarla sin derecho a recompensa. Se trata empleando -otra terminología- que esa deuda es social tanto desde el punto de vista de la obligación a la deuda como desde el punto de vista de la contribución a la deuda. La sociedad paga y soporta el pago.

Una deuda integra el **pasivo aparente o relativo** de la sociedad conyugal, cuando ésta debe pagarla pero no soportarla, pues al pagar adquiere una recompensa en contra del cónyuge de que se trate, que hará efectiva a la disolución de la sociedad conyugal. En este caso la deuda es social desde el punto de vista de la obligación a la deuda, pues el tercero acreedor se dirigirá para cobrarla en contra de los bienes sociales, pero esa deuda es personal del cónyuge desde el punto de vista de la contribución a la deuda pues, en definitiva él va a soportar el pago, desde que la sociedad conyugal hará efectiva en su contra la correspondiente recompensa.

La obligación a la deuda mira las relaciones de un tercero con la sociedad conyugal, en cambio, el de la contribución a la deuda dice relación con los cónyuges, con los ajustes económicos que tienen que producirse entre ellos al momento de liquidar la sociedad conyugal.

3.3.1 Pasivo absoluto

Lo integran todas las deudas que son sociales tanto desde el punto de vista de la obligación como de la contribución a la deuda. Es decir, la sociedad conyugal está obligada a pagar y a soportar el pago. Paga sin derecho a recompensa.

Integran este pasivo absoluto las siguientes deudas:

a) Pensiones e intereses que corran sea contra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen durante la sociedad

Este caso lo establece el artículo 1740, Nº 1. Esta norma es la contrapartida de la establecida en el artículo 1725 Nº 2, pues si de acuerdo a esa disposición ingresan al activo absoluto de la sociedad conyugal todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada cónyuge, es lo lógico que recíprocamente, las pensiones e intereses que corran contra la sociedad o contra cualquiera de los

cónyuges, sean soportadas por la sociedad conyugal. Así, por ejemplo, las rentas de arrendamiento que produce un inmueble propio o social, ingresan al activo absoluto. Recíprocamente, la renta de arrendamiento que se tiene que pagar, debe soportarla la sociedad conyugal.

De acuerdo a esta norma, si uno de los cónyuges celebró de soltero, un contrato de mutuo, y los pagos los hace durante la vigencia de la sociedad conyugal, los intereses serán de cargo de la sociedad conyugal. Y es justo, porque si a la inversa él hubiere prestado dinero a interés, y los pagos se los hicieran cuando ya está casado en régimen de sociedad conyugal, tales intereses ingresarían al haber absoluto de la sociedad conyugal, de acuerdo al artículo 1725 N° 2.

b) Deudas contraídas durante el matrimonio, por el marido o la mujer con autorización del marido o de la justicia en subsidio y que no fueren personales de éste o de aquélla.

Así lo consigna el artículo 1740 N° 2.

Como se puede observar, la norma distingue varias situaciones:

i) Deuda contraída por el marido. Sin duda, será esta la situación normal, desde que el marido es quien administra la sociedad conyugal.

ii) Deuda contraída por la mujer con autorización del marido. A Ramos le parece que esta situación, antes de la Ley 18.802, debía relacionarse con el antiguo artículo 146, pues allí se decía que "la mujer que procede con autorización del marido, obliga al marido en sus bienes de la misma manera que si el acto fuera del marido...". Hoy, después de la modificación de la Ley 18.802, no tiene sentido la norma a menos de entender que ella importa un mandato. En efecto, tal disposición debía ser interpretada en relación con el artículo 146, que reglamentaba los efectos que producía el hecho de que la mujer contratara autorizada por su marido, pero el artículo 4º de la Ley 18.802 derogó el artículo 146. Ramos cree que al redactarse la Ley 18.802, no se reparó en esa circunstancia y por ello se mantuvo la frase "o la mujer con autorización del marido", en el numeral 2º del artículo 1740.

iii) Deuda contraída por la mujer con autorización judicial. Esta situación tenemos que vincularla con el artículo 138 inciso 2º, según el cual cuando al marido le afectare un impedimento que no fuere de larga o indefinida duración, la mujer puede actuar respecto de los bienes del marido, de la sociedad conyugal y de los suyos que administre el marido, con autorización del juez, con conocimiento de causa. En tal caso, dice el inciso 3º del artículo 138, la mujer obliga al marido en sus bienes y en los sociales de la misma manera que si el acto fuere del marido; y obliga además sus bienes propios, hasta concurrencia del beneficio particular que reportare del acto.

iv) Deudas contraídas por la mujer con mandato general o especial del marido. Esta situación está tratada en el artículo 1751: "Toda deuda contraída por la mujer con mandato general o especial del marido, es, respecto de terceros, deuda del marido y por consiguiente de la sociedad..." (inc. 1º, primera parte). En esta parte el artículo 1751 es perfectamente concordante con lo dispuesto en el artículo 1448 según el cual "lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo".

Con la reforma de la Ley 18.802, se salvó una situación que no estaba reglamentada en la ley y que era el caso en que la mujer mandataria no actuara en representación del marido, sino a nombre propio, lo que es perfectamente posible atendido lo dispuesto en el artículo 2151. De acuerdo a esta

disposición cuando el mandante contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al mandante. Con el objeto de mantener la concordancia entre esta norma y el artículo 1751, la Ley 18.802, al dar un nuevo texto al artículo 1751, estableció un inciso 2º que dice: "Si la mujer mandataria contrata a su propio nombre, registrará lo dispuesto en el artículo 2151". De consiguiente, en este caso, la deuda contraída por la mujer no integra el pasivo absoluto de la sociedad conyugal, puesto que no podrá hacerse efectiva en los bienes sociales. Dicha deuda, de acuerdo al artículo 137 inciso 1º, sólo podrá hacerse efectiva en el patrimonio reservado de la mujer o en los bienes que administre de acuerdo al artículo 166 ó 167.

v) Deudas contraídas conjunta, solidaria o subsidiariamente por el marido y mujer. Este caso está tratado en el artículo 1751 inciso final: "Los contratos celebrados por el marido y la mujer de consuno o en que la mujer se obligue solidaria o subsidiariamente con el marido, no valdrán contra los bienes propios de la mujer..." lo que significa que deberán cobrarse a la sociedad conyugal, salvo en cuanto se probare que el contrato cedió en utilidad personal de la mujer, como en el pago de deudas anteriores al matrimonio (art. 1751 inciso final en relación con el art. 1750 inciso 2º)

vi) Deudas provenientes de compras al fiado, que haga la mujer de bienes muebles destinados al consumo ordinario de la familia. Así lo establece el artículo 137 inciso 2º. Para que nos encontremos frente a esta situación que es claramente excepcional -la regla es que los contratos celebrados por la mujer, no obligan los bienes sociales sino exclusivamente los bienes que la mujer administra en conformidad a los artículos 150, 166 y 167 (art. 137 inc. 1º)- tendrán que concurrir copulativamente los requisitos que la norma contempla: i) compra al fiado, ii) de bienes muebles; y iii) que esos bienes estén destinados naturalmente al consumo ordinario de la familia.

c) Pago de las obligaciones generadas por contratos accesorios cuando, las obligaciones garantizadas por ellos no fueren personales de uno de los cónyuges.

Esta situación está establecida en el artículo 1740, Nº 2, inciso 2º: "La sociedad, por consiguiente, es obligada, con la misma limitación, al lasto de toda fianza, hipoteca o prenda constituída por el marido".

Pueden presentarse diversas situaciones:

i) Que el marido haya garantizado con prenda, hipoteca o fianza una obligación de la sociedad conyugal. En este caso, la sociedad está obligada al pago de esta deuda que también soporta la sociedad conyugal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

ii) Que el marido garantice con prenda, fianza o hipoteca una obligación ajena. Para que el marido pueda constituir esta garantía requiere de la autorización de la mujer, y si no la obtiene, sólo obliga sus bienes propios (art. 1749, inc. 5º). De manera que si la mujer da su autorización, es incuestionable que los pagos que por este concepto haga la sociedad conyugal, los hace sin derecho a recompensa.

iii) Que el marido garantice con prenda, fianza o hipoteca una obligación personal de uno de los cónyuges. En este caso, y en virtud del principio de lo accesorio, la sociedad está obligada al pago, pero con derecho de recompensa. Es decir, se trata de una deuda que está en el pasivo relativo de la sociedad conyugal.

d) Todas las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada cónyuge (art. 1740 Nº 4).

La ley no ha indicado lo que entiende por cargas y reparaciones usufructuarias. Por ello, parece atendible aplicar en esta materia las normas que establece el Código Civil al tratar del derecho de usufructo. Allí en el artículo 795 se dice que "corresponden al usufructuario todas las expensas ordinarias de conservación y cultivo". Y, en seguida, en el artículo 796 se agrega que "serán de cargo del usufructuario las pensiones, cánones y en general las cargas periódicas con que de antemano haya sido gravada la cosa fructuaria y que durante el usufructo se devenguen..." (inc. 1º); y que "corresponde asimismo al usufructuario el pago de los impuestos periódicos fiscales y municipales, que la graven durante el usufructo, en cualquier tiempo que se haya establecido" (inc. 2º). Estas reparaciones usufructuarias se contraponen a las obras o reparaciones mayores, que en el decir del artículo 798, son las que ocurren por una vez o a intervalos largos de tiempo, y que conciernen a la conservación y permanente utilidad de la cosa fructuaria. Según el art. 797 son de cargo del propietario. Ejemplos. El pago de contribuciones de bienes raíces, es una carga usufructuaria. Por ello, la sociedad conyugal está obligada a su pago, sea que correspondan al bien propio de un cónyuge, sea que el bien sea social, sin derecho a recompensa. Si se trata de cambiar el techo de la casa, es una reparación mayor y por ello, si el bien es social, lo hace la sociedad conyugal sin cargo de recompensa (pasivo absoluto), pero si el bien es propio del cónyuge, lo debe hacer la sociedad conyugal, con derecho a recompensa (pasivo relativo, art. 1746).

Aparentemente se pudiera ver como una situación injusta el que sean de cargo de la sociedad conyugal las reparaciones usufructuarias de un bien propio de un cónyuge. Sin embargo, nada más equitativo desde que esta norma viene a ser la contrapartida de la establecida en el artículo 1725 Nº 2, según la cual, ingresan al activo absoluto de la sociedad conyugal "todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, **sea de los bienes propios** de cada uno de los cónyuges..."

e) Gastos de mantenimiento de los cónyuges; de mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes; y de toda otra carga de familia (art. 1740 Nº 5).

Dentro de este rubro se contienen diversas situaciones:

i) **Gastos de mantenimiento de los cónyuges.** Si las remuneraciones que obtienen los cónyuges ingresan al activo absoluto de la sociedad conyugal (art. 1725 Nº 1) resulta absolutamente razonable que el mantenimiento de ellos sea también de cargo de la sociedad conyugal.

ii) **Gastos de mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes.** El artículo 1740, en esta parte, debe ser concordado con el artículo 230, en cuanto dicha norma señala que "Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos, son de cargo de la sociedad conyugal, según las reglas que tratando de ella se dirán..."

En relación con los gastos de crianza o gastos de mantenimiento comprenden la alimentación, habitación, vestido, atención de salud, etc. (Alessandri). Son de cargo de la sociedad conyugal puesto que, según el artículo 224, toca de consuno a los padres "el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos".

Respecto a los gastos de educación, comprenden los que demande la enseñanza básica, media, profesional o universitaria. El artículo 1744 distingue entre expensas ordinarias o extraordinarias de educación de un descendiente común. Los gastos ordinarios son de cargo de la sociedad conyugal aunque el hijo tuviere bienes propios (arts. 231, 1740 Nº 5 y 1744). Sólo se podrían sacar de los bienes propios del hijo en caso necesario, o sea, cuando los bienes sociales no fueren suficientes.

Los gastos extraordinarios de educación, en cambio, deberán pagarse con los bienes propios del hijo, si los tuviere, y sólo en cuanto le hubieren sido efectivamente útiles. Serán de cargo de la sociedad conyugal, en caso contrario (art. 1744 inc. final).

"Las expensas ordinarias y extraordinarias de educación de un descendiente común, y las que se hicieren para establecerle y casarle, se imputarán a los gananciales, siempre que no constare de un modo auténtico que el marido, o la mujer o ambos de consuno, han querido que se sacasen estas expensas de sus bienes propios" (art. 1744 inc. 1º). Agrega la norma que "aun cuando inmediatamente se saquen ellas de los bienes propios de cualquiera de los cónyuges, se entenderá que se hacen a cargo de la sociedad, a menos de declaración contraria".

En relación con los gastos de establecimiento de los descendientes comunes, cabe señalar que tienen este carácter "los necesarios para dar al hijo un estado o colocación estable que le permita satisfacer sus propias necesidades, como los que demanden el matrimonio o profesión religiosa, su ingreso a un servicio público o particular, la instalación de su oficina o taller, etc." (Alessandri). Estos gastos van a ser de cargo de la sociedad conyugal, cuando el hijo careciere de bienes propios (art. 231) y cuando, además, no constare de un modo auténtico que marido, mujer o ambos de consuno han querido que se sacasen de sus bienes propios (art. 1744 inc. 1º).

iii) Gastos para atender otras cargas de familia. El artículo 1740 en el inciso 2º de su numeral 5º prescribe que "se mirarán como carga de familia los alimentos que uno de los cónyuges esté por ley obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges; pero podrá el juez moderar este gasto si le pareciere excesivo, imputando el exceso al haber del cónyuge". De manera que, según esta norma, los alimentos legales que un cónyuge debe pagar a los hijos de un matrimonio anterior, o a sus padres o a un hijo tenido fuera del matrimonio son de cargo de la sociedad conyugal, sin derecho a recompensa, salvo que sean excesivos. En este último caso, si los paga la sociedad conyugal, será con derecho a recompensa por el exceso.

f) Dineros pagados a la mujer en virtud de haberse consignado en las capitulaciones matrimoniales tal obligación, a menos que se haya establecido que el pago sería de cargo del marido (art. 1740 inciso final).

De acuerdo al artículo 1720 inciso 2º, en las capitulaciones matrimoniales "se podrá estipular que la mujer dispondrá libremente de una determinada suma de dinero, o de una determinada pensión periódica, y este pacto surtirá los efectos que señala el artículo 167".

En este caso, estas sumas de dinero que se entregan a la mujer, de una vez o periódicamente, serán de cargo de la sociedad (pasivo absoluto), a menos de haberse convenido en las mismas capitulaciones que serían de cargo del marido (art. 1740, Nº 5º inciso final).

3.3.2 Pasivo relativo o aparente o provisorio de la sociedad conyugal

Este pasivo lo componen aquellas deudas que la sociedad está obligada a pagar pero que le otorgan un derecho de recompensa en contra del cónyuge respectivo. Dicho de otra forma, lo integran aquellas deudas que la sociedad paga pero que en definitiva no soporta. O todavía podría agregarse, que se trata de deudas sociales desde el punto de vista de la obligación a las deudas, pero personales desde el punto de vista de la contribución a las deudas.

Este pasivo está integrado por las **deudas personales** de los cónyuges. Así lo dice el artículo 1740 Nº 3º: "La sociedad es obligada al pago: 3º De las deudas personales de cada uno de los cónyuges, **quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invierta en ello**". Lo destacado demuestra que tales deudas integran el pasivo relativo. Confirma la misma idea el Nº 2 del mismo

artículo, en cuanto dice que la sociedad es obligada al pago: "de las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, o la mujer con autorización del marido o de la justicia en subsidio, **y que no fueren personales de aquél o ésta**, como lo serían..." y el inciso 2º del mismo Nº 2 "con la misma limitación".

El problema consiste en determinar cuáles son las deudas personales de un cónyuge. No hay una definición exacta pero la ley va indicando casos:

a) Deudas anteriores al matrimonio.

b) Deudas contraídas durante el matrimonio y que ceden en beneficio exclusivo de uno de los cónyuges. Ej. las que se hacen para establecer a los hijos de un matrimonio anterior de uno de los cónyuges (art. 1740 Nº 2). El mismo principio lo confirman otras disposiciones: art. 137 inc. 2º; 138 inciso 3º y 138 bis inciso 3º.

c) Deudas provenientes de multas o reparaciones pecuniarias a que fuere condenado uno de los cónyuges por un delito o cuasidelito (art. 1748).

d) Deudas hereditarias o testamentarias provenientes de una herencia adquirida por uno de los cónyuges (art. 1745 inc., final).

3.3.3 Presunción de deuda social

Algunos autores (Somarriva) sostienen que del artículo 1778 del Código Civil, se desprende una presunción de ser sociales todas las deudas. Dice la norma "El marido es responsable del total de las deudas de la sociedad; salvo su acción contra la mujer para el reintegro de la mitad de estas deudas, según el artículo precedente".

3.4 Las Recompensas.

Durante la vida de la sociedad conyugal se producen diferentes situaciones que van generando créditos o recompensas sea de uno de los cónyuges en favor de la sociedad conyugal, sea de la sociedad conyugal en favor de uno de los cónyuges, sea, por último, de un cónyuge en favor del otro. Así ocurre, por ejemplo, cuando el cónyuge al casarse tiene especies muebles o dineros. Estos ingresan al activo relativo de la sociedad conyugal, lo que significa que le otorgan un crédito en contra de la sociedad. Lo mismo acontece cuando, el cónyuge adquiere durante la vigencia de la sociedad, dinero o especies muebles a título gratuito. Por otra parte, mientras subsiste la sociedad conyugal, se van pagando una serie de deudas personales de los cónyuges, que hace la sociedad, pero con derecho a recompensa, es decir, el cónyuge beneficiado tiene que reembolsar estos gastos cuando la sociedad termina.

Manuel Somarriva las define diciendo que "recompensa es el conjunto de créditos o indemnizaciones en dinero que se hacen valer al momento de liquidar la sociedad conyugal, a fin de que cada cónyuge aproveche los aumentos y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponde" o, como el mismo dice, "son los créditos que el marido, mujer y sociedad pueden reclamarse recíprocamente".

3.4.1 Objetivos de las recompensas

Se ha dicho que las recompensas tienen por objeto:

- a) Evitar todo enriquecimiento, a menudo involuntario, de un patrimonio a expensas del otro; nadie puede enriquecerse a costa ajena sin causa;
- b) Evitar que los cónyuges se hagan donaciones disimuladas en perjuicio de sus respectivos legitimarios y acreedores; los cónyuges sólo pueden hacerse donaciones revocables y la ley quiere que las hagan ostensiblemente para asegurarse que tienen ese carácter;
- c) Mantener la inmutabilidad del régimen matrimonial y el equilibrio entre los tres patrimonios. La composición de cada uno ha sido determinada por la ley o por las capitulaciones matrimoniales y no puede alterarse una vez celebrado el matrimonio; de ahí que cada vez que un valor sale de alguno de ellos, para ingresar a otro, debe ser reemplazado por uno equivalente;
- d) Proteger a la mujer contra los abusos del marido. Si las recompensas no existieren, sería fácil a éste, como administrador de la sociedad y de los bienes de la mujer, enriquecerse a su costa; "le bastaría utilizar los bienes sociales y de la mujer en su propio beneficio" (Alessandri).

En definitiva, el fundamento de esta institución está en evitar el enriquecimiento sin causa.

3.4.2 Clasificación de las recompensas

Pueden ser de tres clases:

a) Recompensa adeudada por uno de los cónyuges a la sociedad conyugal

Uno de los cónyuges puede adeudar a la sociedad recompensas por diversas razones:

- Porque la sociedad pagó una deuda personal suya (art. 1740 Nº 3);
- Porque durante la sociedad adquirió un bien raíz subrogándolo a valores o a otro inmueble propio, y el valor del bien adquirido es superior al que subrogó (art. 1733 inc. 3º);
- Porque durante la sociedad, se hicieron mejoras no usufructuarias en un bien propio, que aumentó el valor de la cosa, como por ejemplo, en un sitio propio se construyó una casa. En este caso, el monto de la recompensa está regulado por el artículo 1746: "Se le debe asimismo recompensa por las expensas de toda clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los cónyuges, en cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor de los bienes; y en cuanto subsistiere este valor a la fecha de la disolución de la sociedad; a menos que este aumento del valor exceda al de las expensas, pues en tal caso se deberá sólo el importe de éstas";
- Porque adquirió una herencia y la sociedad pagó las deudas hereditarias o testamentarias (art. 1745);
- Porque hizo una erogación gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente común (arts. 1735, 1742, 1747);
- Porque la sociedad pagó una multa o indemnización generada por un delito o cuasidelito suyo (art. 1748);
- Porque, con dolo o culpa grave, causó perjuicios a la sociedad (art. 1748);
- Por los precios, saldos, costas judiciales y expensas de toda clase que se hicieron en la adquisición o cobro de los bienes, derechos o créditos que pertenezcan al cónyuge (art. 1745);

- Porque disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación, se adquirió un bien a título oneroso, caso en que se adeuda recompensa a la sociedad por el precio de adquisición del bien, a menos que se pruebe que fue adquirido con bienes propios o provenientes de la sola actividad personal (art. 1739 inc. final).

b) Recompensas debidas por la sociedad conyugal al cónyuge.

La sociedad conyugal puede adeudar recompensas al cónyuge, por distintos conceptos:

- Por las especies muebles o dineros que éste aportó a la sociedad o que durante ella adquirió a título gratuito (art. 1725 N°s. 3 y 4);
- Porque durante la vigencia de la sociedad conyugal se enajenó un bien propio de uno de los cónyuges, a menos que con esos dineros se haya adquirido otro bien que se subrogó al primero o se haya pagado una deuda personal del cónyuge. Así lo dice el artículo 1741: "Vendida alguna cosa del marido o de la mujer, la sociedad deberá recompensa por el precio al cónyuge vendedor, salvo en cuando dicho precio se haya invertido en la subrogación de que habla el artículo 1733, o en otro negocio personal del cónyuge cuya era la cosa vendida; como en el pago de sus deudas personales, o en el establecimiento de sus descendientes de un matrimonio anterior";
- Porque durante la sociedad conyugal operó la subrogación de inmueble a inmueble o a valores, y el bien adquirido era de menor valor que el bien subrogado (art. 1733 incisos 3º, 4º y 5º);
- Si las expensas ordinarias y extraordinarias de educación de un descendiente común o las necesarias para establecerle o casarle se sacaren de los bienes propios de un cónyuge sin que aparezca ánimo de éste de soportarlas (art. 1744 inc. 1º).

c) Recompensas debidas por los cónyuges entre sí

Un cónyuge va a deber recompensas al otro cuando se ha beneficiado indebidamente a su costa; o cuando con dolo o culpa, le ha causado perjuicios. Hay varios ejemplos:

- Cuando con bienes de un cónyuge se paga una deuda personal del otro;
- Cuando con bienes propios del cónyuge, se hicieron reparaciones o mejoras en un bien del otro;
- Cuando un cónyuge, con dolo o culpa grave, causare daños a los bienes del otro, por ejemplo, lo incendiare (art. 1771).

3.4.3 Prueba de las recompensas

El que alega una recompensa deberá probar los hechos en que la funda (art. 1698). Para ello podrá valerse de todos los medios probatorios que establece la ley, con excepción de la confesión, puesto que el artículo 1739 inciso 2º establece que: "Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán suficiente prueba, aunque se hagan bajo juramento". Sin embargo, la confesión produce una consecuencia, que indica el inciso 3º de la misma norma: "la confesión, no obstante, se mirará como una donación revocable, que, confirmada por la muerte del donante, se ejecutará en su parte de gananciales o en sus bienes propios, en lo que hubiere lugar".

3.4.4 Las recompensas se pagan en dinero y en valor reajustado

Artículo 1734: "Toda las recompensas se pagarán en dinero, de manera que la suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la recompensa". "El

partidor aplicará esta norma de acuerdo a la equidad natural". Como se puede observar otorga amplias facultades al partidor o liquidador de la sociedad conyugal, para poder establecer la reajustabilidad.

3.4.5 Las recompensas no son de orden público

Las recompensas no son de orden público. De ello se sigue:

- Que los cónyuges pueden renunciar a ellas. La renuncia se puede hacer en las capitulaciones matrimoniales. De no hacerse allí, no se podría, durante la vigencia de la sociedad conyugal, hacerla en términos generales, pues ello importaría alterar el régimen matrimonial. Pero sí se podría renunciar a una recompensa determinada (Alessandri), y
- Que se puede convenir otra forma de calcularlas o de pagarlas. Así por ejemplo, el artículo 1734, dice que se pagarán en dinero, pero nada obsta a que pueda aceptarse otra forma de pago, rigiendo en esta materia las reglas generales en materia de partición de bienes y de dación en pago (Fernando Rozas).

3.5 Administración Ordinaria de la Sociedad Conyugal.

Para estudiar la administración de la sociedad conyugal debe distinguirse entre administración ordinaria y extraordinaria.



Observación

La **administración ordinaria de la sociedad conyugal**, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de la mujer, corresponde únicamente al marido. Así se establece en el artículo 1749 y se reitera en los artículos 1752 y 1754 inciso final. La primera de estas normas dice: *"El marido es el jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer, sujeto empero, a..."* (inciso 1º, primera parte). El artículo 1752 agrega: *"La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del artículo 145"* (la referencia al artículo 145, después de la ley 19.335, debe entenderse hecha al artículo 138). Y reitera la idea, en relación a los bienes propios de la mujer, el artículo 1754 inciso final: *"La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis"*

No obstante que la Ley 18.802 otorgó plena capacidad a la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, mantuvo la administración de los bienes sociales y de los bienes propios de la mujer, en el marido.

3.5.1 Administración de los bienes sociales

El Código trata la administración de los bienes sociales en el artículo 1749, norma que en su primera parte sienta el principio de que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y en tal carácter administra esos bienes.

En seguida, establece las limitaciones: "sujeto empero, a las obligaciones y limitaciones que por el presente Título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales".

Hay, pues, dos clases de limitaciones:

- a) Las establecidas por los esposos en las capitulaciones matrimoniales; y
- b) Las impuestas por el título XXII del Libro IV del Código Civil.

a) Limitaciones a la administración del marido impuestas en las capitulaciones matrimoniales

Esta situación se da, por ejemplo, en el caso que los cónyuges, haciendo uso del derecho que les confiere el artículo 1720 inciso 2º estipularen que la mujer dispondrá de una determinada suma de dinero, o de una determinada pensión periódica. Estos acuerdos de los esposos no pueden tener una amplitud tan grande que se llegare por esta vía a privar al marido de la administración de los bienes sociales o propios de la mujer, pues si así ocurriera, tal pacto adolecería de objeto ilícito atendido lo dispuesto en el artículo 1717 y por ello sería absolutamente nulo (art. 1682, en relación con el art. 1466 y con el art. 1717).

b) Limitaciones a la administración del marido impuestas en el Título XXII del Libro IV

De acuerdo al artículo 1749 el marido necesita de la autorización de la mujer, para realizar los siguientes actos jurídicos:

- Para enajenar voluntariamente bienes raíces sociales;
- Para gravar voluntariamente bienes raíces sociales;
- Para prometer enajenar o gravar bienes raíces sociales;
- Para enajenar o gravar voluntariamente o prometer enajenar o gravar los derechos hereditarios que correspondan a la mujer;
- Para disponer por acto entre vivos a título gratuito de los bienes sociales;
- Para dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales por más de 5 años si son urbanos o por más de 8 si son rústicos;
- Para otorgar avals o constituirse en deudor solidario u otorgar cualquiera otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros.

En todos los casos recién señalados, la mujer debe prestar su autorización al marido, y si no la otorga se siguen las sanciones que más adelante se dirán.

c) Características de la autorización de la mujer

De acuerdo al artículo 1749, inciso 7º, esta autorización tiene las siguientes características:

c.1) La autorización debe ser específica. El artículo 1749, inciso 7º señala en su primera parte: "La autorización de la mujer deberá ser específica...".

La autorización de la mujer debe ser específica y se entiende por tal la que da la mujer para celebrar un acto jurídico determinado en condiciones también determinadas. Pablo Rodríguez expresa que específica significa que "debe referirse precisamente al acto de que se trata. Por consiguiente, agrega, ella no puede ser genérica ni manifestarse la voluntad sin describir e individualizar el acto que se ejecutará".

c.2) La autorización es solemne. Dice el artículo 1749 inciso 7º que "la autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad...". La solemnidad puede ser por escrito o por escritura pública según lo sea el acto para el cual se va a dar la autorización. Así, por ejemplo, si se da la autorización para vender o hipotecar un bien raíz, debe darse por escritura pública; en cambio, si se requiere para celebrar un contrato de promesa sobre un bien raíz social o para dar en arriendo un bien raíz social, bastará con que se de por escrito, porque ni la promesa ni el arriendo requieren de escritura pública.

c.3) La autorización puede ser dada personalmente o a través de mandatario. El inciso 7º del artículo 1749, en su parte final así lo dice: "Podrá prestarse -la autorización- en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el caso".

Si se otorga el mandato para una autorización de las que deben darse por escritura pública, el mandato también debe cumplir esa solemnidad; en cambio si se confiere para una autorización que debe darse por escrito, bastará con que el mandato se sujete sólo a esa solemnidad. En todo caso, el mandato tiene que ser especial. Así lo exige el artículo 1749.

También se entiende dada la autorización cuando la mujer interviene "expresa y directamente **de cualquier modo** en el mismo (acto)". Así lo dice el artículo 1749 inc. 7º. Se destaca la expresión "de cualquier modo", porque fue agregada por la Ley 18.802 y en esa forma quedó definitivamente aclarado que la mujer puede comparecer como parte o de otra manera en el acto. Así la mujer podría limitarse a poner su firma al pie de la escritura de venta, hipoteca o arrendamiento otorgada por el marido, pero sin comparecer en ella.

c.4) La autorización de la mujer puede ser suplida por la justicia. El inciso final del artículo 1749 permite la autorización judicial en dos casos:

i) En caso de negativa de la mujer: Dice el artículo 1749 inciso final, primera parte: "La autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez, previa audiencia a la que será citada la mujer, si esta la negare sin justo motivo" (redacción de la Ley 19.968). La ley no quiere, que la mujer pueda oponerse a la autorización sin razones valederas, por eso, si ella no quiere darla, deberá resolver el conflicto la justicia, ponderando hasta qué punto son justificadas sus razones.

El Código ha previsto la autorización judicial en el caso de negativa de la mujer, porque quiere mantener el principio que quien administra es el marido, de tal suerte que si la mujer se opone tiene que ser por razones valederas. En caso contrario estaría haciendo un mal uso de esta facultad legal, habría un abuso del derecho.

ii) Si la mujer está impedida para otorgarla. El inciso final del artículo 1749 señala: "Podrá asimismo ser suplida (la autorización de la mujer) por el juez en caso del algún impedimento de la mujer, como el de la menor edad, demencia, ausencia real o aparente u otro, **y de la demora se siguiere perjuicio**".

En este caso se exige que de la demora de la mujer se siga perjuicio. De manera que el marido tendrá que probar que la mujer está impedida, y que de no hacerse la operación se seguirían perjuicios, puesto que el negocio de que se trata es necesario o conveniente para la sociedad. En este caso se procede sin citación de la mujer, por cuanto no está en situación de poder comparecer ante el tribunal justamente por el impedimento que le afecta.

c.5) La autorización debe ser previa. Don Arturo Alessandri sostiene que "la autorización de la mujer debe ser anterior al acto que el marido pretende celebrar o coetánea o simultánea con su

celebración. Lo segundo ocurre cuando esa autorización resulta de la intervención expresa o directa de la mujer en él. En ningún caso puede ser posterior. No cabe autorizar la realización de un acto ya celebrado. La autorización de la mujer otorgada con posterioridad, constituiría una ratificación...".

d) Actos respecto de los cuales la mujer debe dar su autorización al marido.

d.1) Enajenación voluntaria de bienes raíces sociales.

Dice el artículo 1749 inciso 3º: "El marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente... los bienes raíces sociales".

Se refiere exclusivamente a la enajenación **voluntaria**, no a la forzada. Ello es lógico, pues, en caso contrario, los acreedores sociales no podrían hacer efectivos los créditos que tuvieran en contra de la sociedad o del marido. Se desvirtuaría su derecho de prenda general.

La limitación dice relación únicamente con los **bienes raíces sociales**. Es decir, el marido puede con absoluta libertad enajenar los bienes muebles, cualquiera sea su valor, sin necesidad de la autorización de la mujer, por ejemplo, vender un camión o un avión. Este es otro ejemplo de la tendencia constante del Código de atribuir mayor importancia a los bienes inmuebles que a los muebles. Puede tratarse de una cosa corporal o incorporeal. La ley no hace distinciones. Así por ejemplo se requiere autorización de la mujer para enajenar una concesión minera, porque de acuerdo a la Ley Minera (Ley 18.097) y al Código de Minería dichas concesiones son derechos reales inmuebles (art. 2º de la Ley Minera; art. 2º Código de Minería).

Para que rija la exigencia se tiene que tratar de bienes raíces **sociales**. De consiguiente, la limitación no opera tratándose de bienes raíces propios de cada cónyuge. Dicho esto sin perjuicio de que tratándose de bienes raíces propios de la mujer va a ser necesario cumplir ciertas exigencias para su enajenación de acuerdo al artículo 1754.

Si bien el artículo 1749 exige la autorización de la mujer para la **enajenación** y no hay tal mientras no se haga la respectiva tradición, hay que entender que la autorización deberá darse para la celebración del respectivo título traslativo que antecede a la tradición. Así lo señala don Arturo Alessandri: "La autorización de la mujer se requiere, para el acto jurídico en virtud del cual se haga la tradición y no para ésta, es decir, para el contrato traslativo de dominio, ya que, para que valga la tradición se requiere un título de esta especie (art. 675). La tradición no es sino la consecuencia necesaria de él, la forma de hacer el pago de la obligación contraída por el marido, y como todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes contratantes, celebrado el contrato, el marido no podría eludir la tradición de la cosa sobre que versa. Es pues, el contrato que tal efecto produce el que debe celebrarse con autorización de la mujer".

d.2) Gravamen voluntario de bienes raíces sociales.

El artículo 1749 en su inciso 3º así lo establece: "el marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente bienes raíces sociales...". La limitación, lo mismo que en el caso anterior, incide exclusivamente en los bienes raíces sociales.

Si se impone una servidumbre legal a un predio social, no se requiere de la autorización de la mujer, porque no se trata de un gravamen voluntario. Lo mismo si se decreta un usufructo sobre un bien raíz social como forma de pagar una pensión alimenticia, de acuerdo a la Ley 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

d.3) Promesa de enajenación o gravamen de un bien raíz social.

Esta limitación fue introducida por la Ley 18.802. Y sin duda fue un acierto del legislador por cuanto con anterioridad había una gran discusión sobre si era necesario para la validez del contrato de promesa que la mujer tuviera que dar su autorización.

d.4) Enajenación o gravamen voluntario o promesa de enajenación o de gravamen sobre derechos hereditarios de la mujer.

Dice el artículo 1749 que "el marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales **ni los derechos hereditarios de la mujer**, sin autorización de ésta" (inc. 3º). Esta limitación fue introducida por la Ley 18.802. En relación con ella, dice el profesor Fernando Rozas que "en las actas de las sesiones conjuntas de las comisiones legislativas se dejó constancia de que la limitación se extendía a todos los derechos hereditarios de la mujer, aunque no comprendieran inmuebles".

d.5) Disposición gratuita, por acto entre vivos, de bienes sociales.

El artículo 1749, señala en su inciso 4º que "No podrá tampoco (el marido), sin dicha autorización (de la mujer) disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735...".

Es decir, el marido no puede hacer ninguna donación de bienes sociales sin autorización de su mujer, salvo la excepción del artículo 1735. Nótese que esta limitación si bien parece tener un alcance general, relativa tanto a bienes muebles como inmuebles, hay que entenderla referida exclusivamente a los bienes muebles puesto que si se tratare de inmuebles, la situación ya estaba contemplada en el inciso 3º.

d.6) Arrendamiento o cesión de la tenencia de bienes raíces sociales por más de 5 años si se trata de predios urbanos o más de 8 si el predio es rústico.

Esta limitación está contemplada en el artículo 1749 inciso 4º: "ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales urbanos por más de cinco años, ni los rústicos por más de ocho, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido"

La norma se refiere a bienes inmuebles sociales.

La limitación rige para el arrendamiento o para cualquier otro contrato que implique ceder la tenencia de esos bienes, por ejemplo, el contrato de comodato sobre un inmueble social.

Deben computarse las prórrogas para el cálculo de los 5 u 8 años.

La sanción a la falta de la autorización de la mujer, no es la nulidad del contrato de arriendo sino la inoponibilidad por el exceso de plazo a la mujer (art. 1757, inciso 1º).

d.7) Constitución de avales u obligaciones accesorias para garantizar obligaciones de terceros.

Esta limitación la introdujo la ley Nº 18.802, y está contenida en los incisos 5º y 6º del artículo 1749. Dicen estas normas: "Si el marido se constituye aval (debió haber dicho avalista), codeudor solidario, fiador u otorga cualquiera otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará sus bienes propios" (inc. 5º); "En los casos a que se refiere el inciso anterior para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la mujer" (inc. 6º).

e) Sanción para el caso de que se omita la autorización de la mujer

El artículo 1749 requiere de la autorización de la mujer para que el marido pueda realizar una serie de actos o contratos. La sanción, cuando se omite tal autorización es, por regla general, la nulidad relativa, según lo señala el artículo 1757: "Los actos ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en los artículos 1749, 1754 y 1755, adolecerán de nulidad relativa...". Hacen excepción a esta regla las siguientes situaciones:

- Cuando la mujer no autoriza el contrato de arrendamiento o aquel que cede la tenencia de un inmueble social por más de 5 años si es urbano o por más de 8 si es rústico. La sanción es la inoponibilidad de esos contratos más allá de los plazos máximos señalados. Así lo dice el artículo 1757, inciso 1º, segunda parte: "En el caso del arrendamiento o de la cesión de la tenencia, el contrato regirá sólo por el tiempo señalado en los artículos 1749 y 1756".
- Cuando el marido constituya cauciones para garantizar obligaciones de terceros. La sanción consiste en que sólo obliga sus bienes propios. No se obligan los bienes sociales (art. 1749, inc. 5º).

f) Titulares de las acciones de nulidad e inoponibilidad y plazo para interponerlas

El artículo 1757 señala que "la nulidad o inoponibilidad (esto en el caso de los arriendos superiores a los plazos de 5 u 8 años) anteriores podrán hacerlas valer la mujer, sus herederos o cesionarios" (inc. 2º). "El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal, o desde que cese la incapacidad de la mujer o sus herederos" (inc. 3º). "En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la celebración del acto o contrato" (inc. 4º).

g) Situación que se produce cuando la mujer al casarse es socia de una sociedad de personas

Cuando una persona es socia, los derechos que tiene en la sociedad tienen naturaleza mueble. Por ello, al momento de casarse en régimen de sociedad conyugal, dichos derechos, de acuerdo al artículo 1725 Nº 4º, ingresan al activo relativo o aparente de la sociedad conyugal y, por ello, su administración va a corresponder al marido (art. 1749). Como esta situación puede no convenir a los terceros que se asocian con la mujer, la ley permite que al celebrarse la sociedad se pueda acordar que si ésta se casa, la sociedad se extinga. Tal pacto constituye la forma como los terceros pueden protegerse de la injerencia de un tercero -el marido- en los negocios sociales. Pero si nada han convenido, rige la norma del artículo 1749 inciso 2º: "Como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá los derechos de la mujer que siendo socia de una sociedad civil o comercial se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150".

Nótese que el marido va a pasar a administrar los derechos de que se vienen tratando, pero no en calidad de representante legal de su mujer, pues tal representación desapareció con la Ley 18.802, sino en su condición de administrador de la sociedad conyugal. Por eso, esta norma que introdujo la Ley 18.802, vino a reemplazar al inciso final del artículo 2106 que establecía que "el marido como administrador de la sociedad conyugal, representará de la misma manera a la mujer que siendo socia se casare".

Si la mujer, de acuerdo al contrato social, es la administradora de la sociedad, ella continúa con tal administración aunque contraiga matrimonio (Pablo Rodríguez G.). A Ramos esto le parece absolutamente lógico, pues en ese caso se deben aplicar las reglas del mandato y tal mandato no se extingue por el hecho del matrimonio, en virtud de la derogación que la Ley 18.802 hizo del Nº 8 del artículo 2163. La administración de la sociedad no es un derecho que le corresponda a la mujer como socia, pues podría tenerlo sin ser socia (artículo 385 del Código de Comercio).

El artículo 1749 inciso 2º señala que el marido como administrador de la sociedad conyugal ejercerá los derechos de la mujer que siendo socia de una sociedad civil o comercial se casare, **sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150**. Ramos dice que cuesta imaginarse en qué caso puede operar el artículo 150, puesto que es requisito para que exista patrimonio reservado el que la mujer tenga durante el matrimonio una actividad separada de su marido que le produzca ingresos. Y en la

situación que estamos estudiando la mujer había celebrado la sociedad de soltera, es decir los ingresos con que lo hizo no pudieron provenir de una actividad separada de su marido, porque era soltera. Fernando Rozas pone como un ejemplo de esta situación, una sociedad de profesionales. Dice que en ese caso, "la mujer sigue ejerciendo los derechos sociales, sin solución de continuidad, en el ejercicio de su patrimonio reservado. Después de disuelta la sociedad conyugal se aplicarán a los derechos sociales las reglas que señala el artículo 150".

h) Situación que se produce cuando la mujer después de casada celebra un contrato de sociedad.

Se trata de un asunto distinto al que reglamenta el artículo 1749 inciso 2º.

Durante el matrimonio la mujer puede celebrar un contrato de sociedad, pudiendo presentarse diversas hipótesis:

i) Que tenga un patrimonio reservado, y actuando dentro de él, celebre un contrato de sociedad. Este caso no presenta mayores problemas, porque queda regido íntegramente por el artículo 150.

ii) Que no tenga patrimonio reservado y celebre un contrato de sociedad. La mujer, por ser plenamente capaz, puede hacerlo. Debe entenderse que los artículos 349 del Código de Comercio y 4º inciso 3º de la Ley sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada, que exigían autorización del marido, han quedado derogados de acuerdo con el artículo 2º de la ley Nº 18.802.

Sin embargo, al no tener bienes bajo su administración (porque sus bienes los administra el marido) no va a poder cumplir con la obligación de hacer los aportes convenidos, a menos que el marido consienta. Si así ocurre, Ramos no ve problemas, pero sí lo ve en el caso de que el marido no acepte. En tal supuesto, le parece, opera el artículo 2101, según el cual "si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta".

Fernando Rozas dice que si "la mujer se obliga a aportar un bien propio de aquellos que administra el marido, hay que distinguir si lo hace con consentimiento del marido o sin él". "Si lo hace con consentimiento del marido, creemos que en la proporción del valor de ese aporte, el marido es socio". A Ramos no le parece que sea así. No puede ser socio el marido, porque los terceros no celebraron con él el contrato de sociedad. Y en seguida, el bien que se aporta, tampoco es del marido, sino de la mujer. No ve, entonces, en qué podría fundarse esta afirmación de que el marido pasaría a ser socio.

iii) Si la mujer tiene alguno de los patrimonios especiales establecidos en los artículos 166 ó 167, puede celebrar el contrato de sociedad, obligando únicamente los bienes de tales patrimonios (art. 137, inc. 1º). Ramos tampoco ve problemas si la mujer casada celebra el contrato de sociedad y se obliga a aportar únicamente su trabajo personal. La sociedad es válida y ella está en condiciones de poder cumplir con su obligación de aportar lo convenido.

i) Situaciones excepcionales en que la mujer participa en la administración ordinaria de los bienes sociales y los obliga.

Hay algunas situaciones en que, por excepción, la mujer participa en la administración de bienes sociales y los obliga.

i.1) Las compras que la mujer haga al fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia, obligan los bienes sociales (art. 137 inc. 2º)

Por esta vía la mujer está interviniendo en la administración de los bienes sociales, y los está comprometiendo;

i.2) Caso de impedimento del marido, que no sea de larga o indefinida duración (porque si fuere de larga o indefinida duración entran a jugar las reglas de la administración extraordinaria) y de la demora se siguiere perjuicio (art. 138 inciso 2º).

La mujer puede actuar respecto de los bienes de la sociedad conyugal con autorización judicial que deberá darse con conocimiento de causa.

i.3) Caso de la mujer que actúa con mandato general o especial del marido (art. 1751).

La mujer mandataria puede hacerlo en representación del marido o a nombre propio. Si lo hace en representación del marido, está obligando únicamente los bienes sociales y del marido (lo que no hace más que confirmar la regla del artículo 1448). Sólo obligará sus propios bienes si se probare que el acto cedió en su utilidad personal (art. 1751 inc. 1º).

Si la mujer mandataria contrata a su propio nombre regirá lo dispuesto en el artículo 2151. Así lo establece el artículo 1751 inciso 2º. Ello significa que sólo obliga sus bienes propios.

Según René Ramos con la modificación que la ley Nº 18.802 introdujo al artículo 1739, habría otra posibilidad de que la mujer pueda intervenir en la administración de los bienes sociales. La ley 18.802 reemplazó el artículo 1739. Dice el inciso 4º: "Tratándose de bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges quedarán a cubierto de toda reclamación que éstos -los cónyuges- pudieran intentar fundada en que el bien es social o del otro cónyuge, siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la entrega o tradición del bien respectivo". Ejemplo: un tercero compra a una mujer casada un refrigerador, un piano o un televisor, y se le hace la correspondiente tradición. Esos bienes son sociales y por ende la mujer no podía disponer de ellos. Por la misma razón, tales ventas son inoponibles a la sociedad conyugal, y el marido podría reivindicarlos. Sin embargo, el Código, con el claro propósito de proteger a los terceros de buena fe que contrataron con la mujer, establece que "quedarán a cubierto de toda reclamación que éstos pudieren intentar fundada en que el bien es social". En el fondo, con esta frase "quedarán a cubierto de toda reclamación" presume de derecho que el bien era de la mujer y que por lo mismo podía venderlo.

Para que opere esta situación tan excepcional, se deben cumplir los siguientes requisitos que indica la norma: i) que se trate de bienes muebles; ii) que el tercero esté de buena fe, esto es que no sepa que el bien es social; iii) que se haya efectuado la tradición del bien; y iv) que no se trate de bienes sujetos a régimen de inscripción, pues sí así fuere y el bien está inscrito a nombre del marido, desaparece la presunción de buena fe, desde que el tercero tenía la forma de saber que el bien no era de la mujer (art. 1739 inciso 5º). Contrario sensu, si el bien está inscrito a nombre de la mujer -situación muy corriente en el caso de los automóviles- y la mujer lo vende, el tercero adquirente queda a cubierto de toda reclamación del marido. De manera que si la mujer vende, como propios, un automóvil o acciones de una sociedad anónima -todos bienes sujetos a régimen de inscripción- tal venta es inoponible a la sociedad y el marido podría reivindicarlos, siempre que tales bienes se encontraren inscritos a nombre del marido. Si están inscritos a nombre de la mujer, no cabe la acción reivindicatoria del marido.

3.5.2 Administración de los bienes propios de la mujer

Dentro de la administración ordinaria de la sociedad conyugal, es necesario distinguir la administración de los bienes sociales y la administración de los bienes propios de la mujer.

De acuerdo al artículo 1749 "el marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales **y los de su mujer**; sujeto empero, a las obligaciones y limitaciones que por el presente Título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales" (inc. 1º). En seguida, al reglamentar en el artículo 1754 la enajenación de los bienes propios de la mujer, se señala que "La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis". Estas dos normas dejan perfectamente perfilada la idea de que es el marido quien administra los bienes propios de la mujer sin que ella tenga más facultades que autorizar a su marido en ciertos casos.

a) Sanción para el caso que la mujer contraviniera la norma del artículo 1754 inciso final.

Hay controversia respecto de la sanción que se sigue en el caso de contravenirse por la mujer el inciso final del artículo 1754. Así, para Fernando Rozas, es la nulidad absoluta, "ya que el inciso final del artículo 1754 es una disposición prohibitiva. Si la enajenación la hace la mujer a través de una compraventa, ésta es nula por disponerlo así el artículo 1810, que prohíbe la compraventa de cosas cuya enajenación esté prohibida por la ley; y ese es el caso del inciso final del artículo 1754".

Pablo Rodríguez G., sostiene que "para determinar que tipo de nulidad corresponde aplicar en caso de que la mujer enajene, grave, dé en arrendamiento o ceda la tenencia de sus bienes propios que administra el marido, debe precisarse, previamente, si el inciso final del artículo 1754, en el día de hoy, es una norma prohibitiva o imperativa" y agrega por una serie de razones que da que antes de la reforma de la ley 19.335 dicha disposición era indudablemente una norma prohibitiva, pero con la modificación ha devenido en imperativa y, por ende, la nulidad absoluta ha sido sustituida por la nulidad relativa.

La jurisprudencia ha optado por la nulidad absoluta "la compraventa de derechos hereditarios que recaen en un inmueble perteneciente a la mujer casada en sociedad conyugal y hecha por ésta, sin la intervención del marido, adolece de nulidad absoluta. El inciso final del artículo 1754 del C. Civil prohíbe a la mujer gravar, enajenar o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido y por lo mismo, tratándose de una ley prohibitiva, su infracción produce la nulidad absoluta del negocio que la contraviene, por mandato de los artículos 10, 1466 y 1682 del C. Civil. Esta sanción aparece más conforme con los principios generales de la clasificación de las leyes, pues el artículo 1754 inciso final, no permite a la mujer enajenar por sí sola sus bienes inmuebles bajo ningún pretexto" (Corte de Concepción, sentencia de 28 de septiembre de 1994, causa rol 14-94). La misma sentencia agregó que "la mujer que interviene en el contrato nulo por falta de concurrencia de su marido no puede menos que saber que es casada y por lo mismo está impedida de demandar la nulidad absoluta del negocio que celebró en estas condiciones".

El fallo tiene un comentario favorable de los profesores Ramón Domínguez Benavente y Ramón Domínguez Águila, quienes expresan que comparten la tesis de la nulidad absoluta, por varias razones: a) la regla de la nulidad relativa del artículo 1757 no cabe aplicarla, porque dicha norma sanciona con nulidad relativa la falta de cumplimiento de requisitos del artículo 1754, pero el inciso final del artículo 1754, no establece requisito alguno, "sino una enfática orden: la mujer no puede celebrar actos de enajenación, gravamen o arrendamiento de sus bienes raíces. Sólo puede hacerlo

en la hipótesis del artículo 145 (debe entenderse 138, con el cambio de numeración que introdujo la ley 19.335); b) el artículo 1754 contiene requisitos para aquellos casos en que es el marido quien celebra el negocio y ese requisito consiste en contar con la voluntad de la mujer. Luego la nulidad relativa se produce cuando es el marido quien celebre el negocio sin el consentimiento de su mujer. Pero en el caso que nos preocupa el acto lo celebra la mujer; c) finalmente, la nulidad relativa del artículo 1757, está establecida en interés de la mujer y no de su marido, "a diferencia de lo que ocurría bajo el imperio del antiguo artículo 1684 que entendía conferida la acción de nulidad relativa, por incapacidad de la mujer casada en sociedad conyugal, al marido, a ella y a sus herederos y cesionarios. Pues bien -continúa el comentario de los profesores Domínguez- si ahora la nulidad relativa del artículo 1757 se concede a la mujer, no es posible aplicarla para el caso en que sea ella quien enajene sus bienes sin intervención del marido, porque se daría el absurdo de que quien concurre en el vicio sería el titular de la acción..."

b) Fundamento de esta administración

La razón de esta situación no es, la incapacidad de la mujer, ya que ésta, desde la entrada en vigencia de la Ley 18.802, es plenamente capaz. El fundamento según René Ramos y Pablo Rodríguez debemos buscarlo en el hecho de que los frutos de los bienes propios de la mujer ingresan al haber absoluto de la sociedad conyugal (art. 1725 Nº 2) y por ello son administrados por el marido, o en otras palabras la mujer pierde la administración de su bienes propios porque el marido adquiere un derecho legal de goce respecto de todos esos bienes.

c) Facultades del marido en esta administración

Las facultades que tiene el marido en la administración de estos bienes son más limitadas que respecto de los bienes sociales. Ello se explica, pues aquí está administrando bienes ajenos.

d) Limitaciones a las facultades del marido en esta administración

Las limitaciones a la administración del marido dicen relación con los siguientes actos:

- d.1) Aceptación o repudiación de una herencia o legado;
- d.2) Aceptación o repudiación de una donación;
- d.3) Nombramiento de partidario en bienes que tiene interés la mujer.
- d.4) Provocación de la partición en bienes en que tiene interés la mujer.
- d.5) Enajenación de los bienes muebles de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie.
- d.6) Arriendo o cesión de la tenencia de bienes raíces más allá de 5 u 8 años, según se trate de predios urbanos o rústicos.
- d.7) Enajenación o gravamen de los bienes raíces de la mujer.

d.1) Aceptación o repudiación de una herencia o legado deferida a la mujer.

La ley 19.585 introdujo un inciso final al artículo 1225, que contiene esta limitación: "El marido requerirá el consentimiento de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal para aceptar o repudiar una asignación deferida a ella. Esta autorización se sujetará a lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 1749".

La sanción para el caso que el marido omita esta exigencia es indudablemente la nulidad relativa de esa aceptación o repudiación, por tratarse de la omisión de un requisito establecido en favor de la mujer.

d.2) Aceptación o repudiación de una donación hecha a la mujer.

Requiere también del consentimiento de ésta en atención a lo dispuesto en el artículo 1411 inciso

final: "Las reglas dadas sobre la validez de la aceptación y repudiación de herencias o legados se extienden a las donaciones".

d.3) Nombramiento de partidor en bienes en que tiene interés la mujer.

Esta limitación está contemplada en el artículo 1326. Dice el inciso 1º: "Si alguno de los coasignatarios no tuviere la libre disposición de sus bienes, el nombramiento de partidor, que no haya sido hecho por el juez, deberá ser aprobado por éste". Y agrega en el inciso 2º: "Se exceptúa de esta disposición la mujer casada cuyos bienes administra el marido; *bastará en tal caso el consentimiento de la mujer*, o el de la justicia en subsidio".

Si se incumple esta regla hay nulidad relativa, por tratarse de la omisión de un requisito que dice relación con el estado o calidad de las partes.

De acuerdo a lo que se acaba de señalar, cuando es el marido quien pide el nombramiento de partidor en bienes de su mujer debe hacerlo con el consentimiento de ésta. La pregunta que cabe formular es si la mujer puede por sí sola, solicitar el nombramiento de partidor. A juicio de Ramos ello es perfectamente posible dado que desde que entró en vigencia de la ley Nº 18.802, es plenamente capaz para intentar acciones judiciales y es sabido que la solicitud de designación de partidor es la forma de hacer efectiva la acción de partición.

d.4) Provocación de la partición de bienes en que tiene interés la mujer.

De acuerdo al artículo 1322 quienes administran bienes ajenos por disposición de la ley, no podrán proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tengan parte sus pupilos, sin autorización judicial (inc 1º). El inciso 2º contempla la situación especial de la mujer casada: "Pero el marido no habrá menester esta autorización para provocar la partición de los bienes en que tenga parte su mujer: *le bastará el consentimiento de su mujer*, si esta fuera mayor de edad y no estuviere imposibilitada de prestarlo, o el de la justicia en subsidio".

Debe tenerse presente que esta limitación rige para "provocar" la partición. Por ello no opera si la partición se hace de común acuerdo, en conformidad al artículo 1325, pues en tal caso el marido no está "provocando" la partición. Tampoco rige la limitación si la partición la pide otro comunero.

La sanción a la falta de consentimiento de la mujer es la nulidad relativa (art. 1682 inc. final en relación con el art. 1348).

La mujer según Ramos puede pedir por sí sola la partición de los bienes en que tenga interés. Llega a esta conclusión en atención a las razones dadas para el nombramiento de partidor.

d.5) Enajenación de bienes muebles que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie.

Esta limitación está contenida en el artículo 1755: "Para enajenar o gravar otros bienes de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie, bastará el consentimiento de la mujer, que podrá ser suplido por el juez cuando la mujer estuviere imposibilidad de manifestar su voluntad".

Cuando la norma habla de "otros bienes" hay que entenderlo en relación con lo que se dice en el artículo anterior, que está referido a los bienes inmuebles. De consiguiente, está claro que estos "otros bienes" son muebles.

El artículo 1755, se refiere a dos situaciones diferentes: i) enajenación de bienes muebles que el marido esté obligado a restituir en especie; y ii) enajenación de bienes muebles que el marido pueda estar obligado a restituir en especie.

i) El marido **está obligado** a restituir en especie, los bienes muebles de la mujer que fueron excluidos de la sociedad conyugal en conformidad al artículo 1725 Nº 4 inciso 2º.

ii) El marido **puede estar obligado** a restituir en especie aquellos bienes muebles que la mujer aporta en las capitulaciones matrimoniales al matrimonio, debidamente tasados para que el marido

se los restituya en especie o en valor a elección de la mujer. Tal estipulación en las capitulaciones matrimoniales parece perfectamente lícita, de acuerdo al artículo 1717.

Si la mujer no prestare su consentimiento para la enajenación de estos bienes, tal enajenación adolecería de nulidad relativa, según lo establece el artículo 1757. Y podría ser alegada por la mujer, sus herederos o cesionarios, en el plazo que esa misma disposición contempla.

d.6) Arrendamiento o cesión de la tenencia de bienes raíces de la mujer, por más de 5 u 8 años según se trate de predios urbanos o rústicos.

Esta situación está tratada en el artículo 1756: "Sin autorización de la mujer, el marido no podrá dar en arriendo o ceder la tenencia de los predios rústicos de ella por más de ocho años, ni los urbanos por más de cinco, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido".

Un buen ejemplo de acto que ceda la tenencia es el contrato de comodato.

El inciso 2º del artículo 1756, agrega que "es aplicable a este caso lo dispuesto en los incisos 7º y 8º del artículo 1749". La referencia al inciso 7º significa que la autorización de la mujer debe ser específica, y por escrito y que se entiende dada si interviene expresa y directamente, de cualquier modo, en el contrato. Quiere decir también, que la mujer puede dar su autorización personalmente o por medio de mandatario especial cuyo mandato conste por escrito. Y la referencia al inciso 8º implica que en caso de impedimento o de imposibilidad de la mujer para prestar su autorización, opera la autorización judicial subsidiaria. Algunos critican esto en orden a que no resulta lógica la autorización supletoria de la justicia en el caso de negativa de la mujer desde que, después de todo, se trata de bienes raíces de ella. Ramos no comparte tal crítica pues es cierto que se trata de bienes raíces de la mujer, pero de no arrendarse, el perjuicio es de la sociedad conyugal, ya que las rentas de arriendo ingresan al activo absoluto de esa sociedad conyugal (art. 1725 Nº 2).

La sanción al incumplimiento de esta norma es la inoponibilidad para la mujer de los contratos de arrendamiento o de aquellos en que se cede la tenencia, en lo que excedan de los 5 u 8 años. Así lo dice el artículo 1757, inciso 1º, parte final. El inciso 2º agrega que la acción de inoponibilidad le corresponde a la mujer, herederos o cesionarios.

d.7) Enajenación o gravamen de bienes raíces propios de la mujer.

Esta situación está tratada en el artículo 1754: "No se podrán enajenar ni gravar los bienes raíces de la mujer, sino con su voluntad" (inc. 1º).

El inciso 2º del artículo 1754 establece que: "la voluntad de la mujer deberá ser específica y otorgada por escritura pública, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el acto. Podrá prestarse, en todo caso, por medio de mandato especial que conste de escritura pública".

No requiere la norma mayor comentario, puesto que casi es copia de la del artículo 1749 ya estudiada. Deberá sí tenerse presente que, en este caso, el mandato deberá constar siempre por escritura pública.

El inciso 3º del artículo 1754 establece que: "Podrá suplirse por el juez el consentimiento de la mujer cuando ésta se hallare **imposibilitada** de manifestar su voluntad". Se destaca "imposibilitada" para destacar que si la mujer se opone, no cabe la autorización judicial supletoria, porque la disposición no la contempla. Y es lógico porque después de todo, se trata de un bien de la mujer.

e) Autorización supletoria de la justicia para el caso que el marido se oponga a la enajenación de un bien propio de la mujer

El art. 138 bis dice que "Si el marido se negare injustificadamente a ejecutar un acto o a celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, el juez podrá autorizarla para actuar por sí misma, previa audiencia a la que será citado el marido" (la Ley 19.968, sobre Tribunales de Familia, dio a esta norma este texto). De manera que si la mujer quiere enajenar o gravar un bien raíz propio, y el marido se opone, puede recurrir a la justicia, para que ésta lo autorice.

Al obrar la mujer autorizada por la justicia por negativa del marido, "sólo obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios reservados o especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no obligará el haber social ni los bienes propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieren reportado del acto" (art. 138 bis, inc. 2º).

Si el marido está impedido para dar la autorización (impedimento que no sea de larga o indefinida duración, pues en caso contrario entran a operar las reglas de la administración extraordinaria) la mujer puede solicitar autorización al juez, que la dará con conocimiento de causa, si de la demora se siguiere perjuicio. En este caso, la mujer "obliga al marido en sus bienes y en los sociales de la misma manera que si el acto fuera del marido; y obliga además sus bienes propios, hasta concurrencia del beneficio particular que reportare del acto" (art. 138 incisos 2º y 3º).

f) El marido es quien realiza la enajenación

No obstante tratarse de bienes propios de la mujer, quien comparece enajenando o gravando es el marido en su condición de administrador de los bienes de su mujer. Esta última sólo presta su consentimiento en los términos que señala el artículo 1754.

De acuerdo a lo que se acaba de decir, deberá dejarse claramente establecido que el marido comparece como administrador de los bienes de su mujer. Sería erróneo expresar que concurre en representación legal de su mujer, porque esa representación cesó con la ley Nº 18.802, ya que siendo la mujer plenamente capaz no requiere de representante legal. Por ello, esa ley modificó el artículo 43 eliminando al marido como representante legal de su mujer.

g) Sanción a la falta de autorización de la mujer

La enajenación o gravamen de los bienes raíces propios de la mujer, sin su consentimiento, trae consigo su nulidad relativa. Así lo establece el artículo 1757, disposición que agrega que la acción de nulidad compete a la mujer, sus herederos o cesionarios; que el cuadrienio para impetrarla se contará desde la disolución de la sociedad conyugal, o desde que cese la incapacidad de la mujer o de sus herederos; y que, en ningún caso, se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la celebración del acto o contrato.

h) Casos en que la mujer durante la sociedad conyugal puede celebrar actos sobre sus bienes propios administrados por el marido.

Dice el art. 1754 inciso final: "La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, *sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis*". Respecto de estas dos situaciones de excepción vale lo dicho al estudiar la enajenación o gravamen de los bienes raíces propios de la mujer.

3.6 Administración Extraordinaria de la Sociedad Conyugal.

El artículo 138, en su inciso 1º señala que "si por impedimento de larga o indefinida duración, como el de interdicción, el de prolongada ausencia, o desaparecimiento, se suspende la administración del marido, se observará lo dispuesto en el párrafo 4º del Título De la Sociedad conyugal". Y el párrafo 4º del Título de la Sociedad Conyugal, trata "De la administración extraordinaria de la sociedad conyugal". Quiere decir entonces, que la administración extraordinaria de la sociedad conyugal es la que procede en los casos en que por incapacidad o larga ausencia del marido éste no puede ejercerla.

Está tratada, en el párrafo 4º del Título XXII del Libro IV, artículos 1758 y siguientes del Código. La

primera de estas normas dice: "La mujer que en el caso de interdicción del marido, o por larga ausencia de éste sin comunicación con su familia, hubiere sido nombrada curadora del marido, o curadora de sus bienes, tendrá por el mismo hecho la administración de la sociedad conyugal".

"Si por incapacidad o excusa de la mujer se encargaren estas curadurías a otra persona, dirigirá el curador la administración de la sociedad conyugal".

La administración extraordinaria ha sido definida como "la que ejerce la mujer como curadora del marido o de sus bienes por incapacidad o ausencia de éste, o un tercero en el mismo caso" (Arturo Alessandri).

Lo que tipifica la administración extraordinaria es que la ejerza un curador del marido o de sus bienes, que puede o no puede ser la mujer. Lo normal será que la curadora sea la mujer y por ello le corresponda la administración extraordinaria.

3.6.1 Casos en que tiene lugar la administración extraordinaria.

Tiene lugar cuando se le ha designado curador al marido lo que puede ocurrir por alguna de las siguientes razones:

- a) Por ser menor de 18 años;
- b) Por haber sido declarado en interdicción por demencia, prodigalidad o sordomudez (previo a ello tendrá que existir la resolución judicial que declare la interdicción); y
- c) Por encontrarse ausente, en los términos del artículo 473.

3.6.2 La administración extraordinaria no requiere de decreto judicial que la confiera.

Cumplidos los requisitos recién señalados, y discernida la curatela, (el discernimiento supone que se ha rendido la fianza o caución y realizado el inventario solemne: art. 374), el curador asume la administración extraordinaria de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.

3.6.3 Casos en que la administración extraordinaria le corresponde a la mujer.

Ello ocurre cuando ha sido designada curadora de su marido, situación que puede darse respecto del marido:

- a) Demente (artículos 462 Nº 1, 463 y 1758);
- b) Sordomudo (art. 470 en relación con artículos 462 Nº 1, 463 y 1758);
- c) Menor de edad, desde que ninguna norma incapacita a la mujer para ser curadora de su marido en este caso; y
- d) Ausente (artículo 475, en relación con artículos 83, 462 Nº 1, 463 y 1758).

3.6.4 Casos en que la administración extraordinaria corresponde a un tercero.

La administración extraordinaria va a corresponder a un tercero, cuando sea designado curador del marido, lo que puede ocurrir en alguno de los siguientes supuestos:

- a) En el caso de incapacidad o excusa de la mujer para servir ella el cargo de curadora de su marido

(art. 1758 inciso 2º);

b) Cuando el marido está declarado en interdicción por disipación, pues ningún cónyuge puede ser curador del otro declarado disipador (art. 450).

3.6.5 Derecho de la mujer que no quiere asumir la administración extraordinaria.

Si la mujer no deseara o no pudiese asumir la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, ella va a corresponder a un tercero: al curador que se designe al marido. La ley ha supuesto que ello pueda incomodar a la mujer desde que será este tercero, como administrador de la sociedad conyugal, el que administrará incluso los bienes propios de la mujer. Por ello, el artículo 1762, la faculta para pedir en este caso, la separación judicial de bienes.

3.6.6 Facultades con que se ejerce la administración extraordinaria de la sociedad conyugal.

Para estudiar las facultades con que se realiza la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, es necesario distinguir si la administración la tiene un tercero; o la tiene la mujer.

3.6.7 Administración extraordinaria por un tercero

Cuando la administración extraordinaria la tiene un tercero, se trata simplemente de un curador que está administrando bienes ajenos y por ello, no la ejerce de acuerdo con este párrafo 4º del título XXII del Código Civil sino en conformidad a las reglas propias de los tutores y curadores, establecidas en el título XXI del Libro I, artículos 390 al 427, y en los artículos 487 al 490 en el caso del marido ausente.

3.6.8 Administración extraordinaria hecha por la mujer

Cuando la administración la tiene la mujer (no obstante que como hemos visto la va a tener por ser curadora del marido), no se aplican las reglas de la curaduría de bienes, sino las especiales contempladas en el Libro IV, título XXII, párrafo 4º, artículos 1759, 1760 y 1761. De acuerdo a estas reglas es necesario hacer una nueva distinción:

a) Administración de los bienes sociales.

La regla está contenida en el inciso 1º del artículo 1759: "La mujer que tenga la administración de la sociedad, administrará con iguales facultades que el marido".

Las limitaciones que tiene la mujer en esta administración, son las siguientes:

- Para enajenar o gravar voluntariamente o prometer gravar o enajenar bienes raíces sociales, requiere de autorización judicial con conocimiento de causa (art. 1759 inciso 2º).
- Para disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, requiere de autorización judicial, dada con conocimiento de causa (art. 1759 inciso 3º). Nótese que la limitación se refiere a los "bienes sociales" en general, por lo que quedan comprendidos tanto los muebles como inmuebles. No se requiere, sin embargo, de la autorización, para hacer donaciones de poca monta, atendidas las fuerzas del haber social (art. 1759 inciso 3º, parte final, en relación con el artículo 1735).
- Para constituirse en aval, codeudora solidaria, fiadora u otorgar cualquier otra caución respecto de terceros, requiere también de autorización judicial con conocimiento de causa (art. 1759 inciso 6º).
- Para dar en arriendo o ceder la tenencia de bienes raíces sociales, por más de cinco u ocho años

según se trate de predios urbanos o rústicos, respectivamente, la mujer requiere de autorización judicial, previa información de utilidad (art. 1761).

a.1) Sanción para el caso que la mujer realice algunos de los actos recién señalados, prescindiendo de la autorización judicial

En los casos 1 y 2, la sanción es la nulidad relativa, correspondiendo la acción al marido, sus herederos o cesionarios y corriendo el cuadrienio para pedir la nulidad desde que ocurrió el hecho que motivó la curaduría, no pudiendo demandarse la nulidad en ningún caso pasados diez años desde la celebración del acto o contrato (art. 1759 inciso 4º y 5º).

En el caso 3, la sanción es que la mujer que otorga esas cauciones en beneficio de terceros, sólo obliga sus bienes propios y los que administra en conformidad a los artículos 150, 166 y 167. No obliga los bienes sociales (art. 1759 inciso 6º).

Finalmente, en el caso de contratos de arriendo o que impliquen la cesión de la tenencia de un bien inmueble por plazos superiores a los indicados, sin autorización judicial, la sanción es la inoponibilidad al marido o sus herederos de esos contratos más allá de los plazos indicados (art. 1761 inciso 1º, parte final).

a.2) Bienes que obliga la mujer administradora de la sociedad conyugal

El artículo 1760 señala que "todos los actos y contratos de la mujer administradora, que no le estuvieren vedados por el artículo precedente, se mirarán como actos y contratos del marido, y obligarán en consecuencia a la sociedad y al marido; salvo en cuanto apareciere o se probare que dichos actos y contratos se hicieron en negocio personal de la mujer".

b) Administración de los bienes propios del marido

Respecto de la administración de los bienes propios del marido, la mujer los administrará de acuerdo a las reglas dadas para las curadurías. Así lo establece el artículo 1759 inciso final.

La mujer como administradora de la sociedad conyugal, debe rendir cuentas de su administración desde que está actuando en su carácter de curadora del marido o de los bienes de aquél. Por ello y de acuerdo al artículo 415 debe, igual que cualquier otro tutor o curador, rendir cuenta.

3.6.9 Término de la administración extraordinaria

De acuerdo al artículo 1763: "cesando la causa de la administración extraordinaria de que hablan los artículos precedentes, recobrará el marido sus facultades administrativas, previo decreto judicial".

3.7 Disolución de la Sociedad Conyugal.

La sociedad conyugal, se disuelve por las causales contempladas en el artículo 1764. Las causales son taxativas; no pueden las partes establecer otras:

3.7.1 Clasificación de las causales

Las causales se pueden clasificar en dos grupos:

a) Aquellas en que la sociedad conyugal se disuelve por vía de consecuencia, por haberse extinguido el matrimonio. Así acontece con las causales 1, 5 y 6 art. 1764); y

b) Aquellas otras en que la sociedad conyugal, se extingue por vía principal, lo que significa que termina no obstante continuar el matrimonio (causales 2, 3, 4, 7 y 8 art. 1764).

La distinción es importante, porque cuando se extingue por vía principal, los cónyuges continúan casados en régimen de separación total de bienes.

3.7.2 Causales

a) Muerte natural de uno de los cónyuges.

La muerte natural de uno de los cónyuges, constituye la forma normal de disolver el matrimonio y, por vía de consecuencia, la sociedad conyugal.

Cuando el art. 1764 Nº 1 dice que la sociedad conyugal termina por “la disolución del matrimonio” hay que entender que se está refiriendo a la muerte natural, pues la muerte presunta está en el numeral 2º y la nulidad está en el numeral 4º. Hoy con la ley 19.947 puede decirse que también en el número 1 se incluye el divorcio.

b) Decreto que concede la posesión provisoria o definitiva de los bienes del cónyuge desaparecido.

Cuando desaparece una persona, sin que se tengan noticias de su paradero, se puede solicitar judicialmente la muerte presunta. Hay que distinguir tres etapas en relación con la suerte que siguen los bienes:

- Etapa del simple desaparecimiento, mera ausencia (5 años contados desde la fecha de las últimas noticias o 6 meses en los casos de los números 6, 7 y 8 del artículo 81);
- Etapa del decreto de posesión provisoria de los bienes del desaparecido; y
- Etapa del decreto de posesión definitiva.

La sociedad conyugal se disuelve normalmente, con el decreto que concede la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Así lo dice el artículo 84, en su primera parte: “En virtud del decreto de posesión provisoria, terminará la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales, según cual hubiere habido con el desaparecido...”. Hemos dicho que esta es la situación normal y ello, porque, por excepción, en algunos casos no se concede la posesión provisoria sino directamente la posesión definitiva.

El matrimonio termina por la muerte presunta en los casos del art. 43 de la nueva Ley de Matrimonio Civil.

c) Sentencia de separación judicial.

Esta causal está contemplada en el artículo 1764 Nº 3, en el texto dado por la ley 19.947, y en el artículo 34 de la actual Ley de Matrimonio Civil: “Por la separación judicial termina la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubiere existido entre los cónyuges...”.

El artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil establece que “la reanudación de la vida en común, luego de la separación judicial, no revive la sociedad conyugal ni la participación en los gananciales, pero los cónyuges podrán pactar este último régimen en conformidad con el artículo 1723 del Código Civil”.

El artículo 178 del Código Civil, en el texto dado por la ley 19.947, expresa que “A la separación judicial se aplicará lo dispuesto en los artículos 160 y 165”. La referencia al artículo 165 significa que la separación es irrevocable y no podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial.

d) Sentencia de separación total de bienes.

Esta causal también está contemplada en el artículo 1764 Nº 3. Por su parte el artículo 158 establece que "Una vez decretada la separación, se procederá a la división de los gananciales y al pago de las recompensas...".

En conformidad al artículo 165 "la separación efectuada en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley es irrevocable y no podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges, ni por resolución judicial".

e) Sentencia que declara la nulidad del matrimonio.

Está establecida en el artículo 1764 Nº 4. Esta situación se va a producir únicamente cuando el matrimonio que se anula sea putativo, pues en caso contrario -matrimonio simplemente nulo- las partes en virtud del efecto propio de la nulidad (art. 1687) vuelven al estado anterior al matrimonio, con lo que viene a resultar que como no hubo matrimonio, no hubo tampoco sociedad conyugal y, por ello, mal podría disolverse.

f) Sentencia de divorcio.

La sentencia firme de divorcio al poner término al matrimonio (art. 42 Nº 4 de la Ley de Matrimonio Civil), ha pasado a ser causal de disolución de la sociedad conyugal.

g) Pacto de participación en los gananciales, celebrado en conformidad al Título XXII-A del Libro Cuarto.

Esta causal fue introducida por la ley 19.335.

En conformidad al artículo 1792-I inc. 2º, los cónyuges pueden, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1723, sustituir el régimen de sociedad conyugal por el régimen de participación en los gananciales.

Con anterioridad a la ley 19.335, el objetivo único del pacto del artículo 1723, era la substitución del régimen de sociedad conyugal por el de separación total de bienes. Hoy, sirve también para reemplazar el régimen de sociedad conyugal por el de participación en los gananciales. Y no hay otra forma de hacerlo que cumpliendo con las solemnidades y requisitos que esta norma establece y que veremos en el número siguiente.

En la misma escritura en que se pacte la participación en los gananciales, los cónyuges pueden proceder a liquidar la sociedad conyugal o celebrar otros pactos lícitos (art. 1723 inc. 3º).

h) Pacto de separación total de bienes celebrado en conformidad al artículo 1723.

Esta causal de disolución está contemplada en el artículo 1764 Nº 5.

3.7.3 Efectos de la disolución de la sociedad conyugal

Disuelta la sociedad conyugal, se producen los siguientes efectos:

- **Se genera entre los cónyuges o, en su caso, entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido, un estado de indivisión.** La sociedad conyugal no constituye una comunidad, entre otras razones, porque la comunidad se viene a producir al momento de su disolución. Y en efecto así es, extinguida la sociedad conyugal, se forma una comunidad entre los cónyuges o, si la sociedad se ha disuelto por muerte de uno de ellos, entre el sobreviviente y los herederos del difunto. Es una comunidad a título universal, pues recae sobre un patrimonio, con un activo y un pasivo. En el activo se contienen todos los bienes que eran sociales incluyendo los bienes reservados, los frutos de las cosas que administraba la mujer de acuerdo a los artículos 166 y 167 y lo que hubiere adquirido con

esos frutos; y en el pasivo, todas las deudas sociales, incluidas las deudas contraídas por la mujer en su patrimonio reservado. Sin embargo, si la mujer renuncia a los gananciales, el activo y el pasivo de su patrimonio reservado no ingresa a la comunidad (art. 150 inciso 7º).

El marido mientras estuvo vigente la sociedad conyugal administró, con amplios poderes, los bienes sociales. Pero producida la disolución, esta situación cambia, pues al generarse una comunidad, los bienes que la integran son administrados por todos los comuneros, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2305 y 2081. De aquí el adagio tan conocido que el marido vive como dueño y muere como socio.

- **Queda fijado irrevocablemente el activo y el pasivo social.** Disuelta la sociedad conyugal queda definitivamente fijado el activo y el pasivo social. El activo queda integrado por todos los bienes que eran sociales al momento de producirse la disolución. De consiguiente, los bienes que cualquiera de los cónyuges pueda adquirir con posterioridad, no integran la comunidad sino que pertenecen al que lo adquirió.

No obstante, si el nuevo bien se adquiere en el período que media entre la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal, la ley presume -presunción simplemente legal- que el bien fue adquirido con bienes sociales, por lo que el cónyuge adquirente deberá la correspondiente recompensa a la sociedad. Esta situación fue establecida por la Ley 18.802, que agregó dos incisos finales al artículo 1739 que dicen lo siguiente: "Se presume que todo bien adquirido a título oneroso por cualquiera de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación, se ha adquirido con bienes sociales" (inc. 6º). "El cónyuge deberá por consiguiente, recompensa a la sociedad, a menos que pruebe haberlo adquirido con bienes propios o provenientes de su sola actividad personal" (inc. 7º).

En cuanto al pasivo, queda también fijado al momento de la disolución y lo integran las deudas que a ese momento eran sociales y las que hubiere contraído la mujer en su patrimonio reservado (salvo que renuncie a los gananciales). Las deudas que un cónyuge contraiga posteriormente son personales suyas y sólo podrán perseguirse en los derechos que le corresponden en los bienes comunes. Por ello, si por una deuda de este tipo, se embargaren bienes comunes, el otro cónyuge (o sus herederos) podrá plantear la correspondiente tercería de dominio, para que se restrinja el embargo a la cuota que corresponda (R.D.J., T. 23, Sec. 1ª, p. 517).

- **Cesa el derecho de goce que la sociedad tenía sobre los bienes de los cónyuges;** Vigente la sociedad conyugal, ingresan al activo absoluto, los frutos de los bienes propios de cada cónyuge (artículo 1725 Nº 2). Sin embargo, ello cambia con la disolución. Dice el artículo 1772: "Los frutos pendientes al tiempo de la restitución, y todos los percibidos desde la disolución de la sociedad, pertenecerán al dueño de las respectivas especies" (inc. 1º). Esta disposición sigue el mismo criterio adoptado en el usufructo, artículo 781. La norma del artículo 1772, sólo es aplicable a los frutos naturales. Respecto de los frutos civiles, la regla a aplicar es el artículo 790, que si bien está establecida en el usufructo es de aplicación general: "Los frutos civiles pertenecerán al usufructuario día por día". Por ello, si la sociedad se disuelve un día 15 de agosto, por ejemplo, la renta de arriendo de un bien raíz propio de uno de los cónyuges, se reparte de la forma siguiente: la correspondiente a los primeros quince días, ingresa la masa común; la proveniente de los últimos 15 días, incrementa el haber del cónyuge dueño.

- **Deberá procederse a la liquidación de la sociedad conyugal.** La ley no obliga a la inmediata liquidación; se puede permanecer en la indivisión todo el tiempo que se desee, sin perjuicio del derecho que asiste a cada comunero para pedir la partición en cualquier tiempo, de acuerdo al artículo 1317. Sin embargo, lo recomendable es liquidar en el menor tiempo posible, con el objeto de evitar confusiones de carácter patrimonial. Recuérdese que hoy día, con la modificación de la Ley 18.802, se presume -artículo 1739 inciso 6º- que los bienes adquiridos por cualquiera de los

cónyuges después de la disolución y antes de la liquidación, han sido adquiridos con bienes sociales, lo que hace recomendable liquidar a la mayor brevedad.

- **La mujer que no hubiere renunciado a los gananciales en las capitulaciones matrimoniales, puede hacerlo ahora.**

3.8 Liquidación de la sociedad conyugal.

3.8.1 Concepto de liquidación

Somarriva dice que la liquidación de la sociedad "es el conjunto de operaciones que tienen por objeto establecer si existen o no gananciales, y en caso afirmativo partirlos por mitad entre los cónyuges, reintegrar las recompensas que la sociedad adeude a los cónyuges o que éstos adeuden a la sociedad; y reglamentar el pasivo de la sociedad conyugal".

La liquidación comprende las siguientes operaciones:

1. Inventario y tasación de los bienes;
2. Formación del acervo común o bruto;
3. Formación del acervo líquido;
4. Partición de los gananciales; y
5. División del pasivo.

3.8.2 Inventario y tasación de los bienes.

a) Facción de inventario

El artículo 1765 señala que "disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente a la confección de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable, en el término y forma prescritos para la sucesión por causa de muerte".

La ley quiere que quede constancia de los bienes y deudas que van a ser objeto de la liquidación. Ello para evitar la ocultación o distracción de bienes en perjuicio de los cónyuges o de sus herederos y de los terceros.

b) Plazo para practicar el inventario.

El artículo 1765, no fija un plazo para proceder a la confección del inventario. Sin embargo, la expresión "se procederá inmediatamente a la confección de un inventario", está demostrando que la intención del legislador es que se haga en el menor tiempo posible.

c) Bienes que deben inventariarse.

El artículo 1765 establece que el inventario debe comprender "todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable (la sociedad)". Ello significa que deben inventariarse los bienes sociales, los bienes propios de cada cónyuge (porque la sociedad usufructuaba de ellos), los bienes reservados (a menos que la mujer o sus herederos renuncien a los gananciales), y todos los bienes que a la disolución de la sociedad se encontrare en poder del marido o de la mujer, ya que de acuerdo al artículo 1739 inciso 1º se presumen sociales. Además el inventario debe comprender las deudas sociales y las provenientes del patrimonio reservado de la mujer (salvo que haya renunciado a los gananciales). No quedan comprendidos los bienes que la mujer administre de acuerdo a los artículos 166 y 167, pero sí los frutos de esos bienes que siguen la misma suerte que los bienes reservados

(arts. 166 Nº 3 y 167, en relación con el 150).

d) Forma de practicar el inventario.

El artículo 1765, señala que el inventario debe hacerse "en el término y forma prescritos para la sucesión por causa de muerte". En otras palabras, se está remitiendo al artículo 1253 que, a su turno, se remite a las normas establecidas para los tutores y curadores, vale decir a los artículos 382 y siguientes. Dice el artículo 382: "El inventario hará relación de todos los bienes raíces y muebles de la persona cuya hacienda se inventaría, particularizándolos uno a uno, o señalando colectivamente los que consisten en número, peso o medida, con expresión de la cantidad y calidad; sin perjuicio de hacer las explicaciones necesarias para poner a cubierto la responsabilidad del guardador". El artículo 384 agrega que: "Debe comprender el inventario aún las cosas que no fueren propias de la persona cuya hacienda se inventaría, si se encontraren entre las que lo son; y la responsabilidad del tutor o curador se extenderá a las unas como a las otras". El hecho de señalar bienes en el inventario no constituye prueba de su dominio. Así lo consigna el artículo 385. Finalmente, si con posterioridad a la confección del inventario aparecieren nuevos bienes, se debe hacer un nuevo inventario (art. 383).

e) Clases de inventario.

El inventario puede ser de dos clases: simple o privado y solemne. El inventario **solemne** es aquel que se efectúa por funcionario competente, previa resolución judicial, con las solemnidades previstas en la ley. Así lo establece el artículo 858 del Código de Procedimiento Civil. El inventario que no reúna estos requisitos será **simple o privado**.

f) Obligación de hacer inventario solemne.

Deberá practicarse inventario solemne cuando entre los partícipes de gananciales hubiere menores, dementes u otras personas inhábiles para la administración de sus bienes. Así lo establece el artículo 1766 inciso 2º. En los demás casos bastará el inventario privado a menos que alguno de los interesados pida inventario solemne (art. 1765 en relación con el art. 1284).

g) Sanción cuando debiendo hacerse inventario solemne, sólo se hace privado.

La sanción consiste en que la persona responsable de esta omisión debe responder de los perjuicios que de ella deriven, debiendo procederse, en el menor tiempo, a regularizar esta situación. Así está establecido en el artículo 1766. Son responsables de esta omisión, todos los partícipes de los gananciales, salvo naturalmente los propios incapaces, que son los únicos que pueden reclamar. Y responden solidariamente de los perjuicios.

Es importante destacar que la omisión del inventario solemne no invalida la liquidación de la sociedad conyugal. Así ha sido fallado reiteradamente.

h) Conveniencia de practicar inventario solemne.

Si bien sólo cuando hay incapaces debe realizarse inventario solemne, en los demás casos no da lo mismo realizar uno u otro puesto que el inciso 1º del artículo 1766 señala que "El inventario y tasación, que se hubieren hecho sin solemnidad judicial, no tendrá valor en juicio, sino contra el cónyuge, los herederos o los acreedores que lo hubieren debidamente aprobado y firmado". De manera que el inventario simple no es oponible a los acreedores que no lo hubieren firmado (Ramos dice que existe variada y reciente jurisprudencia, que han desechado tercerías de dominio interpuestas por la mujer, cuando la tercería se funda en adjudicaciones hechas en una liquidación practicada sin inventario solemne).

Además, la mujer para gozar del beneficio de emolumento, contemplado en el inciso 1º del artículo 1777, esto es, para no responder de las deudas de la sociedad sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales, debe probar el exceso que se le cobra, mediante inventario, tasaciones u otros documentos *auténticos*. Así pues, para ella es fundamental contar con un inventario solemne.

i) Distracción u ocultación dolosa de un bien social.

El artículo 1768 sanciona al cónyuge o sus herederos que dolosamente ocultaren o distrajeran algún bien de la sociedad, haciéndolos perder su porción en la misma cosa y obligándolos a restituirla doblada. Textualmente dice: "Aquél de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y se verá obligado a restituirla doblada".

Ejemplo: el marido oculta 100 acciones del Banco de Chile. La sanción sería que dicho cónyuge pierde su derecho a las acciones y está obligado a restituirlas dobladas.

"Ocultar" implica esconder la cosa y "distracer" apropiársela y disponer de ella.

Alessandri estima que la acción que tiene el cónyuge inocente en el caso del art. 1768 prescribe de acuerdo al artículo 2515, por constituir esa disposición la regla general. En cambio, Somarriva, piensa que por tratarse de un hecho ilícito debe aplicarse el plazo de prescripción de 4 años contemplado en el artículo 2332. A Ramos le parece más jurídica esta última posición.

j) Tasación de bienes.

El artículo 1765 establece que "disuelta la sociedad se procederá inmediatamente a la confección de un inventario y tasación de todos los bienes...". De manera que no basta con que se inventarién los bienes sino que además es necesario tasarlos, es decir, fijarles valor.

Naturalmente que los bienes que se deben tasar son los mismos que han sido inventariados, por lo que en esta parte nos atenemos a lo que dijimos a propósito del inventario. El artículo 1765 se remite en esta materia, a las reglas de la sucesión por causa de muerte; es decir al artículo 1335. Según esta norma la tasación deberá realizarse por peritos, "salvo que los coasignatarios hayan legítima y unánimamente convenido en otra forma, o en que se liciten las especies, en los casos previstos por la ley".

Para hacer la tasación en forma privada se requiere, según el artículo 1766 inc. 2º, que todas las partes sean plenamente capaces. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil, ha venido a complementar y modificar lo dicho por el artículo 1335, al establecer en el artículo 657 que "Para adjudicar o licitar los bienes comunes, se apreciarán por peritos nombrados en la forma ordinaria" (inc. 1º). "Podrá, sin embargo, omitirse la tasación, si el valor de los bienes se fija por acuerdo unánime de las partes, o de sus representantes, aún cuando haya entre aquéllas incapaces, con tal que existan en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes, o que se trate de bienes muebles, o de fijar un mínimo para licitar bienes raíces con admisión de postores extraños" (inc. 2º).

Luego, desde la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil, no se requiere de tasación solemne aun cuando entre los interesados haya personas incapaces, en los siguientes casos:

a. Si sólo se trata de liquidar bienes muebles;

b. Cuando en los autos existen antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes (es frecuente que cuando las partes otorgan una escritura de liquidación, en que adjudican bienes raíces se señale, para justificar el valor que ellos asignan al bien, el avalúo fiscal, insertando al efecto un certificado de avalúo o el último recibo de contribuciones); y

c. Cuando sólo se trata de fijar un mínimo para licitar bienes raíces con admisión de postores

extraños.

La fuerza probatoria del inventario y tasación simples, no es la misma que la del inventario y tasación solemnes, pues el artículo 1766 señala que "el inventario y tasación, que se hubieren hecho sin solemnidad judicial, no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, los herederos o los acreedores que los hubieren debidamente aprobado y firmado". El Código de Procedimiento Civil, en los artículos 895 y siguientes, ha reglamentado la forma de hacer la tasación solemne y si debiendo hacerse tasación solemne se hiciere simple, la sanción es la misma estudiada para el caso del inventario, es decir, los responsables responderán solidariamente de los perjuicios, sin perjuicio de normalizar la situación en el menor tiempo (art. 1766).

3.8.3 Formación del acervo común o bruto.

Sobre la base del inventario se debe formar el acervo bruto o común, que lo integran todos los bienes sociales, reservados de la mujer y propios de cada cónyuge que usufrutuaba la sociedad conyugal. Se debe formar también un cuerpo común de frutos que incluya los frutos provenientes de los bienes recién indicados y también los frutos de los bienes que la mujer administraba de acuerdo a los artículos 166 y 167.

3.8.4 Formación del acervo líquido.

Hecho lo anterior, se deben realizar las siguientes deducciones, para llegar al acervo líquido partible:

a) Retiro de las especies o cuerpos ciertos que pertenezcan a cada cónyuge (art. 1770).

- Cada cónyuge, o sus herederos, tienen derecho a sacar del acervo bruto, sus bienes propios, muebles o inmuebles, corporales o incorporales.
- El retiro se efectúa a título de dueño. Es un simple retiro material. No hay adjudicación porque ésta supone una comunidad previa, lo que no se da en este caso, pues se trata de bienes que han pertenecido exclusivamente al cónyuge que ahora los retira.
- Los bienes se restituyen en el estado en que se encuentran, aprovechando al cónyuge los aumentos naturales que la cosa ha experimentado (los aumentos debidos a la mano del hombre otorgan a la sociedad una recompensa en contra del cónyuge, que se rige por el artículo 1746) y sufriendo sus deterioros, salvo que se deban a dolo o culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso deberá éste resarcirlos (art. 1771).
- Deben restituirse los bienes con sus frutos pendientes al tiempo de la restitución y también los frutos percibidos desde el momento de la disolución (art. 1772 inciso 1º).
- La ley no fija un plazo para la restitución. El artículo 1770, inciso 2º, primera parte, sólo expresa que "La restitución de las especies o cuerpos ciertos deberá hacerse tan pronto como fuere posible después de la terminación del inventario y avalúo".

b) Retiro de los precios, saldos y recompensas que corresponden a cada cónyuge (art. 1770).

Puede ocurrir que la sociedad adeude recompensas a alguno de los cónyuges o éstos a la sociedad. Hay, por así decirlo, una verdadera cuenta corriente entre el cónyuge y la sociedad que será necesario liquidar. Mientras no se haga esta liquidación no se va a saber si el cónyuge respectivo tiene un crédito que hacer efectivo en la partición, o, a la inversa, si es deudor. Por la misma razón, mientras no se practique esta operación, los acreedores de un cónyuge no podrían embargar el crédito que este tiene contra la sociedad. Tampoco podría, el cónyuge exigir el pago de la

recompensa mientras no esté hecha la liquidación.

En definitiva si practicado el balance, éste arroja un saldo acreedor para el cónyuge, hará la respectiva deducción. Si resulta un saldo deudor, quiere decir que él debe a la sociedad conyugal tal saldo, por lo que debe acumularlo imaginariamente -vale decir en valor- de acuerdo al artículo 1769.

Estas deducciones se rigen por las reglas siguientes:

- Las hace efectiva, pagándose directamente con bienes sociales, respetándose el siguiente orden: dinero y bienes muebles y a falta de éstos bienes inmuebles. Así lo dice el artículo 1773: "y las que consistan en dinero, sea que pertenezcan a la mujer o al marido, se ejecutarán sobre el dinero y muebles de la sociedad, y subsidiariamente sobre los inmuebles de la misma".
- Los cónyuges hacen estas deducciones a título de acreedores-comuneros, no a título de propietarios, como ocurría en el retiro de los bienes propios. Por ello, estos retiros constituyen una adjudicación (ya que el pago se ejecuta con bienes que pertenecen en condominio a ambos cónyuges). Y esto es importante para varios efectos: a) porque la nulidad o rescisión de la partición acarrea la nulidad de estas adjudicaciones; b) porque como toda adjudicación, ésta es declarativa, no traslativa de dominio.
- Estos pagos deben hacerse dentro del año siguiente a la terminación del inventario y avalúo, plazo que puede ampliarse o restringirse por el partidor (art. 1770 inc. 2º).
- Respecto de estos retiros, la ley otorga a la mujer algunos beneficios especiales: a) Le permite hacer estas deducciones antes que el marido (art. 1773 inc. 1º); b) Si los bienes sociales fueren insuficientes, podrá hacer efectivo su crédito sobre los bienes propios del marido, elegidos de común acuerdo o, a falta de acuerdo, por el partidor (art 1773 inc. 2º). En este caso, no hay adjudicación sino una dación en pago (título traslativo); y c) La mujer es respecto de su marido una acreedora que goza de un privilegio de cuarta clase (art. 2481 Nº 3).

c) Deducción del pasivo social.

Del acervo bruto podrá deducirse también el pasivo social. Se "**podrá**" deducir el pasivo del acervo bruto, porque ello no es obligatorio para las partes, pudiendo si así lo desean, prescindir del pasivo y repartir sólo el activo. El artículo 1774 señala que "establecidas las antedichas deducciones -y entre estas no está el pasivo- el residuo se dividirá por mitad entre los cónyuges". Si al momento de la liquidación no se rebaja el pasivo, los acreedores sociales podrán de todas formas hacer efectivos sus créditos en la forma dispuesta en los artículos 1777 a 1779.

Lo conveniente es considerar el pasivo al momento de hacer la liquidación, resolviéndose qué deudas soportará cada cónyuge.

3.8.5 Reparto de los gananciales.

Una vez que se hacen las operaciones anteriores el resto se debe dividir por mitad entre los cónyuges. Así lo establece el artículo 1774.

Hay, sin embargo, algunas excepciones a la regla de reparto por mitad de los gananciales. Ello ocurre en los casos siguientes:

1. Cuando hubiere habido ocultación o distracción dolosa de un bien de la sociedad, caso en que el cónyuge o heredero responsable pierde su porción en la misma cosa y debe restituirla doblada (art. 1768).

2. Cuando en las capitulaciones matrimoniales se hubiere convenido que los gananciales se repartan en otra proporción o si la mujer y el marido han convenido de consuno una distribución distinta a la establecida en la ley una vez disuelta la sociedad conyugal. En estos dos supuestos la pregunta es si el art. 1774 es o no de orden público (véase ¿Puede alterarse, en el hecho, la proporcionalidad del 50% para la división de gananciales". Fernando Fueyo, Revista Derecho Universidad de Concepción, Nº 119, p. 3).

3. Cuando la mujer renunció a los gananciales. Si uno de los herederos de la mujer renunció a su cuota en los gananciales, la porción del que renuncia acrece a la porción del marido (art. 1785).

3.8.6 División del pasivo social.

Esta materia está tratada en los artículos 1777, 1778 y 1779. Es necesario distinguir entre: a) la obligación a las deudas y b) la contribución a las deudas.

a) Obligación a las deudas.

Frente a los terceros el marido es responsable de las deudas sociales. Como administrador de la sociedad conyugal, él contrajo la deuda y él debe responder por la totalidad de la obligación sin que importe que haya o no recibido gananciales (arts. 1749, 1750, 1751). El artículo 1778, en su primera parte, así lo establece: "El marido es responsable del total de las deudas de la sociedad...". Esta situación no cambia por la disolución de la sociedad, de tal suerte que el tercero acreedor puede dirigirse por el total de la deuda sobre todo el patrimonio del marido.

La situación de la mujer es diferente. Ella está obligada frente a terceros exclusivamente hasta lo que recibió a título de gananciales. El artículo 1777 inciso 1º dice que "La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales". De manera que demandada la mujer por una deuda social, puede oponer al acreedor **el beneficio de emolumento** y defenderse alegando que ella no responde de la deuda sino hasta el monto de lo que recibió a título de gananciales.

b) Contribución a las deudas.

El problema de la contribución a la deuda consiste en determinar en qué medida va a soportar cada cónyuge una deuda social. La respuesta la da el artículo 1778: "El marido es responsable del total de las deudas de la sociedad; salvo su acción contra la mujer para el reintegro de la mitad de estas deudas, según el artículo precedente". De manera que ambos cónyuges soportan el pago de la deuda por mitades. Y la regla es justa, puesto que si el activo se divide por mitad (art. 1774), lo equitativo es que en la misma forma se divida el pasivo (art. 1778).

c) Beneficio de emolumento.

Ha sido definido como "la facultad que tiene la mujer o sus herederos para limitar su obligación y su contribución a las deudas de la sociedad hasta concurrencia de su mitad de gananciales, es decir del provecho o emolumento que obtuvieron en ella" (Alessandri). Está contemplado en el artículo 1777.

Para que la mujer pueda hacer uso de este beneficio sólo deberá probar el exceso que se le cobra, en la forma dispuesta en el inciso 2º del art. 1777, esto es "sea por el inventario y tasación, sea por otros documentos auténticos". La prueba sólo puede consistir en instrumentos públicos -ese es el significado de documentos auténticos según el art. 1699- de manera que no es admisible ni la prueba de testigos ni instrumentos privados, salvo el inventario privado pero sólo respecto del acreedor que lo aprobó y firmó (art. 1766).

La razón que ha tenido la ley para limitar la responsabilidad de la mujer, está en que no ha sido ella quien ha administrado la sociedad conyugal, sino su marido. Es una protección que se le otorga para defenderla de la mala administración del marido.

El beneficio de emolumento no produce una separación de patrimonios. Por ello, los acreedores pueden hacer efectivo su crédito en todos los bienes de la mujer, no sólo en los que haya recibido a título de gananciales.

d) ¿A quién se opone el beneficio de emolumento?

La mujer lo puede oponer a un acreedor de la sociedad (jamás a un acreedor personal suyo), cuando se la demanda por una deuda social; y también lo puede oponer a su marido. Respecto de este último por vía de acción o como excepción. Lo primero ocurrirá cuando ella haya pagado una deuda social de monto superior a su mitad de gananciales, para que el marido le reembolse el exceso. Opondrá el beneficio por vía de excepción, cuando el marido haya pagado una deuda social y demande a la mujer para que le restituya su mitad (art. 1778); la mujer le dirá que nada debe restituir o que sólo debe reembolsar una parte porque lo que se le cobra excede a lo que percibió a título de gananciales.

e) Irrenunciabilidad del beneficio de emolumento.

La mujer no puede renunciar en las capitulaciones matrimoniales a este beneficio (art. 1717) pues como dice Alessandri ello importaría "facultar al marido para obligar los bienes propios de la mujer por las obligaciones de la sociedad". Sin embargo, nada le impide renunciarlo una vez disuelta la sociedad conyugal.

f) Los cónyuges pueden acordar una división de las deudas en una proporción diferente.

Los cónyuges pueden convenir que una deuda social la soporte uno de ellos en su integridad o en una proporción diferente al cincuenta por ciento. Ello es perfectamente posible, y lo aceptan los artículos 1340 y 1359 para los herederos, normas que se aplican al caso de la liquidación de la sociedad conyugal de acuerdo al artículo 1776. Este acuerdo de los cónyuges no obliga a los acreedores según los mismos artículos citados.

g) Pago de una deuda personal.

Cuando la sociedad paga una deuda personal de uno de los cónyuges, tiene un derecho de recompensa en contra de ese cónyuge, para que de esa forma, soporte en definitiva el pago total (art. 1740 N° 3).

h) Pago por uno de los cónyuges de una deuda garantizada con una caución real constituida sobre un bien adjudicado.

Esta situación está tratada en el artículo 1779: "Aquél de los cónyuges que, por el efecto de una hipoteca o prenda constituida sobre una especie que le ha cabido en la división de la masa social, paga una deuda de la sociedad, tendrá acción contra el otro cónyuge para el reintegro de la mitad de lo que pagare; y pagando una deuda del otro cónyuge, tendrá acción contra él para el reintegro de todo lo que pagare".

La explicación es simple: la prenda e hipoteca son indivisibles. De consiguiente, el acreedor va a demandar por el total, en contra del cónyuge a quien se le ha adjudicado la cosa hipotecada o empeñada (arts. 1526 N° 1, 2405, 2408). Tendrá entonces que pagar el total de la deuda, sin

perjuicio de que podrá dirigirse en contra del otro cónyuge, para que le reintegre la mitad que éste tenía que soportar de la deuda.

3.9 Renuncia de los Gananciales.

El artículo 1719, en su inciso 1º, establece que "La mujer, no obstante la sociedad conyugal, podrá renunciar su derecho a los gananciales que resulten de la administración del marido, con tal que haga esta renuncia antes del matrimonio o después de la disolución de la sociedad". Y el artículo 1781 agrega que "Disuelta la sociedad, la mujer mayor o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieren derecho...".

Esta renuncia es un beneficio que la ley da a la mujer (o a sus herederos) que consiste en que verificada esta renuncia, la mujer no responde de las deudas sociales, que sólo podrán ser exigidas y en su integridad al marido, sin derecho de reintegro. Constituye un importante medio de protección que la ley otorga a la mujer para defenderla de la mala administración del marido.

3.9.1 Momento en que se pueden renunciar los gananciales

La mujer puede renunciar los gananciales en dos momentos:

a) En las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio (arts. 1719, 1721). Esta renuncia puede constituir uno de los objetos de las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio. Puede hacerla la esposa menor de edad, pero en ese caso requiere de autorización judicial (art. 1721 inc. 1º).

b) Con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal (art. 1781). El artículo 1781 señala que "disuelta la sociedad, la mujer o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieren derecho". Y agrega "No se permite esta renuncia a la mujer menor, ni a sus herederos menores, sino con aprobación judicial". Como se ve hay perfecta concordancia entre la norma del artículo 1721 con la recién transcrita, pues en ambos casos se permite a las menores de edad renunciar, pero sujeta a la autorización o aprobación judicial.

La renuncia, en este caso, puede hacerse en cualquier momento, desde que se disuelve la sociedad conyugal y hasta mientras no ingrese ningún bien social al patrimonio de la mujer. Así lo dice el artículo 1782 inciso 1º. Ello se explica porque el hecho de recibir bienes a título de gananciales importa la aceptación de los gananciales. Por ello, porque ya se aceptaron, no se pueden renunciar. Cuando la sociedad conyugal se disuelve por haber operado el pacto de separación de bienes establecido en el artículo 1723, puede hacerse la renuncia en la misma escritura pública en que los cónyuges se separan de bienes.

3.9.2 Características de la renuncia de gananciales.

La renuncia a los gananciales presenta las siguientes características:

1. Como toda renuncia, es un acto jurídico unilateral que sólo requiere de la voluntad de la mujer o de sus herederos;
2. La renuncia que se hace después de disuelta la sociedad conyugal es consensual, pues la ley no lo ha sometido a ninguna formalidad especial. La que se hace antes del matrimonio en las

capitulaciones matrimoniales es un acto solemne que requiere de escritura pública (art. 1716);

3. Es un acto puro y simple. Ello se desprende aplicando por analogía el artículo 1227 relativo a la repudiación de las asignaciones testamentarias.

4. Es un acto irrevocable. Así lo establece el artículo 1782 inciso 2º: "Hecha una vez la renuncia, no podrá rescindirse..." Si bien la ley habla de "rescindir", tenemos que entender que lo que quiso decir fue "revocar". Hay casos en que, por excepción, se puede dejar sin efecto:

a) Si la mujer o sus herederos prueban que fueron inducidos a renunciar por engaño. Es un caso de nulidad relativa por existir dolo;

b) Si la mujer o sus herederos prueban que renunciaron por un justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales. Es un caso de nulidad relativa por error;

c) Si la mujer o sus herederos renunciaron violentados por la fuerza. Este caso no está especialmente contemplado, pero resulta de aplicar las reglas generales, contenidas en los artículos 1456 y 1457;

En los casos a) y b), la acción de nulidad prescribe en cuatro años contados desde la disolución de la sociedad (art. 1782 inc. final).

Cuando la causal de nulidad es la fuerza, prescribe en el plazo de 4 años contados desde que la fuerza cesa.

3.9.3 Forma de renunciar los gananciales.

Según Ramos la ley no ha dado ninguna norma especial sobre la forma como deben renunciarse los gananciales. Por ello entiende que la voluntad de la mujer se puede manifestar, como ocurre en la generalidad de los actos jurídicos, en forma expresa o en forma tácita. Será tácita cuando pueda desprenderse inequívocamente de hechos realizados por la mujer. Pone como ejemplo de esta situación, el que la mujer después de disuelta la sociedad conyugal, enajene un bien que era parte de su patrimonio reservado, no obstante que con motivo de la disolución tal bien debe ingresar a la masa común. Por ello, si lo enajena ella sola, con esa conducta está manifestando su voluntad de que el bien no entre a los gananciales lo que implica renunciarlos.

En cambio Pablo Rodríguez dice que "la renuncia debe ser expresa, puesto que ella nunca se presume. Tratándose de un acto abdicativo, es necesario que concurra la voluntad del renunciante, la cual en caso de discusión, deberá acreditarse conforme las reglas generales del derecho".

3.9.4 Efectos de la renuncia de los gananciales.

Cuando se renuncia a los gananciales antes del matrimonio, de todas formas va a haber sociedad conyugal (art. 1719) y de todas maneras, los frutos de los bienes propios de la mujer, ingresarán a la sociedad conyugal, para soportar las cargas de familia (art. 1753). En lo demás, los efectos serán los normales de toda renuncia de gananciales y van a operar a la disolución de la sociedad.

Los efectos normales de la renuncia -hecha antes del matrimonio o después de su disolución- son los siguientes:

1. Los derechos de la sociedad y del marido se confunden aun respecto de los cónyuges (art. 1783). De aquí derivan las siguientes consecuencias:

- a) A la disolución todos los bienes pertenecen al marido, no hay comunidad que liquidar;
- b) La mujer no tiene derecho alguno en el haber social; y
- c) La mujer no responde de parte alguna de las deudas sociales;

2. Los bienes del patrimonio reservado de la mujer le pertenecen a ella exclusivamente, no ingresan a los gananciales (art. 150 inc. 7º). La misma suerte corren los frutos de los bienes que administra separadamente la mujer de acuerdo a los artículos 166 y 167; y

3. La mujer conserva sus derechos y obligaciones a las recompensas e indemnizaciones (art. 1784).

3.9.5 Aceptación de los gananciales.

El Código no ha dado normas sobre la forma en que deben aceptarse los gananciales. Por ello debe concluirse que la aceptación puede hacerla la mujer en forma expresa o en forma tácita. Será expresa cuando la hace en términos explícitos, v. gr. en escritura pública; será tácita, cuando de hechos suyos pueda desprenderse inequívocamente su voluntad de aceptar los gananciales. Ramos cree que debe aplicarse por analogía lo dispuesto para la aceptación de las herencias por el artículo 1241 del Código Civil.

Pablo Rodríguez señala que la aceptación será tácita por ejemplo si la mujer solicita la liquidación de la comunidad.

El derecho de los herederos a renunciar los gananciales es divisible. Así fluye del artículo 1785: "Si sólo una parte de los herederos de la mujer renuncia, las porciones de los que renuncian acrecen a la porción del marido.

3.10 Los Bienes Reservados de la Mujer Casada.

Son bienes reservados de la mujer los que ella adquiere con su trabajo separado de su marido, lo que adquiere con ellos y los frutos de unos y otros. Están tratados en el artículo 150.

3.10.1 Características de los bienes reservados

- 1. Forman un patrimonio especial, con activo y pasivo propios;
- 2. Constituyen un régimen especial de administrar un conjunto de bienes sociales. El hecho de que los administre la mujer no le quita el carácter de sociales. Son sociales porque provienen del trabajo de uno de los cónyuges (art. 1725 Nº 1). Y la mayor prueba de que lo son está en que a la disolución de la sociedad conyugal ingresan a la masa de gananciales, a menos que la mujer o sus herederos renuncien a los gananciales;
- 3. Constituyen una protección que la ley otorga a la mujer que trabaja. Luego son privativos de la mujer;
- 4. Esta institución opera de pleno derecho por la sola circunstancia de que los cónyuges se casen en

régimen de sociedad conyugal y de que la mujer tenga un trabajo separado del marido, es decir, no se requiere resolución judicial alguna;

5. Es una institución de orden público. Por ello la regulación la hace la ley, sin que las partes puedan modificarla. El artículo 150 inciso 2º, emplea la expresión "no obstante cualquier estipulación en contrario". Por la misma razón, la mujer no podría en las capitulaciones matrimoniales renunciar a tener un patrimonio reservado (art. 1717).

3.10.2 Requisitos de los bienes reservados

El artículo 150 inciso 2º establece que: "La mujer casada, que desempeñe algún empleo o que ejerza una profesión, oficio o industria, separados de los de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria y de lo que en ellos obtenga, no obstante cualquier estipulación en contrario...". De aquí se desprende que los requisitos para que nos encontremos frente a esta institución de los bienes reservados, son los siguientes:

a) Trabajo de la mujer.

La única fuente de los bienes reservados es el trabajo de la mujer. Los bienes que la mujer adquiera por otro medio, herencia por ejemplo, no ingresa a este patrimonio, quedando sometidos al derecho común.

b) Trabajo remunerado.

Este requisito es lógico, por cuanto, el artículo 150 inciso 2º, la considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria **"y de lo que en ellos obtenga"**. Luego, su trabajo separado tiene que producirle bienes, tiene que ser remunerado. Las labores domésticas que haga en el hogar o los servicios de beneficencia que realice, no van a generar bienes reservados. Cualquier trabajo remunerado, permanente, accidental, industrial, agrícola, comercial, profesional, lícito o ilícito, público o privado, es fuente de bienes reservados.

c) El trabajo tiene que desarrollarse durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Por esta razón si la mujer trabaja de soltera y adquiere bienes, estos bienes no formarán parte de sus bienes reservados, sino que seguirán la suerte que les corresponda de acuerdo al derecho común. Así, por ejemplo, si de soltera compró un inmueble, éste será bien propio; en cambio, si tiene un automóvil o acciones de un banco, tales bienes ingresarán al activo relativo de la sociedad conyugal (art. 1725 Nº 4).

Para determinar si un bien es reservado hay que estarse al momento en que se prestó el servicio. Así si la mujer de soltera realizó un trabajo, y se lo pagaron cuando ya estaba casada, ese pago no ingresa a los bienes reservados. Y a la inversa, si de casada realizó un trabajo que le es pagado cuando ya la sociedad está disuelta, tal bien es reservado.

Es corriente, que la mujer trabaje algunos años después de casada y en seguida jubile o se retire a las labores propias de su hogar. Ello, sin embargo, no hace que desaparezca el patrimonio reservado. Así lo demuestra el inciso 4º del artículo 150, parte final, que habla de "que ejerce **o ha ejercido** un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido".

d) Trabajo separado de su marido.

De la historia fidedigna del establecimiento de la ley -dice Alessandri- se desprende que "hay trabajo separado de la mujer y del marido siempre que no trabajen en colaboración, aunque reciban

una remuneración común. Y explica que en el Senado, a indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se sustituyó la palabra "distintos", que figuraba en el proyecto de la Cámara de Diputados, por "separados", a fin de expresar mejor la idea manifestada en el primer informe de esa Comisión, según la cual por trabajo separado de la mujer "debe entenderse no solamente aquél que se desempeña por la mujer en una repartición, industria o negocio diverso, sino, también, el que ésta sirva en el mismo negocio, industria o repartición en que trabaje el marido, **siempre que, en este último caso, no haya entre ambos una relación directa, personal y privada de colaboración y ayuda solamente,** sino una efectiva o independiente contratación de servicios con un determinado empleador o patrón, ya sea éste el propio marido o un extraño".

Por la importancia del punto, reproducimos los comentarios de Alessandri: "Para determinar si hay o no trabajo separado de la mujer, no se atiende a si los cónyuges reciben una remuneración separada o única: la forma de remuneración es indiferente; a si se dedican al mismo o a distinto género de actividades ni a si trabajan en el mismo negocio, industria u oficina o en otro diverso, sino exclusivamente **a si hay o no colaboración y ayuda directa, personal y privada entre ellos.** Si la mujer se limita a ayudar al marido en virtud del deber de asistencia que le impone el artículo 131 del C.C., prestándole cooperación en las labores agrícolas, industriales, comerciales o profesionales, si, por ejemplo, atiende el negocio conjuntamente con el marido, despacha a los clientes cuando éste no puede hacerlo, le ayuda a contestar sus cartas, le dactilografía sus escritos o trabaja en colaboración con su marido, como si ambos escriben una obra en común, o si, teniendo una misma profesión, la ejercen de consuno, no cabe aplicar el artículo 150: los bienes que adquiere quedarán sometidos a la administración del marido, de acuerdo con el derecho común (artículos 1725 Nº 1, y 1749). Lo mismo sucederá si es el marido quien coopera en idéntica forma a la industria, comercio o profesión de la mujer. Pero si la mujer no es colaboradora del marido o viceversa, hay trabajo separado y bienes reservados..."

En definitiva, este es un requisito complejo que tendrá que ser ponderado en cada caso por los tribunales.

3.10.3 Activo de los bienes reservados

Los bienes reservados constituyen un patrimonio especial, por lo que, como ocurre en todo patrimonio, nos encontramos con un activo y un pasivo.

Integran el activo de este patrimonio, los siguientes bienes:

a) Bienes provenientes del trabajo de la mujer.

Todas las remuneraciones obtenidas por la mujer en su trabajo separado, ingresan a los bienes reservados. Quedan incluidos los sueldos, honorarios desahucios, indemnizaciones por accidentes del trabajo, pensiones de jubilación, las utilidades que ella obtenga en la explotación de un negocio cualquiera.

b) Bienes que adquiere con el producto de su trabajo.

Lo que la mujer adquiera con el producto de su trabajo, también pasa a formar parte del patrimonio reservado.

Así por ejemplo, si con su trabajo, la mujer compra un departamento, ese departamento es un bien reservado.

c) Frutos del producto del trabajo o de los bienes adquiridos con ese producto.

Los frutos que obtenga la mujer de sus bienes reservados constituyen también un bien reservado.

Ejemplo: si los dineros provenientes de su trabajo, los presta a interés. Este interés es un bien reservado. Lo mismo las rentas de arrendamiento de un bien reservado.

3.10.4 Pasivo de los bienes reservados

Hablar del pasivo de los bienes reservados es lo mismo que decir qué deudas se pueden hacer efectivas en este patrimonio. Durante la vigencia de la sociedad conyugal, se pueden exigir las siguientes obligaciones:

1. Las provenientes de los actos y contratos celebrados por la mujer dentro de este patrimonio (art. 150 inciso 5º).
2. Las provenientes de actos y contratos celebrados por la mujer aunque actúe fuera de los bienes reservados. Esto fluye del artículo 137 inciso 1º: "Los actos y contratos de la mujer casada en sociedad conyugal, sólo la obligan en los bienes que administre en conformidad a los artículos 150, 166 y 167". De manera que, si por ejemplo, la mujer compra un automóvil y se obliga a pagar su precio a plazo, quien se lo vende puede hacer efectivo su crédito en sus bienes reservados, aunque la mujer no haya comprado el automóvil con el producto de su trabajo.
3. Obligaciones provenientes de actos o contratos celebrados por la mujer respecto de un bien propio, autorizada por la justicia por negativa del marido. El inciso 2º del art. 138 bis prescribe que "en tal caso, la mujer sólo obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios reservados o especiales de los artículos 150, 166 y 167...".
4. Obligaciones contraídas por el marido, cuando se pruebe que el contrato celebrado por él cedió en utilidad de la mujer o de la familia común (art. 150, inciso 6º).

a) Casos en que responden bienes ajenos al patrimonio reservado de deudas provenientes de ese patrimonio.

Ello puede ocurrir en dos situaciones:

1. Bienes del marido responden de una deuda contraída por la mujer en su patrimonio reservado.

El inciso 5º del artículo 150 establece que: "Los actos y contratos celebrados por la mujer en esta administración separada, obligarán los bienes comprendidos en ella y los que administre con arreglo a las disposiciones de los artículos 166 y 167, *y no obligarán los del marido sino con arreglo al artículo 161*".

Está claro entonces que la regla es que los bienes del marido no responden por las obligaciones que la mujer contraiga en su patrimonio reservado. La excepción, es que el marido responda con sus bienes, con arreglo al artículo 161, esto es:

- a) Cuando hubiere accedido como fiador o de otro modo, a las obligaciones contraídas por la mujer. Cuando la norma dice "o de otro modo", significa conjunta o solidariamente.
- b) Cuando el marido ha obtenido un beneficio de las obligaciones contraídas por la mujer, comprendiéndose en este beneficio el de la familia común, en la parte en que de derecho haya debido proveer a las necesidades de ésta. En este caso, los bienes del marido van a responder a

prorrata del beneficio del marido o de la familia común.

2. Cuando la mujer tiene bajo su administración bienes de acuerdo a los artículos 166 y 167.

El inciso 5º del art. 150 permite que las obligaciones contraídas por la mujer en su patrimonio reservado, puedan hacerse efectivas en los bienes que separadamente administra de acuerdo a los artículos 166 y 167.

3.10.5 Administración de los bienes reservados.

La administración de los bienes reservados la ejerce la mujer con amplias facultades. La ley la considera para estos efectos como separada de bienes. Así lo establece el artículo 150, inciso 2º: "La mujer casada, que desempeñe algún empleo o ejerza una profesión, oficio o industria, separados de los de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria y de lo que en ellos obtenga...".

La limitación se contiene en la segunda parte del inciso: "pero si fuere menor de dieciocho años, necesitará autorización judicial, con conocimiento de causa, para gravar y enajenar los bienes raíces". En esta parte la ley es absolutamente lógica. Sería absurdo que por el hecho de estar casada la mujer tuviera una capacidad mayor que si fuere soltera (el art. 254 le exige autorización judicial en este caso).

Con la ley Nº 19.935, del año 1994, se ha generado la posibilidad de que algunos bienes del patrimonio reservado de la mujer, sean declarados "bienes familiares", caso en que ya no podrá la mujer enajenarlos ni gravarlos voluntariamente, ni prometerlos gravar o enajenar, sin la autorización de su marido o de la justicia en subsidio (arts. 141, 142 y 144).

3.10.6 Administración de los bienes reservados hecha por el marido.

Hay casos en que la administración de los bienes reservados la tiene el marido:

1. La mujer puede conferir mandato a su marido para que administre. En este caso, se siguen las reglas del mandato. Así lo dice el artículo 162: "Si la mujer separada de bienes confiere al marido la administración de alguna parte de los suyos, será obligado el marido a la mujer como simple mandatario".

2. En el caso de incapacidad de la mujer por demencia o sordomudez el marido puede ser designado su curador y en ese carácter administrar el patrimonio reservado de su mujer, sujetándose en todo a las reglas de los curadores. Si la mujer es menor de edad la solución es distinta, pues el artículo 150 inciso 1º, establece que en ese supuesto la mujer administra su patrimonio. Si la mujer fuere declarada en interdicción por disipación, el marido no podría ser su curador, en conformidad al artículo 450.

Es importante tener presente que en la situación que estamos estudiando, no rige para el marido la incapacidad del artículo 503, que impide a un cónyuge ser curador del otro cuando están separados totalmente de bienes. Ello, porque la prohibición sólo opera para la separación total de bienes, que no es el caso del artículo 150, en que sólo hay separación parcial de bienes.

3.10.7 Prueba de los bienes reservados.

Este es un aspecto de la mayor trascendencia.

Por ser los bienes reservados una institución excepcional, quien alegue la existencia de ese patrimonio y que se actuó dentro de él o que un determinado bien es reservado deberá probarlo.

La prueba puede referirse a dos aspectos:

a) Prueba de la existencia del patrimonio reservado y de que se actuó dentro del mismo.

Esta prueba corresponde a quien alega estas circunstancias.

Puede interesar esta prueba tanto a la mujer, como al marido, como a los terceros que contrataron con ella. A la mujer, porque si demanda, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato celebrado dentro de tal administración, tendrá que probarlo pues, en caso contrario, sería el marido como administrador de la sociedad conyugal, quien debería accionar; al marido, si un tercero lo demanda por una obligación contraída por la mujer, para excepcionarse alegando que tal deuda la contrajo la mujer dentro de su patrimonio reservado por lo que no se pueden dirigir en su contra; y, finalmente, los terceros que contrataron con la mujer tienen un interés evidente en poder probar que la mujer actuó dentro del patrimonio reservado cuando pretendan hacer efectivos sus créditos en bienes de ese patrimonio.

a.1) Presunción de derecho del inciso 4º del art. 150.

La ley considera vital facilitar la prueba a los terceros pues, en caso contrario, ellos no contratarían con la mujer o exigirían la comparecencia del marido, con lo que se desnaturalizaría la institución. Con esta finalidad estableció en su favor una presunción de derecho, en el inciso 4º: "Los terceros que contratasen con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación que pudieren interponer ella o el marido, sus herederos o cesionarios, fundada en la circunstancia de haber obrado la mujer fuera de los términos del presente artículo, siempre que, no tratándose de bienes comprendidos en los artículos 1754 y 1755, se haya acreditado por la mujer, mediante instrumentos públicos o privados, a los que se hará referencia en el instrumento que se otorgue al efecto, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido".

a.2) Características de la presunción.

1. Se trata de una presunción de derecho. Así lo prueba la frase contenida en la primera parte del inciso 4º "quedarán a cubierto de toda reclamación". De consiguiente, cumpliéndose los requisitos establecidos en el inciso 4º, la ley no admite que se pueda probar de ninguna forma que la mujer no ejercía ni había ejercido antes del contrato, un empleo, oficio, profesión o industria separado de su marido;

2. Es una presunción establecida en favor de los terceros. Así lo dice el inciso 4º: "Los terceros que contratasen con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación...". La mujer no se favorece con la presunción por lo que si a ella interesa la prueba, tendrá que rendirla, recurriendo a todos los medios de prueba legales, incluso la prueba de testigos por cuanto se trata de probar hechos. Podrá probar su patrimonio reservado con el pago de una patente profesional, comercial o industrial, con un decreto de nombramiento, etc.;

3. La presunción está destinada únicamente a probar la existencia del patrimonio reservado y que la mujer actuó dentro de tal patrimonio. Por ello, si la mujer alega la nulidad del contrato por haber existido, por ejemplo, dolo, fuerza o cualquier otro vicio del consentimiento, no opera tal presunción. Tampoco sirve la presunción para probar que un determinado bien es reservado.

a.3) Requisitos para que rija la presunción del inciso 4º del artículo 150.

Para que opere esta presunción deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que el acto o contrato no se refiera a los bienes propios de la mujer. Ese es el alcance de la referencia a los artículos 1754 y 1755;
2. Que la mujer acredite mediante instrumentos públicos o privados, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de su marido. Pueden tratarse de instrumentos públicos o privados. Lo único que interesa es que prueben por sí solos el trabajo separado de la mujer. Por ejemplo, una patente profesional, industrial o comercial; un contrato de trabajo, un decreto de nombramiento, etc.

Algunos exigen que sea más de un instrumento, por cuanto la norma habla en plural de "instrumentos públicos o privados". No pensamos que se deba dar a la norma tal alcance. No tendría ningún sentido desde que con un sólo instrumento se puede probar el trabajo separado de la mujer. Por lo demás, hay un antecedente de historia fidedigna que demuestra que un solo instrumento basta. Se trata del propio Mensaje con que el Ejecutivo envió la ley al Parlamento. Allí se dice lo siguiente: "La exigencia del proyecto no puede parecer muy rigurosa, porque siempre la mujer que ejerza un empleo, oficio, profesión o industria, podrá procurarse un instrumento que acredite su ejercicio. Si es empleada pública, exhibirá el decreto de nombramiento, si es empleada particular u obrera, exhibirá un certificado de su empleador, de su patrón o del jefe de taller o fábrica en que trabaje; si es industrial, la patente profesional; y si ejerce alguna profesión, el respectivo título profesional".

3. Que el contrato de que se trata conste por escrito. Lo dice la ley: "a los que se hará referencia **en el instrumento que se otorgue al efecto**".

4. Que en el acto o contrato se haga referencia al instrumento público o privado que demuestre que la mujer ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, industria o profesión separados de su marido. El inciso 4º sólo habla de hacer referencia. Parece prudente copiar el instrumento, insertarlo en el contrato que se está otorgando.

Por ello cuando la mujer contrata dentro de su patrimonio reservado, por ejemplo, comprando una propiedad, habrá de tomarse la precaución de insertar en la escritura de venta algunos de los documentos que prueben el trabajo separado. No basta con que se diga que la mujer actúa dentro de su patrimonio reservado. Y no basta porque al no insertarse el instrumento, no opera la presunción.

b) Prueba de que un determinado bien es parte del patrimonio reservado.

Esta situación, está tratada en el artículo 150 inciso 3º: "Incumbe a la mujer acreditar, tanto respecto del marido como de terceros, el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Para este efecto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley".

A la mujer puede interesar esta prueba, tanto respecto de su marido, como de terceros. Respecto del marido, por ejemplo, si la mujer renuncia a los gananciales y pretende quedarse con el bien. Y le interesará probar, respecto de un tercero, el carácter de reservado de un determinado bien, cuando el tercero pretenda hacer efectivo en él una deuda social.

Si bien el inciso 3º establece que la mujer podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos en la ley, se ha entendido que no puede valerse de la confesión, atendido lo dicho en el inciso 2º del artículo 1739: "ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán suficiente prueba, aunque se hagan bajo

juramento".

3.10.8 Suerte de los bienes reservados a la disolución de la sociedad conyugal.

Para determinar la suerte que siguen los bienes reservados a la disolución de la sociedad conyugal, es necesario hacer una distinción si la mujer o sus herederos aceptaron los gananciales; o si la mujer o sus herederos renunciaron a tales gananciales. En el primer caso los bienes reservados entran a formar parte de dichos gananciales, y se repartirán de acuerdo a las reglas de la liquidación de la sociedad conyugal. Los terceros acreedores del marido o de la sociedad, podrán hacer efectivos sus créditos en esos bienes por pasar a formar parte de la masa partible.

Si la mujer o sus herederos renuncian a los gananciales se producen las siguientes consecuencias:

- a) Los bienes reservados no entran a los gananciales. La mujer o sus herederos se hacen definitivamente dueños de los mismos. (Ramos estima que si se trata de bienes raíces, que la mujer adquirió en este patrimonio y están inscritas a su nombre, es importante que la renuncia se haga por escritura pública y se anote al margen de la inscripción de dominio. De esa forma, los terceros tendrán conocimiento de que la mujer o sus herederos tienen el dominio definitivo de tal bien).
- b) El marido no responde por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada (art. 150 inciso 7º).

3.10.9 Beneficio de emolumento en favor del marido.

Si la mujer o sus herederos aceptan los gananciales el artículo 150 contiene un verdadero beneficio de emolumento en favor del marido al establecer que sólo responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada hasta concurrencia del valor de la mitad de esos bienes (reservados) que existan al disolverse la sociedad. Pero para ello deberá probar el exceso de contribución que se le exige con arreglo al artículo 1777 (art. 150 inciso final).

Este beneficio de emolumento lo puede oponer el marido tanto a los terceros, cuando lo demanden por deudas que exceden el valor de la mitad de los bienes reservados con que se ha beneficiado; como a la mujer, cuando ésta pague una deuda contraída en ese patrimonio y pretenda que el marido le reintegre la mitad de lo pagado, podría éste defenderse alegando que lo que se le está pidiendo reembolsar excede al beneficio que él obtuvo con los bienes reservados.

Tema 4: Separación de Bienes.

4.1 Concepto

"Separación de bienes es la que se efectúa sin separación judicial, en virtud de decreto de tribunal competente, por disposición de la ley o por convención de las partes" (art. 152).

El régimen de separación de bienes se caracteriza porque cada cónyuge tiene su propio patrimonio que administra con absoluta libertad.

4.2 Efectos

- a) Los cónyuges separados de bienes administran, con plena independencia el uno del otro, los bienes que tenían antes del matrimonio y los que adquieren durante éste, a cualquier título (art. 159).

Si los cónyuges se separaren de bienes durante el matrimonio, la administración separada comprende los bienes obtenidos como producto de la liquidación de la sociedad conyugal o del régimen de participación en los gananciales que hubiere existido entre ellos.

“Lo anterior se entiende si perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Título VI del Libro Primero de este Código” (inc. 2º). La referencia a este párrafo 2 del Título VI, se entiende hecha a los bienes familiares, con lo que se quiere señalar que los bienes que resulten de la separación pueden ser declarados bienes familiares.

b) En el estado de separación, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común a proporción de sus facultades (arts. 160 y 134).

El juez en caso necesario reglará la contribución.

c) Los acreedores de la mujer sólo podrán dirigirse sobre sus bienes, respondiendo el marido únicamente en los siguientes casos:

- Cuando se ha obligado como codeudor conjunto, solidario o subsidiario de la mujer (cuando el art. 161, inc. 2º, dice “o de otro modo”, se está refiriendo a que el marido se obliga conjunta o solidariamente), y
- Cuando las obligaciones de la mujer cedieron en beneficio exclusivo del marido o de la familia común, en la parte que de derecho él haya debido proveer a las necesidades de ésta (art. 161).

d) Los acreedores del marido sólo podrán dirigirse sobre los bienes de éste y no sobre los de la mujer, salvo que se haya producido alguna de las situaciones de excepción recién indicadas (deuda conjunta, solidaria o subsidiaria o beneficio exclusivo de la mujer o familia común).

A esto se refiere el art. 161, inc. 4º, cuando dice: “*Rigen iguales disposiciones para la mujer separada de bienes respecto de las obligaciones que contraiga el marido*”.

e) Si la mujer separada de bienes confiere al marido la administración de alguna parte de los suyos, será obligado el marido a la mujer como simple mandatario (art. 162).

f) Al marido y a la mujer separados de bienes se dará curador para la administración de los suyos en todos los casos en que siendo solteros necesitarían de curador para administrarlos (art. 163). Ver art. 503.

g) La separación de bienes es irrevocable.

Al respecto dice el art. 165: “*La separación de bienes efectuada en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley es irrevocable y no podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial.*”

Tratándose de separación convencional, y además en el caso del artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil (reanudación de la vida en común luego de decretada la separación judicial de los cónyuges), los cónyuges podrán pactar por una sola vez el régimen de participación en los gananciales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723”.

4.3 Clases de Separación de Bienes.

1. Atendiendo a su fuente: legal, judicial y convencional. Así se desprende del art. 152;
2. Atendiendo a su extensión: total y parcial.

La separación legal puede ser total o parcial; lo mismo la convencional. En cambio, la separación judicial es siempre total.

4.4 Separación Legal de Bienes.

Puede ser total o parcial.

4.4.1 Separación legal total.

La ley contempla dos casos de separación legal total:

a) Separación judicial de los cónyuges.

Nótese que la separación judicial constituye un caso de separación legal y no judicial, puesto que aunque hay una sentencia judicial, los cónyuges han litigado sobre otra materia, no sobre la separación de bienes. Si ésta se produce es porque la sociedad conyugal se disuelve (arts. 1764 N° 3 y 34 de la Ley de Matrimonio Civil), y como por otra parte, el vínculo matrimonial subsiste (arts. 32, inc. 2º, y 33 de la Ley de Matrimonio Civil), tiene que existir un régimen matrimonial, que no puede ser otro que el de separación de bienes, pues la otra posibilidad, participación en los gananciales, requiere acuerdo de las partes.

El art. 34 de la Ley de Matrimonio Civil dispone: *“Por la separación judicial termina la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubiere existido entre los cónyuges...”*.

Por su parte el art. 173 del Código Civil expresa que: *“Los cónyuges separados judicialmente administran sus bienes con plena independencia uno del otro, en los términos del artículo 159”*.

Si se produce reconciliación entre los cónyuges, el art. 40 de la Ley de Matrimonio Civil dice: *“La reanudación de la vida en común, luego de la separación judicial, no revive la sociedad conyugal ni la participación en los gananciales, pero los cónyuges podrán pactar este último régimen en conformidad con el artículo 1723 del Código Civil”*. En concordancia el art. 165 inc. 2º del Código Civil señala: *“Tratándose de separación convencional, y además en el caso del artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil, los cónyuges podrán pactar por una sola vez el régimen de participación en los gananciales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723”*.

b) Personas casadas en el extranjero.

El segundo caso de separación legal total es el contemplado en el artículo 135 inciso 2º: *“Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, de lo que se dejará constancia en dicha inscripción”*.

De modo que las personas que se casan en el extranjero se entienden separadas de bienes en Chile. Sin embargo, la ley les da oportunidad de pactar sociedad de bienes o participación en los gananciales, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

- Inscribir su matrimonio en Chile, en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago (Recoleta), y
- Que en el acto de inscribir su matrimonio -sólo en ese momento- pacten sociedad conyugal o participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción matrimonial.

Este ha pasado a ser el único caso en nuestra legislación en que la sociedad conyugal puede comenzar con posterioridad al matrimonio; es una excepción a lo establecido en el artículo 1721 inciso final, pues comenzará con la inscripción de su matrimonio en Chile, lo que naturalmente es posterior a la fecha en que se casaron en el extranjero. Además es excepcional en cuanto nos encontramos frente a una sociedad conyugal convenida.

4.4.2 Separación legal parcial.

Dos casos de separación legal parcial contemplan el Código Civil:

a) El artículo 150, bienes reservados de la mujer casada, ya analizado a propósito de la sociedad conyugal.

b) Separación legal parcial del artículo 166.

Este caso de separación dice relación con los bienes que adquiere la mujer por haber aceptado una donación, herencia o legado que se le hizo con la condición precisa de que no los administrare el marido. Respecto de ellos, la mujer se considera separada de bienes, aplicándose las reglas siguientes:

i) Se aplican los arts. 159-163 (art. 166 N° 1°).

ii) Los acreedores del marido no pueden dirigirse en contra de estos bienes a menos que probaren que el contrato cedió en utilidad de la mujer o de la familia común en la parte que de derecho ella debiera proveer a la satisfacción de dichas necesidades (art. 166 N° 2°);

iii) Los frutos producidos por estos bienes y todo lo que con ellos adquiriera pertenecen a la mujer, pero disuelta la sociedad conyugal los frutos y lo que adquirió con ellos ingresan a los gananciales, a menos que la mujer los renuncie, caso en que se hará definitivamente dueña de ellos (art. 166 N° 3°, en relación con el 150). Si la mujer acepta los gananciales, el marido responderá de las obligaciones contraídas por la mujer en esta administración separada, sólo hasta el monto de la mitad de lo que le correspondió por los frutos y adquisiciones hechas con esos frutos. Esto último porque se aplican a este caso las normas del artículo 150 (art. 166 N° 3), que otorgan al marido un verdadero derecho de emolumento.

iv) Si hay sociedad conyugal, estos bienes responden en el caso de que la mujer hubiere realizado un acto o celebrado un contrato respecto de un bien propio, autorizada por la justicia, por negativa del marido (art. 138 bis). Igualmente estos bienes responden respecto de los actos celebrados por la mujer en el ejercicio de su patrimonio reservado (art. 150, inc. 5°).

4.5 Separación Judicial de Bienes.

La separación judicial sólo puede demandarla la mujer por las causales específicamente establecidas en la ley. Es un beneficio que la ley contempla exclusivamente en su favor para defenderla de la administración del marido.

4.5.1 Características de la separación judicial

- a) Sólo puede demandarla la mujer. Excepcionalmente puede ser planteada por el marido, en caso de que el régimen que regule a los cónyuges sea la participación en los gananciales (art. 158);
- b) La facultad de pedir la separación de bienes es irrenunciable e imprescriptible. Respecto a la renuncia, lo dice el artículo 153: *“La mujer no podrá renunciar en las capitulaciones matrimoniales la facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes”*;
- c) Sólo opera por las causales taxativamente señaladas en la ley;
- d) La separación judicial es siempre total, y
- e) Es irrevocable (art. 165).

4.5.2 Capacidad para demandar la separación

Si la mujer es menor de edad, requiere de un curador especial para poder pedir la separación judicial de bienes (art. 154).

4.5.3 Causales de separación judicial.

Sólo puede demandarse la separación judicial de bienes por las causales taxativamente señaladas en la ley:

a) Si la mujer no quiere tomar sobre sí la administración extraordinaria de la sociedad conyugal ni someterse a un curador.

Así está establecido en el artículo 1762 al tratar de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal.

b) Si el cónyuge obligado al pago de pensiones alimenticias en favor del otro o en el de sus hijos comunes hubiere sido apremiado por dos veces.

Esta causal está contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Ley 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

c) Insolvencia del marido.

El artículo 155 establece en su inciso primero que *“el juez decretará la separación de bienes en el caso de insolvencia... del marido”*.

Sobre esta causal existe variada jurisprudencia. Así se ha fallado que “para decretar la separación de bienes no es necesario que la insolvencia del marido haya sido declarada por fallo judicial” (Corte de Concepción, 6 de julio de 1932, Gaceta de los Tribunales, año 1932, 2° semestre, N° 111, p. 413). Otra sentencia ha definido la insolvencia estableciendo que “se produce cuando un individuo se halla incapacitado para pagar una deuda, o cesa en el pago de sus obligaciones por comprometer su patrimonio más allá de sus posibilidades” (t. 45, sec. 1°, pág. 623. En el mismo sentido puede verse t. 81, sec. 1°, p. 149).

En relación con esta materia, algunos autores creen que la sola circunstancia de que se declare en quiebra al marido basta para obtener la separación judicial de bienes invocando la insolvencia del último (Claro Solar, Barros Errázuriz). Opinión contraria se encuentra en la memoria Separación de Bienes, de Bernardo del Río Aldunate, quien afirma que la quiebra sólo es un antecedente valioso para la prueba de la insolvencia. Lo que la mujer debe probar, en forma precisa, es que el pasivo del marido es superior a su activo.

Somarriva considera que cuando se invoca esta causal, la confesión del marido no hace prueba. Aplica la norma del artículo 157 a este caso, no obstante que él está referido al mal estado de los negocios del marido. Dice: “Si nos atenemos a la letra de la ley, es evidente que en estos juicios se aceptaría la confesión del marido, ya que el artículo 157 sólo la elimina en el caso del mal estado de los negocios. Pero el origen de la disposición -ella fue tomada de Pothier, quien se refería a ambos casos-, el principio según el cual donde hay una misma razón debe existir una misma disposición; el hecho de que la insolvencia supone mal estado de los negocios; la circunstancia de que a diferencia del fraude el marido no tendría inconveniente en confesar su insolvencia, lo que conduciría a aceptar juicios de separación de común acuerdo, son razones de peso para estimar que el legislador al referirse en el artículo 157 al mal estado de los negocios también se ha querido referir a la insolvencia; y que, por lo tanto, es posible concluir que en ninguno de estos casos es aceptable la confesión del marido”.

d) Administración fraudulenta del marido.

Esta causal está contemplada en el artículo 155 inciso 1° parte final: “El juez decretará la separación de bienes en el caso de.... administración fraudulenta del marido”.

Los bienes que el marido debe administrar fraudulentamente para que opere esta causal son sus propios bienes, los de la sociedad conyugal o los de su mujer. En este sentido, Somarriva, Claro Solar, Barros Errázuriz, Del Río Aldunate. La administración fraudulenta que el marido pueda hacer de bienes de terceros (de un pupilo, de una sociedad, por ejemplo), no habilita para pedir la separación de bienes. En ese sentido los autores recién citados, salvo Somarriva que no toca el punto.

Los tribunales han tenido oportunidad de precisar el alcance de esta causal. Así, se ha fallado que “se entiende por administración fraudulenta aquella en que el marido deliberadamente ejecuta actos ilícitos para perjudicar a su mujer y en que se disminuye el haber de ésta por culpa lata. Basta comprobar la existencia de un solo acto de esa especie para que se decrete por el juez la separación de bienes” (C. Suprema, Gaceta de los Tribunales, año 1913, 1er. semestre, N° 24, p. 78). En otro fallo se afirma que “la administración fraudulenta del marido es la que se ejerce con fraude o dolo o sea con intención positiva de inferir injuria a la propiedad de la mujer. Tal punto debe probarlo ella estableciendo los actos o hechos positivos del marido tendientes a producirle perjuicios en sus bienes, es decir, actos o hechos efectuados con malicia o mala fe, dado que el dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley” (t. 31, sec. 2°, p. 1).

e) Mal estado de los negocios del marido.

Para que opere la causal no basta que los negocios del marido se encuentren en mal estado. Es necesario, además, que este mal estado provenga de especulaciones aventuradas o de una administración errónea o descuidada (art. 155, inc. 4°).

Se ha fallado que “el hecho de afirmarse que el marido haya poseído en época anterior una fortuna muy superior a la actual, no constituye mal estado de los negocios. El mal estado de los negocios que no es sinónimo de pobreza debe buscarse en la relatividad actual del pasivo con el activo liquidable y la mayor o menor facilidad de realización” (t. 35, sec. 1°, p. 248). También se ha resuelto que “no es necesario que sean múltiples los actos que acusan descuido en la administración de los bienes de la mujer para que proceda la separación; basta con que se advierta el peligro que puede resultar a aquellos intereses de una administración errónea o descuidada” (t. 33, sec. 1°, p. 324).

No es necesario que los negocios del marido se hallen en mal estado para demandar la separación judicial de bienes. Basta que exista riesgo inminente de ello.

Esta causal presenta dos particularidades:

- El marido puede oponerse a la separación, prestando fianza o hipotecas que aseguren suficientemente los intereses de su mujer (art. 155, inc. final), y

- Que en este juicio, la confesión del marido no hace prueba (art. 157). Esta norma tiene por objeto amparar los derechos de los terceros y evitar que puedan el marido y la mujer coludirse en desmedro de los intereses de aquellos.

f) Incumplimiento culpable del marido de las obligaciones que le imponen los artículos 131 o 134.

Esta causal se contiene en el artículo 155 inciso 2°: *“También la decretará (la separación de bienes) si el marido, por su culpa, no cumple con las obligaciones que imponen los artículos 131 y 134....”*

El artículo 131 contempla las obligaciones de fidelidad, socorro, ayuda mutua, protección y respeto; y el artículo 134 establece el deber de proveer a las necesidades de la familia común (deber de socorro).

De manera que la infidelidad del marido, por ejemplo, es causal de separación de bienes; lo mismo el hecho de que no le proporcione alimentos a su mujer o a la familia común.

Para que nos encontremos frente a la causal de separación de bienes, deben reunirse los siguientes requisitos:

- Incumplimiento de alguno de estos deberes;
- Que quien incumpla sea el marido, y
- Que el incumplimiento sea culpable.

g) Caso del marido que incurre en alguna causal de separación judicial

Artículo 155 inciso 2° parte final.

Las causales de separación judicial están señaladas en los artículos 26 y 27 de la nueva Ley de Matrimonio Civil (violación grave a los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos que haga intolerable la vida común; cese de la convivencia).

Basta con que concurra la causal de separación judicial para que se pueda pedir la separación de bienes. No es necesario que exista sentencia de separación judicial o que ésta se haya demandado.

h) Ausencia injustificada del marido por más de un año.

Artículo 155 inciso 3°.

i) Separación de hecho, sin mediar ausencia, por más de un año.

Artículo 155 inciso 3° parte final.

René Ramos llama la atención sobre los siguientes aspectos de esta causal:

- Basta la simple separación de hecho, sin que sea necesario cumplir los requisitos que según el artículo 473 el Código Civil, configuran la ausencia, esto es, no presencia en el hogar, ignorancia de su paradero y falta de comunicación con los suyos.
- Carecen de relevancia los motivos de la separación; y
- No tiene importancia determinar quién tiene la responsabilidad en la separación. Por ello aunque la haya provocado la mujer, tiene derecho a demandarla.

No sin razón podría argumentarse que si la separación se produjo por culpa de la mujer (fue ella la que abandonó el hogar común) se estaría aprovechando de su propio dolo, lo que resulta contrario a todo el sistema del Código. Aparecería invocando una causal que ella misma se fabricó. Sin embargo, y mirado desde otro ángulo, parece adecuado que si los cónyuges no están haciendo vida común, cese una sociedad conyugal que priva a la mujer de la administración de sus bienes propios.

En relación con esta causal la Corte de Concepción en sentencia del 24 de mayo de 1999, resolvió que “el tribunal carece de facultades para entrar a pronunciarse sobre la inconveniencia que pudiera tener para la mujer y la familia, el que se acoja la demanda por este motivo. Sólo le compete verificar si se ha producido o no la situación descrita en la norma invocada, es decir, si existió o no la

separación de hecho por el lapso indicado en la ley”. (Considerando 9º). La misma sentencia, agregó en otro de sus fundamentos que “en estrados se ha hecho cuestión por la parte demandada en el sentido que no tuvo responsabilidad en la separación de hecho, por cuanto quien habría dejado la casa familiar habría sido la mujer. Sin desconocer el fundamento que una alegación de este tipo pudiera tener, si se tiene presente que en el sistema del Código Civil la separación judicial viene a ser una sanción al marido que por diversas razones tiene una conducta inconveniente o perjudicial para los intereses económicos de la mujer, en el caso de autos, no se puede entrar a considerar tal alegación, por no haber sido planteada como excepción al contestarse la demanda y, por consiguiente, tampoco haber sido objeto de prueba” (Considerando 13º). De esta parte de la sentencia parece fluir que si se hubiere planteado oportunamente la excepción de la culpa de la mujer en la separación, los falladores pudieran haber considerado tal excepción (Causa rol Nº 1145-98 del Ingreso de la Corte: “Bancalari con Zattera”). En el mismo sentido, Corte de Concepción, 7 de enero de 2005, causa rol 4514-2003.

4.5.4 Medidas precautorias en favor de la mujer.

El artículo 156 establece que *“demandada la separación de bienes podrá el juez a petición de la mujer tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de los intereses de ésta, mientras dure el juicio”*. La norma es de la mayor amplitud, por lo que debe entenderse que las medidas a tomar serán todas las que la prudencia del tribunal estime aconsejables sin que se puedan entender limitadas a las establecidas en los títulos IV y V del libro II del Código de Procedimiento Civil (Somarriva).

El art. 156 inc 2º permite a la mujer, en el caso de separación judicial por ausencia del marido o separación de hecho sin mediar ausencia, pedir al juez en cualquier tiempo -antes de demandar la separación de bienes- las providencias que estime conducentes a la seguridad de sus intereses.

4.5.5 Efectos de la separación judicial de bienes

Los efectos de la separación de bienes no operan retroactivamente sino hacia el futuro. Para que la sentencia afecte a terceros es necesario que se inscriba al margen de la inscripción matrimonial (art. 4º, N° 4º en relación con el artículo 8º de la Ley 4.808).

En cuanto a los efectos mismos de la sentencia son los siguientes:

- Produce la disolución de la sociedad conyugal y término del régimen de participación en los gananciales (arts. 1764 N° 3º, 1792-27 N° 5);
- Una vez decretada la separación, se procederá a la división de los gananciales y al pago de recompensas o al cálculo del crédito de participación en los gananciales, según cual fuere el régimen al que se pone término (art. 158, inc. 2º);
- Se aplican los arts. 159-163.
- Decretada la separación de bienes, ésta es irrevocable (art. 165). De manera que ya no se puede volver al régimen de sociedad conyugal.

4.6 Separación Convencional de Bienes.

4.6.1 Oportunidad en que se puede pactar

La separación convencional de bienes puede ser acordada en tres momentos:

1. En las capitulaciones matrimoniales que se celebran antes del matrimonio, pudiendo ser en tal caso total o parcial (art. 1720, inc. 1º).

2. En las capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto de matrimonio, en que sólo se puede establecer separación total de bienes (art. 1715, inc. 2º), y

3. Durante el matrimonio, los cónyuges mayores de edad, que se encontraren casados en régimen de sociedad conyugal o de participación en los gananciales, pueden convenir la separación total de bienes (arts. 1723 y 1792-1, inc. 2º, parte final).

4.6.2 Efectos de la separación convencional de bienes

Están regulados en los arts. 159 a 163 y ya fueron analizados.

4.6.3 Clases de separación convencional

a) Separación convencional parcial.

Tiene lugar en dos casos:

- Si en las capitulaciones se hubiere estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes (art. 167) y
- Si en las capitulaciones matrimoniales se estipula que la mujer dispondrá libremente de una suma de dinero o de una pensión periódica (art. 1720, inc. 2º).
- En ambos casos la mujer se mirará como separada de bienes y esa separación parcial se regirá por el art. 166.

b) Separación convencional total.

Es el pacto de separación total de bienes del art. 1723

Este pacto de separación total es causal de disolución de la sociedad conyugal y de término del régimen de participación en los gananciales (arts. 1764 N° 5º y 1792-27 N° 6, respectivamente).

b.1) Objeto del pacto del art. 1723

Con la dictación de la Ley N° 19.335, el objeto del pacto de que trata el art. 1723 ha sido considerablemente ampliado. En síntesis, en virtud de este pacto hoy día se puede:

- pasar de sociedad conyugal a separación total de bienes;
- de sociedad conyugal a participación en los gananciales;
- de separación de bienes a participación en los gananciales;
- de participación en los gananciales a separación total de bienes.

b.2) Capacidad

Sólo pueden celebrar el pacto del art. 1723 los cónyuges mayores de edad (arts. 1723 y 1792-1 inc. 2º).

Si un cónyuge menor de edad celebra este pacto, la sanción sería la nulidad absoluta por objeto ilícito, pues se habría celebrado un acto prohibido por la ley (art. 1723, en relación con los artículos 1466 y 1682). También podría afirmarse que la nulidad es absoluta por haberse omitido un requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a su naturaleza y no en atención al estado o calidad de quien lo ejecuta o celebra. Pablo Rodríguez piensa que la sanción será la nulidad relativa del pacto, en consideración a que dicho requisito está establecido en atención a la calidad o estado de las partes.

b.3) Características del pacto

i) El pacto es solemne.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1723, inciso 2º, las solemnidades son las siguientes:

- Debe otorgarse por escritura pública;

- La escritura debe subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial, y
- La subinscripción debe practicarse dentro del plazo fatal de 30 días contados desde la fecha de la escritura.

Respecto de la exigencia de que la escritura pública se subinscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial, el artículo 1723 es muy claro en el sentido de que el pacto “no surtirá efectos **entre las partes** ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se subinscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial”. La frase “entre las partes” demuestra que la subinscripción es una solemnidad y no un simple requisito de oponibilidad a los terceros.

En cuanto al plazo para practicar la inscripción es importante tener presente:

- Que el plazo se cuenta desde la fecha de la escritura de separación;
- Que el plazo es fatal (la norma dice que “sólo podrá practicarse *dentro del* plazo de 30 días”);
- Que el plazo es de días corridos, no se descuentan los días feriados, por aplicación de la regla del artículo 50 del Código Civil;
- Que si bien en la misma escritura pública en que se pacte la separación de bienes se puede liquidar la sociedad conyugal y celebrar otros pactos (art. 1723 inc. 3°), el plazo dice relación exclusivamente con la separación, no con los otros actos jurídicos. Por ello, no habría ningún inconveniente, por ejemplo, para modificar la liquidación de la sociedad practicada en esta escritura, después de los 30 días.

En la misma escritura en que se pacta la separación total de bienes o participación en los gananciales, se puede liquidar la sociedad conyugal o determinar el crédito de participación y acordar otros pactos lícitos.

Así lo establece el artículo 1723 inciso 3°: *“En la escritura pública de separación total de bienes, o en la que se pacte participación en los gananciales, según sea el caso, podrán los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación o celebrar otros pactos lícitos, o una y otra cosa; pero todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto de terceros, sino desde la subinscripción a que se refiere el inciso precedente”*.

Un ejemplo sobre estos otros pactos lícitos es la renuncia de gananciales, que en esta oportunidad podría hacer la mujer.

Es importante, en todo caso, tener presente que si en la misma escritura se pacta la separación de bienes y se liquida la sociedad conyugal, se están celebrando en un mismo instrumento dos actos jurídicos distintos. Esta distinción es importante, pues si bien el pacto de separación de bienes debe subinscribirse al margen de la inscripción del matrimonio, no acontece lo mismo con la escritura de liquidación.

ii) El pacto de separación de bienes no puede perjudicar el interés de los terceros

El artículo 1723 inciso 2° sienta este principio en los siguientes términos: *“El pacto no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer...”*.

Esta característica es la que ha presentado mayores problemas pues no está claro qué significa exactamente la frase “no perjudicará en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros”. Ha habido sobre el particular opiniones diversas. Así para Alessandri, la frase bien pudo no haberse escrito porque con ella lo único que se quiere significar es que la situación de los acreedores, una vez pactada la separación total de bienes, es la misma que tendrían en el evento de haberse disuelto la sociedad conyugal por otros modos.

Para don Manuel Somarriva, la frase consagra una **forma de inoponibilidad**, de tal manera que los acreedores sociales o del marido pueden dirigirse sobre los bienes adjudicados a la mujer del mismo modo que lo habrían hecho si no se hubiere producido la separación. En el mismo sentido Luis Claro Solar.

La Corte Suprema en sentencia de 16 de diciembre de 1996, ha dicho que “el sentido muy claro del aludido artículo 1723, hecho suyo por la doctrina y la jurisprudencia, es que la referencia a “los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer” alude a los acreedores de uno u otro cónyuge. Sólo estos tienen derechos adquiridos en contra de ellos. Y tener derechos adquiridos es sinónimo de ser acreedor, vale decir, de tener un derecho personal o crédito vigente respecto de cualquiera de los cónyuges” (R.D.J., t. 93, sec. 1ª, p. 167; Fallos del Mes Nº 457, sentencia 12, p. 2611). En otro fallo, de 26 de marzo de 1997, el más alto tribunal resolvió que “como lo que persigue el legislador es proteger a los terceros que detentan un crédito, que pueden hacer efectivo en el patrimonio de la sociedad conyugal; obviamente la calidad de acreedores la deben tener a la época en que los cónyuges modifican el régimen patrimonial de la sociedad conyugal y no después de aquél acto; ya que, en ese caso, los acreedores, para conocer el estado patrimonial y la situación real y jurídica de su deudor, pueden recurrir al estudio de los registros pertinentes de los Conservadores de Bienes Raíces....” (Fallos del Mes Nº 459, sentencia 6, p. 27). Véase también R.D.J., t. 91, sec. 4ª, p. 166.

iii) El pacto es irrevocable.

Esta característica la consigna el art. 1723 en su inciso 2º, parte final: “... y, una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges”.

iv) El pacto no es susceptible de condición, plazo o modo alguno.

El art. 1723 inc., final contempla este principio en forma expresa.

Tema 5: Participación en los Gananciales.

Hasta la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.335, 24 de diciembre de 1994, sólo podían darse en Chile dos regímenes matrimoniales: sociedad conyugal o separación total de bienes. Esta ley incorporó una tercera posibilidad: que los esposos o cónyuges puedan convenir el régimen de participación en los gananciales.



El régimen de participación en los gananciales constituye una fórmula ecléctica entre el de sociedad conyugal y el de separación de bienes, que concilia dos aspectos fundamentales del matrimonio, la comunidad de intereses que implica la vida matrimonial con el respeto a la personalidad individual de cada cónyuge.

El D.F.L. Nº 2 del 25 de septiembre de 1995, publicado en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 1996, fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil, incorporando a este Código un título nuevo -Título XXII A- destinado a regular este régimen, lo que hace en los artículos 1792-1 al 1792-27.

5.1 Generalidades.

5.1.1 En qué momento se puede convenir este régimen

Se puede establecer en tres oportunidades:

1. En las capitulaciones matrimoniales que celebren los esposos antes del matrimonio (art. 1792-1, inc. 1º),
2. En las capitulaciones que se celebren al momento del matrimonio (art. 1715, inc. 2º), y
3. Durante la vigencia del matrimonio, mediante el pacto del artículo 1723 (art. 1792-1, inc. 2º).

5.1.2 El régimen puede estipularse originariamente o mediante la sustitución de alguno de los otros regímenes.

Se puede convenir en forma originaria en las capitulaciones matrimoniales celebradas antes o en el acto del matrimonio. Si los cónyuges se hubieren casado en régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes, pueden sustituir esos regímenes por el participación en los gananciales. Así, lo establece el art. 1792-1, inc. 2º: *“Los cónyuges podrán, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1723 de ese mismo Código -se refiere al Código Civil-, sustituir el régimen de sociedad conyugal o el de separación por el régimen de participación que esta ley contempla...”*

Si los cónyuges se hubieren casado en régimen de sociedad conyugal y posteriormente hubieren hecho separación de bienes, ¿podrían sustituir esa separación por el régimen de participación en los gananciales?. Hay dos soluciones posibles al problema:

Una primera, según la cual ello no es posible, en razón de que el artículo 1723, inc. 2º, parte final, prescribe que este pacto “no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges”. Abona esta tesis el principio de la inmutabilidad del régimen matrimonial consagrado en el art. 1716, inciso final. Esta opinión la sustenta Hernán Corral T.

Pero también puede estimarse que ello sería factible, en razón de que para la recta interpretación de la frase final del inc. 2º del art. 1723 “no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges”, debe tenerse en cuenta que ella ya se encontraba en el artículo 1723 con anterioridad a la Ley N° 19335, siendo entonces su significación muy clara en orden a que si los cónyuges habían sustituido la sociedad conyugal por el pacto de separación total de bienes, les estaba vedado volver al régimen de sociedad conyugal. Pero en el caso que nos ocupa el problema es distinto: los cónyuges se casaron en régimen de sociedad conyugal hicieron uso del artículo 1723 y sustituyeron ese régimen por el de separación de bienes. Ahora, encontrándose casados en separación de bienes, desean reemplazarlo por el de participación en los gananciales. Como se ve, no se trata de dejar sin efecto el pacto anterior volviendo al régimen de sociedad conyugal, sino de celebrar un nuevo pacto en conformidad al artículo 1723 para sustituir el régimen de separación de bienes por el de participación en los gananciales. Además, esta situación no está prohibida por la ley, de hecho está contemplada en el inc. 1 parte final del art. 1723.

Esta última interpretación, dice Francisco Merino “posee la ventaja que hace accesible al nuevo régimen de participación en los gananciales a los actuales matrimonios que hoy se encuentran casados bajo el régimen de separación total como consecuencia de haber ya optado por él luego de haberse casado en sociedad de bienes, lo que sería imposible si damos a la oración “no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges” un alcance más amplio que el señalado. El mismo profesor asegura que esta interpretación “presenta como contrapartida que atentaría contra

el principio de la estabilidad, conveniente en todo régimen patrimonial, en cuya virtud se debe propender otorgar al sistema adoptado por los cónyuges la mayor fijeza posible, en atención a los múltiples intereses que en ellos se conjugan y que trascienden a los particulares del marido y de la mujer”.

5.1.3 Cónyuges casados en el extranjero pueden adoptar este régimen

En el caso de los cónyuges casados en el extranjero, pueden adoptar este régimen al momento de inscribir su matrimonio en Chile. Así lo establece el artículo 135, inc. 2º: *“Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción”*.

5.1.4 Variantes del régimen de participación en los gananciales

En doctrina, el régimen de participación en los gananciales, admite dos modalidades: a) sistema de comunidad diferida; o b) sistema crediticio o de participación con compensación de beneficios.

En el primero, vigente el régimen, cada cónyuge tiene su propio patrimonio, que administra con libertad. A su extinción, se forma entre los cónyuges o, entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido, una comunidad respecto de los bienes que cada uno adquirió durante el matrimonio a título oneroso, que se divide entre ellos por partes iguales. Se denomina de comunidad diferida, pues la comunidad se posterga hasta la extinción del régimen. Claudia Schmidt señala que “en la participación con comunidad diferida, como su nombre lo da a entender, nace una comunidad efímera, limitada en el tiempo, para el solo efecto de ser liquidada y dividida entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto”.

En la segunda variante, vigente el régimen cada cónyuge tiene su propio patrimonio que administra con libertad, pero producida su extinción, el cónyuge que ha adquirido bienes a título oneroso por menos valor, tiene un crédito de participación en contra del otro cónyuge, con el objeto de que, en definitiva, ambos logren lo mismo a título de gananciales. No se produce comunidad en ningún momento. Tuvo su origen en una ley de Finlandia de 13 de junio de 1929 y ha sido establecido como régimen supletorio en los códigos alemán y francés.

5.1.5 Sistema adoptado en Chile

La ley Nº 19.335 optó por la variante crediticia, esto es, que tanto durante su vigencia como a la expiración del régimen, los patrimonios de ambos cónyuges (o del cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto), permanezcan separados. Luego a su extinción, no se genera un estado de comunidad, sino sólo se otorga al cónyuge que obtuvo gananciales por menor valor, un crédito en contra del que obtuvo más, con el objeto de que, a la postre, los dos logren la misma suma. El inciso 3º del artículo 1792-19 es categórico: “Si ambos cónyuges hubiesen obtenido gananciales, éstos se compensarán hasta la concurrencia de los de menor valor y aquel que hubiere obtenido menores gananciales tendrá derecho a que el otro le pague, a título de participación, la mitad del excedente”.

El profesor César Parada sostiene que la vertiente seguida por nuestro legislador adolece de tres defectos: “a) Se aparta de nuestras tradiciones jurídicas, ya que para mantenerlas tal como hoy se concibe, al disolverse la sociedad conyugal, era preferible establecer un régimen de comunidad y no de compensación y de crédito de gananciales, como se establece en la ley que analizamos; b) Que conforme a lo que se establece en esta ley, al momento de terminar el régimen, los cónyuges o sus herederos no tendrán ningún derecho real sobre los bienes objeto de la ganancia, sino que sólo tendrán un derecho personal o de crédito, que, a nuestro juicio, es notoriamente más débil que

tener un derecho real; y c) Además el régimen de comunidad final parece más acorde con lo que es el matrimonio que constituye una comunidad espiritual y sólo por consecuencia, una comunidad patrimonial...".

Una opinión contraria sustenta Carlos Peña G., quien afirma que "desde el punto de vista del derecho común y constitucional, tanto los derechos reales como los personales están igualmente garantizados. Unos y otros se encuentran protegidos constitucionalmente en conformidad al artículo 19 Nº 24, inciso 1º de la Constitución y en virtud del antiguo artículo 583 del Código Civil". Y agrega que los acreedores pueden embargar lo mismo, derechos reales o personales, exceptuándose, solamente los no embargables. Por igual razón, uno y otro tipo de derechos están sometidos al desasimiento para el caso de la quiebra. Ello lo lleva a concluir que "desde el punto de vista de los cónyuges, y enfrente de terceros, la situación de comunero o acreedor resulta exactamente la misma". El profesor Peña tampoco participa de la idea de que el sistema rompa una tradición comunitaria fuertemente arraigada, tradición que, a su juicio, es inexistente.

René Ramos se pronuncia por la variante crediticia. Cree que si los cónyuges adoptaron el régimen de participación en los gananciales y no el de sociedad conyugal, es porque desean que los bienes que cada uno adquiera sean de su dominio exclusivo y ello, en forma definitiva, idea que se desvirtúa en la alternativa de la comunidad diferida.

5.1.6 Características del sistema chileno

Las principales características del sistema chileno son las siguientes:

1. Es un régimen económico matrimonial de carácter legal o regulación predeterminada: sus normas están establecidas por la ley, y no pueden ser alteradas por la voluntad de los cónyuges.
2. Se trata de un régimen alternativo a la sociedad conyugal y a la separación total de bienes.
3. Régimen convencional pues requiere pacto expreso de ambos cónyuges.
4. Mutabilidad prevista por la ley (arts. 1792-1, inc. 2º, parte final y 1792-27, Nº 6).
5. Régimen de participación restringida de ganancias y adquisiciones: por regla general, sólo son considerados como gananciales los bienes muebles o inmuebles adquiridos a título oneroso durante el matrimonio.
6. Modalidad crediticia: al finalizar no se forma una comunidad de bienes, sino que la participación se traduce en el nacimiento de un crédito que compensa e iguala los beneficios.

5.2 Funcionamiento Durante la Vigencia del Régimen.

Durante la vigencia del régimen, cada cónyuge es dueño de sus bienes, que administra con libertad, sujeto, empero, a las siguientes limitaciones:

- a) Ninguno de ellos podrá otorgar cauciones personales a obligaciones de terceros sin el consentimiento del otro cónyuge (art. 1792-3).
- Se trata de cauciones personales: fianza, aval, solidaridad pasiva, cláusula penal, etc. (art. 43), y no es aplicable la limitación a las cauciones reales.

- La obligación caucionada debe ser necesariamente de un tercero y no propia del cónyuge caucionante.
 - El “otorgamiento de cauciones”, supone excluir la autorización del otro cónyuge para la realización de actos jurídicos que indirecta y eventualmente pueden dar lugar a una responsabilidad solidaria (v. gr. la celebración de una sociedad colectiva comercial o el endoso en dominio de una letra de cambio o pagaré).
 - El consentimiento del otro cónyuge debe prestarse conforme a las reglas que se establecen para la autorización de los actos sobre bienes familiares (arts. 142, inc. 2º y 144).
 - Los actos ejecutados en contravención a lo dispuesto adolecerán de nulidad relativa. Y en este caso “el cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde el día en que el cónyuge que la alega tuvo *conocimiento del acto*” (norma que modifica los principios generales contenidos en el Código Civil), pero no podrá perseguirse la rescisión pasados diez años desde la celebración del acto o contrato (art. 1792-4). Su titular es el cónyuge llamado a consentir en la caución, sus herederos o cesionarios (art. 1684). La suspensión y el saneamiento se rige por las reglas generales (arts. 1692 y 1693).
- b) Si un bien es declarado “bien familiar”, el cónyuge propietario no podrá enajenarlo ni gravarlo voluntariamente ni prometer gravarlo o enajenarlo, sin la autorización del otro cónyuge, o del juez si la negativa de aquél no se funda en el interés de la familia o se encuentra imposibilitado de dar dicha autorización (arts. 142 y 144).

5.3 Funcionamiento del Sistema a la Extinción del Régimen.

Para estudiar esta materia es necesario precisar los siguientes conceptos: **Gananciales; Patrimonio originario, y Patrimonio final.**

5.3.1 Gananciales

En conformidad al artículo 1792-6, “se entiende por *gananciales* la diferencia del valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge”. La comparación ha de hacerse en “**valor neto**”, es decir, se deben descontar los pasivos constituidos por deudas. Por ello, para calcular los gananciales es necesario realizar una operación contable que indique la diferencia entre el patrimonio originario y el patrimonio final.

5.3.2 Patrimonio originario

“Se entiende por *patrimonio originario* de cada cónyuge el existente al momento de optar por el régimen que establece este Título...” (art. 1792-6, inc. 2º).

Si la participación se ha convenido en capitulaciones matrimoniales anteriores al matrimonio, el patrimonio originario será aquel que exista a la fecha del matrimonio (art. 1716).

El patrimonio originario se determinará aplicando las reglas de los artículos 1792-7 y siguientes. Ello significa que se procede del modo siguiente:

- a) Se deducen del valor de los bienes que el cónyuge tiene al inicio del régimen las obligaciones de que sea deudor en esa misma fecha. La ley habla de “obligaciones de que sea deudor” el cónyuge, sin precisión de los caracteres que deben reunir esas obligaciones. Hernán Corral estima que se debe

tratar de obligaciones líquidas, actualmente exigibles y avaluables en dinero, pues de otra manera no podría practicarse la deducción, sin perjuicio de que una obligación ilíquida o sujeta a condición suspensiva, pueda ser deducida con posterioridad con efecto retroactivo. Si el valor de las obligaciones excede al valor de los bienes, el patrimonio originario se estimará carente de valor (art. 1792-7). La norma parece criticable, si se piensa que un patrimonio negativo que con el tiempo disminuye sus pasivos, importa una efectiva ganancia para su titular.

b) Se agregan al patrimonio originario las adquisiciones a título gratuito efectuadas durante la vigencia del régimen, deducidas las cargas con que estuvieren gravadas (art. 1792-7 inc. 2°).

c) También se agregan a este patrimonio originario las adquisiciones a título oneroso hechas durante la vigencia del régimen, si la causa o título de la adquisición es anterior al inicio del régimen. Así, lo dice el artículo 1792-8, que después de enunciar en su inciso primero el principio, indica en el inciso siguiente algunos casos en que tal situación se produce. Se trata de una norma muy semejante al art. 1736.

El art. 1792-8 contiene una enumeración no taxativa.

1. Los bienes que uno de los cónyuges poseía antes del régimen de bienes, aunque la prescripción o transacción con que los haya hecho suyos haya operado o se haya convenido durante la vigencia del régimen de bienes;

2. Los bienes que se poseían antes del régimen de bienes por un título vicioso, siempre que el vicio se haya purgado durante la vigencia del régimen de bienes por la ratificación o por otro medio legal;

3. Los bienes que vuelvan a uno de los cónyuges por la nulidad o la resolución de un contrato, o por haberse revocado una donación;

4. Los bienes litigiosos cuya posesión pacífica haya adquirido cualquiera de los cónyuges durante la vigencia del régimen;

5. El derecho de usufructo que se haya consolidado con la nuda propiedad que pertenece al mismo cónyuge;

6. Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos constituidos antes de la vigencia del régimen. Lo mismo se aplicará a los intereses devengados antes y pagados después;

7. La proporción del precio pagado con anterioridad al inicio del régimen, por los bienes adquiridos de resultas de contratos de promesa. Aquí no se tomó la precaución -que sí tomó el art. 1736 N° 7°- de que las promesas tuvieran que constar en un instrumento público o privado cuya fecha sea oponible a terceros. Corral dice que ello debe entenderse implícito por aplicación de las reglas generales (arts. 1554 N° 1 y 1703).

a) No integran el patrimonio originario.



Pregunta

No integran el patrimonio originario los frutos, incluso los que provengan de los bienes originarios, las minas denunciadas por uno de los cónyuges ni las donaciones remuneratorias por servicios que hubieren dado acción contra la persona servida. Así lo establece el artículo 1792-9.

¿Qué significa que estos bienes no ingresen al patrimonio originario?
Simplemente, que van a integrar los gananciales contribuyendo a aumentar el

valor del crédito de participación en favor del otro cónyuge. Esto es así, porque al no integrar el patrimonio originario, éste se ve disminuido, por lo que la diferencia con el patrimonio final es más amplia y los gananciales están determinados por esta diferencia (art. 1792-6).

b) Adquisiciones de bienes hechas en común por ambos cónyuges

Esta situación está reglada por el artículo 1792-10: *“Los cónyuges son comuneros, según las reglas generales, de los bienes adquiridos en conjunto, a título oneroso. Si la adquisición ha sido a título gratuito por ambos cónyuges, los derechos se agregarán a los respectivos patrimonios originarios, en la proporción que establezca el título respectivo, o en partes iguales, si el título nada dijere al respecto”*.

Luego, si el bien es adquirido por los cónyuges en común, a título oneroso, la cuota de cada uno incrementará sus respectivos gananciales, favoreciéndose de ese modo, al término del régimen, al otro cónyuge que participará de ellas; no ocurriendo lo mismo en las adquisiciones a título gratuito, que pasan a formar parte de sus respectivos patrimonios originarios.

c) Prueba del patrimonio originario. Obligación de practicar inventario

El artículo 1792-11 establece que *“Los cónyuges o esposos, al momento de pactar este régimen, deberán efectuar un inventario simple de los bienes que componen el patrimonio originario”*. Corral señala que aunque la ley no lo dispone debemos entender que cada inventario será suscrito por ambos cónyuges, como también que puede tratarse de un solo instrumento para ambos.

La falta de inventario no produce nulidad del régimen. El inciso 2º señala que *“a falta de inventario, el patrimonio originario puede probarse mediante otros instrumentos, tales como registros, facturas o títulos de crédito”*, y el inciso final agrega: *“Con todo, serán admitidos otros medios de prueba si se demuestra que, atendidas las circunstancias, el esposo o cónyuge no estuvo en situación de procurarse un instrumento”*.

De manera que hay una jerarquía de pruebas. En primer lugar el inventario; a falta de inventario, se aceptan otros instrumentos; y finalmente, si se acredita que, atendidas las circunstancias, el esposo o cónyuge no estuvo en situación de procurarse un instrumento, se admite que pueda probar por cualquier otro medio, pues la ley no establece ninguna limitación al respecto.

La limitación probatoria no parece aplicable a los terceros, que podrán acreditar el patrimonio originario conforme a las reglas generales.

La confesión de los cónyuges o esposos parece admisible, la ley no ha excluido expresamente este modo probatorio (criterio diverso al de la sociedad conyugal, art. 1739, inc. 2º), con la limitación del art. 2485 que, en cuanto, al privilegio de cuarta clase reconocido al crédito de gananciales (art. 2481, Nº 3), señala que la confesión de alguno de los cónyuges no hará prueba por sí sola, contra los acreedores. Así Corral y Frigerio.

En cuanto al pasivo del patrimonio originario la ley no exige que el inventario contemple la enumeración o valoración de las deudas, como sí lo hace respecto del inventario del patrimonio final (art. 1792-16). Por ello, pareciera que las deudas deberán acreditarse mediante prueba escrita, o en caso de imposibilidad de procurarla por otros medios probatorios admisibles según las reglas generales.

d) Valorización del activo originario.

Interesa destacar dos aspectos:

- Forma como se valorizan los bienes, y
- Quién practica la valoración.

Respecto al primer punto, el artículo 1792-13, inciso 1°, expresa que *“Los bienes que componen el activo originario se valoran según su estado al momento de la entrada en vigencia del régimen de bienes o de su adquisición. Por consiguiente su precio al momento de la incorporación en el patrimonio será prudencialmente actualizado a la fecha de la terminación del régimen”*.

En cuanto al segundo aspecto, el inciso 2° establece que *“la valoración podrá ser hecha por los cónyuges o por un tercero designado por ellos. En subsidio, por el juez”*.

El inciso final del artículo 1792-13 agrega que *“las reglas anteriores rigen también para la valoración del pasivo”*. Ello quiere decir que tanto el activo como el pasivo del patrimonio originario deben reajustarse, al término del régimen, a los valores que corresponda.

5.3.3 Patrimonio final

Según el art. 1792-6, inc. 2º, se entiende por patrimonio final “el que exista al término de dicho régimen”. Para calcularlo se deben practicar las siguientes operaciones:

a) Forma de calcularlo

1. Deducir del valor total de los bienes de que el cónyuge sea dueño al momento de terminar el régimen, el valor total de las obligaciones que tenga en esa misma fecha (art. 1792-14);
2. En conformidad al artículo 1792-15, se deben agregar “imaginariamente los montos de las disminuciones de su activo, que sean consecuencia de los siguientes actos, ejecutados durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales:

- Donaciones irrevocables que no correspondan al cumplimiento proporcionado de deberes morales o de usos sociales, en consideración a la persona del donatario;
- Cualquier especie de actos fraudulentos o dilapidación en perjuicio del otro cónyuge;
- Pago de precios de rentas vitalicias u otros gastos que persigan asegurar una renta futura al cónyuge que haya incurrido en ellos. Lo dispuesto en este número no regirá respecto de las rentas vitalicias convenidas al amparo de lo establecido en el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, salvo la cotización adicional voluntaria en la cuenta de capitalización individual y los depósitos en cuentas de ahorro voluntario, los que deberán agregarse imaginariamente conforme al inciso primero del presente artículo”.

Para que proceda la agregación imaginaria deben darse algunos presupuestos:

- a) Que se produzca una disminución del activo del patrimonial final de uno de los cónyuges como consecuencia de algunos de los actos expresamente previstos en la ley y que se han analizado (art. 1792-15, inc. 1º).
- b) Que el acto haya sido ejecutado durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales (art. 1792-15, inc. 1º)
- c) El acto no haya sido autorizado por el otro cónyuge (art. 1792-15, inc. final).

La explicación de agregar cada uno de estos valores es proteger al otro cónyuge de actos que impliquen indebida generosidad (art. 1792-15, N° 1), fraude (art. 1792-15, N° 2º) o que persiguen sólo la utilidad del cónyuge que los hace (art. 1792-15, N° 3). Y por la misma razón, no se siguen estas reglas si el otro cónyuge los autoriza.

Al agregarse al patrimonio final estos rubros, se protege al otro cónyuge, ya que se aumenta la diferencia entre el patrimonio originario y el final, lo que conduce a que sean más altos los gananciales y como consecuencia, más elevado el crédito de participación.

b) Valor acumulable

No hay determinación precisa del valor acumulable. Se habla de que se agregarán imaginariamente “los montos de las disminuciones” del activo del patrimonio final que sean consecuencia de los actos mencionados (art. 1792-15, inc. 1º). La misma norma en su inc. 2º dispone que las agregaciones se harán “considerando el estado que tenían las cosas al momento de su enajenación”. Por otra parte, el art. 1792-17, inc. 2º, dice que los bienes referidos “se apreciarán según el valor que hubieren tenido al término del régimen de bienes”.

Conclusión: el importe acumulable será el valor en dinero que tendrían las cosas al momento del término del régimen, pero considerado su estado en la época en que fueron enajenados.

c) Inventario valorado de los bienes que integran el patrimonio final.

El artículo 1792-16 establece que *“dentro de los tres meses siguientes al término del régimen de participación en los gananciales, cada cónyuge estará obligado a proporcionar un inventario valorado de los bienes y las obligaciones que comprenda su patrimonio final. El juez podrá ampliar este plazo por una sola vez y hasta por igual término”*.

Este inventario será, normalmente, simple, y si está firmado por el cónyuge declarante, hará prueba en favor del otro cónyuge para determinar su patrimonio final. Sin embargo, este último *“podrá objetar el inventario, alegando que no es fidedigno, caso en que podrá usar todos los medios de prueba para demostrar su composición o el valor efectivo del patrimonio del otro cónyuge”* (art. 1792-16, inc. 2º).

Finalmente, el artículo 1792-16 prescribe que *“cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la facción de inventario en conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Civil y requerir las medidas precautorias que procedan”*.

d) Evaluación del activo y pasivo del patrimonio final.

El artículo 1792-17 prescribe: “Los bienes que componen el activo final se valoran según su estado al momento de la terminación del régimen de bienes” (inc. 1º). Las mismas reglas se aplican para la valoración del pasivo (art. 1792-17, inc. final).

La valoración del activo y pasivo será hecha por los cónyuges o por un tercero designado por ellos. En subsidio, por el juez (art. 1792-17, inc. 3º).

e) Sanción al cónyuge que oculta o distrae bienes o simula obligaciones

En conformidad al artículo 1792-18, *“Si alguno de los cónyuges, a fin de disminuir los gananciales, 1) oculta o 2) distrae bienes o 3) simula obligaciones, se sumarán a su patrimonio final el doble del valor de aquéllos o de éstas”*.

Al sumarse al patrimonio final el doble del valor de los bienes ocultados o distraídos o de las obligaciones simuladas, este patrimonio final aumentará y, con ello los gananciales, lo que hará mayor el crédito de participación en favor del otro cónyuge.

Esta norma es similar a la establecida para la sociedad conyugal por el art. 1768.

Se trata de actos manifiestamente dolosos realizados en perjuicio del otro cónyuge, desde que están destinados a disminuir los gananciales para achicar el crédito de participación que deberá pagar este último. Ello explica la sanción. La conducta dolosa deberá probarla el cónyuge que la alegue (arts. 1459 y 1698 inc. 1º).

La acción para hacer efectiva esta sanción prescribe, según René Ramos, en conformidad a lo establecido en el artículo 2332, por tratarse de un hecho ilícito.

f) Situaciones que se siguen al existir diferencias entre el patrimonio originario y el patrimonio final

Para la determinación de los gananciales se debe comparar el patrimonio originario con el patrimonio final. De este cotejo pueden resultar distintas situaciones:

- a) Que el patrimonio final de un cónyuge fuere inferior al originario. En este caso, dice el artículo 1792-19, “sólo él soportará la pérdida” (inciso 1°). La regla es justa, pues debe soportar las consecuencias de su mala administración. En caso que ambos cónyuges presenten pérdidas, éstas no se comparten;
- b) Que sólo uno de los cónyuges haya obtenido gananciales. En este caso, el otro participará de la mitad de su valor (art. 1792-19, inc. 2°);
- c) Que ambos hayan logrado gananciales. En este supuesto, estos gananciales “se compensarán hasta concurrencia de los de menor valor y aquel que hubiere obtenido menores gananciales tendrá derecho a que el otro le pague, a título de participación, la mitad del excedente” (art. 1992-19, inc. 3°). Esta compensación opera por el solo ministerio de la ley.

El crédito de participación en los gananciales será sin perjuicio de otros créditos y obligaciones entre los cónyuges. Así lo establece el artículo 1792-19, inciso final.

5.4 Del Crédito de Participación en los Gananciales.

La ley no ha definido lo que entiende por crédito de participación en los gananciales. Para Ramos, es el que la ley otorga al cónyuge que a la expiración del régimen de participación en los gananciales, ha obtenido gananciales por monto inferior a los del otro cónyuge, con el objeto de que este último, le pague, en dinero efectivo, a título de participación, la mitad del exceso.

5.4.1 Características del crédito de participación

1. Se origina al término del régimen de bienes. Así lo dice el artículo 1792-20. Obsérvese, sin embargo, que si bien el crédito se va a originar a ese momento, su determinación va a resultar sólo una vez que se liquiden los gananciales.
2. Es una obligación que tiene como fuente la ley (art. 1437).
3. Durante la vigencia del régimen, es eventual. Así lo consigna el artículo 1792-20, inciso 2°.
4. Es inenajenable e irrenunciable. En efecto *“Se prohíbe cualquier convención o contrato respecto de este eventual crédito, así como su renuncia, antes del término de régimen de participación en los gananciales”* (art. 1792-20, inciso 2°). Nótese que se trata de una disposición prohibitiva, por lo que su incumplimiento produce nulidad absoluta (arts. 10, 1466, 1682). Nótese también que estas características sólo se dan mientras está vigente el régimen, pues sólo hasta ese momento tiene carácter eventual. Producida su extinción, deja de ser eventual, por lo que nada impide que pueda ser enajenado, transmitido, renunciado. Y ello es así aun antes de que se liquiden los gananciales.
5. Es puro y simple (art. 1792-21, inc. 1°). Ello significa que determinado el crédito de participación (lo que supone que se liquidaron los gananciales), el cónyuge beneficiado puede exigir el pago de inmediato. Sin embargo, en el inciso 2° del artículo 1792-21 se establece una excepción: *“Con todo, si lo anterior causare grave perjuicio al cónyuge deudor o a los hijos comunes, y ello se probare*

debidamente, el juez podrá conceder una año para el pago del crédito, el que se expresará en unidades tributarias mensuales. El plazo no se concederá si no se asegura por el propio deudor o un tercero, que el cónyuge acreedor quedará de todos modos indemne”.

6. Se paga en dinero (art. 1792-21, inc. 1º, parte final). Esta característica no es de orden público, por lo que nada obsta a que los cónyuges acuerden lo contrario. El artículo 1792-22, inciso 1º, establece que “los cónyuges o sus herederos podrán convenir daciones en pago para solucionar el crédito de participación en los gananciales”.

La misma disposición (inc. 2º) ha previsto lo que ocurre si la cosa dada en pago es evicta: “renacerá el crédito, en los términos del inciso primero del artículo precedente -renace la obligación de pagarlo en dinero efectivo y de inmediato-, si la cosa dada en pago es evicta, a menos que el cónyuge acreedor haya tomado sobre sí el riesgo de la evicción, especificándolo”.

7. Goza de una preferencia de cuarta clase. Así lo establece el artículo 2481, N° 3: “La cuarta clase de créditos comprende: 3º Los de las mujeres casadas, por los bienes de su propiedad que administra el marido, sobre los bienes de éste o, en su caso -es el caso del régimen de participación- los que tuvieren los cónyuges por gananciales”.

Sobre este particular, Francisco Merino S. expresa que este privilegio “sólo cabe hacerlo valer frente a obligaciones que contraiga el cónyuge deudor con posterioridad al término del régimen de participación, siendo inoponible a los créditos cuya causa sea anterior a dicho momento...”, pues, en conformidad al art. 1792-25, “estos créditos, entre los que debemos comprender a los comunes o valistas, prefieren al de participación”.

8. Es un derecho transmisible *mortis causa*, y lo es aún cuando sea la muerte del titular la que produzca la disolución del régimen. No lo dice la ley, pero es lo que se concluye del texto del art. 1792-22, que dispone que los cónyuges “o sus herederos” puedan convenir daciones en pago.

9. El crédito de participación en los gananciales no constituye renta para los efectos de la Ley de Impuesto a la Renta. Art. 17 N° 30 de la Ley de la Renta.

5.4.2 Liquidación del crédito

- Por acuerdo de los cónyuges. Si se pone fin a la participación por pacto de separación total de bienes se faculta a los cónyuges para determinar el crédito en la misma escritura en que se pacte la separación total (art. 1723, inc. 3º).
- Si no hay acuerdo, se efectuará judicialmente, mediante procedimiento sumario (art. 1792-26 en relación con el art. 680 CPC). Es competente el juez del domicilio del demandado (art. 134 COT). Terminado el régimen, cualquiera de los cónyuges (o sus herederos si la extinción se debió a la muerte de uno de ellos) tendrá que demandar, en juicio sumario, que se liquiden los gananciales determinándose a cuánto asciende su crédito de participación.

La acción para solicitar esta liquidación de los gananciales prescribe en el plazo de cinco años contados desde la terminación del régimen y no se suspende entre los cónyuges, salvo respecto de los herederos menores (art. 1792-26).

¿Puede ser sometido a arbitraje? No es arbitraje forzoso (art. 227 COT), ni tampoco prohibido (art. 230 COT).



5.4.3 Prescripción de la acción para demandar el pago del crédito de participación.

El artículo 1792-26 establece que la acción para pedir la liquidación de los gananciales prescribe en 5 años contados desde la extinción del régimen, pero no ha dado normas sobre el plazo en que prescribe la acción para exigir el pago del crédito. Por ello ha de concluirse que se aplican en esta materia las reglas generales, de 3 años para la acción ejecutiva y de 5 años para la ordinaria, plazos que se cuentan desde que la obligación se haya hecho exigible (arts. 2514 y 2515). En este sentido Hernán Corral. Agrega este profesor que “el plazo se contará, en el caso de liquidación judicial, desde que queda firme la sentencia que liquide el crédito, o desde el vencimiento del plazo que haya sido fijado para su pago, es decir, desde que la deuda se haya hecho exigible (art. 2414, inc. 2°) y por tratarse de una prescripción ordinaria de largo plazo, admitirá suspensión de acuerdo con las reglas generales (arts. 2509 y 2520)”.

5.4.4 Bienes sobre los cuales se puede hacer efectivo el crédito de participación

Si el cónyuge que está obligado a pagar no lo hace, procederá el cumplimiento forzado. Y, en este caso, la ley establece un orden respecto de los bienes sobre los cuales se hará efectivo el cobro. Dice al respecto el artículo 1792-24: *“El cónyuge acreedor perseguirá el pago, primeramente, en el dinero del deudor; si éste fuere insuficiente, lo hará en los muebles y, en subsidio, en los inmuebles”*.

5.4.5 Insuficiencia de bienes del cónyuge deudor

Si los bienes del cónyuge deudor fueren insuficientes para hacer efectivo el pago del crédito de participación, el acreedor podrá “perseguir su crédito en los bienes donados entre vivos, sin su consentimiento, o enajenados en fraude de sus derechos” (art. 1792-24, inc. 2°).

Como puede observarse, la ley otorga en este caso dos acciones al cónyuge perjudicado:

- a) Una acción de inoficiosa donación, que deberá dirigirse en contra de los donatarios en un orden inverso al de sus fechas, esto es, principiando por las más recientes, y
- b) La acción pauliana, si la enajenación la efectuó el cónyuge deudor en fraude de los derechos del cónyuge acreedor.

La primera acción prescribe en el plazo de 4 años contados desde la fecha del acto (donación).

En el caso de la acción pauliana, prescribirá, en concepto de René Ramos, conforme a las reglas generales, en un año contado desde la fecha del acto o contrato fraudulento (art. 2468, N° 3). Hernán Corral tiene una opinión distinta. Sostiene que la acción del art. 1796-24 sólo es una acción revocatoria especial, que presenta semejanzas con la acción revocatoria del artículo 2468 (en la enajenación fraudulenta) y con la de inoficiosa donación del artículo 1187 (respecto de las donaciones). Y afirma que la prescripción de que trata la parte final del inciso 2° es siempre de 4 años contados desde la fecha del acto que se pretende revocar.

5.4.6 Los créditos de terceros, anteriores a la extinción del régimen, prefieren al crédito de participación

Así lo establece el artículo 1792-25: *“Los créditos contra un cónyuge cuya causa sea anterior al término del régimen de bienes, preferirán al crédito de participación en los gananciales”*.

Esta norma guarda relación con lo dispuesto en el artículo 1792-14, que obliga, para calcular el patrimonio final, a deducir previamente las obligaciones que el cónyuge tenga al término del

régimen. Pretende evitar el perjuicio de los acreedores de los cónyuges por obligaciones que éstos hubieren contraído durante la vigencia del régimen.

5.5 Relación entre el Régimen de Participación en los Gananciales y los Bienes Familiares.

La institución de los bienes familiares puede operar cualquiera sea el régimen matrimonial bajo el cual los cónyuges se encuentran casados. Para el caso de que lo estén en el de participación en los gananciales, el artículo 1792-23 establece que *“Para determinar los créditos de participación en los gananciales, las atribuciones de derechos sobre bienes familiares, efectuadas a uno de los cónyuges en conformidad con el artículo 147 del Código Civil, serán valoradas prudencialmente por el juez”*.

En conformidad al artículo 147 del Código Civil, el juez puede constituir sobre un bien familiar, de propiedad de uno de los cónyuges, derechos de usufructo, uso o habitación en favor del otro. Pues bien, en tal caso esos derechos tendrán que ser valorados para determinar el crédito de participación, y tal valoración la hará el juez. Esa es la explicación de lo dispuesto en el artículo 1792-23.

5.6 Extinción del Régimen de Participación en los Gananciales.

El artículo 1792-27 prescribe que “el régimen de participación en los gananciales termina:

- 1) Por la muerte de uno de los cónyuges.
- 2) Por la presunción de muerte de uno de los cónyuges según lo prevenido en el Título II, “Del principio y fin de la existencia de las personas”, del Libro I del Código Civil.
- 3) Por la declaración de nulidad de matrimonio o sentencia de divorcio.
- 4) Por la separación judicial de los cónyuges.
- 5) Por la sentencia que declare la separación de bienes.
- 6) Por el pacto de separación de bienes”.

Esta disposición es equivalente al artículo 1764, que establece las causales de extinción de la sociedad conyugal. Es necesario, sin embargo, precisar lo siguiente:

En el caso de la muerte presunta, la extinción se produce con el decreto de posesión provisoria. Así lo establece el artículo. Naturalmente que en aquellas situaciones en que no haya decreto de posesión provisoria, la extinción se producirá con el decreto de posesión definitiva.

En el caso de la nulidad de matrimonio, sólo operará la extinción del régimen cuando el matrimonio sea putativo, pues si es simplemente nulo, no ha existido matrimonio y por lo mismo no se generó régimen matrimonial alguno, en virtud del efecto retroactivo de la declaración de nulidad, artículo 1687.

En el caso de la separación judicial de los cónyuges, el artículo 34 de la Ley de Matrimonio Civil reitera que ella produce la extinción del régimen de participación en los gananciales. Por otra parte, como el matrimonio se mantiene, lo que hace necesario un régimen matrimonial, el art. 173 del Código Civil señala que en tal situación los cónyuges se considerarán separados de bienes.

En el caso de la sentencia que declare la separación de bienes cualquiera de los cónyuges puede pedir la separación judicial de bienes, por las mismas causas que rigen para la sociedad conyugal (art. 158 inc. 1º).

5.7 Efectos Del Término del Régimen.

La disolución del régimen de participación produce las siguientes consecuencias jurídicas:

1. Continuación de la separación patrimonial.

Los patrimonios de los cónyuges o sus herederos permanecen separados, sin que se forme comunidad de gananciales: *"A la disolución del régimen de participación en los gananciales los patrimonios de los cónyuges permanecerán separados, conservando éstos o sus causahabientes plenas facultades de administración y disposición de sus bienes"* (art. 1792-5).

2. Comunidad sobre bienes muebles.

No obstante lo anterior, al término del régimen de participación se presumen comunes los bienes muebles adquiridos durante él, salvo los que son de uso personal de los cónyuges (art. 1792-12). La presunción de comunidad se aplica a los bienes muebles que hayan sido adquiridos durante la vigencia del régimen y que existan al momento de su terminación en poder de cualquiera de los cónyuges.

Como la ley no distingue, ha de estimarse que la presunción resulta aplicable tanto a los bienes corporales como a los incorporales. La presunción no se aplica, sin embargo, a los bienes muebles "de uso personal", quedando esta calificación entregada a la prudencia de los tribunales, que decidirán caso por caso.

Corral entiende que la presunción de comunidad se aplica tanto entre los cónyuges como respecto de terceros, pero en todo caso ella rige sólo una vez terminado el régimen de participación y no durante su vigencia.

Se trata de una presunción simplemente legal, pero la prueba en contrario debe fundarse en antecedentes escritos (art. 1792-12), por lo que no bastará ni la prueba testimonial ni la confesión. La prueba contraria debe ser producida por el cónyuge (o sus causahabientes) que alegue dominio exclusivo, o por los terceros que invoquen derechos sobre dichos bienes derivados de actos del cónyuge que suponían propietario. Es criticable que la presunción se aplique a los terceros, sin que existan normas protectoras a la buena fe, como la que expresamente contiene el art. 1739 inc. 4º para la sociedad conyugal.

Si la presunción no es destruida, se formará un cuasicontrato de comunidad, que será necesario liquidar de acuerdo con las reglas generales (arts. 2313 y 1317 y ss.). De esta forma, el régimen de participación que establece la ley no es puramente de crédito, sino que puede contemplar también la comunidad de bienes.

3. Fijación de los gananciales de cada cónyuge.

A la fecha de la disolución, "se determinarán los gananciales obtenidos durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales" (art. 1792-5, inc. 2º). Los bienes que componen el patrimonio de los cónyuges a esa fecha, deducidas las deudas existentes, constituyen el patrimonio final que se comparará con el existente al comenzar el régimen, para determinar entonces el monto de los gananciales.

Los bienes adquiridos por los cónyuges, como también las obligaciones contraídas con posterioridad a esa fecha no se tomarán en cuenta para la determinación de dichos gananciales.

4. Compensación del valor de los gananciales.

Si ambos cónyuges han obtenido ganancias, al finalizar el régimen se compensan esos gananciales hasta el monto de los de menor valor, y sobre el excedente, tienen derecho a participar por mitades. Así lo establece la ley: "Al finalizar la vigencia del régimen de bienes, se compensa el valor de los gananciales obtenidos por los cónyuges y éstos tienen derecho a participar por mitades en el excedente" (art. 1792-2, inc. 1º, parte final).

5. Crédito de participación.

El derecho a participar en los gananciales se traduce en el surgimiento de un crédito a favor del cónyuge que obtuvo menos ganancias, cuyo monto ascenderá a la mitad del excedente ya referido. Se trata de un derecho personal, que surge solamente una vez que se ha disuelto el régimen de participación y siempre que existan diferencias de gananciales entre los cónyuges. Dispone la ley que "El crédito de participación en los gananciales se originará al término del régimen de bienes" (art. 1792-20, inc. 1º).

Esta opción por la modalidad crediticia ha sido cuestionada por quienes hacen ver que habría sido más conforme con nuestra tradición jurídica el que el régimen de participación diera lugar a una comunidad diferida. A ello se suma el hecho de que habría una mayor protección efectiva si el cónyuge fuera copropietario de los bienes finales y no un mero acreedor.

Unidad 7: Los Bienes Familiares.

La institución de los bienes familiares fue incorporada por la ley Nº 19.335, mediante una modificación al Código Civil, en cuya virtud agregó un párrafo, que pasó a ser el párrafo 2º, al Título VI del Libro I del Código Civil, compuesto de 9 artículos, 141 al 149 inclusive.

Los antecedentes de esta institución los encontramos en el **Código Civil español**, después de la reforma introducida en 1981, y en el **Código de Quebec**. En el primero, el artículo 1320 establece que **"para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial"** (inc. 1º). La semejanza de esta norma, con los bienes familiares creados por la ley 19.335 es manifiesta.

Por su parte el artículo 449 del Código de Quebec dispone que la vivienda familiar y su mobiliario no puedan ser enajenados sino con el consentimiento de ambos cónyuges. A falta de acuerdo, la autorización debe darla la justicia. Como podrá observarse lo mismo ocurre en Chile.

Está claro que la ley Nº 19.335, se inspiró en estos ordenamientos positivos extranjeros.

Tema 1: Fundamento de la institución.

Con esta institución se persigue asegurar a la familia un hogar físico estable donde sus integrantes puedan desarrollar la vida con normalidad, aun después de disuelto el matrimonio. Como señala un autor la introducción del patrimonio familiar es una fuerte garantía para el cónyuge que tenga el cuidado de los hijos, en casos de separación de hecho o de disolución del matrimonio, y para el cónyuge sobreviviente, en caso de muerte. En el caso del cónyuge sobreviviente, apunta al mismo fin la incorporación de la asignación preferencial incorporada por la ley 19.585, al agregar un nuevo número al artículo 1337 (normas dadas al partidor para cumplir su cometido).

La institución que estamos tratando evita que las disputas patrimoniales entre los cónyuges o entre el sobreviviente y los herederos del otro cónyuge, concluyan con el desarraigo de la residencia habitual de la familia y es una garantía mínima de estabilidad para el cónyuge patrimonialmente más débil (Enrique Barros Bourie).

Tema 2: Ámbito de aplicación.

Los Bienes Familiares tienen cabida cualquiera sea el régimen matrimonial a que se encuentre sometido el matrimonio. Lo declara así, en forma expresa, la parte final del inciso 1º del artículo 141. Por lo demás, si nada se hubiere dicho, de todas formas así resultaría por formar parte este nuevo párrafo -"De los Bienes Familiares"- del Título VI del Código Civil "Obligaciones y Derechos entre los cónyuges".

Tema 3: Bienes que pueden ser declarados familiares.

En conformidad a lo que disponen los artículos 141 y 146, la declaración de familiar puede recaer únicamente sobre los bienes siguientes:

a) El inmueble de propiedad de uno o de ambos cónyuges, que sirva de residencia principal a la familia (art. 141).

Luego, el inmueble puede ser propio de un cónyuge, de ambos, social o reservado de la mujer.

Los autores concuerdan en que, como es requisito que el inmueble tenga que servir de residencia principal a la familia, ello implica que tiene que ser uno solo; y que no quedan comprendidos en el concepto, las casas de veraneo o de descanso.

b) Los bienes muebles que guarnecen el hogar (art. 141).

En general la doctrina entiende que estos bienes son los señalados en el artículo 574 del Código Civil que forman el ajuar de una casa.

c) Los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias del inmueble que sea residencia principal de la familia (art. 146).

Para que nos encontremos en este caso, tienen que cumplirse los siguientes requisitos: 1) que la familia tenga su residencia principal en un inmueble que sea de propiedad de una sociedad; y 2) que uno o ambos cónyuges tengan acciones o derechos en esa sociedad.

Tema 4: Forma de constituir un bien como familiar.

En cuanto a la forma de constituir un bien como familiar, debemos hacer una distinción, según que el bien en que incide la declaración sea de propiedad de uno de los cónyuges o de una sociedad en la que uno o ambos cónyuges tengan acciones o derechos. En el primer caso, rige la norma del artículo 141; y en el segundo, la del artículo 146.

a) Constitución de bien familiar de un inmueble de propiedad de uno de los cónyuges.

El inc. 2º del art. 141, con la redacción de la ley 19.968, dice: "El juez citará a los interesados a la audiencia preparatoria. Si no se dedujese oposición, el juez resolverá en la misma audiencia. En caso contrario, o si el juez considerase que faltan antecedentes para resolver, citará a la audiencia de juicio".

El proyecto original establecía que la declaración de bien familiar podía hacerla cualquiera de los cónyuges, mediante escritura pública, anotada al margen de la inscripción de dominio respectiva. Posteriormente se cambió a la forma actual, por cuanto el Senado consideró que "por razones de prudencia era conveniente entregar la declaración de bien familiar a la decisión de un órgano jurisdiccional..." y así fue finalmente aprobado.

Lo anterior explica lo establecido en el inciso final del artículo 141. En efecto, esta disposición expresa que "el cónyuge que actúe fraudulentamente para obtener la declaración a que se refiere este artículo -entiéndase de bien familiar- deberá indemnizar los perjuicios causados, sin perjuicio de la sanción penal que pudiere corresponderle". Tal precepto tenía sentido en el proyecto original, pero dejó de tenerlo cuando se aprobó que la declaración de familiar la hacía la justicia, pues al ocurrir así, mal puede hablarse de declaración fraudulenta de un cónyuge.

a.1) Constitución provisoria.

Si bien, como se acaba de explicar, la declaración como bien familiar la hace la justicia, el inciso 3º del artículo 141, dispone que "con todo, la sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien de que se trate". Después continúa la norma señalando que "en su primera resolución el juez dispondrá que se anote al margen de la inscripción respectiva la precedente circunstancia" y termina expresando que "el Conservador practicará la subinscripción con el solo mérito del decreto que, de oficio, le notificará el tribunal".

De manera que basta que se interponga la demanda al tribunal, para que provisoriamente quede transformado el bien en familiar. Este aspecto de la ley, ha sido el más controvertido. El profesor Hernán Corral dice: "el artículo 141 del Código Civil dispone, para asombro de todos quienes tienen algún grado de conocimiento jurídico, que "la sola presentación de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien de que se trate". Esto, lisa y llanamente, quiere decir que con sólo dejar una demanda en el mesón del tribunal, y sin que siquiera se haya proveído o notificado al cónyuge propietario, los bienes pasan a la categoría de familiares -y como resultado- cualquier enajenación, gravamen, hipoteca e incluso arrendamiento o simples préstamos de uso (comodatos), son anulables si no cuenta con el consentimiento también del cónyuge no propietario demandante". De esta forma los terceros se verían afectados y además entre los cónyuges se rompe el principio de la bilateralidad de la audiencia.

Carlos Peña afirma que la interpretación anterior es equivocada, si bien admite que el art. 141 no quedó redactado adecuadamente. Su posición es que la inscripción en el Conservador tiene por objeto justamente hacer oponible al tercero la declaración de familiar del bien, de tal suerte que mientras tal inscripción no se practique, el tercero no se puede ver afectado. Sostiene que con la interpretación de Corral dejaría de tener sentido la obligación de practicar la inscripción.

Ramos concluye que hay que entender que lo que el art. 141 inc. 3º ha querido decir es que para que el bien sea familiar no es necesario esperar a que exista sentencia firme, teniendo provisoriamente tal carácter respecto del cónyuge propietario, cuando se presenta la demanda al tribunal; y respecto de los terceros, desde que se practique la correspondiente subinscripción en el Conservador.

El inc. 3º dispone que "en su primera resolución el juez dispondrá que se anote al margen de la inscripción respectiva la precedente circunstancia". La ley no dice cuál es esa "inscripción respectiva", pero lo razonable es entender que lo será la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad, de manera que al margen de esa inscripción deberá practicarse la anotación.

a.2) Titular de la acción para demandar la constitución de un bien como familiar.

La acción para demandar la constitución de un bien como familiar sólo compete al cónyuge no propietario. Los hijos, en consecuencia, no son titulares de ella aun cuando puedan resultar beneficiados con la declaración. Así fluye de los arts. 141 inciso final, artículos 142, 143 y 144, que hablan de cónyuges. En este sentido Eduardo Court y Claudia Schmidt.

b) Constitución de familiar de los bienes muebles que guarnecen el hogar.

La ley no se ha puesto en el caso de que la declaración de familiar recaiga exclusivamente, sobre los bienes muebles que guarnecen el hogar. A Ramos le parece obvio que en tal supuesto, la declaración tendrá que hacerse por la justicia. Sin embargo, en este caso, atendida la naturaleza de los bienes,

no procede hacer inscripción de ningún tipo, no siendo aplicable el inciso 3º de la misma disposición. Así lo entiende también Leslie Tomasello.

c) Constitución como bien familiar de las acciones y derechos del cónyuge en la sociedad propietaria del bien raíz en que tiene la residencia principal la familia.

En conformidad al artículo 146 inc. 3º "la afectación de derechos (o acciones) se hará por declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en escritura pública. En el caso de una sociedad de personas, deberá anotarse al margen de la inscripción social respectiva, si la hubiere. Tratándose de sociedades anónimas, se inscribirá en el registro de accionistas".

Como puede observarse, esta declaración es solemne, siendo la solemnidad la escritura pública.

Si la sociedad fuere colectiva civil, como no están sujetas al régimen de inscripción, no será posible cumplir con el requisito de inscripción o anotación. Por eso el artículo 146 emplea la frase "si la hubiere".

Tema 5: Efectos de la declaración de bien familiar.

La declaración de familiar de un bien no lo transforma en inembargable, por lo que no se causa perjuicio a terceros; sólo limita la facultad de disposición de su propietario (que ya no lo podrá enajenar o gravar ni prometer enajenar o gravar, ni ceder la tenencia, sin la autorización de su cónyuge) y otorga al cónyuge en cuyo favor se hace la declaración, un beneficio de excusión, con el objeto de que si el bien familiar es embargado por un tercero, pueda exigir que antes de procederse en contra de dicho bien se persiga el crédito en otros bienes del deudor.

a) Limitación a la facultad de disposición.

Esta limitación será diferente según: a) el bien que se declara familiar sea el inmueble que sirva de residencia principal a la familia, o los bienes muebles que guarnecen el hogar, o b) se trate de las acciones o derechos que los cónyuges tengan en una sociedad propietaria del bien raíz que sirve de residencia principal a la familia.

En el primer caso, el efecto está consignado en el artículo 142 inciso 1º: "No se podrán enajenar ni gravar voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, los bienes familiares, sino concurriendo la voluntad de ambos cónyuges. Lo mismo regirá para la celebración de contratos que concedan derechos personales de uso o goce sobre algún bien familiar" (arrendamiento, comodato). Agrega el inciso 2º que "La autorización a que se refiere este artículo deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura pública si el acto exigiere esa solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el caso".

En el segundo caso, el efecto está indicado en el artículo 146 inc. 2º: "Producida la afectación de derechos o acciones, se requerirá asimismo la voluntad de ambos cónyuges para realizar cualquier acto como socio o accionista de la sociedad respectiva, que tenga relación con el bien familiar" (la expresión bien familiar en este inciso, es impropia, desde que el bien no es de ninguno de los cónyuges sino de la sociedad en que los cónyuges son socios). Luego, el cónyuge propietario, en este caso, queda sujeto a una doble limitación: 1. no puede disponer de los derechos o acciones en la sociedad, sino con autorización del otro cónyuge o de la justicia en subsidio (art. 142); y, 2. requiere

de la voluntad del otro cónyuge para realizar los actos que deba hacer como socio o accionista, siempre que recaigan sobre el bien familiar.

a.1) Autorización judicial subsidiaria.

El artículo 144 establece que "En los casos del artículo 142, la voluntad del cónyuge no propietario de un bien familiar podrá ser suplida por el juez en caso de imposibilidad o negativa que no se funde en el interés de la familia. El juez resolverá previa audiencia a la que será citado el cónyuge, en caso de negativa de éste" (redacción de la Ley 19.968).

¿Puede darse la autorización judicial supletoria en el caso del artículo 146? El problema se presenta porque el artículo 144 sólo establece tal autorización "en los casos del artículo 142". A juicio de Ramos, al no estar expresamente establecida para el caso que nos ocupa, la autorización judicial, ella no es procedente. Al parecer, tiene una opinión contraria Tomasello, ya que al tratar el artículo 146, expresa que "en cuanto a la forma de manifestarse la voluntad del cónyuge no socio o accionista de la sociedad respectiva, son aplicables los artículos 142 y 144 y, en cuanto a la sanción, el artículo 143".



a.2) Sanción para el caso de que se realicen estos actos sin la autorización del cónyuge no propietario.

La sanción es la nulidad relativa, correspondiendo la acción rescisoria al cónyuge no propietario. Así lo dice el artículo 143 inciso 1º. En el caso del artículo 146, también la sanción es la nulidad relativa, pero no por aplicación del artículo 143 (que sólo hace referencia al artículo anterior), sino de las reglas generales, por haberse omitido un requisito establecido en atención al estado o calidad de las partes.

No señala la ley desde cuándo se debe contar el cuadrienio para alegar la nulidad relativa. Ramos piensa que debe comenzar a correr desde la celebración del acto o contrato. En ese sentido Claudia Schmidt. Court, en cambio, es de opinión que en esta materia, debería seguirse la misma fórmula que el artículo 1792-4 señala en el régimen de participación, esto es, que el cuadrienio se cuente desde el día en que el cónyuge que alega la nulidad tomó conocimiento del acto. Ello siempre, que se aplique también la limitación de los 10 años, que ese artículo contempla.

a.3) Efectos de la nulidad respecto de los terceros adquirentes de un bien familiar.

El artículo 143 en su inciso 2º establece que "Los adquirentes de derechos sobre un inmueble que es bien familiar, estarán de mala fe a los efectos de las obligaciones restitutorias que la declaración de nulidad origine".

Es una presunción de derecho y rige únicamente para la enajenación de bienes inmuebles. No para los muebles, por no encontrarse sujetos a registro. Para ellos mantienen su vigencia el artículo 1687 y la presunción de buena fe del artículo 707.

b) Beneficio de excusión en favor del cónyuge beneficiado con la declaración de bien familiar.

La constitución de un bien, como familiar, no le da el carácter de inembargable. Sin embargo, y con el objeto de proteger al cónyuge beneficiado con tal declaración, se le otorga un beneficio de excusión, para que pueda "exigir que antes de proceder contra los bienes familiares se persiga el crédito en otros bienes del deudor" (art. 148). Este beneficio se debe hacer valer como excepción dilatoria (art. 303 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil).

Las disposiciones del Título XXXVI del Libro Cuarto sobre la fianza se aplicarán al ejercicio de la

excusión, en cuanto corresponda.

El artículo 148 en su inciso 2º establece que "Cada vez que en virtud de una acción ejecutiva deducida por un tercero acreedor, se disponga el embargo de algún bien familiar de propiedad del cónyuge deudor, el juez dispondrá se notifique personalmente el mandamiento correspondiente al cónyuge no propietario. Esta notificación no afectará los derechos y acciones del cónyuge no propietario sobre dichos bienes".

La finalidad de esta notificación es que el cónyuge no propietario, pueda plantear el beneficio de excusión, mediante la correspondiente excepción (art. 464 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil).

c) Derechos de usufructo, uso o habitación constituidos judicialmente sobre un bien familiar.

El artículo 147 inciso 1º, prescribe que "durante el matrimonio, el juez podrá constituir, prudencialmente, a favor del cónyuge no propietario, derechos de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares". Agrega que "en la constitución de estos derechos y en la fijación del plazo que les pone término, el juez tomará especialmente en cuenta el interés de los hijos, cuando los haya, y las fuerzas patrimoniales de los cónyuges" y termina señalando que "el tribunal podrá, en estos casos, fijar otras obligaciones o modalidades si así pareciere equitativo".

En relación con la constitución de estos gravámenes, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) El título de estos derechos reales, lo constituye la resolución judicial. Así lo consigna el inciso 2º del artículo 147: "La declaración judicial a que se refiere el inciso anterior servirá como título para todos los efectos legales". Esta sentencia deberá inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes, respectivo (artículos 32 inciso 2º y 52 Nº 1 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces).

b) La sentencia judicial que constituya estos derechos debe determinar el plazo de término. No pueden tener el carácter de vitalicios. Cumplido el plazo se extinguen (arts. 804 y 812).

c) Estos gravámenes no podrá afectar los derechos de los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la fecha de su constitución (art. 147, inc. 3º).

d) No aprovechan a los acreedores que el cónyuge no propietario tuviere en cualquier momento (art. 147, inc. 3º).

c.1) Tribunal competente y procedimiento para constituir estos derechos.

A partir del 1º de octubre de 2005, en que entran en vigencia los Tribunales de Familia, esta materia será de competencia de esos tribunales -artículo 8 Nº 15 letra c) de la ley 19.968- que conocerá de ella en el procedimiento establecido en los artículos 55 y siguientes de la misma ley.

c.2) Si los cónyuges estuvieren casados en régimen de participación en los gananciales, la constitución de estos gravámenes deberá considerarse al fijarse el crédito de participación.

Así lo señala el artículo 1792-23: "Para determinar los créditos de participación en los gananciales, las atribuciones de derechos sobre bienes familiares, efectuadas a uno de los cónyuges en conformidad al artículo 147 del Código Civil, serán valoradas prudencialmente por el juez".

La norma resulta absolutamente justificada pues, en caso contrario, el cónyuge beneficiado con estos derechos reales, estaría recibiendo un doble beneficio.

Tema 6: Desafectación de un bien familiar.

Regla esta materia el artículo 145, estableciendo tres formas de desafectación:

a) Por acuerdo de los cónyuges, caso en que cuando se refiera a un inmueble debe constar en escritura pública que debe anotarse al margen de la inscripción respectiva (art. 145 inc. 1º).

No resuelve la ley si del mismo modo se hace la desafectación en el caso de las acciones o derechos en sociedades propietarias del inmueble donde tiene residencia principal la familia. Claudia Schmidt, considera que deberá cumplirse con las mismas formalidades.

b) Por resolución judicial, recaída en juicio seguido por el cónyuge propietario en contra del no propietario, fundado en que el bien no está destinado a los fines que indica el artículo 141, esto es que no sirve de residencia principal a la familia si se trata de un inmueble o, tratándose de muebles, que no guarnecen el hogar común, lo que deberá probar.

c) Por resolución judicial “cuando el matrimonio ha sido declarado nulo o ha terminado por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio. En tales casos el propietario del bien familiar o cualquiera de sus causahabientes deberá formular al juez la petición correspondiente” (art. 145 inciso final). Luego, la simple extinción del matrimonio, no produce de pleno derecho la desafectación del bien, pues aun disuelto el matrimonio, el bien puede continuar siendo la residencia principal de la familia, caso en que no cabe la desafectación.

Unidad 8: Filiación.

Se la ha definido como **"el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o con su madre y que consiste en la relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente, o sea, su descendiente en primer grado"** (Enrique Rossel). Somarriva dice que "es la relación de descendencia entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra" o, "dicho en otros términos: es la relación que existe entre padre e hijo".

El fundamento de toda filiación es el vínculo de sangre existente entre el padre y el hijo, proveniente de las relaciones sexuales, lícitas o ilícitas, de los padres. Hace excepción a esta regla, la llamada filiación adoptiva.

Al legislador preocupan dos aspectos de la filiación: su establecimiento con la mayor certidumbre, y la regulación de sus efectos, o sea los derechos y obligaciones existentes entre padres e hijos.

Tema 1: La filiación en el Código Civil originario y sus cambios.

Una de las ideas fundamentales del Código Civil fue la distinción entre **la filiación legítima, natural e ilegítima**, y la protección que se otorgó a la primera. En términos generales, esta situación se mantuvo inmovible hasta el año 1952, en que la ley 10.271 mejoró sustancialmente la situación de los hijos naturales pero sin llegar a otorgarles los mismos derechos que a los hijos legítimos. Tuvieron que transcurrir más de 45 años, para que esta discriminación odiosa desapareciera, y todos los hijos pasaran a tener los mismos derechos. Ello viene a ocurrir recién con la ley Nº 19.585, publicada en el Diario Oficial del 26 de octubre de 1998.

La ley 19.585 eliminó la distinción entre filiación legítima, natural e ilegítima. No pudo sin embargo, prescindir de un hecho que es más fuerte que su intención de igualar a todos los hijos: que hay hijos que nacen en el matrimonio de sus padres y otros que son el fruto de relaciones extramatrimoniales.

No es cierto entonces que haya igualado a todos los hijos, porque ello es contrario a la realidad. La nueva normativa sólo ha conferido a todos los hijos los mismos derechos. Como dice Daniel Peñailillo, "establece la igualdad de efectos, es decir, de derechos y cargas, entre todos los hijos, con prescindencia del origen de la filiación, y esa idea igualitaria se expande hacia los padres (manifestándose destacadamente en el acceso al cuidado personal y a la patria potestad)".

Tema 2: Clases de filiación

Con las modificaciones introducidas por las leyes Nºs 19.585 y 19.620, la filiación admite las siguientes clasificaciones:

2.1 Filiación por naturaleza, que puede ser: 1) determinada y 2) no determinada.

La filiación determinada se clasifica a su vez en: a) matrimonial; b) no matrimonial; y c) por fecundación mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida (arts. 179, 180, 181

y 182.).

2.1.1 Filiación matrimonial.

Dice el artículo 179 que “La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial”. Y en conformidad al artículo 180, la filiación matrimonial se produce en los siguientes casos:

- a) Cuando al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo exista matrimonio entre los padres (art. 180 inc. 1º);
- b) Cuando con posterioridad al nacimiento del hijo, los padres contraen matrimonio entre sí, siempre que a la fecha del matrimonio, la paternidad y la maternidad hayan estado previamente determinadas por los medios que el Código establece (art. 180 inc. 2º);
- c) Si la paternidad o la maternidad no estuviere determinada con anterioridad al matrimonio de sus padres, habrá filiación matrimonial si los padres han reconocido al hijo en el acto del matrimonio o durante su vigencia en la forma prescrita en el artículo 187 (art. 180 inc. 2º);

Los elementos de la filiación matrimonial son la maternidad, paternidad y matrimonio.

2.1.2 Filiación no matrimonial.

Es la que existe fuera de los casos anteriores. Así lo señala el inciso final del artículo 180: “En los demás casos, la filiación es no matrimonial”.

Los elementos de la filiación no matrimonial son sólo la paternidad, la maternidad o ambos.

2.1.3 Filiación del hijo concebido mediante técnicas de reproducción asistida.

La situación del hijo concebido mediante estas técnicas está regulada en el artículo 182. Esta disposición establece dos ideas fundamentales:

- a) El padre y la madre de este hijo son el hombre y la mujer que se sometieron a la aplicación de estas técnicas (inc. 1º): y
- b) No se puede en este caso impugnar la filiación; ni se admite reclamar una filiación diferente (inc. 2º).

De acuerdo a lo que se acaba de expresar, en el caso en que en la aplicación de estas técnicas se hubiere recurrido a un tercero (donante de espermios o de óvulos; o utilización de un útero ajeno), el hijo ni el tercero tendrían acción de reclamación de filiación. Por su parte, ni los padres ni el hijo podrían impugnar esta filiación.

En esta forma el legislador chileno, cierra la puerta a juicios difíciles, a veces escandalosos, como los que han tenido que conocer y resolver los tribunales extranjeros.

2.2 Filiación adoptiva.

Esta filiación queda regulada por la ley 19.620.

El artículo 179 inciso 2º establece que “la adopción, los derechos entre adoptante y adoptado y la filiación que pueda establecerse entre ellos, se rigen por la ley respectiva”.

Tema 3: Determinación de la filiación.

Para estudiar esta materia es necesario hacer las siguientes distinciones:

3.1 Determinación de la maternidad.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 183, hay tres formas de determinar la maternidad:

- a) Por el parto, cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz constan en las partidas del Registro Civil;
- b) Por el reconocimiento de la madre; y
- c) Por sentencia judicial firme, recaída en un juicio de filiación.

3.2 Determinación de la filiación matrimonial.

La filiación matrimonial queda legalmente determinada de tres maneras:

- a) Por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus padres, con tal que la maternidad y paternidad estén legalmente establecidas en conformidad con los arts. 183 y 184, respectivamente (art. 185, inc. 1º).
- b) Tratándose del hijo nacido antes de casarse sus padres, la filiación matrimonial queda determinada por la celebración del matrimonio, siempre que la maternidad y la paternidad estén ya determinadas por el reconocimiento de los padres o por sentencia firme en juicio de filiación o, en caso contrario, por el último reconocimiento efectuado conforme a lo establecido en los arts. 187 y siguientes (art. 185, inc. 2º).
- c) Por último, la filiación matrimonial puede también ser determinada por sentencia dictada en juicio de filiación, que debe subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo (art. 185, inc. 3º). Ejemplo: concepción antes del matrimonio y desconocimiento judicial del marido (art. 184, inc. 2º)

- **Presunción de paternidad**

El artículo 184 establece una presunción de paternidad: “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges” (presunción *pater is est*).

Esta presunción es distinta a la establecida en el artículo 180 del Código Civil anterior a la ley 19.585, pues en aquella se presumía la paternidad de los hijos nacidos después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio, lo que se fundamentaba en la regla del artículo 76, que da normas para determinar la fecha de la concepción. Hoy es diferente, pues se presume la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio, en cualquier tiempo, salvo el caso de los nacidos después de los 300 días de decretada la separación judicial, con lo que claramente la norma se separa de la regla del

artículo 76.

La presunción se apoya en el hecho de que el marido al tiempo de casarse haya tenido conocimiento del embarazo de la mujer. Por ello el inciso 2º del art. 184 establece que “no se aplicará esta presunción respecto del que nace antes de expirar los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, si el marido no tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse...”. La excepción se acerca, ahora sí, a la regla del artículo 76.

Pero el marido, en este caso, puede desconocer la paternidad interponiendo la correspondiente acción de desconocimiento de paternidad que se tramita en el plazo y forma de la acción de impugnación, pero no podrá ejercerla si por actos positivos ha reconocido al hijo después de nacido (art. 184 inc. 2º). Será entonces el hijo quien tendrá que probar que su padre se casó con conocimiento del estado de preñez de su madre lo que deberá hacer en el correspondiente juicio de desconocimiento de paternidad iniciado por su padre, artículo 212.

En el caso de los hijos nacidos después de 300 días de decretada la separación judicial de sus padres, por excepción opera la presunción de paternidad por el hecho de consignarse como padre el nombre del marido, a petición de ambos cónyuges, en la inscripción de nacimiento del hijo. La excepción es ampliamente justificada, pues si los dos padres piden que se consigne como padre al marido ello implica un manifiesto reconocimiento de paternidad. Para que opere esta excepción, debe consignarse como padre el nombre del marido, a petición de ambos cónyuges, no bastando en consecuencia, la sola voluntad del marido o de la mujer (art. 184 inc. 3º).

En todo caso, “la paternidad así determinada o desconocida podrá ser impugnada o reclamada, respectivamente, de acuerdo con las reglas establecidas en el Título VIII” (art. 184 inc. final).

3.3 Determinación de la filiación no matrimonial

Hay dos formas de determinar la filiación no matrimonial: a) **por reconocimiento voluntario de los padres**; o b) **por reconocimiento forzado mediante sentencia judicial recaída en un juicio de filiación** (art. 186).

a) Reconocimiento voluntario.

Se puede reconocer a cualquier clase de hijos: mayores, menores, vivos o muertos. La ley no ha establecido ninguna limitación. El artículo 191, al tratar de la repudiación, distingue entre el reconocimiento a un hijo mayor y a uno menor; y el artículo 193, deja en claro que se puede reconocer a un hijo fallecido, al comenzar expresando que “Si es muerto el hijo que se reconoce...”.

a.1) Capacidad para reconocer

Pueden reconocer válidamente los menores adultos, que lo harán por si solos, sin necesidad de ser autorizados o representados por su representante legal. El artículo 262 lo dice expresamente: “El menor adulto no necesita de la autorización de sus padres para disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener efecto después de su muerte, ni para reconocer hijos”.

a.2) Clases de reconocimiento

El reconocimiento puede ser: a) **expreso**; y b) **tácito o presunto**.

- **Reconocimiento voluntario expreso**

Es reconocimiento voluntario expreso, el que se hace mediante una declaración formulada con ese

determinado objeto por el padre, la madre o ambos, en alguno de los instrumentos que indica el artículo 187.

El artículo 187 señala: “El reconocimiento del hijo tendrá lugar mediante una declaración formulada con ese determinado objeto por el padre, la madre o ambos, según los casos: 1º Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de inscribirse el nacimiento del hijo o en el acto del matrimonio de los padres; 2º En acta extendida en cualquier tiempo, ante cualquier oficial del Registro Civil; 3º En escritura pública, o, 4º En un acto testamentario” (inc. 1º).

El reconocimiento debe ser expreso: la declaración del padre, la madre o ambos debe ser formulada con el determinado objeto de reconocer al hijo como tal. No basta una declaración incidental o secundaria, sino que debe tener por objeto preciso el reconocimiento del hijo. Así, por ejemplo, no cumple este requisito un mandato en que se diga “confiero poder a mi hijo...”.

Cuando la declaración se efectúa en el acto del matrimonio de los padres si el reconocimiento lo hacen ambos padres, quedará determinada la filiación matrimonial del hijo (como se desprende del art. 180, inc. 2º), y no la filiación no matrimonial, que supone ausencia del matrimonio.

El Nº 1º de esta disposición debe relacionarse con los artículos 37 y 38 de la ley 4.808. Artículo 37: “El Oficial del Registro Civil no procederá a la inscripción del matrimonio sin haber manifestado privadamente a los contrayentes que pueden reconocer a los hijos comunes nacidos antes del matrimonio para los efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente”. El artículo 38 agrega: “En el acto del matrimonio o de requerir la inscripción a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil, podrán los contrayentes reconocer los hijos habidos con anterioridad, y la inscripción que contenga esa declaración producirá los efectos señalados en el inciso segundo del artículo 185 del Código Civil”.

El reconocimiento voluntario expreso por acto entre vivos puede hacerse a través de mandatarios.

Así lo establece el artículo 190: “El reconocimiento por acto entre vivos señalado en el artículo 187, podrá realizarse por medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con este objeto”. Nótese que se trata de un mandato especial y solemne.

Si el reconocimiento tiene su origen en un testamento, no cabe hacerlo a través de mandatarios, desde que la facultad de testar es indelegable (art. 1004).

- **Reconocimiento voluntario tácito o presunto**

Es el que la ley establece por el hecho que el respectivo padre o madre, o ambos, pidan al momento de inscribir al hijo, que se deje constancia de su nombre en esa inscripción. Lo establece el artículo 188 inciso 1º: “El hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción de nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación”.

La norma señala que “el hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, **a petición de cualquiera de ellos**, al momento de practicarse...”, con lo que podría entenderse que se produce el reconocimiento si se deja constancia del nombre de uno de los padres a petición del otro. No hay duda que no es ese el sentido de la norma. Simplemente no quedó bien redactada. Tratándose de un reconocimiento voluntario, sólo puede derivar de una manifestación de voluntad, expresa o tácita pero, en todo caso, emanada de quien reconoce.

El reconocimiento que no conste en la inscripción de nacimiento, debe subinscribirse al margen de ésta. Así está establecido en el artículo 187 inciso final. La subinscripción no constituye solemnidad del reconocimiento, sino una medida de publicidad para que el acto sea oponible a terceros de tal forma que mientras no se cumpla con ella no podrá hacerse valer en juicio (art. 8 inc. 1º ley 4.808). El artículo 189 inciso final confirma el carácter de requisito de oponibilidad al establecer que “el reconocimiento no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que hayan sido adquiridos con anterioridad a la subinscripción de éste al margen de la inscripción de nacimiento del hijo”.

a.3) Límites al reconocimiento

El artículo 189 inc. 1º establece que “no surtirán efectos el reconocimiento de un hijo que tenga legalmente determinada una filiación distinta, sin perjuicio del derecho de ejercer las acciones a que se refiere el artículo 208”. Esta última frase significa que quien pretende ser el padre o la madre deberán ejercer simultáneamente las acciones de impugnación de la filiación existente y de reclamación de la nueva filiación.

a.4) Características de todo reconocimiento

Es un acto jurídico unilateral. De consiguiente se perfecciona por la sola voluntad del padre o madre que reconoce. No requiere de la aceptación del reconocido. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del hijo para repudiar tal reconocimiento, en los plazos y cumpliendo las exigencias que contempla el artículo 191.

El reconocimiento es un acto solemne. Ello porque para que se perfeccione se requiere que la voluntad de quien lo hace se exprese de alguno de los modos señalados en el artículo 187 y 188, según el reconocimiento sea voluntario expreso o tácito.

El reconocimiento es irrevocable. Lo dice expresamente el artículo 189 inciso 2º, en los términos siguientes: “El reconocimiento es irrevocable, aunque se contenga en un testamento revocado por otro acto testamentario posterior...”.

Nada tiene de novedoso que el reconocimiento sea irrevocable, pues es lo que ocurre normalmente con los actos unilaterales (el testamento es la excepción a esta regla y por ello la consignó expresamente el legislador) y, por otra parte, ello se justifica plenamente por la calidad de permanente que tiene todo estado civil.

El reconocimiento no puede sujetarse a modalidades. Esta característica está consignada en forma expresa en el artículo 189 inc. 2º parte final. Tampoco constituye novedad, pues sabido es que las modalidades no juegan en el ámbito del Derecho de Familia.

a.5) Repudiación del reconocimiento

El hijo puede repudiar el reconocimiento de que ha sido objeto (art. 191). En la historia de la ley quedó claro que la repudiación procede aunque sea efectiva la filiación que se le pretende imponer (Informe Comisión, Boletín 1060-07, p. 86).

Daniel Peñailillo, defendiendo la idea de la repudiación explica que “atendido el carácter unilateral del reconocimiento, no es razonable que por esa decisión quede el reconocido atrapado, en la situación de tener que emprender todo un litigio impugnatorio”. “Es apropiado entonces que el sólo repudio, como acto simple y también unilateral, le baste”.

- **Sólo se puede repudiar el reconocimiento voluntario.**

No procede respecto del reconocimiento forzado, pues sería un contrasentido que se demande una calidad para posteriormente repudiarla.

- **Personas que pueden repudiar y plazos para hacerlo.**

La ley regula distintas situaciones:

a) Si el hijo al momento de reconocimiento es mayor edad, sólo él puede hacerlo, dentro del plazo de un año, contado desde que tomó conocimiento del reconocimiento (art. 191 inc. 1º, primera parte);

b) Si fuere menor, sólo él puede repudiar, dentro de un año contado desde que llegado a la mayor edad supo del reconocimiento (art. 191, inc. 1º, parte final);

c) Si el hijo mayor de edad se encuentra en interdicción por demencia o sordomudez, repudiará por

él, su curador, previa autorización judicial (art. 191, inc. 2º);

d) Si el hijo es disipador declarado en interdicción, la repudiación deberá hacerla personalmente, sin autorización de su representante legal ni de la justicia (art. 191 inc. 3º);

e) Si se reconoció a un hijo muerto o que falleció antes de llegar a la mayoría de edad, pueden repudiar sus herederos. En el primer caso, tienen para repudiar el plazo de un año contado desde el reconocimiento; y en el segundo, el plazo de un año contado desde su muerte (art. 193 inc. 1º); y

f) Si el reconocido mayor de edad falleciere antes de expirar el término que tiene para repudiar, sus herederos pueden efectuar la repudiación durante el tiempo que a aquél hubiere faltado para completar dicho plazo (art. 193 inc. 2º).

- **Características de la repudiación.**

La repudiación es un acto jurídico que presenta las siguientes características:

- a) Es unilateral, desde que se perfecciona por la sola voluntad de quien repudia;
- b) Es solemne, pues debe hacerse por escritura pública (art. 191 inc. 4º). Para que esta repudiación afecte a terceros es necesario que se subinscriba al margen de la inscripción de nacimiento del hijo (arts. 191 inc. 4º, parte final del Código Civil y artículo 8º de la ley 4.808);
- c) Es irrevocable. Así lo consigna el artículo 191 inciso final: “toda repudiación es irrevocable”.

- **No se puede repudiar si se aceptó el reconocimiento.**

El artículo 192 así lo establece: “No podrá repudiar el hijo que, durante su mayor edad, hubiere aceptado el reconocimiento en forma expresa o tácita” (inc. 1º). En seguida, en sus incisos siguientes, define lo que entiende por aceptación expresa y tácita, señalando: “La aceptación es expresa cuando se toma el título de hijo en instrumento público o privado, o en acto de tramitación judicial” (inc. 2º); y “Es tácita cuando se realiza un acto que supone necesariamente la calidad de hijo y que no se hubiere podido ejecutar sino en ese carácter” (inc. 3º).

- **Efectos de la repudiación**

Los artículos 191 inc. Penúltimo y 194 reglan esta situación.

El primero establece que “la repudiación privará retroactivamente al reconocimiento de todos los efectos que beneficien exclusivamente al hijo o a sus descendientes, pero no alterará los derechos ya adquiridos por los padres o terceros, ni afectará a los actos o contratos válidamente ejecutados o celebrados con anterioridad a la subinscripción correspondiente”. Al discutirse la ley se dejó constancia que la repudiación “debe tener efectos retroactivos completos en lo que se refiere al hijo y sus descendientes, en términos que se reputa que nunca ha existido el vínculo de filiación con quien efectuó el reconocimiento” “De manera que si se produce la repudiación, la calidad de heredero legitimario que el hijo adquirió respecto de su padre o madre como consecuencia del reconocimiento, desaparece” (Informe Comisión cit., p. 90).

El artículo 194 dice: “la repudiación de cualquiera de los reconocimientos que dan lugar a la filiación matrimonial de los nacidos antes del matrimonio de los padres, que fuere otorgada en conformidad con las normas anteriores, impedirá que se determine legalmente dicha filiación”.

Para entender este artículo debe recordarse que en el caso del hijo que nace con anterioridad a la celebración del matrimonio de sus padres, tiene filiación matrimonial “siempre que la paternidad y la maternidad hayan estado previamente determinadas por los medios que este Código establece...”. Luego, si los padres reconocen al hijo y posteriormente se casan, el hijo, por ese sólo hecho, tiene filiación matrimonial. Pero si con posterioridad el hijo repudia los reconocimientos, deja de haber filiación matrimonial.

Tema 4: Acciones de Filiación.

Esta materia la regula el Código Civil en un título especial, el Título VIII del Libro Primero que contempla dos tipos de acciones: **a) acciones de reclamación de filiación, matrimonial o extramatrimonial;** y **b) acciones de impugnación de filiación.**

4.1 Reglas generales

- **Las acciones de filiación suponen la investigación de la paternidad o maternidad.**

Así lo dice el artículo 195: “La ley posibilita la investigación de la paternidad o maternidad, en la forma y con los medios previstos en los artículos que siguen” (inc. 1º).

- **Competencia y procedimiento.**

Son de competencia de los tribunales de familia (art. 8 Nº 9 de la ley 19.968), y el procedimiento es el contemplado en Título III de esa ley, artículos 9 y siguientes.

- **Excepción al principio de publicidad.**

El proceso tiene el carácter de secreto hasta que se dicte sentencia de término, teniendo acceso a él únicamente las partes y sus apoderados judiciales (art. 197 inc. 1º).

- **Responsabilidad del que interpone una acción de filiación de mala fe.**

Para evitar las demandas infundadas el artículo 197 inc. 2º dispone que “la persona que ejerza una acción de filiación de mala fe o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada es obligada a indemnizar los perjuicios que cause al afectado”. Para que proceda esta acción de indemnización se tiene que tratar de demandas deducidas de mala fe o hechas con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada, circunstancias éstas que deberá acreditar quien accione de indemnización (art. 1698 inc. 1º).

- **Prueba en los juicios de reclamación de filiación**

Si se examina el Derecho extranjero se puede apreciar que en los juicios sobre investigación de la paternidad o maternidad, uno de los aspectos más controvertidos es el relativo a la prueba. Ello explica que la ley 19.585 y la ley 20.030 hayan regulado esta materia con especial cuidado. Las normas dadas por los artículos 197 a 201, podemos resumirlas del modo siguiente:

a) La regla es que la paternidad o maternidad se puede establecer mediante toda clase de pruebas, decretadas de oficio o a petición de parte (art. 198 inc. 1º).

Sin embargo, la prueba de testigos por sí sola es insuficiente. Y en cuanto a las presunciones, deberán cumplir con los requisitos del artículo 1712, vale decir, deben ser graves, precisas y concordantes.

El juez pueda decretar pruebas de oficio, lo que importa una excepción señalada a la regla general de que en materia civil las pruebas las aportan las partes.

La ley 19.968 sobre tribunales de familia establece en su artículo 28 la libertad de prueba, estableciendo que “todos los hechos que resulten pertinentes para la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juez podrán ser probados por cualquier medio producido en conformidad a la ley”. Además el artículo 54 establece que “podrán admitirse como pruebas: películas cinematográficas, fotografías, fonografías, video grabaciones, otros sistemas de reproducción de imagen o del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto

para producir fe” (inciso 1º), agregando en seguida que “el juez determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo”. Cabe agregar que en conformidad al artículo 32 de la ley 19.968, los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

b) La ley admite las pruebas periciales de carácter biológico.

La más conocida es la prueba del A.D.N. (sigla que corresponde al ácido desoxirribonucleico), técnica inventada por los ingleses en el año 1985, que según el decir de los especialistas, tiene un grado de certeza, para excluir la paternidad o maternidad, que alcanza a un 100 % y para incluirla oscila entre el 98,36 al 99,9999999982 %.

La prueba del A.D.N. es la más conocida pero no la única pues existen otras como el “análisis de grupos y subgrupos sanguíneos” y “el análisis de antígenos de histocompatibilidad”. La primera tiene un grado de certeza de un 100% para excluir la paternidad o maternidad y de un 60 a un 70% para incluirlas; y en la segunda, la probabilidad de exclusión es del 100% y el valor de inclusión entre el 90% y el 99%.

Estas pruebas de carácter biológico deben practicarse por el Servicio Médico Legal o por laboratorios idóneos, designados por el tribunal. Las partes siempre, y por una sola vez, tendrán derecho a solicitar un nuevo informe pericial (art. 199).

En cuanto al valor de estas pruebas la ley 20.030 de 5 de julio de 2005 señaló que: “El juez podrá dar a estas pruebas periciales, por sí solas, valor suficiente para establecer la paternidad o maternidad, o para excluirla” (art. 199 inc. 2º).

Sanción a la negativa injustificada a someterse a un peritaje biológico. La misma ley 20.030 dispuso que: “La negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen hará presumir legalmente la paternidad o la maternidad, o la ausencia de ella, según corresponda.

Se entenderá que hay negativa injustificada si, citada la parte dos veces, no concurre a la realización del examen. Para este efecto, las citaciones deberán efectuarse bajo apercibimiento de aplicarse la presunción señalada en el inciso anterior” (art. 199 incs. 4º y 5º).

La ley 20.030 agregó un artículo 199 bis: “Entablada la acción de reclamación de filiación, si la persona demandada no comparece a la audiencia preparatoria o si negare o manifestare dudas sobre su paternidad o maternidad, el juez ordenará, de inmediato, la práctica de la prueba pericial biológica, lo que se notificará personalmente o por cualquier medio que garantice la debida información del demandado.

El reconocimiento judicial de la paternidad o maternidad se reducirá a acta que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo o hija, para lo cual el tribunal remitirá al Registro Civil copia auténtica”.

c) Posesión notoria de la calidad de hijo.

Trata de esta prueba el artículo 200 que la define, establece sus requisitos, señala la forma de probarlos y el artículo 201 que determina su valor probatorio.

El artículo 200 inciso 2º señala que “consiste en que el padre, madre o ambos le han tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal”. Esta definición contiene los requisitos tradicionales de toda posesión notoria: trato, nombre y fama.

En cuanto a sus requisitos: a) debe haber durado a lo menos cinco años continuos; y b) los hechos que la constituyen deben probarse por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable (art. 200 inc.1º).

Acreditada la posesión notoria del estado civil de hijo, constituye una prueba que preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico en caso de que haya contradicción entre unas y otras (art.

201 inc. 1º). Sin embargo, no se aplicará esta norma si hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar tal regla, caso en que prevalecerán las pruebas de carácter biológico (art. 201 y inc. 2º). Por ejemplo, en el caso de que la posesión notoria derive de la perpetración de un delito, como el de sustracción de menores o de sustitución de un niño por otro, contemplados en los artículos 142 y 353 del Código Penal.

d) Valor probatorio del concubinato de los padres.

El concubinato de la madre con el supuesto padre, durante la época en que ha podido producirse legalmente la concepción, esto es art. 76, “servirá de base para una presunción judicial de paternidad” (artículo 210).

El inciso 2º agrega que “si el supuesto padre probare que la madre cohabitó con otro durante el período legal de la concepción, está sola circunstancia no bastará para desechar la demanda, pero no podrá dictarse sentencia en el juicio sin emplazamiento de aquél”.

4.2 Acciones de reclamación de filiación.

Son aquéllas que la ley otorga al hijo en contra de su padre o de su madre, o a éstos en contra de aquél, para que se resuelva judicialmente que una persona es hijo de otra. Luego, los titulares de las acciones de reclamación pueden ser: el hijo, el padre o la madre.

- **Clases de acciones de filiación.**

Las acciones de filiación pueden ser: a) de reclamación de filiación matrimonial, o b) de reclamación de filiación no matrimonial.

- **Acciones de reclamación de filiación matrimonial.**

La acción de reclamación la puede intentar el hijo en contra de sus padres o los padres en contra del hijo.

Si es el hijo quien demanda, deberá entablar la acción conjuntamente en contra de ambos padres (art. 204 inc. 2º). Es lógico que así sea, desde que no se puede reconocer filiación matrimonial respecto de uno solo de los padres. Lo que caracteriza la filiación matrimonial es que los padres estén casados y por ello para que se declare esta filiación debe demandarse conjuntamente a ambos.

En el caso en que sea el padre o la madre quien demande la filiación matrimonial del hijo, debe el otro padre intervenir forzosamente en el juicio, so pena de nulidad (artículo 204 inciso final). Y ello también es plenamente justificado, pues el resultado del juicio va a afectar a ambos padres. Por consiguiente, y teniendo en cuenta los efectos relativos de las sentencias judiciales (artículo 3º inciso 2º) resulta absolutamente necesario emplazar a ambos padres.

Si bien la norma señala que “deberá el otro progenitor intervenir forzosamente en el juicio...” es evidente que sólo es necesario emplazarlo, sin que sea necesario que haga gestiones en la causa.

- **Acción de reclamación de filiación no matrimonial**

La puede interponer el hijo, personalmente o a través de su representante legal, en contra de su padre o de su madre, o en contra de ambos.

También la puede intentar el padre o la madre, cuando el hijo tenga determinada una filiación diferente, para lo cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 208 (art. 205). Esta referencia al artículo 208, significa que si el hijo ya tiene reconocida la calidad de hijo de otra persona, deberá el padre o madre que demande, impugnar la filiación existente y pedir que se declare que es su hijo. Así lo consigna el artículo 208: “Si estuviere determinada la filiación de una persona y quisiere

reclamarse otra distinta, deberán ejercerse simultáneamente las acciones de impugnación de la filiación existente y de reclamación de la nueva filiación”.

Las acciones a interponer en este caso son dos: una primera, de impugnación de una filiación anterior existente; y una segunda, de reclamación de la nueva filiación. Ambas acciones deben interponerse conjuntamente. Y es lógico que así sea, pues mientras se mantenga la primera filiación, no se puede adquirir una nueva. Deben ser partes en el juicio, el hijo y las otras personas respecto de las cuales existe filiación.

En el caso de una persona que no tiene filiación determinada (no tiene la calidad de hijo de nadie), no cabe la interposición por parte del padre o madre de la acción de reclamación de filiación. Y ello porque en tal supuesto, este padre o madre no requieren demandar al hijo desde que tienen la opción de reconocerlo voluntariamente en alguna de las formas establecidas en el artículo 187.

No necesita entonces el padre o madre en este caso, demandar la filiación. Ello, sin perjuicio de que si al hijo no le satisface este reconocimiento, pueda repudiarlo en la forma y dentro del plazo establecido en el artículo 191.

- **Si hijo fallece mientras es incapaz, la acción de reclamación la pueden ejercer sus herederos.**

Así está establecido en el artículo 207: “Si hubiere fallecido el hijo siendo incapaz, la acción podrá ser ejercida por sus herederos, dentro del plazo de tres años contado desde la muerte” (inc. 1º). Agrega este artículo que “si el hijo falleciere antes de transcurrir tres años desde que alcanzare la plena capacidad, la acción corresponderá a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dicho plazo” (inc. 2º). “El plazo o su residuo empezará a correr para los herederos incapaces desde que alcancen la plena capacidad” (inc. 3º).

- **Situación del hijo póstumo.**

En el caso el hijo póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los 180 días siguientes al parto, la acción de reclamación se podrá dirigir en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos, dentro del plazo de tres años, contados desde su muerte o, si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad (art. 206). Luego si la acción es ejercida por el representante legal del hijo el plazo de tres años se cuenta desde la muerte del padre o madre; y si quien la ejerce es el hijo los tres años corren desde que haya alcanzado su plena capacidad. Si el hijo fallece siendo incapaz, la acción podrá ser ejercida por sus herederos, dentro del plazo de tres años contados desde la muerte. Si el hijo fallece antes de transcurrir tres años desde que alcanzare la plena capacidad, la acción corresponderá a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dicho plazo (art. 207).

- **Características de la acción de reclamación de filiación.**

La acción de reclamación presenta las siguientes características:

a) Es imprescriptible e irrenunciable (art. 195 inc. 2º). Esta norma agrega que “Sin embargo, sus efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas generales de prescripción y renuncia”;

b) Es personalísima, por lo que no se puede ceder ni transmitir. El único caso en que la pueden intentar los herederos, es aquel en que fallece el hijo siendo incapaz, caso en que sus herederos podrán ejercerla dentro del plazo de 3 años contados desde la muerte o dentro del plazo que falta al hijo para cumplir los 3 años desde que cesó su incapacidad (art. 207);

- **Legítimos contradictores en la acción de reclamación de filiación**

El Código distingue entre la acción de reclamación matrimonial y la acción de reclamación de filiación no matrimonial.

La primera está reglada en el artículo 204 que a la letra expresa: “La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde exclusivamente al hijo, al padre o a la madre” (inc. 1º) “En el caso de los hijos, la acción deberá entablarse conjuntamente contra ambos padres” (inc. 2º) “Si la acción es ejercida por el padre o la madre, deberá el otro progenitor intervenir forzosamente en el juicio, so pena de nulidad” (inc. 3º).

En el caso de la filiación matrimonial es lógico que tenga que demandarse conjuntamente a ambos padres.

La segunda está tratada en el artículo 205: “La acción de reclamación de la filiación no matrimonial corresponde sólo al hijo contra su padre o madre, o a cualquiera de éstos cuando el hijo tenga determinada una filiación diferente, para lo cual se sujetará a lo dispuesto en el artículo 208” (inc. 1º) “Podrá asimismo, reclamar la filiación el representante legal del hijo incapaz, en interés de éste” (inc. 2º). En este caso la acción no la tienen los padres, pues ellos pueden reconocer voluntariamente al hijo.

- **Legitimación de los herederos**

El artículo 205 establece que la acción corresponde sólo al hijo contra su padre o madre. La pregunta que cabe plantear es si podría intentarse estas demandas después de fallecido el supuesto padre o madre. O dicho de otra manera, si podrían ser demandados los herederos del padre o madre supuesto.

La doctrina nacional y también la jurisprudencia, han entendido que en estos juicios sólo puede ser emplazado el padre (o madre), de tal suerte que fallecido éste (o ésta) no cabe enderezar la demanda en contra de los herederos, salvo en el caso excepcional del hijo póstumo contemplado en el artículo 206. Así René Abeliuk, Paulina Veloso, Hernán Corral.

- **Alimentos provisionales**

El artículo 209 prescribe que “Reclamada judicialmente la filiación, el juez podrá decretar alimentos provisionales, en los términos del artículo 327”.

Puede a primera vista, parecer un despropósito que antes de encontrarse probada la filiación, se puedan decretar alimentos provisionales, siendo los alimentos una consecuencia de filiación. Sin embargo, ello no es así, por varias razones. La primera, porque constituye una facultad del juez, no una obligación el decretarlos. La norma es clara en cuanto a que el juez “podrá decretar”. Y porque los alimentos se decretan en los términos del artículo 327, lo que significa que la petición al tribunal debe ser fundada y que para el caso de que la sentencia sea absolutoria se deben, por regla general, restituir.

4.3 Acciones de Impugnación de Filiación.

Esta materia está tratada en el párrafo 3º del Título VIII del Libro Primero del Código Civil, artículos 211 hasta el 221.

Como su nombre lo indica, estas acciones tienen por objeto dejar sin efecto la filiación generada por una determinada paternidad o maternidad, por no ser efectivos los hechos en que se funda. Así aparece de los artículos 211 y siguientes.

a) Generalidades

- **No cabe la impugnación de la filiación determinada por sentencia firme.**

Según el artículo 220 “No procederá la impugnación de una filiación determinada por sentencia firme...”. Ello es la consecuencia de la cosa juzgada generada por dicha sentencia firme.

La norma agrega que ello es “sin perjuicio de lo que dispone el artículo 320”. Esta disposición expresa que “ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce”.

De consiguiente, si judicialmente se ha resuelto que una persona es hijo de un determinado padre o madre, no puede ni el hijo ni los padres que intervinieron en el pleito en que aquello se resolvió, impugnar la filiación establecida en la sentencia. Pero nada obsta a que si un tercero pretende ser el padre o madre del mismo hijo, pueda demandar dicha filiación en los términos establecidos en el artículo 208, esto es, ejerciendo simultáneamente las acciones de impugnación de la filiación existente y de reclamación de la nueva. Es decir, estas personas pueden ejercer la acción de reclamación del verdadero estado filial y para ello pueden impugnar incluso la filiación determinada por sentencia dictada en un juicio en el que no fueron partes.

- **Citación de la mujer**

Si se impugna la paternidad del hijo de filiación matrimonial, la madre debe ser citada, pero no es obligada a comparecer. Así lo establece el artículo 215. Y ello es lógico, pues la sentencia que en este caso se dicte, afectará no sólo al padre y al hijo, sino también a la madre, por eso es necesario emplazarla, pues en caso contrario, no podría afectarle la sentencia, atendido lo dispuesto en el artículo 3 inc. 2º del Código Civil (efecto relativo de las sentencias).

b) Situaciones que regula la ley.

El Código reglamenta diversas situaciones:

b.1) Impugnación de la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio.

Pueden hacerlo: a) **el marido**, b) **los herederos del marido o cualquier persona al que la pretendida paternidad irrogare perjuicio**; y c) **el hijo**.

- **Impugnación hecha por el marido**

Esta situación está tratada en el artículo 212: “La paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio podrá ser impugnada por el marido dentro de los ciento ochenta días siguientes al día en que tuvo conocimiento del parto, o dentro del plazo de un año, contado desde esa misma fecha, si prueba que a la época del parto se encontraba separado de hecho de la mujer” (inc. 1º).

De manera que el plazo para impugnar es diferente según se trate de cónyuges que viven juntos, en que es de 180 días, o separados, situación está en que el plazo se alarga a un año. En ambos casos los plazos se cuenta desde que el marido tuvo conocimiento del parto.

El artículo 212 en sus incisos 2º y 3º establece presunciones legales (simplemente legales) sobre la fecha en que el marido tomó conocimiento del parto. Dice el inciso 2º: “La residencia del marido en el lugar de nacimiento del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente; a menos de probarse que por parte de la mujer ha habido ocultación de parto”. El inciso 3º agrega: “Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que lo supo inmediatamente después de su vuelta a la residencia de la mujer; salvo el caso de ocultación mencionado en el inciso precedente”.

- **Impugnación hecha por los herederos del marido o por cualquiera persona al que la pretendida paternidad causare perjuicios**

Mientras el marido vive, sólo a él compete el derecho de impugnar la paternidad, lo que es lógico. Sin embargo, si fallece antes de tomar conocimiento del parto o mientras está corriendo el plazo para impugnar, la acción de impugnación pasa a sus herederos o a toda persona a la que la pretendida paternidad causare perjuicios. Pasa la acción por la totalidad del plazo (cuando fallece el marido sin haber tomado conocimiento del parto) o por el tiempo que faltare para completarlo, en caso contrario (art. 213 inc. 1º)

No cabe que los herederos o terceros interesados impugnen si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público (art. 213 inc. 2º).

- **Impugnación de la paternidad por el hijo**

En el caso del hijo concebido o nacido durante el matrimonio, la paternidad podrá ser impugnada por el hijo, sea a través de su representante legal o en forma personal. Si quien impugna es el representante legal debe hacerlo en el plazo de un año contado desde la fecha de nacimiento del hijo; y si es el hijo quien impugna en forma personal, también debe hacerlo en el plazo de un año que, en este caso, se cuenta desde que adquiere su plena capacidad (art. 214).

b.2) Impugnación de la paternidad determinada por reconocimiento.

En este caso la paternidad puede ser impugnada por el propio hijo y por toda persona que prueba interés actual en la impugnación.

- **Impugnación de la paternidad por el hijo**

Cuando el hijo ha sido reconocido por su padre puede impugnar la paternidad dentro del plazo de 2 años contados desde que el hijo supo del reconocimiento (art. 216 inc. 1º).

Si el hijo es incapaz la acción se ejerce conforme al art. 214 (art. 216 inc. 2º).

Si el hijo muere desconociendo el reconocimiento o antes de vencido el plazo para impugnar, la acción de impugnación corresponderá a sus herederos por el mismo plazo o por el tiempo que faltare para completarlo, plazo que se cuenta desde la muerte del hijo (art. 216 inc. 3º).

En el caso de los hijos nacidos antes del matrimonio de sus padres (supuesto en que también hay filiación matrimonial de acuerdo al artículo 180 inciso 2º), se aplican estas mismas reglas de impugnación, pero el plazo de dos años se cuenta desde que el hijo supo del matrimonio o del reconocimiento que la producen” (art. 216 inc. 4º).

- **Impugnación de la paternidad por toda persona que pruebe interés actual en ello**

Esta situación está regulada en el artículo 216 inciso final: “También podrá impugnar la paternidad determinada por reconocimiento toda persona que pruebe un interés actual en ello, en el plazo de un año contado desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer su derecho”. Interés actual significa interés patrimonial. El puro interés moral no es suficiente.

b.3) Impugnación de la maternidad.

La maternidad puede ser impugnada atacándose los dos hechos en que ella se funda: existencia del parto y que el hijo es el producto de ese parto. Por ello el artículo 127 inciso 1º dispone: “La maternidad podrá ser impugnada, probándose falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero”.

- **Titulares de la acción de impugnación de la maternidad**

Pueden impugnar la maternidad: a) el marido de la supuesta madre; b) la madre supuesta; c) los verdaderos padre o madre del hijo; d) el verdadero hijo; e) el hijo supuesto; y e) toda otra persona a quien la maternidad aparente perjudique actualmente en sus derechos sobre la sucesión

testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre, siempre que no exista posesión notoria del estado civil (art. 217 incs. 2º y 3º y artículo 218).

Si se trata del marido de la supuesta madre y de la madre supuesta la acción debe ejercerse dentro del año siguiente al nacimiento.

La acción de los verdaderos padre o madre, del hijo verdadero o del supuesto hijo es imprescriptible, en la medida en que se ejerza conjuntamente con la impugnación la acción de reclamación de la verdadera filiación. En realidad, sólo de esta forma podrían ejercerla los verdaderos padres y el hijo verdadero en virtud de lo dispuesto en el art. 208. El hijo supuesto podría, en cambio, ejercer sólo la acción de impugnación: en tal caso deberá ejercerla dentro del año contado desde que alcance su plena capacidad.



No obstante haber expirado los plazos establecidos, si sale inopinadamente a la luz algún hecho incompatible con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción respectiva por un año contado desde la revelación justificada del hecho (art. 217 inc. final).

En el caso que quien impugne la maternidad sea la persona a quien la maternidad aparente perjudique actualmente en sus derechos hereditarios sobre la sucesión testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre, el plazo para impugnar es de un año contado desde el fallecimiento de dichos padre o madre (art. 218 inc. 2º).

- **Sanción a los que intervengan en la suplantación del parto**

El artículo 219 sanciona a los que hayan intervenido en el fraude de falso parto o suplantación de parto, estableciendo que no les aprovechará en modo alguno el descubrimiento del fraude ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de patria potestad, o para exigirle alimentos, o para suceder en sus bienes por causa de muerte. La norma agrega que “la sentencia que sancione el fraude o la suplantación deberá declarar expresamente esta privación de derechos y se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo”.

c) Situación especial del hijo concebido mediante técnicas de reproducción humana asistida.

En el caso del hijo que ha sido concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida no cabe la impugnación de la filiación ni la reclamación de una filiación diferente (art. 182 inc. 1º). Esto tiene especial importancia cuando se han usado gametos ajenos.

d) Subinscripción de la sentencia que acoge acciones de reclamación o de impugnación.

Las sentencias que se dicten en esta clase de juicios deben subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo (art. 221). Esta subinscripción es un requisito de oponibilidad para que la sentencia afecte a terceros. Lo anterior se desprende de esta disposición, en cuanto señala que “no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que hayan sido adquiridos con anterioridad a la subinscripción”, y del artículo 8º inc. 1º de la ley Nº 4808.

Tema 5: Otras acciones de filiación

5.1 Acción de desconocimiento de la paternidad

Está tratada en el **artículo 184 inc. 2º**. Se refiere al hijo que nace antes de los 180 días siguientes al matrimonio de sus padres. En conformidad a esta disposición, si el marido no tuvo

conocimiento de la preñez al momento de casarse, puede desconocer judicialmente la paternidad. Esta acción no es propiamente una acción de impugnación, sino de desconocimiento, pero en conformidad a lo que dispone el artículo 184 inc. 2º debe ejercerse en el plazo y forma que se expresa en los artículos 212 y siguientes, vale decir, en el plazo y forma de las acciones de impugnación, circunstancia que no cambia su naturaleza jurídica -sigue siendo acción de desconocimiento y no de impugnación- distinción que tiene importancia, porque lo que se debe solicitar al tribunal es únicamente que constate los supuestos del desconocimiento, esto es, que el marido ignoraba al tiempo de casarse la preñez de la mujer y que no reconoció al hijo por hechos positivos.

5.2 Acción de nulidad del acto de reconocimiento de un hijo

Interesa destacar que en este caso el padre no es titular de la acción de impugnación. Ello es lógico y guarda concordancia con el sistema de la ley, según el cual no hay impugnación si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público (art. 213 inc. 2º). Así ha sido fallado (Corte Suprema, 3 de octubre de 2002, causa rol 2646-2002).

No tiene el padre acción de impugnación, pero sí puede impetrar la nulidad del reconocimiento por vicios de la voluntad en conformidad al artículo 202: “La acción para impetrar la nulidad del reconocimiento por vicios de la voluntad prescribirá en el plazo de un año contado desde la fecha de su otorgamiento, o en el caso de fuerza, desde el día en que ésta hubiere cesado”. Este plazo de un año es excepción a lo establecido en el art. 1684. Cuando la norma dice que el plazo de un año se cuenta desde la fecha de su otorgamiento hay que entender que se está refiriendo al caso de error o dolo.

Tema 6: Efectos de la determinación de la filiación

6.1 La sentencia que acoge la acción de reclamación es declarativa, no constitutiva de filiación. Retroactividad.

Así aparece del artículo 181: “la filiación produce efectos civiles cuando queda legalmente determinada, pero éstos se retrotraen a la época de la concepción del hijo” (inc. 1º). La misma disposición agrega que “no obstante, subsistirán los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas antes de su determinación, pero el hijo concurrirá en las sucesiones abiertas con anterioridad a la determinación de su filiación cuando sea llamado en su calidad de tal” (inc. 2º) “Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la prescripción de los derechos y de las acciones, que tendrá lugar conforme a las reglas generales” (inc. 3º).

Para la correcta inteligencia de los incisos que se acaban de transcribir, es ilustrativo tener en cuenta las explicaciones que se dieron en la discusión en el Senado. Allí se dijo: “Por otro lado, creyó -la Comisión- de toda lógica desde el punto de vista de la certeza jurídica, particularmente considerando los efectos patrimoniales de la filiación del hijo frente a terceros, hacer salvedad de la validez de los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en el tiempo intermedio. Ello permite evitar dudas, por ejemplo, respecto de los actos celebrados por un curador del hijo, antes de que se determine la filiación de éste, hecho que, de acuerdo al solo inciso primero, produciría efectos retroactivos”.

En seguida continua el Informe “pero la aplicación estricta de esta excepción a la retroactividad (que

no se vean afectados los derechos adquiridos) permitiría a los herederos del pariente fallecido en ese lapso alegar que se vulnerarían sus derechos adquiridos, que quedaron fijados a la época de apertura de la sucesión y delación de la herencia, esto es, a la muerte del causante, si participase en la sucesión el hijo cuya filiación se ha determinado con posterioridad. Para evitar esta interpretación, se dijo expresamente que el hijo concurrirá en las sucesiones abiertas antes de la determinación de su filiación cuando sea llamado en su calidad de tal. O sea, cuando habría estado incluido en la delación de la herencia si su filiación se hubiese determinado en forma previa a la muerte del causante”. “De esta manera, se agregó, el hijo podrá ejercer las acciones propias del heredero, en especial la de petición de herencia, mientras no transcurran los plazos de prescripción” (Boletín 1067-07, pp. 68-70).

- **Período que va entre la determinación y la anotación registral**

La ley no sólo protege los derechos adquiridos *antes de la determinación de la filiación* (art. 181, inc. 2º, primera parte), sino que además protege los derechos adquiridos por terceros de buena fe *antes que se subinscriba* el reconocimiento o la sentencia que determina la filiación respectiva (arts. 189, inc. final y 221, respectivamente).

En estas situaciones la filiación está ya determinada, pero bien puede suceder que terceros no estén en condiciones de conocer la determinación y podrían verse perjudicados por ese desconocimiento. Es así como la ley establece que los medios de determinación serán inoponibles a terceros de buena fe mientras no consten en el Registro Civil.

Lo dice el art. 189 inc., 3º para el reconocimiento y lo repite el art. 221 para la determinación por sentencia judicial.

Se trata sólo de terceros. Es decir, entre padre e hijo se producen todos los efectos aunque todavía no se haya subinscrito el reconocimiento o la sentencia.

Además se exige que el tercero esté de buena fe. Esta se presumirá en virtud del art. 707, pero podrá probarse en contrario que el tercero estaba al corriente de la determinación.

6.2 Sanción al padre o madre cuando la filiación ha sido determinada contra su oposición.

El artículo 203 establece que “cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, aquél o ésta quedará privado de la patria potestad y, en general, de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo o de sus descendientes. El juez así lo declarará en la sentencia y de ello se dejará constancia en la subinscripción correspondiente” (inc. 1º).

Luego el padre o madre pierde sus derechos de tal, tanto respecto de la persona como respecto de los bienes del hijo. Sin embargo, mantiene sus obligaciones. Así lo consigna el inciso 2º: “El padre o madre conservará, en cambio, todas sus obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o sus descendientes”.

El inciso 1º del artículo 203, debe concordarse con el artículo 324 inciso final, según el cual “Quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre que le hayan abandonado en su infancia, cuando la filiación haya debido ser establecida por medido de sentencia judicial contra su oposición”.

De acuerdo al inciso final del artículo 203, el hijo, alcanzada su plena capacidad, puede restituir los derechos a este padre o madre. Señala este precepto: “Sin embargo, se restituirán al padre o madre todos los derechos de los que está privado, si el hijo, alcanzada su plena capacidad, manifiesta por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerle en ellos”. Continúa

expresando que “el restablecimiento por escritura pública producirá efectos desde su subinscripción al margen de la inscripción de nacimiento del hijo y será irrevocable. El restablecimiento por acto testamentario producirá efectos desde la muerte del causante”.

Tema 7: Efectos de la filiación.

Los efectos de la filiación son los derechos y obligaciones que derivan de ella y son los siguientes: autoridad paterna, patria potestad, derecho de alimentos y derechos hereditarios. Sólo trataremos los dos primeros ya que los dos últimos serán tratados posteriormente.

7.1 Autoridad Paterna

Tradicionalmente ha sido definida como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido eminentemente moral, existente entre padres e hijos.

El Código Civil dedica a esta materia el Título IX del Libro Primero, artículos 222 al artículo 242. Para su estudio, hay que distinguir entre: a) Deberes de los hijos para con sus padres y ascendientes; y b) Derechos-deberes de los padres para con los hijos.

7.1.1 Deberes de los hijos para con sus padres y ascendientes.

Los hijos tienen respecto de sus padres los siguientes deberes: 1) respeto y obediencia a los padres; y 2) deber de cuidado a los padres y demás ascendientes.

a) Deber de respeto y obediencia a los padres.

El artículo 222 establece que “los hijos deben respeto y obediencia a sus padres” (inc. 1º).

b) Deber de cuidado.

Lo consagra el artículo 223: “Aunque la emancipación confiera al hijo el derecho a obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitare sus auxilios” (inc. 1º). El inciso 2º agrega que: “Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes, en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes”.

7.1.2 Derechos-deberes de los padres para con los hijos.

Se habla de “derechos-deberes”, pues el cuidar, criar y educar a los hijos no es sólo un derecho o prerrogativa de los padres, sino, y muy fundamentalmente, el cumplimiento de una obligación que les impone su condición de progenitores.

Para la cabal comprensión de las normas que pasan a estudiarse deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 222, que constituye una verdadera declaración de principios sobre la protección que debe darse al menor: “La preocupación fundamental de los padres es el **interés superior del hijo**, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades”.

a) Cuidado.

Esta materia está regulada por los artículos 224 al 228. El primero señala “Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos”

(inc. 1º) “El cuidado personal del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio, reconocido por uno de los padres, corresponde al padre o madre que lo haya reconocido. Si no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez” (inc. 2º). En el caso de los hijos de filiación no matrimonial, el cuidado corresponde al padre o madre que lo haya reconocido (art. 224 inc. 2º). Sin embargo, si el reconocimiento ha sido por resolución judicial con oposición del padre o de la madre, este padre o madre quedará privado del cuidado del hijo. Así resulta de aplicar el artículo 203.

Tratándose de padres separados, toca a la madre el cuidado personal de los hijos (art. 225 inc. 1º). Esta norma no se aplica en dos casos: i) cuando existe un acuerdo de los padres en sentido diverso y ii) cuando por resolución judicial se dispone otra cosa.

i) Acuerdo de los padres.

Así lo consigna el inciso 2º del artículo 225: “No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre...”

Este acuerdo tiene las siguientes características: 1) es solemne, ya que debe constar en escritura pública o en un acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil; 2) para que sea oponible a terceros, el instrumento en que consta el acuerdo deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento; y 3) es revocable, debiendo para ello cumplirse las mismas solemnidades (art. 225 inc. 2º, parte final).

ii) Resolución judicial.

El artículo 225 inciso 3º prescribe: “En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo”.

En caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, podrá el juez confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, debiendo preferirse a los consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los ascendientes (art. 226). Esta norma debe ser concordada con el artículo 42 de la ley 16.618, sobre Protección de Menores, que precisa que “para los efectos del artículo 226 del Código Civil, se entenderá que uno o ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad física o moral”:

1º Cuando estuvieren incapacitados mentalmente;

2º Cuando padecieren de alcoholismo crónico;

3º Cuando no velaren por la crianza, cuidado personal o educación del hijo;

4º Cuando consintieren en que el hijo se entregue en la vía pública o en lugares públicos a la vagancia o a la mendicidad ya sea en forma franca o a pretexto de profesión u oficio;

5º Cuando hubieren sido condenados por secuestro o abandono de menores;

6º Cuando maltrataren o dieran malos ejemplos al menor, o cuando la permanencia de éste en el hogar constituyere un peligro para su moralidad; y

7º Cuando cualesquiera otras causas coloquen al menor en peligro moral o material.

► Tribunal competente y procedimiento de los juicios de tuición:

A partir del 1º de octubre de 2005, fecha de vigencia de la ley 19.968 que creó los Tribunales de Familia, estas causas se tramitarán ante los Juzgados de Familia (art. 8 Nº 1), en el procedimiento ordinario establecido en el Título III de esa ley (arts. 55 y siguientes).

Dice el art. 227 “En las materias a que se refieren los artículos precedentes, el juez oír a los hijos y parientes” (“en los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines” (art. 42).

El artículo 228 expresa que “La persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su otro cónyuge”.

b) Relación directa y regular con los hijos (ex derecho de visitas)

Esto equivale a lo que antes se denominaba derecho de visita, y se trata en el artículo 229: “El padre o la madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo”. Agrega la norma que “se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente”.

c) Educación.

El art. 236 dispone: “Los padres tendrán el derecho y el deber de educar a sus hijos orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida”.

Este derecho de los padres cesará respecto de los hijos cuyo cuidado haya sido confiado a otra persona, la cual lo ejercerá con anuencia del tutor o curador, si ella misma no lo fuere (art. 237);

d) Facultad de los padres de corregir a sus hijos.

Esta materia está regulada por el artículo 234. Dice la norma: “Los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos, cuidando que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal” (inc. 1º). Si se compara este artículo 234 con el 233 (anterior a la ley 19.585), se podrá apreciar que con la ley 19.585, desapareció la facultad de los padres de “castigar moderadamente al hijo”. Ello con el objeto de ajustar la normativa a la Convención de los Derechos del Niño.

El artículo 234 inc. 2º pone especial énfasis en que esta facultad de los padres debe ser ejercida sin menoscabar la salud del menor ni su desarrollo personal. Si se produce tal menoscabo, queda autorizada cualquier persona para solicitar medidas en resguardo de la salud o desarrollo personal del hijo, pudiendo incluso el tribunal actuar de oficio.

En su inciso 3º el artículo 234 establece que “cuando sea necesario para el bienestar del hijo, los padres podrán solicitar al tribunal que determine sobre la vida futura de aquel por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo que le falte para cumplir 18 años de edad”.

• Padres privados del derecho a educar y corregir a sus hijos

La ley priva a los padres de estos derechos en los siguientes casos:

- a) Cuando la filiación del menor haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o la madre (art. 203);
- b) Cuando el padre hubiere abandonado al hijo (art. 238), y
- c) Cuando el hijo ha sido separado de su padre por inhabilidad moral de éste, a menos que la medida

haya sido revocada (art. 239); y

d) Cuando el padre o madre hubiere sido condenado por un delito sexual cometido en la persona del menor, debiendo así declararlo en la sentencia condenatoria, la que ordenará dejar constancia al margen de la inscripción de nacimiento del menor (art. 370 bis del Código Penal).

e) Gastos de educación, crianza y establecimiento de los hijos.

En esta materia la ley distingue según si los padres están casados en régimen de sociedad conyugal o no lo están (sea porque no hay matrimonio o porque se encuentren sujetos a otro régimen matrimonial). En el primer caso, esos gastos serán de cargo de la sociedad conyugal, según las reglas que allí da el Código (art. 230). La referencia debe entenderse hecha a los artículos 1740 Nº 5 y 1744. De acuerdo a estas reglas, la sociedad es obligada al pago y soporta el gasto que demande el mantenimiento, educación y establecimiento de los hijos.

Si no hay sociedad conyugal ambos padres deberán contribuir en proporción a sus respectivas facultades económicas (art. 230).

“Si el hijo tuviese bienes propios, los gastos de su establecimiento, y en caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible” (art. 231).

El artículo 233 señala que “en caso de desacuerdo entre los obligados a la contribución de los gastos de crianza, educación y establecimiento del hijo, ésta será determinada de acuerdo a sus facultades económicas por el juez, el que podrá de tiempo en tiempo modificarla, según las circunstancias que sobrevengan”.

- **La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa por la falta o insuficiencia de ambos padres, a sus abuelos, por una y otra línea.**

Así lo consigna el artículo 232 que agrega: “En caso de insuficiencia de uno de los padres, la obligación indicada precedentemente pasará en primer lugar a los abuelos de la línea del padre o madre que no provee; y en subsidio de éstos a los abuelos de la otra línea”.

- **Derechos que asisten a quien alimenta y cría a un hijo ajeno**

El artículo 240 establece que “Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarle del poder de ella, deberán ser autorizados por el juez para hacerlo, y previamente deberán pagarle los costos de su crianza y educación, tasados por el juez” (inc. 1º). “El juez sólo concederá la autorización si estima, por razones graves, que es de conveniencia para el hijo” (inc. 2º).

- **Suministro de alimentos al menor ausente de su casa**

El artículo 241 trata de la situación del hijo menor que se ausenta de su casa y que es auxiliado por terceros para que pueda subsistir. Dice la norma: “Si el hijo de menor edad ausente de su casa se halla en urgente necesidad, en que no puede ser asistido por el padre o madre que tiene su cuidado personal, se presumirá la autorización de éste o ésta para las suministros que se le hagan, por cualquier persona, en razón de alimentos, habida consideración de su posición social” (inc. 1º) “El que haga las suministros deberá dar noticia de ellas al padre o madre lo más pronto posible. Toda omisión voluntaria en este punto hará cesar la responsabilidad” (inc. 2º) “Lo dicho del padre o madre en los incisos precedentes se extiende en su caso a la persona a quien, por muerte o inhabilidad de los padres, toque la sustentación del hijo” (inc. 3º).

7.2 Patria potestad.

Este efecto de la filiación está regulado en el título X del Libro Primero del Código Civil, artículos 243 al 273.

El artículo 243 la define diciendo que “es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados”.

La gran innovación que en esta materia incorporó la ley Nº 19.585, es conferir la patria potestad tanto al padre como a la madre, y, además, sin distinguir si la filiación de los hijos es matrimonial o no matrimonial (antes los padres de los hijos naturales no tenían la patria potestad).

a) Titulares de la patria potestad

i) Ejercicio de la patria potestad si los padres viven juntos.

- El artículo 244 prescribe que “la patria potestad será ejercida por el padre o la madre, o por ambos conjuntamente, según convengan...”
Los padres pueden acordar que la patria potestad la tenga el padre, la madre, o ambos en conjunto. Este acuerdo es solemne, siendo la solemnidad el que se haga por escritura pública o en acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil (art. 244 inc. 1º).
- A falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad (art. 244 inc. 2º).
- Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los padres, el juez puede confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre que carecía de este derecho, o radicarlo en uno solo de los padres, si la ejercían conjuntamente (art. 244 inc. 3º). Tanto en el caso del acuerdo de los padres, como de existir una resolución judicial que atribuya la patria potestad a alguno de ellos o a ambos, deberá subinscribirse el acuerdo o la sentencia, al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Tal subinscripción deberá practicarse dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento.
- En defecto del padre o madre que tuviere la patria potestad, los derechos y deberes corresponderán al otro de los cónyuges (art. 244 inc. final).

ii) Ejercicio de la patria potestad si los padres viven separados.

El artículo 245 establece que “si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, de conformidad al artículo 225. Sin embargo, por acuerdo de los padres, o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad...”.

b) Casos en que el hijo no está sujeto a patria potestad y es necesario nombrarle curador.

- Cuando la paternidad y maternidad han sido determinadas judicialmente contra la oposición del padre y de la madre (arts. 248 y 203).
- Cuando los padres no tengan derecho a ejercer la patria potestad (art. 248).
- Cuando la filiación del hijo no esté determinada legalmente ni respecto del padre ni respecto de la madre (arts. 248)

c) Atributos de la patria potestad.

Los atributos de la patria potestad son: a) derecho real de goce (usufructo) del padre sobre ciertos bienes del hijo; b) **administración de los bienes del hijo**; y c) **representación legal del menor**.

c.1) Derecho legal de goce (usufructo legal).

La facultad que tiene el padre para gozar de ciertos bienes del hijo pasó con la ley 19.585, a llamarse “Derecho legal de goce”, cambio que parece adecuado considerando que no corresponde a la idea del derecho real de usufructo, entre otras razones, porque no da derecho de persecución contra terceros adquirentes de los bienes del menor. Sin embargo, el legislador para evitar cualquier duda, precisa que “el derecho legal de goce recibe también la denominación de usufructo legal del padre o

madre sobre los bienes del hijo...”, agregando que “en cuanto convenga a su naturaleza, se registrá supletoriamente por las normas del Título IX del Libro II” (art. 252 inc. final), esto es, por las reglas del derecho real de usufructo.

- **Definición.**

El derecho legal de goce está definido en el artículo 252: **“es un derecho personalísimo que consiste en la facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus frutos, con cargo de conservar la forma y substancia de dichos bienes y de restituirlos, si no son fungibles; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si son fungibles”**. No hay dudas que esta definición se inspira en la del derecho real de usufructo contenido en el artículo 764.

- **Características**

a) Es un derecho personalísimo (art. 252 inc. 1º)

b) Es inembargable (art. 2466 inciso final);

c) No obliga a rendir fianza o caución de conservación y restitución ni tampoco a hacer inventario solemne. Debe sí llevarse una descripción circunstanciada de los bienes desde que entre a gozar de ellos. En el caso de quien gozare del derecho de usufructo enviudare, para contraer nuevas nupcias deberá proceder al inventario solemne de los bienes del menor (art. 252 inc. 2º en relación con el art. 124);

d) Si quien goza del derecho legal de goce es la madre casada en régimen de sociedad conyugal, se considerará separada parcialmente de bienes respecto de su ejercicio y de lo que en él obtenga, rigiéndose esta separación por el artículo 150 (art. 252 inc. 3º).

e) Si la patria potestad la ejercen conjuntamente ambos padres, el derecho legal de goce se distribuirá en la forma que ellos lo tengan acordado. A falta de acuerdo se dividirá por partes iguales (art. 252 inc. 4º).

- **Bienes sobre los que recae el derecho legal de goce.**



Glosario

Este aspecto está regulado por el artículo 250. La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, con las siguientes excepciones:

a) Bienes que integran el peculio profesional o industrial del hijo (art. 250 Nº 1). Respecto de estos bienes, el goce lo tiene el hijo (art. 251);

b) Bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador ha estipulado que no tenga el goce o la administración quien ejerza la patria potestad; o haya impuesto la condición de obtener la emancipación, o haya dispuesto expresamente que tenga el goce de esos bienes el hijo (art. 250 Nº 2);

c) Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la patria potestad (art. 250 Nº 3).

En los casos b) y c) el goce corresponderá al otro padre (art. 250 inc. 2º).

c.2) Administración de los bienes del hijo.

Respecto a la administración de los bienes del hijo, cabe distinguir:

a) Los bienes que forman el peculio profesional o industrial son administrados por el hijo, con la limitación del artículo 254 (art. 251);

b) Respecto de los otros bienes los administra el padre o madre que tenga el derecho legal de goce (art. 253 inc. 1º). Si el padre o la madre que tiene la patria potestad no puede ejercer el derecho de goce sobre uno o más bienes del hijo, este derecho pasará al otro; y si ambos estuvieren impedidos, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración (art. 253 inc. 2º).

- **Limitaciones en la administración de los bienes del hijo**

El padre (o madre) administra con amplias facultades salvo las excepciones legales que constituyen limitaciones a esta administración:

1. Para enajenar o gravar bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional o industrial, o derechos hereditarios, se requiere de autorización judicial con conocimiento de causa (art. 254).

La sanción para el caso de incumplimiento es la nulidad relativa.

2. En conformidad al artículo 255, no se podrá donar parte alguna de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores. Estas limitaciones están contempladas, en el artículo 402, para las donaciones; en el artículo 407, para los arriendos; y en el artículo 397 (reiterado en los artículos 1225, 1236 y 1250) para la aceptación o repudiación de una herencia.

Respecto de las donaciones, debe distinguirse entre bienes inmuebles y bienes muebles. El padre no podrá donar bienes raíces del hijo, ni aun con autorización judicial (art. 402 inciso 1º). Luego si lo hace: nulidad absoluta, por ser una norma prohibitiva (arts. 10, 1466, 1682). Tratándose de bienes muebles, para donarlos requiere de autorización judicial. El juez sólo autorizará estas donaciones cuando exista "una causa grave, como la de socorrer a un consanguíneo necesitado, contribuir a un objeto de beneficencia pública u otro semejante, y con tal que sean proporcionadas a las facultades del pupilo, y que por ellas no sufran un menoscabo notable los bienes productivos" (art. 402 inciso 2º). El padre no tiene limitaciones para hacer gastos de poco valor destinados a objetos de caridad o de lícita recreación (art. 402 inc. 3º). La sanción si no se otorga la autorización judicial es la nulidad relativa (art. 1682)

En el caso de los arriendos, el padre no podrá dar en arriendo los bienes raíces del hijo por más de 5 años si son urbanos, ni por más de 8 si son rústicos, ni por más tiempo que el que falte para que el menor cumpla 18 años (art. 407). La sanción si se incumple es la inoponibilidad: el contrato no afecta al menor más allá de los 5 u 8 años, según se trate de predios urbanos o rústicos, ni más allá del plazo que le falte para cumplir 18 años.

Tratándose de la aceptación de una herencia, el padre tiene que aceptar con beneficio de inventario (arts. 397 y 1250). Si no lo hace de esa forma, el menor no será obligado por las deudas y cargas de la sucesión sino hasta concurrencia de lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda o se probare haberse empleado efectivamente en su beneficio (art. 1250 inciso final).

Respecto de la repudiación de una herencia, el padre requiere de decreto del juez con

conocimiento de causa (arts. 397 y 1236). La última norma señalada tiene más amplitud que las anteriores, por cuanto no alcanza sólo a la repudiación de una herencia, sino también a la de los legados, que requieren de autorización judicial si se refieren a bienes raíces o a bienes muebles que valgan más de un centavo. La sanción a una repudiación hecha sin la competente autorización judicial será la nulidad relativa por haberse omitido un requisito que mira al estado o calidad del menor (art. 1682).

3. Tiene también el padre limitaciones respecto de la partición de bienes en que tenga interés el menor.

Requiere de autorización judicial para provocar la partición de las herencias o de bienes raíces en que tenga interés el menor (art. 1322).

La designación de partidor, salvo la que haya sido hecha por el juez, debe ser aprobada por la justicia (art. 1326).

La falta de autorización judicial para provocar la partición o la omisión de la aprobación judicial del partidor nombrado, trae consigo la nulidad relativa de la partición.

- **Responsabilidad del padre o madre por la administración de los bienes del hijo.**

Responde hasta de la culpa leve (art. 256 inc. 1º).

El artículo 256 agrega que "La responsabilidad del padre para con el hijo se extiende a la propiedad y a los frutos, en aquellos bienes del hijo en que tiene la administración pero no el goce, y se limita a la propiedad cuando ejerce ambas facultades sobre los bienes" (inc. 2º).

- **Privilegio en favor del hijo**

El artículo 2481 Nº 4 otorga al hijo sujeto a patria potestad un crédito privilegiado de cuarta clase, "por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre o la madre, sobre los bienes de éstos".

- **Extinción de la administración del padre o de la madre**

Termina la administración del padre o de la madre, en los siguientes casos:

1. Por la emancipación del hijo, desde que la administración es una consecuencia de la patria potestad;

2. En el caso en que se suspenda la patria potestad del padre o madre en conformidad al artículo 267 (art. 257 inc. 2º). Si se suspende respecto de un padre, la ejercerá el otro padre. Si se suspende respecto de ambos, el hijo quedará sujeto a guarda (art. 267 inc. 2º).

3. En el caso en que se prive al padre, madre o a ambos de la administración de los bienes del hijo por haberse hecho culpable "de dolo, o de grave negligencia habitual, y así se establezca por sentencia judicial, la que deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo" (art. 257 inc. 1º).

Privado uno de los padres de la administración de los bienes, la tendrá el otro; si ninguno de ellos la tuviese, la propiedad plena pertenecerá al hijo, y se le dará un curador para la administración (art. 258).

- **Obligación de quien ejerce la patria potestad de poner en conocimiento de sus hijos la administración realizada**

En conformidad al artículo 259 "Al término de la patria potestad, los padres pondrán a sus hijos en conocimiento de la administración que hayan ejercido sobre sus bienes".

c.3) Representación legal del hijo menor.

El tercer atributo de la patria potestad es la representación del hijo. El hijo menor puede ser absolutamente incapaz (demente, impúber, sordo o sordomudo que no puedan darse a entender claramente) o relativamente incapaz, si es menor adulto (art. 1447). En el primer caso sólo puede actuar a través de su representante legal; en el segundo, representado o autorizado por dicho representante.

- **El hijo menor adulto tiene capacidad para realizar ciertos actos.**

a) Actos judiciales o extrajudiciales que digan relación con su peculio profesional o industrial respecto del cual se le considera mayor de edad (art. 251);

b) Actos de familia, como casarse, pues aunque queda sujeto a ciertas autorizaciones para hacerlo, la omisión de éstas no acarrea la nulidad del matrimonio (arts. 105 y siguientes); puede reconocer hijos (art. 262); hacer testamento (art. 262).

- **Incapacidad del hijo menor**

Fuera de los casos de excepción recién señalados, el hijo tiene que actuar representado o autorizado por su representante legal. Es necesario distinguir entre incapacidad para actos extrajudiciales e incapacidad para actos judiciales.

- **Representación extrajudicial del hijo**

El representante legal del hijo es el padre o la madre que lo tengan bajo su patria potestad. Si ninguno la tuviere, lo representará el respectivo curador (art. 260).

- **Efectos de los actos o contratos del hijo ajenos a su peculio profesional o industrial, realizados a través de sus representantes legales o autorizados por éstos.**

Se debe distinguir según que los que ejercen la patria potestad se encuentren o no casados en régimen de sociedad conyugal.

En el primer caso, los actos y contratos que el hijo celebre fuera de su peculio profesional o industrial y que el padre o madre que ejerce la patria potestad autorice o ratifique por escrito o celebre en su representación, obligan directamente al padre o madre en conformidad a las disposiciones de ese régimen de bienes, y subsidiariamente, al hijo, hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos actos o contratos (art. 261 inc. 1º).

Si no hay sociedad conyugal, los actos y contratos sólo obligan al padre o madre que haya intervenido, lo que no obsta a que éste pueda repetir contra el otro padre en la parte en que de derecho ha debido proveer a las necesidades del hijo (art. 261 inc. 2º).

- **No hay autorización supletoria de la justicia para actos extrajudiciales.**

La ley no contempla lo que ocurre en el caso de impedimento o negativa del padre o madre de dar su autorización. La doctrina estima que no cabe la autorización supletoria de la justicia, por cuanto la judicatura sólo puede actuar a virtud de un texto expreso (Somarriva, Rossel).

- **Actos ejecutados por el hijo sin la autorización o ratificación del padre, de la madre o del curador adjunto.**

Trata de esta situación el artículo 260: "Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre que lo tengan bajo su patria potestad, o por el curador adjunto, en su caso, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial" (inc. 1º).

El inciso 2º del artículo 260, establece una excepción a la regla del inciso 1º, es decir, en ese caso no se va a obligar el peculio profesional o industrial. Dice: "Pero no podrá tomar dinero a interés, ni comprar al fiado (excepto en el giro ordinario de dicho peculio) sin autorización escrita de las

personas mencionadas (padre, madre o curador). Y si lo hiciere, no será obligado por estos contratos, sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos

- **Contratos entre padres e hijos sometidos a su patria potestad.**

La ley nada ha dicho sobre la contratación entre padre e hijo sometido a patria potestad. Como el artículo 1796 prohíbe la celebración del contrato de compraventa entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad, hay que concluir que fuera de este caso (y el de la permuta por aplicación del artículo 1900), la contratación entre ellos sería posible. Naturalmente que si hay incompatibilidad de intereses no podrá autorizar el padre, pues la representación legal llega hasta el momento que se produce incompatibilidad de intereses.

- **Representación judicial del hijo sometido a patria potestad**

Deben distinguirse las siguientes situaciones:

i) Juicios en que el hijo es demandante o querellante.

Rige en este caso la norma del artículo 264: “el hijo no puede parecer en juicio como actor, contra un tercero, sino autorizado o representado por el padre o madre que ejerce la patria potestad, o por ambos, si la ejercen de manera conjunta” (art. 264 inc. 1º). Si el padre, la madre o ambos niegan su consentimiento al hijo para la acción civil que quiera intentar contra un tercero, o si están inhabilitados para prestarlo, podrá el juez suplirlo, y al hacerlo así dará al hijo un curador para la litis” (art. 264 inc. 2º).

Si el juicio versa sobre un derecho que dice relación con el peculio profesional o industrial del hijo, puede actuar por sí solo, pues se le mira como mayor de edad (art. 251).

ii) Acciones civiles seguidas contra el hijo.

Cuando se interponga una acción en contra del hijo, el actor deberá dirigirse al padre o madre que tenga la patria potestad, para que autorice o represente al hijo en la litis. Si ambos ejercen en conjunto la patria potestad, bastará que se dirija en contra de uno de ellos (art. 265 inc. 1º). Si el padre o madre no pudiere o no quisiere prestar su autorización o representación, podrá el juez suplirla, y dará al hijo un curador para la litis (art. 265 inc. 2º).

iii) Juicios criminales en contra del hijo.

La situación la regula el artículo 266, en los términos siguientes: “No será necesaria la intervención paterna o materna para proceder criminalmente en contra del hijo, pero el padre o madre que tiene la patria potestad será obligado a suministrarle los auxilios que necesite para su defensa”.

iv) Juicios del hijo en contra del padre o madre que ejerce la patria potestad.

El artículo 263 establece que “siempre que el hijo tenga que litigar como actor contra el padre o la madre que ejerce la patria potestad, le será necesario obtener la venia del juez y éste, al otorgarla, le dará un curador para la litis”.

Nada dice la ley sobre el caso en que sea el padre o la madre que tienen la patria potestad quienes demanden al hijo. Frente a este vacío se estima que por el hecho de que el padre o la madre demanden al hijo lo están autorizando para litigar. En este caso se le debe designar un curador para que lo represente en la litis. Así ha sido resuelto.

En el caso de juicios entre el padre o madre que tiene la patria potestad con el hijo, sea que el padre o madre actúen como demandantes o demandados, deben proveer al hijo “de expensas para el juicio, que regulará incidentalmente el tribunal, tomando en consideración la cuantía e importancia de lo debatido y la capacidad económica de las partes” (art. 263 inc. 2º). Esta norma la incorporó la ley 19.585 y es de gran utilidad por la frecuencia de juicios entre padres e hijos, especialmente en materia de alimentos.

d) Suspensión de la patria potestad

La patria potestad puede suspenderse sin extinguirse, lo que ocurre en los casos del artículo 267:

- a) Demencia del padre o de la madre que la ejerce;
- b) Menor edad del padre o de la madre que la ejerce;
- c) Por estar el padre o madre que la ejerce en entredicho de administrar sus propios bienes, cualquiera sea la causa de su interdicción; y
- d) Larga ausencia u otro impedimento físico del padre o madre que la ejerza, de los cuales se siga perjuicio grave a los intereses del hijo, a que el padre o madre ausente o impedido no provee.

- **La suspensión de la patria potestad opera por sentencia judicial**

La suspensión de la patria potestad no opera de pleno derecho, salvo que se trate de la menor edad del padre o de la madre, en que la suspensión sí se producirá de pleno derecho (art. 268). En los demás casos, debe ser decretada judicialmente, con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los parientes del hijo y el defensor de menores.

El juez, en interés del hijo, podrá decretar que el padre o madre recupere la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la suspensión (art. 268 inc. 2º).

El inciso final del artículo 268 ordena que la resolución que decreta o deje sin efecto la suspensión debe subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo.

- **Efectos de la suspensión**

Si se suspende la patria potestad respecto de uno de los padres pasará a ser ejercida por el otro padre. Si se suspende respecto de ambos, el hijo quedará sujeto a guarda (art. 267 inc. final).

- **La emancipación**

El artículo 269 la define diciendo que “es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, de la madre, o de ambos, según sea el caso. Puede ser legal o judicial”.

- **Las normas sobre emancipación son de orden público.**

Por esta razón las causales de emancipación las establece taxativamente la ley. Las partes no pueden crearlas. Tanto es así, que cuando se hace al hijo una donación, herencia o legado, bajo condición de que se emancipe, la condición se cumple por equivalencia, es decir el hijo no obstante la aceptación de la donación, herencia o legado, no se emancipa, siendo el efecto exclusivamente que el padre o madre pierde el derecho de goce sobre esos bienes (art. 250 Nº 2).

- **Clases de emancipación:**

- i) Emancipación legal.**

Es la que se produce por el solo ministerio de la ley en los casos taxativamente señalados en el artículo 270:

1. Por la muerte del padre o madre, salvo que corresponda ejercitar la patria potestad al otro;
2. Por el decreto que da la posesión provisoria, o la posesión definitiva en su caso, de los bienes del padre o madre desaparecido, salvo que corresponda al otro ejercitar la patria potestad;
3. Por el matrimonio del hijo,
4. Por haber cumplido el hijo la edad de dieciocho años.

- ii) Emancipación judicial.**

La emancipación judicial es la que se produce por sentencia judicial en los casos taxativamente señalados en el artículo 271:

1. Cuando el padre o la madre maltrata habitualmente al hijo, salvo que corresponda ejercer la

- patria potestad al otro;
2. Cuando el padre o la madre ha abandonado al hijo, salvo el caso de excepción del número precedente;
 3. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada el padre o la madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena, a menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el interés del hijo, o de asumir el otro padre la patria potestad, y
 4. En caso de inhabilidad física o moral del padre o madre, si no le corresponde al otro ejercer la patria potestad.

- **La sentencia que declare la emancipación judicial debe subinscribirse.**

Así lo establece el inciso final del artículo 271: “La resolución judicial que decreta la emancipación deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo”. Esta subinscripción es un requisito de publicidad para que dicha resolución afecte a terceros (art. 8º de la ley 4808).

- **Efectos de la emancipación.**

La emancipación no transforma al menor en capaz, salvo que la causal sea haber llegado a la mayoría de edad. De consiguiente, producida la emancipación será necesario designarle un curador que lo represente y administre sus bienes. Lo dice en forma expresa el artículo 273: “El hijo menor que se emancipa queda sujeto a guarda”.

- **Irrevocabilidad de la emancipación.**

El artículo 272 señala que “toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable”. Esta regla rige sea que se trate de emancipación legal o judicial, pues el artículo 272 es categórico: “Toda emancipación...”.

Se exceptúa de esta regla -de la irrevocabilidad- la emancipación por i) muerte presunta o ii) por sentencia judicial fundada en la inhabilidad moral del padre o madre, las que podrán ser dejadas sin efecto por el juez, a petición del respectivo padre o madre, cuando se acredite fehacientemente su existencia o que ha cesado la inhabilidad, según el caso, y además conste que la recuperación de la patria potestad conviene a los intereses del hijo. La resolución judicial que de lugar a la revocación sólo producirá efectos desde que se subinscriba al margen de la inscripción de nacimiento del hijo (art. 272 inc. 2º).

La revocación procede por una sola vez (art. 272, inc. 3º).

Unidad 9: El Estado Civil.

Tema 1: Definición.

El artículo 304 define el estado civil como **"la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles"**.



Esta definición es criticada por su vaguedad. En efecto, decir que es una calidad que habilita a un individuo para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones, podría ser también una definición de capacidad o de nacionalidad. Por otra parte, no hace ninguna referencia a las características clásicas del estado civil.

Claro Solar lo define diciendo que es "la posición o calidad permanente del individuo en razón de la cual goza de ciertos derechos o se halla sometido a ciertas obligaciones" y para Somarriva "es el lugar permanente de una persona dentro de la sociedad, que depende principalmente de sus relaciones de familia y que la habilitan para ejercitar ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles".

Tema 2: Características.

- a. **Es un atributo de las personas naturales.** Por ello no puede faltar. Las personas jurídicas no tienen estado civil.
- b. **Es uno e indivisible,** lo que significa que no se puede tener simultáneamente más de un estado civil derivado de una misma fuente. No se puede ser a la vez soltero y casado, etc.
- c. **Es intransferible.** La jurisprudencia reiteradamente ha dicho que "el estado civil mismo es intransferible; pero no lo son los derechos puramente pecuniarios que de él emanan: de éstos pueden disponer libremente las partes aún en el caso de que el estado civil al cual los intereses patrimoniales están subordinados sea materia de controversia" (T. 9, sec. 1ª 493; T. 23, sec. 1ª pág. 669).
- d. **Es irrenunciable.**
- e. **No se puede transigir sobre él (art. 2450).**
- f. **Es imprescriptible (art. 2498).**
- g. **Los juicios sobre estado civil no pueden someterse a árbitros** (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales, en relación con el artículo 357 Nº 4 del mismo Código).
- h. **Es permanente.** Ello quiere decir que no se pierde mientras no se adquiera otro que lo sustituya.

Tema 3: Efectos del estado civil.

Los efectos que produce el estado civil, son los derechos y obligaciones que de él derivan. Estos efectos son de orden público, los señala la ley, sin que juegue en esta materia el principio de la autonomía de la voluntad. Así, por ejemplo, del estado civil de casado, derivan una serie de derechos y obligaciones entre los cónyuges (fidelidad, ayuda mutua, socorro, etc.); lo mismo del estado civil de padre (autoridad paterna, patria potestad, alimentos, derechos hereditarios, etc.).

Tema 4: Fuentes del estado civil.

Las fuentes del estado civil, son:

a) La ley, por ejemplo, el estado civil de hijo lo tiene aquel cuya filiación se haya determinado en conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I del Código Civil (art. 33).

b) La voluntad de las partes. Así ocurre con el estado civil de casados.

c) La ocurrencia de un hecho, por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges hace adquirir al otro el estado civil de viudo; y

d) La sentencia judicial, como ocurre por ejemplo, con la sentencia que declara a una persona hijo de otra.

Tema 5: Sentencias en materia de estado civil.



La regla general es que las sentencias judiciales sólo produzcan efectos entre las partes que han litigado (art. 3º, inc. 2º). Esta regla sufre una importante excepción en el caso de sentencias que **declaran verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo**, pues el artículo 315 señala que **“el fallo judicial pronunciado en conformidad con lo dispuesto en el Título VIII que declara verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, no sólo vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea”**.

Esta excepción tiene el alcance que la misma norma señala: rige exclusivamente para los juicios de reclamación e impugnación de paternidad o maternidad. Así aparece del artículo 315 que hace referencia al Título VIII, que se refiere a las acciones de filiación.

El artículo 316 indica los requisitos que deben cumplirse para que los fallos a que se refiere el artículo 315, produzcan estos efectos absolutos. Dice la norma que es necesario:

1. Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada;
2. Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor; y
3. Que no haya habido colusión en el juicio.

Respecto a la segunda exigencia -legítimo contradictor- el artículo 317 señala que "en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad el hijo contra la madre o la madre contra el hijo" (inc. 1º). "Son también legítimos contradictores los herederos del padre o madre fallecidos en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción y, también los herederos del hijo fallecido cuando éstos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla" (inc. 2º).

Este inciso segundo del artículo 317 debe concordarse con los artículos 206, 207, 213 y 216 que establecen los casos en que los herederos del padre o madre pueden entablar las acciones de reclamación o de impugnación de paternidad o maternidad o ser demandados en su calidad de herederos del padre o madre, respecto de esas mismas acciones.

En relación con este punto, el artículo 318 establece que "El fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de los herederos aprovecha o perjudica a los coherederos que citados no comparecieren".

Respecto al requisito de que no haya habido colusión, el artículo 319 indica que "la prueba de colusión en el juicio no es admisible sino dentro de los cinco años subsiguientes a la sentencia".

Tema 6: Prueba del estado civil.

La prueba del estado civil, está sometida a reglas especiales que el Código establece en el Título XVII del Libro I, artículos 304 y siguientes, que deben aplicarse con preferencia a las contenidas en el Título XXI del Libro IV "De la Prueba de las Obligaciones".

Existen a) medios de prueba principales, constituidos por las partidas (art. 305); y b) a falta de partidas, se admite una prueba supletoria, distinguiéndose entre la prueba del matrimonio (art. 309 inc. 1º) y la prueba de la filiación (art. 309 inc. 2º).

a) Medios de prueba principales. Las partidas del Registro Civil.

El artículo 305, en su inciso 1º señala que "el estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado o viudo, y de padre, madre o hijo **se acreditará** frente a terceros y **se probará** por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte, de nacimiento o bautismo" (inc. 1º).

Esta disposición emplea las formas verbales "acreditará" y "probará". Con ello quiere significar que las partidas cumplen una doble función: servir de prueba de la filiación en juicio; y servir de medio de acreditar una filiación determinada ante cualquier requerimiento del quehacer jurídico.

El inciso 2º del artículo 305 dice "El estado civil de padre, madre o hijo se acreditará o probará también por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determine la filiación".

El inciso 1º regula la prueba de la filiación matrimonial, y el inciso 2º la de la filiación no matrimonial.

b) El Servicio del Registro Civil e Identificación.

En relación con la prueba de las partidas del registro civil, se hace necesario explicar que en Chile existe un servicio público denominado "Registro Civil e Identificación" que, como su nombre lo indica, tiene por función principal, llevar un registro de los principales hechos constitutivos del

estado civil de una persona. Tal servicio fue creado por una ley de 17 de julio de 1884 que comenzó a regir el 1º de enero de 1885. Con anterioridad, esta materia estaba entregada a las Parroquias. La Ley de Registro Civil fue reemplazada por la Nº 4.808 de 10 de febrero de 1930 que, con algunas modificaciones, es la que rige hoy día.

De acuerdo al artículo 2º de la Ley 4.808, "El Registro Civil se llevará por duplicado y se dividirá en tres libros, que se denominarán: 1º De los nacimientos; 2º De los matrimonios; y 3º De las defunciones".

Si existe un servicio público creado para llevar el registro del estado civil, resulta absolutamente lógico, que los hechos asentados en tales registros constituyan el medio idóneo de prueba del estado civil. Sin embargo, la ley no se puede desentender de que pudieren no haberse realizado las inscripciones o simplemente haberse extraviado los registros. Por ello tuvo que permitir la existencia de otros medios supletorios.

Las "Partidas" son las inscripciones practicadas en los registros.

De manera que si se quiere probar el estado civil de casado, por ejemplo, se deberá acompañar una copia de la inscripción del matrimonio. Sin embargo, la ley permite que se pueda probar con certificados que expidan los Oficiales del Registro Civil y que ellos tienen la obligación de otorgar (art. 84 Nº 3º de la Ley 4.808). Estos certificados y las copias de las inscripciones o subinscripciones que otorgan los Oficiales del Registro Civil, tienen el carácter de instrumentos públicos y surtirán los efectos de las partidas de que hablan los artículos 305, 306, 307, 308 del Código Civil (art. 24 de la Ley 4.808).

c) Estado civil que puede probarse con las partidas

De acuerdo con el artículo 305, se podrá probar con las partidas el estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado o viudo y de padre, madre o hijo. Se prueba el estado civil de casado, con el certificado o copia de la inscripción de matrimonio; se prueba el estado civil de viudo, con el certificado de matrimonio y el certificado de defunción del cónyuge difunto; se prueba el estado civil de separado judicialmente o de divorciado con el certificado de matrimonio (pues las sentencias que declaran la separación judicial o el divorcio deben subinscribirse, artículos 32 y 59 de la Ley 19.947, respectivamente), se prueba el estado civil de hijo matrimonial por las respectivas partidas (o certificados) de nacimiento y, en el caso del hijo no matrimonial, por la partida (o certificado) de nacimiento donde conste la subinscripción del reconocimiento o del fallo que determine la filiación. Con la combinación de distintas partidas, se pueden probar otros parentescos. Así por ejemplo, la condición de hermano se probará con la partida (o certificado) de matrimonio de los padres y las partidas (o certificados) de nacimiento de los hijos.

d) Las partidas sirven también para probar la edad y la muerte de una persona.

Así lo establece el artículo 305 inciso final. En cuanto a la prueba de la edad de una persona, a falta de partida de nacimiento, la establece el tribunal oyendo el dictamen de facultativos o de otras personas idóneas. Así lo dice el artículo 314, norma que señala además que a falta de partidas, se le debe atribuir una edad media entre la mayor y la menor que parecieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo.

e) Impugnación de las partidas

Las partidas del Registro Civil, como instrumentos públicos que son, constituyen plena prueba sobre los hechos de que dan constancia. Para destruir su valor probatorio es menester impugnarlas. Y ellas se impugnan: a) por falta de autenticidad; b) por nulidad; c) por falsedad en las declaraciones; y d) por falta de identidad.

- **Impugnación por falta de autenticidad:**

De acuerdo al artículo 306, las partidas se presumen auténticas, cuando están en la forma debida. Ello significa, entonces -contrario sensu-, que pueden impugnarse si no son auténticas, si se han falsificado.

- **Impugnación por nulidad:**

No está expresamente contemplada en la ley esta forma de impugnación, pero ella es lógica, desde que se trata de instrumentos públicos que deben cumplir ciertos requisitos cuya omisión acarrea su nulidad. Así por ejemplo, si practicó la inscripción un funcionario incompetente.

- **Impugnación por falsedad en las declaraciones:**

Trata de esta impugnación el artículo 308: "Los antedichos documentos atestiguan la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas en los respectivos casos, pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes" (inc. 1º) "Podrán, pues impugnarse, haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata" (inc. 2º).

Es lógico que la partida no puede hacer fe de lo que las partes declaren, por tratarse de un hecho que al Oficial Civil no le consta. Pero, por otra parte, se presume que las partes dicen la verdad. Por eso, sus declaraciones se presumen verídicas, sin perjuicio de que esta presunción pueda destruirse probando que no era cierto lo que en ellas se dijo. Incumbe el onus probandi al que alega la falsedad, porque él invoca una situación anormal (que las partes mintieron).

Esta causal de impugnación es la que se empleaba en los juicios de nulidad de matrimonio por incompetencia del Oficial del Registro Civil.

- **Impugnación por falta de identidad:**

Esta forma de impugnación está contemplada en el artículo 307: "Podrán rechazarse los antedichos documentos, aun cuando conste su autenticidad y pureza, probando la no identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que el documento se refiere y la persona a quien se pretenda aplicar".

f) Medios de prueba supletorios.

Respecto a los medios de prueba supletorios, es necesario hacer una distinción entre: i) prueba del estado civil de casado; y ii) prueba de la filiación.

i) Prueba del estado civil de casado

- **Prueba supletoria del matrimonio**

La regula el artículo 309 inc. 1º. La falta de la partida de matrimonio podrá suplirse a) por otros documentos auténticos, b) por declaraciones de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio y, c) en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión del estado civil".

- **Prueba del estado civil de casado por la posesión notoria**

Se entiende por poseer un estado civil, su goce público, sin protesta ni reclamo de nadie. Tres

elementos constituyen la posesión notoria de un estado civil: el nombre, el trato y la fama. Sólo se pueden probar por este medio el estado civil de casado (art. 309 inc. 1º).

La posesión notoria del estado de matrimonio -dice el artículo 310- consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales (nombre y trato); y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general (fama).

► **Requisitos de la posesión notoria para que sirva de prueba de estado civil de casado**

De acuerdo a los artículos, 310 al 313, los requisitos son los siguientes:

1. La posesión tiene que ser pública, no clandestina (art. 310);
2. Debe ser continua (art. 312);
3. Debe haber durado 10 años continuos a lo menos (art. 312);
4. Debe haberse probado en la forma indicada en el artículo 313.

El artículo 313 establece que "la posesión notoria del estado de matrimonio se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse".

ii) Prueba supletoria de la filiación

El artículo 309 en su inciso 2º trata de la prueba supletoria de la filiación. Dice este inciso: "La filiación, a falta de partida o subinscripción, sólo podrá acreditarse o probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente. A falta de éstos, el estado de padre, madre o hijo deberá probarse en el correspondiente juicio de filiación en la forma y con los medios previstos en el Título VIII".

De manera que a falta de partida o subinscripción, la filiación -matrimonial o no matrimonial- sólo podrá probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado, v. gr. puede probar el estado civil de hijo con los documentos que señale el artículo 187 (acta extendida ante cualquier oficial del registro civil, escritura pública o testamento en que se haya verificado el reconocimiento). A falta de estos instrumentos auténticos el estado civil de padre, madre o hijo sólo podrá probarse en el correspondiente juicio de filiación, en la forma y con los medios previstos en el Título VIII del Libro Primero del Código Civil (art. 309 inc. 2º, parte final).

Unidad 10: Derecho de Alimentos.

Tema 1: Concepto.

El concepto jurídico de "alimentos" no es igual al vulgar, porque comprende **no sólo el sustento (comida) sino también los vestidos, la habitación, la enseñanza básica y media y los costos del aprendizaje de alguna profesión u oficio**. Así fluye del artículo 323.

El legislador no ha definido lo que entiende por alimentos, pero ha dado una clara idea de ellos en el artículo 323: "Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social" (inc. 1º) "Comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún años la enseñanza básica y media, y la de alguna profesión u oficio. Los alimentos que se concedan según el artículo 332 al descendiente o hermano mayor de veintiún años comprenderá también la obligación de proporcionar la enseñanza de alguna profesión u oficio".

Tomando pie en lo dicho en el artículo 323, y relacionándolo con los artículos 329 y 330, Ramos define el derecho de alimentos como **"el que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media y aprendizaje de alguna profesión u oficio"**.

Tema 2: Clasificación.

Los alimentos pueden clasificarse de diversos modos:

Atendiendo a si la obligación de otorgarlos proviene de la ley o de la voluntad de las partes, pueden ser: **alimentos voluntarios**; y **alimentos legales o forzosos**;

Atendiendo a si se otorgan mientras se tramita el juicio o en forma definitiva, los alimentos legales pueden ser: **provisionales** o **definitivos**;

Otra clasificación, más propia de las pensiones de alimentos que del derecho en sí, es la que distingue entre: pensiones futuras y **pensiones devengadas**.

2.1 Alimentos legales o forzosos y alimentos voluntarios.

Los primeros son los que establece la ley; voluntarios, los que emanan del acuerdo de las partes o de la declaración unilateral de una parte.

Esta distinción es muy importante. El Código en el título XVIII, del Libro I, artículos 321 y siguientes, ha reglamentado únicamente los alimentos legales. La denominación del Título es "De los alimentos

que se deben **por ley** a ciertas personas". Y el artículo 337 señala que las disposiciones de este título no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento o por donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del testador o donante, en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo.

Cuando la persona **obligada** a pagar una pensión de alimentos fallece, esos alimentos constituyen una asignación forzosa que gravan la masa hereditaria (a menos que el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión), y son una baja general de la herencia (arts. 1168, 959 Nº 4).

2.2 Alimentos provisorios y definitivos.

Provisorios son los que el juez ordena otorgar mientras se ventila el juicio de alimentos, desde que en el mismo juicio el que los demanda ofrezca fundamento plausible (art. 327). En cambio son alimentos definitivos, los que se determinan en una sentencia definitiva firme. Se ha fallado que "por fundamento plausible se entiende la existencia de antecedentes que permitan llevar al ánimo del juez el concepto de que podrá prosperar la demanda principal" (T. 78, sec. 2ª, p. 34).

Cuando se ordena el pago de alimentos provisorios, quien los recibe debe devolverlos si en definitiva no se da lugar a su demanda de alimentos, a menos que la haya intentado de buena fe y con fundamento plausible (art. 327, inc. 2º).

2.3 Alimentos provisorios en favor de los hijos menores.

El artículo 5º de la ley 14.908 (en el texto dado por la ley 19.741), contiene reglas especiales respecto de los alimentos provisorios en favor de los hijos menores. Establece que en los juicios en que se solicitaren alimentos a favor de los hijos menores del demandado, siempre que exista fundamento plausible del derecho que se reclama, el juez **deberá decretar** los alimentos provisorios que correspondan, una vez transcurrido el término de diez días contados desde la fecha de la notificación de la demanda. En el inciso 2º se aclara que "se entenderá que existe fundamento plausible cuando se hubiere acreditado el título que habilita para pedir alimentos y no exista una manifiesta incapacidad para proveer".

Dentro del plazo señalado (diez días desde la notificación de la demanda) el demandado podrá exponer los argumentos que estimare pertinentes respecto a la procedencia de los alimentos provisionales y acompañar los antecedentes en que se fundare. En la notificación de la demanda deberá informársele sobre esta facultad (inc. 3º). El artículo 5º obliga al tribunal a pronunciarse de oficio sobre los alimentos provisorios, haya o no el demandado formulado sus observaciones (inc.4º). La resolución que decreta los alimentos provisorios, es susceptible del recurso de reposición con apelación subsidiaria, que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de preferencia para su vista y fallo (art. 5º, inc. final).

2.4 Alimentos futuros o devengados.

Finalmente las pensiones de alimentos pueden clasificarse en pensiones de alimentos futuras y pensiones de alimentos devengadas (o atrasadas). Esta distinción es muy importante, porque, las primeras tienen características totalmente diferentes a las segundas, como luego se verá.

Tema 3: Requisitos del derecho de alimentos.

a) Estado de necesidad en el alimentario.

Este requisito lo establece el artículo 330: "Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social".

La disposición recién citada demuestra que aunque la persona obligada a prestar alimentos tenga medios económicos en exceso, no se le podrá exigir el pago de una pensión alimenticia si el alimentario no los necesita para subsistir de un modo correspondiente a su posición social.

b) Que el alimentante tenga los medios necesarios para otorgarlos.

Así se desprende del artículo 329: "En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas". Incumbe la prueba de que el alimentante tiene los medios para otorgar los alimentos, a quien los demanda (alimentario). Por excepción, la ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones alimenticias, Ley 14.908, en su artículo 3º, inc. 1º, presume que el alimentante tiene los medios para dar alimentos cuando los demanda un menor a su padre o madre. Esta es una presunción simplemente legal, que sólo opera cuando entre el alimentante y alimentario existe el parentesco indicado. Agrega dicho art. 3º que "en virtud de esta presunción, el monto mínimo de la pensión alimenticia que se decrete a favor de un menor alimentario no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del ingreso mínimo remuneracional que corresponda según la edad del alimentante. Tratándose de dos o más menores, dicho monto no podrá ser inferior al 30% por cada uno de ellos" (inc. 2º). Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º inc. 1º, que impide al tribunal fijar como pensión una suma o porcentaje que exceda del 50% de las rentas del alimentante (art. 3º inc. 3º).

c) Fuente legal.

Como estamos hablando de alimentos legales, es inconcuso que tiene que existir una norma legal que obligue a pagar los alimentos. La norma principal es el artículo 321 del Código Civil. Pero no es la única. Hay otros casos: ej. artículo 2º inc. 3º de la Ley 14.908, que confiere alimentos a la madre del hijo que está por nacer; Ley de Quiebras, art. 64 inc. 4º, etc.

El **artículo 321** establece: "Se deben alimentos:

1º Al cónyuge;

2º A los descendientes;

3º A los ascendientes;

4º A los hermanos; y

5º Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.

La acción del donante se dirigirá contra el donatario.

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se los niegue".

Lo normal en materia de alimentos es la reciprocidad, con lo que se quiere decir, que si una persona tiene derecho a reclamar alimentos a otra, está también obligado a proporcionárselo, si esta última los necesitare. Esta regla de la reciprocidad se rompe en algunos casos: por ejemplo, en el caso de los hijos, cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, aquél o ésta quedará privado de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo o de sus descendientes. Luego el hijo puede demandar alimentos a su padre o madre, pero estos últimos no pueden demandar al hijo. Otro caso en que se rompe la regla de la reciprocidad es en el caso 5º, sólo puede demandar alimentos el que

hizo una donación cuantiosa; la situación inversa no se da.

c.1) Orden de precedencia para demandar alimentos

El Código ha reglamentado en el artículo 326, la situación que se produce cuando se tiene derecho a demandar alimentos a distintas personas, por ejemplo: una mujer casada tiene derecho a demandar alimentos a su marido (art. 321 Nº 1), pero también a sus ascendientes (art. 321 Nº 3); si tiene descendientes podría demandarlos de éstos (art. 321 Nº 2); y si hizo una donación cuantiosa, al donatario (art. 321 Nº 5), etc.

Dice el artículo 326: **"El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 321, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, en el siguiente orden: 1º El que tenga según el número 5; 2º El que tenga según el número 1º; 3º El que tenga según el número 2º; 4º El que tenga según el número 3º; 5º El del número 4º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros". En otras palabras los alimentos deben solicitarse en el siguiente orden: al donatario de una donación cuantiosa, al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes y, a falta de todos ellos, a los hermanos".**

"Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo grado. Entre los de un mismo grado, como también entre varios obligados por un mismo título, el juez distribuirá la obligación en proporción a sus facultades. Habiendo varios alimentarios respecto de un mismo deudor, el juez distribuirá los alimentos en proporción a las necesidades de aquellos". "Sólo en el caso de insuficiencia de todos los obligados por el título preferente, podrá recurrirse a otro".

c.2) Obligación de otorgar alimentos a los nietos.

El artículo 3º de la ley 14.908, inciso final, establece que **"Cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá demandar a los abuelos, de conformidad con lo que establece el artículo 232 del Código Civil".** Luego la responsabilidad de los abuelos es subsidiaria, pues la obligación corresponde en primer término a los padres.

Por su parte, el referido artículo 232 prescribe que **"La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes pasa por la falta o insuficiencia de ambos padres, a sus abuelos, por una y otra línea conjuntamente".**

"En caso de insuficiencia de uno de los padres, la obligación indicada precedentemente pasará en primer lugar a los abuelos de la línea del padre o madre que no provee; y en subsidio de éstos a los abuelos de la otra línea".

De la relación de ambas disposiciones pueden sacarse las siguientes conclusiones:

- Los abuelos pueden ser condenados a pagar alimentos a sus nietos, pero su responsabilidad sólo es subsidiaria, ya que la obligación corresponde en primer lugar a los padres;
- Los abuelos no pueden ser demandados directamente, pues el artículo 3º inc. final de la ley 14.908 es clara en cuanto a que éstos sólo van a responder cuando los alimentos "decretados" no fueren pagados o no fueren suficientes;
- Cada abuelo responde de la obligación que su hijo no está cumpliendo o la cumple en forma insuficiente. Así lo establece el artículo 232 inc. 2º del Código Civil: **"En caso de insuficiencia de uno de los padres, la obligación indicada precedentemente pasará en primer lugar a los abuelos de la línea del padre o madre que no provee...";**
- Si el padre o madre del hijo que no cumple o cumple imperfectamente con la obligación alimenticia, no tiene los medios para proporcionar alimentos a sus nietos, esta obligación pasa a los abuelos de la otra línea.

Tema 4: Características del derecho de alimentos.

El derecho a demandar alimentos es un derecho personalísimo. De esta característica derivan una serie de consecuencias del más alto interés:

1. **Es intransferible e intransmisible** (art. 334);
2. **Es irrenunciable** (art. 334);
3. **Es imprescriptible.** Se podrá demandar alimentos en cualquier tiempo siempre que en ese momento se cumplan las exigencias legales;
4. **Es inembargable** (art. 1618 Nº 9 del Código Civil y 445 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil);
5. **No se puede someter a compromiso** (art. 229 del Código Orgánico de Tribunales);
6. **La transacción sobre el derecho de alimentos debe ser aprobada judicialmente** (art. 2451).

Las pensiones alimenticias ya devengadas, no tienen las características señaladas en el punto anterior. En efecto, el artículo 336 establece que se pueden renunciar, vender, ceder, transmitir, etc. Si devengados los alimentos no se cobran, el derecho a cobrar las pensiones atrasadas prescribe de acuerdo a las reglas generales, etc. En el caso de la transacción, el art. 2451 exige la aprobación judicial sólo para la transacción sobre alimentos futuros, etc.

Tema 5: Características de la obligación alimenticia.

La obligación alimenticia tiene algunas características especiales:

a) No se puede extinguir por compensación. Así lo señale el artículo 335: "El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él". Y esta misma idea está reiterada en el artículo 1662 inciso 2º.

b) La obligación alimenticia es intransmisible. Por lo menos así es para un sector importante de la doctrina. Ello, porque de acuerdo al artículo 1168 "los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador ha impuesto esa obligación a uno o más de los partícipes en la sucesión".

De manera que si fallece el alimentante, su obligación no pasa a sus herederos (por eso es intransmisible), sino que se hace exigible sobre el patrimonio del causante, como baja general de la herencia (art. 959 Nº 4º). Sólo va a gravar a alguno de los herederos cuando el testador así lo haya dispuesto, caso en que será una deuda testamentaria. En este sentido Claro Solar y Somarriva.

Se pueden dar las siguientes razones para fundar la intransmisibilidad de la obligación alimenticia:

- El artículo 959 número 4º, ya explicado;
- Porque si esta obligación tuviera el carácter de transmisible no se justificaría el Nº 4 del artículo 959; habría bastado con el Nº 2 de la misma disposición que señala que constituyen baja general de la herencia "las deudas hereditarias";
- Porque la obligación de alimentos se funda en el parentesco, matrimonio, adopción o en una

- donación, vínculos que siempre generan obligaciones intransmisibles;
- Se da también un argumento de historia fidedigna. En el proyecto de 1853, el artículo 371 establecía que la obligación de prestar alimentos "se transmitía a los herederos y legatarios del que ha debido prestarlos". Esta disposición fue suprimida por la Comisión Revisora teniendo en cuenta el Derecho Francés, en que la obligación era intransmisble, y considerando además, los problemas prácticos que la aplicación de la norma podría producir.

Tema 6: Tribunal competente para conocer de los juicios de alimentos y procedimiento a partir del 1 de octubre de 2005.

En conformidad al artículo 8º Nº 4 de la ley 19.968, las causas relativas al derecho de alimentos son de competencia de los juzgados de familia. La ley recién citada sustituyó el inciso 1º del artículo 1º de la ley 14.908, por el siguiente: "De los juicios de alimentos conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último, los que se tramitarán conforme a las normas del procedimiento ordinario establecido en la ley que crea los juzgados de familia en lo no previsto por este cuerpo legal".

a) Transacción en materia de alimentos futuros

En conformidad a lo que establece el artículo 2451 del Código Civil, "la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley, no valdrán sin aprobación judicial; no podrá el juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en los artículos 334 y 335". La referencia a estas disposiciones significa que el juez deberá cuidar que no se hagan renunciaciones o compensaciones, que tales normas prohíben.



¿Cuál es la sanción para el caso de que no cumpla con este requisito de la aprobación judicial? Ramos estima que mientras ello no ocurra, la transacción no produce efectos, por lo que no se puede exigir su cumplimiento.

"En las transacciones sobre alimentos futuros tendrán la calidad de ministros de fe, además de aquellos señalados en otras disposiciones legales, los Abogados Jefes o Coordinadores de los Consultorios de la respectiva Corporación de Asistencia Judicial, para el solo efecto de autorizar las firmas que se estamparen en su presencia" (art. 11 inc. 2º de la ley 14.908).

El art. 11 inc. 3º de la ley 14.908 agrega que: "El juez sólo podrá dar su aprobación a las transacciones sobre alimentos futuros a que hace referencia el artículo 2451 del Código Civil, cuando se señalaren en ellas la fecha y lugar del pago de la pensión, y el monto acordado no sea inferior al establecido en el artículo 3º de la presente ley", esto es, 40% del ingreso mínimo remuneracional que corresponda según la edad del alimentante y tratándose de dos o más menores dicho monto no podrá ser inferior al 30% por cada uno de ellos, debiéndose sí respetar la norma de que la pensión no puede exceder del 50% de las rentas del alimentante.

b) Modificación de las pensiones de alimentos

La sentencia que fija una pensión de alimentos es inamovible mientras se mantengan las circunstancias que la hicieron procedente. Más, si estas circunstancias varían, las sentencias son

modificables. Así fluye del artículo 332 inciso 1º del Código Civil: "Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda". Por ello, se dice que las sentencias en materia de alimentos no producen cosa juzgada.

De acuerdo al inciso 2º del art. 2º de la ley 14.908 "será competente para conocer de las demandas de aumento, rebaja o cese de la pensión alimenticia el mismo juez que decretó la pensión".

c) Formas de obtener el cumplimiento de una resolución que ordenó el pago de alimentos.

La ley ha otorgado diferentes medios para obtener el pago de una pensión de alimentos:

1) En primer lugar, se puede demandar ejecutivamente al alimentante. El artículo 11 de la Ley 14.908, establece que "toda resolución judicial que fijare una pensión alimenticia o que aprobare una transacción bajo las condiciones establecidas en el inciso 3º tendrá mérito ejecutivo. Será competente para conocer de la ejecución el tribunal que la dictó en única o en primera instancia o el del nuevo domicilio del alimentario".

El artículo 12 de la ley reglamenta diversos aspectos de este juicio ejecutivo.

2) Se puede obtener también el pago, recurriendo al artículo 8º de la ley 14.908: "Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia por un trabajador dependiente establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte del empleador. La resolución judicial que así lo ordene se notificará a la persona natural o jurídica que, por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al alimentante su sueldo, salario o cualquier otra prestación en dinero, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo cuidado esté.

Agrega la norma que "el demandado dependiente podrá solicitar al juez, por una sola vez, en cualquier estado del juicio y antes de la dictación de la sentencia, que sustituya, por otra modalidad de pago, la retención por parte del empleador" (inc. 3º) y en el inciso 4º señala que "La solicitud respectiva se tramitará como incidente. En caso de ser acogida, la modalidad de pago decretada quedará sujeta a la condición de su íntegro y oportuno cumplimiento". Finalmente el inciso 5º establece que "De existir incumplimiento, el juez, de oficio, y sin perjuicio de las sanciones y apremios que sean pertinentes, ordenará que en lo sucesivo la pensión alimenticia decretada se pague conforme al inciso primero".

Ver en relación con este art. 8º el art. 13 de la misma ley.

3) Finalmente, "si, decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria, en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución deberá a petición de parte o de oficio y sin más trámite imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación" (art. 14 inc. 1º). "Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos períodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por treinta días" (inc. 2º). Igualmente el juez puede dictar orden de arraigo en contra del alimentante (inc. 5º).

Es importante tener en cuenta que este medio sólo procede en el caso en que los alimentarios tengan con el alimentante el parentesco que la norma señala. Por ello, si una persona es condenada a pagar alimentos a su hermano, por ejemplo, y no cumple, no cabe decretar apremios. Lo mismo cuando el condenado a pagar alimentos es el abuelo.

El tribunal puede suspender el arresto -o arraigo- si el alimentante justifiere que carece de los medios necesarios para el pago de su obligación alimenticia (art. 14 inc. final).

El artículo 15 señala que el mismo apremio se aplicará "al que, estando obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas..., ponga término a la relación laboral por renuncia voluntaria o mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, después de la notificación de la demanda y carezca de rentas que sean suficientes para poder cumplir la obligación alimenticia". Esta disposición tiene por objeto evitar que un alimentante renunciare al trabajo con el objeto de no pagar los alimentos. Era frecuente que en muchos casos se renunciare o, por lo menos se empleare como arma de presión la amenaza de renuncia al trabajo para obtener avenimientos más favorables.

d) Garantías para proteger las pensiones alimenticias

La legislación, ha establecido distintos arbitrios para asegurar el pago oportuno de las pensiones alimenticias.

1. Permite, en ciertos casos, los apremios personales del deudor: arresto o arraigo (artículos 14 y 15 de la Ley 14.908). Y establece también la retención en poder de quien pague al deudor (art. 8 de la Ley 14.908).

2. Se establece en el artículo 18 de la Ley 14.908 que "Serán solidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia quien viviere en concubinato con el padre, madre o cónyuge alimentante, y los que, sin derecho para ello dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno cumplimiento de dicha obligación".

Cuando el artículo 18 de la Ley 14.908, expresa que responden solidariamente del pago de las pensiones alimenticias "los que, sin derecho para ello, dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno cumplimiento de dicha obligación", se está refiriendo, por ejemplo a los empleadores que hacen caso omiso de la orden judicial de retener de la remuneración de un empleado la parte destinada al pago de una pensión alimenticia.

3. El artículo 10 de la Ley 14.908, establece que "el juez podrá también ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución". El inciso 2º de esta disposición agrega que "Lo ordenará especialmente si hubiere motivo fundado para estimar que el alimentante se ausentará del país. Mientras no rinda la caución ordenada, que deberá considerar el período estimado de ausencia, el juez decretará el arraigo del alimentante, el que quedará sin efecto, por la constitución de la caución, debiendo el juez comunicar este hecho de inmediato a la misma autoridad policial a quien impartió la orden, sin más trámite".

4. En conformidad al artículo 19 de la ley 14.908 "Si constare en el expediente que en contra del alimentante se hubiere decretado dos veces alguno de los apremios señalados en el artículo 14, procederá en su caso, ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva, lo siguiente: 1. decretar la separación de bienes de los cónyuges; y 2. autorizar a la mujer para actuar conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 138 del Código Civil, sin que sea necesario acreditar el perjuicio a que se refiere dicho inciso.

La circunstancia señalada en el inciso anterior será especialmente considerada para resolver: a) La autorización para la salida del país de los hijos menores de edad; b) La falta de contribución a que hace referencia el artículo 225 del Código Civil; c) La emancipación judicial por abandono del hijo a que se refiere el artículo 271, número 2, del Código Civil”.

e) Forma de fijación, cuantía, reajustabilidad y fecha desde la cual se deben los alimentos.

El artículo 333 del Código Civil establece que **“el juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se consigne a este efecto en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se restituya al alimentante o sus herederos luego que cese la obligación”**.



De acuerdo a esta disposición, lo normal será que el juez fije la pensión de alimentos en una suma de dinero. Sin embargo, en conformidad al inciso 2º del artículo 9º de la ley 14.908, después de las modificaciones de la ley 19.741, “El juez podrá también fijar o aprobar que la pensión alimenticia se impute total o parcialmente a un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos ni gravarlos sin autorización del juez. Si se tratare de un bien raíz, la resolución judicial servirá de título para inscribir los derechos reales y la prohibición de enajenar o gravar en los registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces. Podrá requerir estas inscripciones el propio alimentario”.

El inciso 3º del artículo 9º establece que “la constitución de los mencionados derechos reales no perjudicará a los acreedores del alimentante cuyos créditos tengan una causa anterior a su inscripción”. Este inciso que fue incorporado por la ley 19.741, tiene el claro propósito de evitar el fraude de algunos deudores que para burlar a sus acreedores se hacían demandar de alimentos por el cónyuge, quien pedía como pensión de alimentos un derecho de usufructo sobre el bien raíz hipotecado o embargado.

“En estos casos, el usufructuario, el usuario y el que goce de derecho de habitación, estarán exentos de las obligaciones que para ellos establecen los artículos 775 y 813 del Código Civil (caución e inventario), respectivamente, estando sólo obligados a confeccionar un inventario simple. Se aplicarán al usufructuario las normas de los artículos 819, inciso primero, y 2466, inciso tercero, del Código Civil” (inc. 4º), es decir, que estos derechos de uso y habitación son intransmisibles, y no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse y son además inembargables.

“Cuando el cónyuge alimentario tenga derecho a solicitar para sí o para sus hijos menores, la constitución de un usufructo, uso o habitación en conformidad a este artículo, no podrá pedir la que establece el artículo 147 del Código Civil respecto de los mismos bienes” (inc. 5º).

“El no pago de la pensión así decretada o acordada hará incurrir al alimentante en los apremios establecidos en esta ley, y en el caso del derecho de habitación o usufructo recaído sobre inmuebles, se incurrirá en dichos apremios aun antes de haberse efectuado la inscripción a que se refiere el inciso segundo” (inciso final).

En cuanto a la cuantía de los alimentos, la fija el tribunal teniendo en cuenta los medios de que dispone el alimentante y las necesidades del alimentario. No obstante, el artículo 7º de la ley Nº 14.908 establece una limitación importante: “El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión

una suma o porcentaje que exceda del 50% de las rentas del alimentante” (inc. 1º). Agrega la norma que “las asignaciones por carga de familia no se considerarán para los efectos de calcular esta renta y corresponderán, en todo caso, a la persona que cause la asignación y serán inembargables por terceros” (inc. 2º).

La idea del legislador es que las pensiones de alimentos se vayan reajustando en el tiempo. Por ello el inciso 3º del artículo 7º de la ley 14.908, establece que “Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de los ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino en una suma determinada, ésta se reajustará semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o el organismo que haga sus veces, desde el mes siguiente a aquél en que quedó ejecutoriada la resolución que determine el monto de la pensión”.

En lo tocante a la fecha desde la cual se deben los alimentos, el artículo 331 del Código Civil dice que “los alimentos se deben desde la primera demanda, y se pagarán por mensualidades anticipadas”.

Tema 7: Extinción de la obligación de pagar alimentos.

El artículo 332 establece que **“los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda”** (inc. 1º). De modo que mientras subsistan las condiciones vigentes al momento en que los alimentos se dieron, la obligación alimenticia se mantiene. Pero en ningún caso más allá de la vida del alimentario, pues el derecho de alimentos no se transmite (art. 334).

La regla del inciso 1º del artículo 332 tiene una excepción importante en el inciso 2º: “Con todo, los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan veintiún años, salvo i) que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los 28 años; II) que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o iii) que, por circunstancias calificadas, el juez los considere indispensables para su subsistencia”.

a) Cese de los alimentos por incurrir el alimentario en injuria atroz.

El artículo 324 establece que “en el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar alimentos”. Y agrega “Pero si la conducta del alimentario fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del alimentante, podrá el juez moderar el rigor de esta disposición” (inc. 1º).

El inciso 2º de la disposición señala que “sólo constituyen injuria atroz las conductas descritas en el artículo 968”, es decir, sólo existe injuria atroz en los casos de indignidad para suceder contemplados en dicho artículo.

b) Los padres que abandonaron al hijo en su infancia carecen del derecho de alimentos.

Así lo establece el inciso final de artículo 324: “Quedarán privados del derecho de pedir alimentos al hijo el padre o la madre que le haya abandonado en su infancia, cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición”.